



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون
قسم الفقه المقارن

قضايا فقهية معاصرة (معاملات مالية)

لطلاب الفرقة الثانية | شعبة: الشريعة الإسلامية

إعداد:

أ.د / زينب عياد حسن أستاذ الفقه المقارن المساعد بالكلية	أ.د / شفيقة الشهاوي رضوان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات - القاهرة
---	---

راجع:

أ.د / زينب عبد الحافظ أحمد رئيس قسم الفقه المقارن بالكلية	أ.د / صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بالكلية
--	--



١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠/٢٠١٩ م

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مقدمة ﴾

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } [الأنعام: ٣٨] والصلاة والسلام على رسوله الكريم أرسله ربه رحمة للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد،،،،

فقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد وهدايتهم إلى سبيل الرشاد، ولهذا نظمت المعاملات المالية تنظيمًا دقيقاً، ومع التقدم التكنولوجي الذي نعيشه اليوم كشف لنا العلم الحديث عن وقائع وحوادث تتعلق بالمعاملات المالية لم تكن معروفة لدى فقهاءنا الأجلاء كموضوع الإجارة المنتهية بالتمليك، والبطاقات الائتمانية، والشرط الجزائي (غرامات التأخير) ، وعقود التوريد، وأحكام المناقصات فهذه الموضوعات من نوازل المعاملات التي تحتاج إلى بيان أحكامها ولما كانت الشريعة عطاؤها وهداياها لا يقف عند حد زمني أو مكاني، فما من معاملة من هذه المعاملات سאלفة الذكر إلا ولها حكم في فروع الشريعة أو قواعدها .

وهذه الدراسة قد أعدت لطلاب وطالبات الفرقة الثانية شعبة
الشريعة الإسلامية وقد روعي فيها سهولة العبارة والمدة الزمنية
المحددة للمنهج .

وختاماً: فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو
نسيان فمن أنفسنا، هذا والله تعالى هو الأعلم بالصواب

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأهداف العامة للمقرر:

- ١- مرونة وصلاحيّة الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان .
- ٢- الربط بين المسائل الفقهية التي وردت في كتب المتقدمين والقضايا المستحدثة للوصول إلى الحكم الشرعي في النوازل الفقهية.
- ٣- تزويد الطالب بمعلومات فقهية تساعد في حياته العملية .

وبنهاية المقرر يكون الطالب قادرًا على أن:

- ١- يتعرف على الأحكام المستحدثة في المعاملات المالية .
- ٢- يتعرف الإجارة المنتهية بالتمليك وما هو محرم ومباح من صورها.
- ٣- يشرح بطاقات الائتمان ويعرف الجهات المصدرة لها وأنواعها، والتوصل إلى الحكم الشرعي.
- ٤- يستخلص أثر التعامل ببطاقات الائتمان على المجتمع والاقتصاد.
- ٥- يذكر أقوال العلماء في الشرط الجزائي ، ويفهم العوامل التي ساعدت على العمل به .
- ٦- يكتسب ملكة قياس الفروع على الأصول.
- ٧- يوضح عقد التوريد وصوره وموضوعه .
- ٨- يقارن بين عقد التوريد وبين غيره من عقود المعاملات .
- ٩- يشرح عقود المناقصات واجراءاتها .
- ١٠- يستنبط الحكم الشرعي لعقود المناقصات من خلال قياسها على ما يشبهها من العقود الأخرى.
- ١١- يكتسب الطالب القدرة على التعاون مع المؤسسات الدينية والمجامع الفقهية في مجال المعاملات المالية في الداخل والخارج.

أساليب التعليم والتعلم:

- ١ - الإلقاء والمحاضرة.
- ٢ - المناقشة والحوار.
- ٣ - العصف الذهني.
- ٤ - المخططات والخرائط.
- ٥ - التكاليفات من المصادر الالكترونية.
- ٦ - تدريب مجموعات من الطلاب يقومون بتحضير الدروس، وشرحها أمام زملائهم .

القسم الأول:

الإجارة المنتهية بالتملك

ويحتوي على ثلاث وحدات:

■ الوحدة الأولى

مدخل لدراسة عقد الإجارة المنتهية بالتملك

■ أهداف الوحدة الأولى

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على أن :

- ١- التعرف على مفهوم عقد الإجارة ومشروعيته.
- ٢- الوقوف على مفهوم الإجارة المنتهية بالتملك، وما يطلق عليها من مصطلحات.
- ٣- ذكر نشأة هذا العقد، مع توضيح الفرق بين هذا العقد وغيره من بعض عقود المعاملات المالية مثل البيع بالتقسيط
- ٤- إيضاح مزايا عقد الإجارة المنتهية بالتملك .

الوحدة الأولى

عقد الإجارة المنتهية بالتملك

أولاً: مفهوم كل من الإجارة والتمليك :

مفهوم الإجارة :

الإجارة لغة: مشتقة من الأجر، والفعل: أجر يأجر، ولها معنيان:

الأول : الكراء على العمل.

والثاني : جبر العظم الكسير، فيقال أجرت يده والمعنى الجامع بينهما: أن أجرة العامل كأنها شئ يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله.^(١)

جاء في التعريفات: أن الإجارة عقد على المنافع بعوض هو مال، أو تملك المنافع بعوض إجارة وبغير عوض إعارة.^(٢)

الإجارة شرعاً :

عرف الحنفية الإجارة: بأنها عقد على المنفعة بعوض هو مال.^(٣)

(١) لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ، مقاييس اللغة ج ١ ص ٦٢-٦٣ .

(٢) التعريفات ص ٢٣ .

(٣) المبسوط ج ١٥ ص ٧٤ .

وعرفها المالكية : بأنها تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض.^(١)

وعرفها الشافعية بقولهم : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.^(٢)

وعرفها الحنابلة : بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم.^(٣)

من خلال تعريفات الفقهاء للإجارة يتضح ما يلي :

أن تعريف الحنفية للإجارة قد جاء خالياً من عدة قيود :

أولهما : كون المنفعة مباحة .

ثانيهما : مدة الانتفاع معلومة .

ثالثهما : كون الأجرة معلومة.

أما تعريف المالكية فقد جاء خالياً من قيد كون المعوض معلوماً.

أما تعريف الشافعية فقد جاء مقيداً بكون المنفعة مقصودة أى

ليست بتافهة .

(١) حاشية الدسوقي ج ٤ ص ٢.

(٢) أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٠٣.

(٣) شرح منتهى الإرادات ج ٣ ص ٦٤ .

أما تعريف الحنابلة فأرى أنه تعريفاً جامعاً : فقد جاء شاملاً لنوعي الإجارة وهى إجارة المنافع وإجارة الأعمال، كما شمل إجارة العين المرئية، والعين الموصوفة فى الذمة، وإن جاء خالياً من قيد كون المنفعة مقصودة أى منفعة ليست بتافهة .

مفهوم التملك:

التمليك لغة: مصدر ملك: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة فى الشيء وصحة، والملك: هو كل ما يملك من مال. ^(١)

والملك اصطلاحاً : هو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه وحاجزاً عن تصرف غيره فيه. ^(٢)

بينما عرفه الإمام الشافعي : بأنه ما انقطع ملك صاحبه عنه إلى من ملكه إياه . ^(٣)

بينما عرفه القرافي : بأنه حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك.

شرح التعريف : أما القول بأنه حكم شرعي فبالإجماع ؛ ولأنه يتبع الأسباب الشرعية، وأما إنه مقدر فلأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع،

(١) مقاييس اللغة ج ٥ ص ٣٥١-٣٥٢.

(٢) التعريفات ص ٢٩٥.

(٣) الأم ج ٤ ص ٢٥ .

والتعلق عديمي ليس وصفاً حقيقياً ، بل يقدر في العين أو المنفعة عند تحقق الأسباب المفيدة للملك ، وقولنا في العين أو المنفعة فإن الأعيان تملك كالبيع والمنافع كالإجارات. ^(١) والتمليك قد يكون للعين وقد يكون للمنفعة، وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض، فإذا كان بغير عوض فهو هبة، وإذا كان تمليكاً للعين بعوض فهذا بيع، وإذا كان تمليكاً لمنفعة بعوض فهذه إجارة، وإذا كان تمليكاً للمنفعة بغير عوض فهذه عارية. ^(٢)

ثانياً: مشروعية الإجارة :

ثبتت مشروعية الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول:

أما الكتاب فأيات منها مايلي :

١- قال تعالى : { قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } . ^(٣)

وجه الدلالة : ذكر المولى سبحانه وتعالى أن نبيناً من أنبيائه صلى الله عليه وسلم أجر نفسه حجاً مسماء يملك بها بضع امرأة ، فدل

(١) أنوار البروق في أنواع الفروق ج ٣ ص ٢٠٨-٢٠٩.

(٢) تكملة المجموع شرح المذهب ج ١٥ ص ٣٧٥.

(٣) سورة القصص آية ٢٦.

ذلك على جواز الإجارة؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ^(١) .
فدل ذلك على أن الإجارة بينهم وعندهم مشروعة وهى كذلك فى كل
ملة، فهى من ضرورات الخليقة.^(٢)

٢- قال تعالى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ }^(٣) .

وجه الدلالة : دلت الآية الكريمة على جواز الإجارة فى قوله تعالى :
{ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ } دليل على جواز الإجارة على الرضاع مع جهالة
مقدراه حيث إنه يختلف بكثرة إرضاع المولود وقتله، وكثرة لبن
المرضعة وقتله، لكن لما جازت الإجارة عليه، جازت الإجارة على
ما هو مثله وما هو فى معناه .^(٤)

٣- قال تعالى : { وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا }^(٥)

وجه الدلالة : دلت الآية الكريمة على مشروعية الإجارة، فى قوله
تعالى : { سُخْرِيًّا } أى ليستعمل بعضهم بعضاً فى مصالحهم
ويستخدمهم فى مهنتهم ويسخروهم فى أشغالهم حتى يتعاشوا.^(١)

(١) الإمام الشافعي: أحكام القرآن ج ١ ص ٢٦٥ ، د/ وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي ج
٥ ص ٤٥٣

(٢) الإمام ابن العربي : أحكام القرآن ج ٣ ص ٤٩٤ .

(٣) سورة الطلاق آية ٦ .

(٤) الإمام الشافعي : أحكام القرآن ج ١ ص ٢٦٣ ، الحاوى الكبير ج ٧ ص ٩٤٣ .

(٥) سورة الزخرف آية ٣٢ .

٤ - قال تعالى : { وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } . (٢)

وجه الدلالة: فى الآية الكريمة نفى المولى سبحانه وتعالى الجناح عمن يسترضع لولده ظئراً، وفى قوله تعالى { إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ } أى إذا سلمتم إلى المرضعة التى تستأجر أجرها بالمعروف (٣) وفى هذا دليل على مشروعية الإجارة .

٥ - قال تعالى : { فَاَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا } . (٤)

وجه الدلالة : دلت الآية الكريمة على جواز الإجارة، وهى سنة الأنبياء. (٥)

أما السنة فأحاديث منها :

١ - رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

(١) الألوسى : روح المعانى ج ٢٥ ص ٧٨ .

(٢) سورة البقرة آية: ٢٣٣ .

(٣) الماوردي : النكت والعيون ج ١ ص ١٧٢ .

(٤) سورة الكهف آية: ٧٧ .

(٥) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج ١١ ص ٣٢ .

(^١) وجه الدلالة : دل ظاهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصل، على جواز الإجارة .(^٢)

٢- روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)(^٣)

٣- روي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت (واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الدئل هادياً خريئاً)^(٤) وهو على دين كفار قريش فدفعاً

(^١) أخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب الأحكام - باب أجر الأجراء ج ٣ ص ٥١١ حديث رقم (٢٤٤٣)، وعلق عليه: شعيب الأرئؤو بقوله: حسن لغيره، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وله شاهد قوي من حديث أبي هريرة ، وفي كشف الخفاء ج ١ ص ١٤٣: رواه ابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عمر وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنهم .

(^٢) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٧٤.

(^٣) أخرجه البخاري في صحيحة - كتاب الإجارة - باب إثم من منع الأجر ج ٣ ص ٩٠ ، حديث رقم (٢٢٧٠).

(^٤) الخريت : الدليل الحائق بالدلالة. المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٦٦.

إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ
ثَلَاثٍ (١).

٤- روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ
الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا
فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ
إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى
قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
كِتَابُ اللَّهِ) (٢).

وجه الدلالة: دل ظاهر الأحاديث السابقة من قول الرسول صلى الله
عليه وفعله على جواز الإجارة ومشروعيتها.

أما الإجماع: فقد نقله ابن قدامة في المغني، والكاساني في البدائع
وغيرهم، قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر
على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبدالرحمن بن الأصم أنه قال:
لا يجوز ذلك لأنه غرر يعنى أنه يعقد على منافع لم تخلق وهذا غلط

(١) أخرجه البخاري في صحيحة - كتاب الإجارة - باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له
بعد ثلاثة أيام، ج ٣ ص ٨٩ (٢٢٦٤).

(٢) المرجع السابق - كتاب الطب - باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، ج ٧
ص ١٣٢-١٣٣ ، حديث رقم (٥٧٣٧) .

لا يمنع انعقاد الإجماع الذى سبق فى الأعصار وسار فى الأمصار .
(١)

قال الكاساني فى البدائع: فان الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة رضى الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير فلا يعبأ بخلافه إذ هو خلاف الإجماع. (٢)

أما القياس : فهو قياس عقد الإجارة على عقد البيع فلما جاز العقد على الأعيان وجب جواز العقد على المنافع ؛ لأن حاجة الناس إلى المنافع كحاجتهم إلى الأعيان. (٣)

أما المعقول : فلأن كل واحد لا يكون له داراً مملوكة يسكنها أو أرضاً مملوكة يزرعها أو دابة مملوكة يركبها ، وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن ، ولا بالهبه والإعارة ؛ لأن نفس كل واحد لا تسمح بذلك فيحتاج إلى الإجارة فجوزت ، لأن التشريع الإسلامى ، شرع لكل حاجة عقداً يختص بها فشرع لتمليك العين بعوض عقداً وهو البيع ، وشرع لتمليكها بغير عوض عقداً وهو الهبة ، وشرع لتمليك المنفعة بغير عوض عقداً وهو الإعارة ، فلو لم يشرع الإجارة مع مساس

(١) المغنى ج ٦ ص ٥ .

(٢) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٧٤ .

(٣) المغنى ج ٦ ص ٥ .

الحاجة إليها لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيلاً ، وهذا خلاف
موضوع الشرع . (١)

(١) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٧٤ .

ثالثاً: أنواع عقد الإجارة باعتبار المعقود عليه

ينقسم عقد الإجارة باعتبار المعقود عليه إلى نوعين:

النوع الأول: عقد الإجارة الوارد على منافع الاعيان وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول : إجارة العقار كالدور والأراضى.

القسم الثانى : إجارة العروض كالملابس والأوانى.

القسم الثالث : إجارة الدواب.

كما ينقسم عقد الإجارة الوارد على منافع الاعيان إلى:

أ- إجارة على أعيان مرئية حيث يشترط فيها ما يشترط لصحة عقد البيع.

ب- إجارة أعيان موصوفة فى الذمة حيث يشترط لها ما يشترط للسلم^(١) بأن توصف بما يضبطها حتى لا يقع تنازع بين المتعاقدين.^(١)

(١) أما عن شروط المسلم فيه : أن يكون معلوم الجنس كحنطة أو شعير أو تمر، والنوع : كحنطة سقية أو نحسية ، وإن كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع ، وأن يكون معلوم الصفة : كجيد أو وسط أو رديء ، ومعلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ؛ لأن جهالة النوع ، والجنس ، والصفة ، والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة ومفسدة للعقد .انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٥ ص ٢٠٧.

النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على الأعمال مثل : استئجار أصحاب الحرف والصنائع، كإعطاء السلعة للخياط مثلاً ليخيط ثوباً يصير إجارة على العمل، فإن كان الثوب من عند الخياط كان عقد استصناع .

وينقسم إلى : أ- أجير خاص وهو الذى يعمل لواحد.

ب- أجير مشترك وهو الذى يعمل لعامة الناس.

(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ١ ص ٤٥٢-٤٥٣ ، شرح منتهى الإرادات ج ٢ ص ٢٥٢ وما بعدها ، كشف القناع ج ٣ ص ٥٦١ وما بعدها .

رابعاً: الفرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك

وبين بعض عقود المعاوضات

الفرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك وبين عقدي البيع والإجارة:

بالنظر لعقدي البيع والإجارة نجد أنهما من العقود اللازمة، إلا أن عقد البيع وارد على العين ومنفعتها ، بحيث يملك المشتري العين ومنفعتها، بينما عقد الإجارة تنتقل فيه ملكية المنفعة فقط للمستأجر دون العين حيث تبقى على ملك المؤجر^(١).

أما عقد الإجارة المنتهي بالتمليك فهو عقد بيع في صورة عقد إيجار ، الهدف منه ضمان بقاء ملكية العين للمؤجر^(٢) إلا أن له مزايا سوف أذكرها بعد التعرض لتعريفها ونشأتها .

الفرق بين الإجارة المنتهية بالتمليك وبين الإجارة التشغيلية:

إن الاختلاف الرئيسي بينهما هو أن الأعيان المؤجرة في الإجارة التشغيلية تعود إلى حياة البنك المؤجر بعد انتهاء مدة العقد، ويبدأ البنك بالبحث عن مستخدم آخر يرغب في استئجار العين، ويتميز ها

(١) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ١ ص ١١٠ ، الفواكه الدواني ج ٢ ص ٧٣

، المجموع شرح المذهب ج ٩ ص ٢٠٧ ، شرح منتهى الإرادات ج ٢ ص ٢٦٣ .

(٢) د/ سعد بن ترك الخثلان : المعاملات المالية المعاصرة ص ١٢١ .

الأسلوب بأن المالك يتحمل مخاطر ركود السوق وانخفاض الطلب على تلك الأعيان مما يؤدي إلى خطر عدم استغلالها ، أما في المنتهية بالتملك فبعد انتهاء مدة العقد تنتقل العين إلى ملكية المستأجر. ^(١)

الفرق بين الإجارة المنتهية بالتملك والبيع بالتقسيط:

١ - البيع بالتقسيط عقد تنتقل فيه ملكية العين إلى المشتري بمجرد إبرام العقد، وله حرية التصرف في المبيع على أن يتم سداد الثمن على أقساط وهو عقد واحد لا يتجدد بإنهاء الأقساط ، وهذا بخلاف الإجارة المنتهية بالتملك فلا تنتقل الملكية الا بعد انتهاء الاجارة وابرام عقد التملك. ^(٢)

٢ - في البيع بالتقسيط تعتبر الأقساط ديناً لازماً في ذمة المشتري بعد إبرام العقد، أما في الاجارة المنتهية بالتملك تعد دفعات الإجارة ديوناً غير مستقرة إلا بعد التمكن من استيفاء المنفعة.

٣ - في البيع بالتقسيط تثبت ملكية البائع بعد البيع للدين الذي في ذمة المشتري، ولذا لا يجوز بيع هذا الدين ولا تصكيكه؛ لأنه من

(١) الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة ، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة مجموعة دلة البركة ، ص ٢١٠، ٢٠٩ .

(٢) د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) ص ٣٩٥-٣٩٦.

تداول الديون بينما في الإجارة المنتهية بالتمليك تثبت ملكية المؤجر للأعيان المؤجرة ولذا يجوز تصكيك هذا الحق. (١)

(١) د/ يوسف الشبيلي: دورة عقد التأجير التمويلي ، ص ٩.

خامساً: مفهوم الإجارة المنتهية بالتملك

وما يطلق عليها من مصطلحات

مفهوم الإجارة المنتهية بالتملك :

عقد الإجارة المنتهية بالتملك هو عقد كان أول ظهور له في إنجلترا، وقد ظهر كصورة معدلة من البيع بالتقسيط، حيث يصاغ فيها البيع في صورة عقد إيجار وهو عقد لم يكتب عنه أحد من الفقهاء المتقدمين، بينما كتب فيه كثير من العلماء المعاصرين.

وقد عرفه د/ خالد الحافى : بأنه عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجره معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد. (١)

بينما عرفها د/ القره داغى : بأنها عقد يتفق فيه الطرفان على إجارة شيء لمدة معينة بأجرة معلومة - قد تزيد على أجره المثل - على أن تنتهى بتمليك العين المؤجرة للمستأجر. (٢)

(١) الإجارة المنتهية بالتملك في الفقه الإسلامي ص ٧ نقلاً من د / خالد الحافى :

الإجارة المنتهية بالتملك فى ضوء الفقه الإسلامى ص ٦٠.

(٢) د/القره داغى: الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة "الإجارة المنتهية بالتملك" ضمن

أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى بجدة، العدد الثانى عشر ج ٢.

بينما جاء استفسار البنك الإسلامي للتنمية الموجه إلى مجمع
الفقه الإسلامي في وصف هذا العقد : بأنه عقد إجارة يتضمن إلزاماً
من المؤجر بهبة العين المستأجرة عقب وفاء جميع أقساط الأجرة.

أما الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي فقد عرفت الإجارة
المنتھية بالتمليك بأنها : عقد على انتفاع المستأجر بمحل العقد بأجرة
محددة موزعة على مدة معلومة على أن ينتهي العقد بملك المستأجر
للمحل. ^(١)

المصطلحات التي تطلق على عقد الإجارة المنتھية بالتمليك : يطلق
على هذا العقد عدة مصطلحات منها :

- البيع الإيجاري.
- الإيجار السائر للبيع.
- الإيجار الذي ينقلب بيعاً.
- الإيجار المقترن بوعد بالبيع. ^(٢)

(١) د/ منذر قحف: الإجارة المنتھية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة. ضمن

أبحاث مجلة المجمع العدد الثاني عشر ج ٢.

(٢) د/ فهد الحسون: الإجارة المنتھية بالتمليك في الفقه الإسلامي ص ١٥ .

سادساً: نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتملك

نشأ هذا العقد فى انجلترا عام ١٨٤٦م وأول من تعامل به تاجر لآلات الموسيقى كان يؤجر آلاته إجارة يتبعها تملك، ثم انتقلت الفكرة من الأفراد إلى الشركات والمصانع، فعمل بالفكرة شركة سنجر لآلات الخياطة حيث كان يتم التعامل مع العملاء عن طريق عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين يمثل فى حقيقته ثمناً لها، ثم تطور هذ العقد، وما لبث أن تزايد مما دفع بالمشرعين إلى تنظيمه بنصوص قانونية، وذلك منذ بداية هذا القرن، فقد تناوله فقهاء القانون تحت مسميات الإيجار الساتر للبيع، أو البيع الإيجارى، أو الإيجار المملك، وذلك عند شرحهم للمواد القانونية الخاصة به مثل المادة (٤٣٠) من القانون المدنى المصرى، ثم انتقل بعد ذلك إلى الدول الإسلامية من خلال البنوك الإسلامية والتي جعلت هذا العقد جزءاً من العمليات الأساسية التى تقوم بها، ومن البنوك الإسلامية التى طبقت هذا العقد - بنك ماليزيا الاسلامى - ، كما قام - بنك مصر إيران للتنمية - بالاشتراك مع هيئة سوق المال بدراسة كافة الجوانب المتعلقة بمثل هذا النشاط، وذلك بالاستعانة بهيئة التمويل التابعة للبنك الدولى للإنشاء والتعمير نظراً لخبرتها فى هذا المجال، وعلى أثر النتائج الإيجابية لهذه الدراسة قام

بنك مصر إيران بتأسيس أول شركة تأجير مالى فى مصر بالإشتراك
مع هيئة التمويل الدولية وشركة مانوفاكتشورز ليسينج الأمريكية.^(١)

(١) د/ ياسر بن طه : المعاملات المالية المعاصرة فى الفكر الاقتصادى الاسلامى
ص ١٣٠ ، د/ سعد بن عبدالله السبر: الإيجار المنتهى بالتملك ص ١٢ نقلاً من
بحث د/القره داغى : ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ج ١،
الإجارة المنتهية بالتملك فى الفقه الإسلامى نقلاً من البيع بالتقسيط والبيع
الائتمانية الأخرى د ابراهيم دسوقى ص ٣٢-٣٤، د/ خالد الحافى : الإجارة
المنتهية بالتملك ص ٦٢-٦٥.

سابعاً: مزايا عقد الإجارة المنتهية بالتملك

ما يحققه التأجير المنتهى بالتملك من مزايا:

يحقق عقد الإجارة المنتهى بالتملك العديد من المزايا سواء بالنسبة للمستأجر أو للمؤجر أو للاقتصاد القومي، وذلك على النحو:

بالنسبة للمستأجر: يحقق الإيجار المنتهى بالتملك بصيغته المقبولة الكثير من المزايا بالنسبة للمستأجر ، وأهمها ما يأتي :

١- حيازة المستأجر للأصل والاستفادة منه بالرغم من عدم قدرته على دفع الثمن نقداً

٢- عدم الحاجة إلي تجميد جزء كبير من رأس ماله وذلك في حالة قدرته على السداد مما يحسن مركز السيولة لديه.

٣- يعمل على اقتناء معدات حديثة قد لا تتوافر للمستأجر إمكانية شرائها لضعف الموارد الذاتية لديه، أو عدم القدرة على الاقتراض .

٤- يقدم أسلوب التأجير المنتهى بالتملك تمويلاً كاملاً للأصول المستأجرة، إذ أنه لا يتطلب أن يدفع المستأجر جزءاً من ثمنه مقدماً.

٥- تفادى القيود التي تلتزم بها البنوك في تمويلها للمشروعات أو إقراضها، فهو يعد أسلوباً تمويلياً أفضل من الإقراض بالفوائد الربوية المحرمة.

٦- عدم التعرض لمخاطر التمويل عن طريق الاقتراض .

٧- أنه يحقق ميزة مهمة للمستأجر وهو تجنب الضرائب التي قد تفرض على بعض الملاك في بعض الأنظمة، إذ يعمل على أن تكون الضرائب منخفضة بأكبر قدر ممكن، حيث يتم خصم قيمة الأقساط الإيجارية من أرباح المستأجر وصولاً إلى صافى الربح الخاضع للضريبة.

٨- عدم إرهاب المستأجر بالديون، إذ في حالة التأجير لا تظهر قيمة الأصل في ميزانية المستأجر، وإنما تنعكس عملية التأجير مالياً في حساب الأرباح والخسائر فقط حيث تمثل الأقساط إحدى بنود المصروفات، وهذا على العكس فيما إذا اقتضت الشركة لشراء هذا الأصل فعندئذ تظهر قيمة الأصل في جانب الأصول من الميزانية، وتظهر المبالغ المقرضة في جانب الخصوم، وهذا يؤثر على النسب التحليلية المستخرجة من المركز المالي.

بالنسبة للمؤجر: يحقق الإيجار المنتهي بالتمليك بصيغته المقبولة الكثير من المزايا بالنسبة للمؤجر ، وأهمها ما يأتي :

١- يحمل هذا الأسلوب المستأجر كل تكاليف الصيانة اللازمة للمحافظة على الأصول المؤجرة مع تحمل تكلفة التأمين .

٢- يحتفظ من خلال هذا العقد بحق الرقابة بحيث يمكنه استرجاع الأصل في حالة عدم سداد المستأجر لباقي الأقساط أو عند الإخلال ببعض شروط التعاقد .

٣- توفر شروط التعاقد فى التأجير المنتهى بالتملك مرونة كبيرة بين المؤجر والمستأجر بحيث يمكن للمؤجر إختيار العميل الذى تتوافق إحتياجاته مع طبيعة الخدمة التى يقدمها المؤجر .

٤- بتملك المعدات المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأقساط يوفر على المؤسسة المالية كثيراً من التكاليف فيما لو كانت هذه المعدات تحتاج إلى تفكيك وإرجاع إليها .

- بالنسبة للاقتصاد القومي: تحقق الإجارة المنتهية بالتملك العديد من المزايا بالنسبة للاقتصاد القومي ، ومن أهمها ما يأتي :

١- إتاحة الأصول والمعدات عن طريق هذا العقد مما يساعد على انشاء مزيد من المشروعات الانتاجية فى البلاد، أو على تبنى الوحدات القائمة بمشروعات للتوسع، وهذا له أثره البارز فى احداث التنمية الاقتصادية .

٢- زيادة فرص تشغيل العمالة فى المجتمع ، وهو ما يحد من البطالة.

٣- التعجيل بإقامة صناعات متقدمة أكثر إنتاجية . (١)

(١) د/ سعد بن عبدالله السبر: التأجير المنتهى بالتملك ص١٥، نقلاً من : بيع التقسيط للتركي ص (١٩٤) ، د/ محى الدين القره داغى ، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى- العدد الثانى عشر ، دكتور عصام أبو النصر: دور صيغة الإيجار المنتهى بالتملك (في دعم وتنمية الصناعات الصغيرة) ص ٨ .

الوحدة الثانية:

في ذكر صور الإجارة المنتهية بالتمليك مع بيان بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها التكييف الفقهي لتلك الصور.

أهداف الوحدة الثانية:

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على أن :

١ - فهم واستيعاب صور هذا العقد .

٢ - الإلمام ببعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها التكييف الفقهي لتلك الصور ، وتتمثل تلك المسائل: في إجتماع البيع والإجارة في عقد واحد - نفقات الصيانة والتأمين - بيع العين المؤجرة للمستأجر - وحكم الوفاء بالوعد.

الوحدة الثانية:

صور الإجارة المنتهية بالتمليك، مع بيان بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها هذا العقد

أولاً: صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

للإجارة المنتهية بالتمليك صور عديدة نذكر منها ما يلي:

الصورة الأولى : أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهى بتملك
الشئ المؤجر - إذا رغب المؤجر فى ذلك - مقابل ثمن يتمثل فى
المبالغ التى دفعت فعلاً كأقساط إيجار لهذا الشئ المؤجر خلال المدة
المحددة، ويصبح المستأجر مالكاً للشئ المؤجر تلقائياً بمجرد سداد
القسط الأخير، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد .

ويمكن صياغة هذا العقد على النحو التالى :

أجرتك هذه السلعة بأجرة فى كل شهر أو عام هى كذا لمدة
ثلاث سنوات مثلاً، على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها فى
السنوات الثلاث، كان الشئ المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من
أقساط الأجرة فى هذه السنوات، ويقول الآخر قبلت.

فالعقد فى هذه الصورة إجارة تنتهى بتمليك العين دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية المتفق عليها. (١)

الصورة الثانية : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يمكن المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة فى مقابل أجرة محددة فى مدة محددة للإجارة على أن يكون للمستأجر الحق فى تملك العين المؤجرة فى نهاية مدة الإجارة مقابل دفع مبلغ هو كذا .

ويمكن تصور صياغة هذا العقد على النحو التالى: أجرتك هذه السلعة بأجرة فى كل شهر أو عام هى كذا، لمدة ثلاث سنوات - مثلاً - على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها فى المدة المحددة بعثتك هذه السلعة إذا رغبت فى ذلك بثمن هو كذا، ويقول الآخر قبلت .

من خلال عرض تصور لصياغة العقد فى هذه الصورة نجد أن العقد اشتمل على إجارة للعين فى المدة المحددة ثم بيعها فى نهاية المدة بثمن إما رمزى أو حقيقى.

والثمن إذا كان رمزياً فإنه قد روعى فيه عند الاتفاق على الأقساط الإيجارية أنها تعادل فى مجموعها ثمن السلعة الحقيقى مع ما أضيف إليه من ربح، وقد وضع هذا الثمن رمزياً لهدفين:

(١) د/ حسن الشاذلى : الإيجار المنتهى بالتمليك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد الخامس ، د/ فهد بن على الحسون : الإجارة المنتهية بالتمليك فى الفقه الإسلامى ص ١٢ .

الأول: إظهار الاتفاق بأنه كان فى البداية عقد إجارة .

الثانى: أنه فى النهاية عقد بيع .

ولا شك بأن العقد فى هذه الصورة قد اشتمل على عقدين، وإذا كان الثمن حقيقياً فهى صورة جمعت بين عقدين أيضاً :

الأول: عقد ناجز وهو عقد الإجارة، اقترن به شرط فاسخ يبدأ بعده عقد البيع .

الثانى : عقد بيع معلق على شرط . (١)

الصورة الثالثة : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فى مقابل أجرة محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً - إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية فى المدة المحددة - ببيع العين المؤجرة فى نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين .

ويمكن تصور صياغة العقد على النحو التالى: أجرتك هذه السلعة بأجرة فى كل شهر - أو عام - هى كذا لمدة ثلاث سنوات مثلاً،

(١) د/ فهد بن على الحسون: الإجارة المنتهية بالتملك فى الفقه الإسلامى ص١٢،

د/ أحمد نصار: عقد الإجارة فقهاً وتطبيقاً ص٢٢ ، د/ حسن الشاذلى: الإيجار

المنتهى بالتملك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد الخامس.

وأعدك وعداً ملزماً ببيعها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في
المدة المحددة، ويقول الآخر قبلت^(١)

فالعقد بهذه الصورة هو إجارة مقترنة بوعد بالبيع .

الصورة الرابعة : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر
من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجره محددة في مدة محددة
للإجارة، على أن المؤجر يعد وعداً ملزماً بهبة العين للمستأجر إذا
وفي سداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة في نهاية العقد .

ويمكن تصور صياغة هذه الصورة بأن يقول المؤجر: أجرتك هذه
السلعة بأجرة في كل شهر مثلاً هي كذا لمدة ثلاث سنوات مثلاً،
وأعدك وعداً ملزماً بهبة العين لك إذا وفيت جميع الأقساط الإيجارية
في المدة المحددة، ويقول الآخر قبلت ، فالعقد في هذه الصورة إجارة
مقترنة بوعد بهبة العين^(٢).

الصورة الخامسة : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن
المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجره محددة في مدة

(١) الإجارة المنتهية بالتملك في الفقه الإسلامي ص ١٩، سعد بن عبد الله السبر:
التأجير المنتهي بالتملك ص ١٣-١٤ نقلاً من الإيجار المنتهي بالتملك
للشاذلي. والإجارة تطبيقاتها المعاصرة للقرّة داغي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه
الإسلامي- العدد الخامس، الثاني عشر.

(٢) د/ سعد بن عبد الله السبر: التأجير المنتهي بالتملك ص ١٤، د/ فهد بن علي
الحسون : الإجارة المنتهية بالتملك في الفقه الإسلامي ص ١٩.

محددة للإجارة، مع وعد ملزم من المؤجر فى أن يجعل للمستأجر فى نهاية مدة الاجارة الحق فى ثلاثة أمور :

الأول : تملك السلعة مقابل ثمن يراعى فى تحديده المبالغ التى دفعها المستأجر كأقساط للإجارة. وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد.

الثانى: مد عقد الإجارة لفترة أخرى .

الثالث: إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها^(١)

نجد أن عقد الاجارة فى هذه الصورة مقترن بوعد التخيير بالتملك أو مد مدة الإجارة أو إعادة العين المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها.

(١) الإجارة المنتهية بالتمليك فى الفقه الإسلامى ص١٣، التأجير المنتهى بالتمليك ص١٤ نقلا من بحث للدكتور حسن على الشاذلى ضمن مجلة مجمع الفقه الاسلامى جدة - الدورة الخامسة ٤/٢٦١٣-٢٦١٧، د/ خالد الحافى : والاجارة المنتهية بالتمليك فى ضوء الفقه الإسلامى ص٦٦-٧٠.

ثانياً: بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها هذا العقد:

أولاً: حكم اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد:

قبل البدء ببيان حكم عقد الإجارة المنتهية بالتملك يلزم بحث بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها هذا العقد فإذا عرف الحكم في هذه المسائل تبين التكليف الفقهي الصحيح لهذا العقد:

وذلك بأن يتراضى العاقدان على إبرام معاهدة تشتمل على عقدي البيع والإجارة بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود، وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليهما جملة واحدة ، أي بمثابة آثار العقد الواحد.

وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على رأيين :

الرأي الأول : يرى جواز اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد سواء كان محل العقد واحداً أو مختلفاً بثمن واحد، كما لو باع له جلوداً على أن يخرزها البائع للمشتري نعالاً أو كانت الإجارة في غير المبيع كما لو باع له ثوباً بدراهم معلومة على أن ينسج له ثوباً آخر، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المالكية ^(١) عدا سحنون، وأصح القولين عند

(١) شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤ .

الشافعية^(١)، والمذهب عند الحنابلة^(٢)، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(٣).

بينما اشترط ابن القاسم في مذهبه وروايته عن مالك: أن جواز اجتماع البيع والإجارة في عين واحدة في إجارة الأعمال ، وعلى منافع ما يعقل: أن يعرف وجه خروج هذا العمل - على أي وجه كان من كونه رديئاً أو جيداً ، بأن كان المستأجر متقناً في صنعته فيخرج جيداً ، أو لا فيخرج رديئاً - ، أو لا يعرف وجه خروجه، ولكن يمكن إعادته - أي كما كان إن لم يرضى به المؤجر -^(٤) كما هو موضح في نص ابن رشد التالي:

جاء في مواهب الجليل: "ابن رشد: هذا معلوم مشهور من مذهب سحنون أن البيع والإجارة في الشيء المبيع عنده لا يجوز على حال، ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك، وهو الصحيح إن كان ذلك فيما يعرف وجه خروجه كيبيعه ثوباً على أن على البائع خياطته، أو قمحاً على أن يطحنه، أو فيما لا يعرف وجه خروجه ولكن يمكن إعادته

(١) المجموع شرح المذهب ج ٩ ص ٣٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٥١ .

(٢) الإنصاف ج ٤ ص ٣٢١ .

(٣) مجموع الفتاوى ج ٢٩ ص ٦٢ .

(٤) شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤ د / حسن الشاذلي : الإيجار المنتهى بالتملك

- ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس ج ٢ ص ١٠٦٠٢ .

للعمل كبيعه صفراً^(١) على أن يعمل البائع منه قدحاً، وما أشبه ذلك
فذلك جائز، وأمّا ما لا يعرف وجه خروجه، ولا يمكن إعادته للعمل
كبيعه غزلاً على أنّ على البائع نسجه، أو الزيتون على أنّ على البائع
عصره، أو الزرع على أنّ على البائع حصاده ودرسه، وما أشبه ذلك
فلا يجوز باتّفاق^(٢).

ويذكر د/ محمد المختار السلامي: إن ما ذكره ابن رشد يبدو حسب
الأمثلة التي مثل بها أن الخلاف يجري في الإجارة على منافع ما
يعقل؛ فهو الذي يتصور فيه الخطر الذي منع من أجله سحنون
اجتماعهما ، لما يحصل من عمل الأجير من تأثير في العين لو
استحق الشيء المبيع مثلاً، بخلاف الإجارة على منافع ما لا يعقل ،
فلا يتصور فيه مثل هذا التأثير ، فالظاهر أنه لا خلاف في جواز
اجتماعهما .^(٣)

ويدل على ذلك ما جاء في التاج والإكلیل: "هذا إذن إنما باع سلعة
بثمن سماه وبعمل هذه الدابة ولباس هذا الثوب أجلاً مسمى فاجتمع
بيع وكراء فلا بأس به".^(٤)

(١) بمعنى: شجر تسوى منه أفداح صفر. لسان العرب ج ٢ ص ٦٤٢.

(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٧ ص ٥٠٤ .

(٣) الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير: د/ محمد المختار السلامي ضمن

أبحاث مجلة الفقه الإسلامي ج ٢ ص ٢٢٤٠٧ .

(٤) التاج والإكلیل ج ٦ ص ٥٦١ .

جاء فى الإنصاف: "(وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف) يعنى بثمن واحد (صح فيهما) فى أحد الوجهين، وقيدته الحنابلة بوجوب معرفة النفع فلو شرط الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح". (١)

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالمعقول من عدة أوجه:

الأول: أن الأصل فى العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه، وإبطاله نص أو قياس (٢).

الثاني: أن الأصل فى العقود رضى المتعاقدين ونتيجته هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد .

الثالث: لأن البيع والإجارة كل منهما عقد يصح إفراده فصح جمعهما (٣).

الرابع: أنه ليس فى اجتماع العقدين أكثر من اختلاف حكمهما، وهذا لا يمنع صحة العقد، ونقسم العوض عليهما. (٤)

الرأي الثانى : يرى عدم جواز اجتماع البيع والإجارة فى عقد واحد، وقول الحنفية (٥)، والشافعية فى وجه (٦)، ورواية للحنابلة (١)، ووافقهم

(١) الإنصاف ج ٤ ص ٣٢١.

(٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج ٤ ص ٧٩، مجموع الفتاوى ج ٢٩ ص ٣٢.

(٣) المغنى والشرح الكبير ج ٤ ص ٥٢.

(٤) تكملة المجموع شرح المذهب ج ١٠ ص ٣٤٧.

(٥) المبسوط للسرخسي ج ١٢ ص ١٩٦.

(٦) المجموع شرح المذهب ج ٩ ص ٣٨٨، السيوطي : الأشباه والنظائر ص ١٥١ .

سحنون من فقهاء المالكية فيما إذا كان محل العقد واحداً، في الإجارة على الأعمال، أما إذا كان محل العقد مختلفاً جاز إجتماع البيع والإجارة في عقد واحد سواء كانت الإجارة على منافع أو أعمال . (٢)

جاء في بدائع الصنائع : " اذا باع داراً على أن يسكنها البائع شهراً ثم يسلمها إليه أو أرضاً على أن يزرعها سنة أو دابة على أن يركبها شهراً أو ثوباً على أن يلبسه أسبوعاً... فالبيع في هذا كله فاسد " . (٣)

يتضح من خلال نص الحنفية نجد أنهم منعوا اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد سواء كانت إجارة أعمال أو إجارة منافع .

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول:

أما السنة فأحاديث منها :

١- مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) (٤)، أي صفقة واحدة وفي عقد واحد .

(١) الإنصاف ج ٤ ص ٣٢١ .

(٢) منح الجليل شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤٤٣ .

(٣) بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٦٩ .

(٤) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ج ٣ ص ٥٢٥ حديث رقم (١٢٣١) ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .

٢- مَا رُويَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ).^(١)

جاء في الكافي في معنى الحديث: " أن يشترط عقداً آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عيناً أخرى أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف فهذا شرط فاسد يفسد العقد به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)... (نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) وهذا منه^(٢).

نوقش الإستدلال بهذا الحديث من وجهين :

الأول: أن المراد من نص الحديث هو أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن التبرع إنما كان لأجل المعاوضة .^(٣)

الثاني: أن المراد من بيعتين في بيعة: أن يملك الرجل السلعة بثمانين عاجل وأجل.

وأما المعقول فمن عدة أوجه :

(١) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح - كتاب البيوع - باب باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ج ٣ ص ٥٢٧ ، حديث رقم (١٢٣٤). قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

(٢) المقدسي: الكافي في فقه ابن حنبل ج ٢ ص ٢٢ .

(٣) مجموع الفتاوى ج ٢٩ ص ٦٢-٦٣ .

الأول: أن اشتراط الإجارة مع البيع يتضمن زيادة منفعة مشروطة في عقد البيع وهى زيادة لا يقابلها عوض، فهى ربا أو فيها شبهة الربا وبالتالي فهو فاسد.

الثانى: أن اشتراط عقد في عقد آخر لا يقتضيه أحدهما، قد تضمن منفعة تجوز المطالبة بها، فصار فى ذاته عقد آخر - إجارة أو إعارة أو بيعاً - تضمنه عقد البيع^(١)؛ لأنه إذا كان بعض البذل فى مقابلة العمل المشروط عليه فهو إجارة مشروطة، وإن لم يكن فى مقابلة العمل شئ فهو إعارة مشروطة فى البيع وهذا مفسد للعقد^(٢).

الثالث: لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما بأولى من الآخر فبطل فيهما؛ وذلك لأن البيع فيه خيار ولا يشترط فيه التقابض فى المجلس، ولا يفسخ العقد بتلف العين، بخلاف الإجارة حيث يفسخ العقد فيها بتلف العين^(٣).

نوقش ذلك : بأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد كما لو جمع فى البيع

(١) مجلة البحوث الاسلامية العدد الثانى ج ٢ ص ١١١.

(٢) المبسوط ج ١٥ ص ٢٨٧.

(٣) الكافى فى فقه أحمد ج ٢ ص ٢٠ .

بين ما فيه شفعة وبين ما ليس فيه فإنه يصح مع إختلاف حكمهما فيجوز إجتماع عقد البيع، والإجارة سواء كان محل العقد واحداً أم مختلفاً^(١).

الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد أرى- والله أعلم - رجحان الرأي الأول القائل بالجواز : لما فيه من التيسير على الناس في معاملاتهم ولقوة ما استدلوا به، وبالتالي فاذا ترجح اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد فإنه يشترط لذلك:

١- تحديد مدة الإجارة .

٢- الشروع في العمل كخياطة الثوب، أو الشروع في العمل حكماً كتأخيره ثلاثة أيام.

٣- العلم بصفة العمل أي خروجه على أي وجه كان من كونه جيداً أو رديئاً^(٢).

لكن هل اجتماع عقد إجارة على عين مع عقد بيع على هذه العين الواحدة المؤجرة معلق على الوفاء بكامل ثمن المنفعة يصح قياساً على ذلك ، أم لا يصح ؟ إن الصورة التي ذكرها الفقهاء هنا هي

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٠ .

(٢) شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤، الانصاف ج ٧ ص ٣٤٣.

إجارة باثة ناجزة ، وبيع بات ناجز ليس معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل على محلين مختلفين ، ومن ثم فلا يصح القياس على ذلك ؛ لأن هذه العقود لا تقبل عندهم التعليق على شرط ولا الإضافة إلى أجل. (١)

كما أن الضوابط التي ذكرها الفقهاء هي في الإجارة على العمل، فلا يلزم تحققها في الإجارة المنتهية بالتملك. (٢)

(١) د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهى بالتملك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس .

(٢) د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة .

ثانياً: حكم إلزام المستأجر نفقات الصيانة والتأمين

اتفق الفقهاء^(١) على أن يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة، فإذا تلفت العين بلا تعد أو تقصير لم يضمنها.

لما روي عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ).^(٢)

ولأن العين المؤجرة قبضها المستأجر ليستوفى منها منفعتها فلم يضمنها بالقبض.

كما اتفق الفقهاء^(٣) على أنه لا يجوز للمؤجر اشتراط الضمان على المستأجر وإلا كانت الإجارة فاسدة.

والعلة التي من أجلها ذهب الفقهاء إلى القول بفساد الإجارة إذا اشترط على المستأجر ضمان العين: هو أن تكاليف هذا الضمان مجهولة، فقد يتكلف الكثير أو القليل من المال، أو لا يتكلف شيئاً، وذلك حسب الأعطال التي قد تحصل للعين، وهذه جهالة مفسدة

(١) بدائع الصنائع ج ٤ ص ٢١٠، التاج والإكليل ج ٧ ص ٥٣٦، أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٢١، تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٩، المغنى ج ٦ ص ٥٣.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب وضع الجوائح ج ٣ ص ١١٩٠ حديث رقم (١٥٥٤) .

(٣) المدونة ج ٣ ص ٤٥٠، المغني ج ٥ ص ٣١١.

للعقد، لأن من شروط صحة العقود العلم بالأجرة المدفوعة. فقد جاء في "الموسوعة الفقهية ما يدل على ذلك: "ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر ، لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة ، فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب" (١)

بينما خالف في ذلك الزيدية (٢) حيث ذهبوا إلى أن المستأجر ضامن للعين المؤجرة عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه سمرة: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَ). (٣)

ولأن المستأجر لها رضي لنفسه الانتفاع بالعين فكان هذا الرضا الصادر منه محلاً لماله الذي دفعه في ضمانها ولا حجر في مثل هذا . (٤)

وبناءً على ما قال به جمهور الفقهاء من أن ضمان العين المؤجرة على المالك لها فقد ذهب أكثر العلماء المعاصرون إلى: أن نفقات الصيانة غير التشغيلية، والتأمين للعين في عقد الإجارة المنتهية بالتملك لا تجب على المستأجر، وإنما تجب على المؤجر سواء كان مصرف أو شركة فهو مطالب بالابقاء على العين المؤجرة بحالة

(١) الموسوعة الفقهية ج ١ ص ٢٨٦ .

(٢) السيل الجرار ص ٥٧٤ .

(٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب البيوع - باب ما جاء في أن العارية مؤداة

ج ٣ ص ٥٥٨ حديث رقم (١٢٦٦) ، وقال: هذا حديث حسن .

(٤) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص ٥٧٤ .

يستطيع معها المستأجر إستيقاء منافعها، وللمؤجر أن يوكل المستأجر للقيام بذلك ثم يخصم ذلك من قيمة الأجرة، ولا مانع أن يزيد في الأجرة لتغطية تلك النفقات، أما إذا قام به المستأجر دون إذن من المؤجر فهو في ذلك يعتبر متبرعاً.^(١)

بينما أجازا كل من د/ منذر قحف^(٢)، د/ محي الدين القرة داغي^(٣): اشتراط ضمان العين المؤجرة ونفقات الصيانة الجهرية والتي تتعلق بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين على المستأجر عند التعاقد؛ لأنه شرط لا يخالف نصاً من كتاب أو سنة بحيث يكون الشرط جزءاً من التعاقد، وإن كان الأفضل والأحرى أن يخصم المبلغ من الإجارة، خروجاً من الخلاف، أما ما هو غير معلوم من نحو

(١) د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة ص ٤٠٣، علي محيي الدين القره داغي: الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة، (الإجارة المنتهية بالتملك)، د/محمد جبر الألفي : الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الاسلامى عدد ١٢، د/محمد عبدالله بركان: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك - دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية - رسالة ماجستير - جامعة الشرق الأوسط - كلية الحقوق - قسم القانون الخاص ص ٨٢ ، د/ حامد عبدالله العلي/ تيسير بعض أحكام البيوع ص ٥٥ .

(٢) د/ منذر قحف : الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة -مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد الثاني عشر نقلاً من المسؤولية عن أعمال الصيانة في إجارة المعدات. حسين حامد حسان. بحث غير مطبوع .

(٣) د/ القرة داغي : الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة، (الإجارة المنتهية بالتمليك) -مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد الثاني عشر .

نفقات إصلاح كجدار أو سقف انهتما فإنه لا يصح اشتراطه على المستأجر؛ لأنه يدخل جهالة فى مقدار الأجرة مما يفسد العقد.

كما أن ما يتعلق بنفقات التأمين اذا كانت معلومة فهى ما يجوز اشتراطه على المستأجر واعتباره جزءاً من الأجرة ؛ لأن التأمين التعاونى قائم على التبرع ؛ ولا بأس بتبرع غير المالك.

ثالثاً: حكم بيع المؤجر العين المؤجرة للمستأجر

لا خلاف بين الفقهاء^(١) على صحة بيع المؤجر العين المؤجرة للمستأجر.

لأن العين المؤجرة في يد المستأجر لا حائل دونها فصح بيعها منه كما لو باع المغصوب من الغاصب؛ لأن الملك بالشراء لا ينافي الإجارة. (٢).

بينما اشترط المالكية لجواز ذلك: أن يبقى من مدة الإجارة ما لا يكون غرراً يخاف تغييرها في مثله. (٣)

بينما اختلف الفقهاء في أثر ذلك على عقد الإجارة على رأيين :

الرأي الأول: ذهب إلى أن عقد الإجارة لا يفسخ بل يستوفي المستأجر المنفعة بالإجارة إلى انتهاء مدتها، ثم يملكها بعقد البيع، فإن تلفت المنافع قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت ورجع المشتري

(١) مواهب الجليل ج ٧ ص ٥٢٣، تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٧، المغنى

ج ٦ ص ٥٣، السيل الجرار ص ٤٨٧ .

(٢) تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٨ .

(٣) المعونة على مذهب عالم المدينة ج ٢ ص ١١٠٦.

بالأجرة لما بقى على البائع وهذا قول للمالكية^(١)، والشافعية في الأصح^(٢)، ورواية للحنابلة^(٣)

قال ابن الجلاب في التفريع : "ومن أكرى داراً أو أرضاً مدة فلا بأس أن يبيعها من مكترها قبل تمام المدة، ... ولا سبيل له إلى فسخ الإجارة قبل مضي المدة والأجرة على كل حال للبائع دون المبتاع".^(٤)

واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجهين:

الأول: أن المستأجر ملك المنافع أولاً ملكاً مستقراً فلا يبطل مما يطرأ من ملك العين، وإن تبعثها المنافع لولا الملك الأول.^(٥)

الثاني: أن المستأجر تملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا، كما يملك الثمرة بعقد ثم يملك الأصل بعقد آخر، وكذا لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها جاز فعلى هذا يكون الأجر باقياً على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره .^(٦)

(١) القوانين الفقهية لابن جزي ص ١٨٣ .

(٢) تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٨.

(٣) المقدسي: الكافي ج ٢ ص ١٧٧، المغنى ج ٦ ص ٥٣، الإنصاف ج ٦ ص ٣.

(٤) التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلاب ج ٢ ص ١٤٨.

(٥) تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٨ .

(٦) المغنى ج ٦ ص ٥٣ .

الرأي الثاني: يرى فسخ الإجارة فيما بقي من المدة، ويسقط عن المشتري الأجر فيما بقي من مدة الإجارة ويحسب من الثمن وهذا ما ذهب جمهور الفقهاء الحنفية^(١) وبعض المالكية^(٢)، والشافعية في وجهه^(٣)، والحنابلة في رواية. ^(٤)

مستدلين على ذلك: بقياس المسألة على اجتماع النكاح وملك اليمين فكما أنه يفسخ النكاح بملك اليمين فكذلك تنفسخ الإجارة بملك العين المؤجرة . ^(٥) وهو القول الراجح.

(١) الفتاوى الهندية ج ٤ ص ٤٦٤ ، وقد جاء فيها : " وإذا ملك المستأجر العين المستأجرة بميراث أو هبة أو نحو ذلك بطلت الإجارة كذا في فتاوى قاضي خان".

(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج٧ص٥٢٢ وقد جاء فيه:"ربها فقال أبو بكر بن عبد الرحمن : شراء المكتري لها عندي جائز، وهو فسخ لما تقدم من الكراء، وعلى هذا لو انهدمت الدار قبل انقضاء أمد الكراء كانت المصيبة من المشتري؟ إذ الكراء قد انفسخ، وقال الشيخ أبو عمران: شراء المكتري لها جائز، ويكون ذلك فسخا للكراء".

(٣) تكملة المجموع ج ١٥ ص ٨٨ .

(٤) المرجع السابق .

(٥) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج٧ص٥٢٢ .

رابعاً: حكم الوفاء بالوعد:

اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد على أربعة آراء :

الرأي الأول : الوفاء بالوعد مستحب فلو ترك الوفاء به فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيهية شديدة، لكن لا يأنم وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية [إذا لم يكن معلقاً^(١)، وبعض المالكية^(٢)، والشافعية^(٣)، والشافعية^(٣)، والحنابلة في رواية^(٤)، ووافقهم الظاهرية^(٥)].

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: " (سئل) فيما إذا وعد زيد عمراً أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئاً فهل يلزم زيداً شيء بمجرد الوعد المذكور؟ (الجواب) : لا يلزمه الوفاء بوعده شرعاً وإن وفى فيها ونعمت"^(٦)

وجاء في الأشباه والنظائر: "وعده أن يأتيه فلم يأتيه لا يأنم ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً"^(٧) .

(١) ابن نجيم : الأشباه والنظائر ٢٤٧ ، المبسوط ج ٤ ص ١٣٢ .

(٢) التمهيد ج ٣ ص ٢٠٨ ، منح الجليل شرح مختصر خليل ج ٧ ص ٤٢٢ .

(٣) أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٨٦ ، المجموع ج ٤ ص ٦٥٣ .

(٤) المبدع ج ٩ ص ٣٢٢ ، انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن

تيمية ص ٣٣١ ، كشف القناع ج ٦ ص ٢٧٩ .

(٥) المحلى ج ٦ ص ٢٧٨ .

(٦) تنقيح الفتاوى الحامدية ج ٢ ص ٣٢١ .

(٧) ابن نجيم : الأشباه والنظائر ٢٤٧ .

حيث نجد أن الحنفية قالوا بلزوم الوفاء بالوعد فيما لو كان معلقاً^(١)، كما لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء لفلان، وإن لم يعطك الثمن فأنا أعطيه لك، فلم يعط المشتري الثمن، لزم الواعد أداء الثمن وفاء بوعدده.

جاء في المبدع: "لا يلزم الوفاء بالوعد، نص عليه"^(٢) أي الإمام أحمد. واستدلوا على ذلك: بما روي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نَيْتِهِ أَنْ يَفِي لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)^(٣).

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْذِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ) فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ

(١) غمز عيون البصائر ج ٣ ص ٢٣٧.

(٢) المبدع ج ٩ ص ٣٢٢ .

(٣) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في العدة ج ٧ ص ٣٤٦، حديث رقم (٤٩٩٥)، وجاء في التعليق عليه: إسناده ضعيف لجهالة أبو النعمان وأبي وقاص، وأخرجه الترمذي - باب ما جاء في علامة المنافق ج ٥ ص ٢٠، برقم (٢٦٣٣) بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي .

اللَّهُ أَعِدُّهَا وَأَقُولُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) (١).

دل ظاهر الحديثان على عدم لزوم الوفاء بالوعد وذلك لنفي الإثم عنه.

نوقش الاستدلال بالحديثين: بأن ذلك يحمل على أنه لم يف مضطراً جمعاً بين الأدلة، وأن حمله على هذا المعنى أولى . (٢)

بينما استدل الحنفية على لزوم الوفاء بالوعد إذا كان معلقاً :

بأن الوعد إذا كان معلقاً ، فإنه يلزم لقوة الارتباط بين الشرط والجزاء ، من حيث إن حصول مضمون الجزاء موقوف على حصول شرطه ، وذلك يكسب الوعد قوة ، كقوة الارتباط بين العلة والمعلول ، فيكون لازماً.

هذا إذا كان الوعد مما يجوز تعليقه بالشرط شرعاً حسب قواعد مذهبهم ، حيث إنهم أجازوا تعليق الإطلاقات والولايات بالشرط الملائم دون غيره ، أما لتمليكات وكذا التقييدات ، فإنه لا يصح تعليقها بالشرط عندهم (٣).

(١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ - كتاب الجامع - باب ما جاء في الصدق والكذب. ج ٢ ص ٩٨٩ حديث رقم (١٥) .

(٢) حاشية ابن الشاط = إدرار الشروق على أنواء الفروق ج ٤ ص ٢٢ .

(٣) ابن نجيم : الأشباه والنظائر ٣٢٠ ، مجلة الأحكام ص ٧٧.

الرأي الثاني : وجوب الوفاء بالوعد إذا ارتبط بسبب ودخل الموعد في السبب، أما إذا لم يباشِر الموعد السبب فلا شيء على الواعد ، كما لو قال الواعد: اهدم دارك وأنا أسلفك فهدمها، أو اخرج للحج، فخرج ، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، فتزوج اعتماداً على هذا الوعد ، فيلزم الواعد بإنجاز وعده قضاءً، بخلاف ما إذا لم يباشِر الموعد السبب، فلا يلزم الواعد بشيء.

وهذا هو القول المشهور والراجح في مذهب مالك، وعزاه القرافي إلى مالك وابن القاسم وسحنون ^(١).

واستدلوا على تفصيلهم هذا: بأن النصوص الشرعية لما تعارضت فمنها ما أوجب الوفاء بالوعد مطلقاً، وهي الأدلة التي استدل بها من أوجب الوفاء بالوعد، ومنها ما لم يجعل إخلاف الوعد من الكذب كأدلة أصحاب الرأي الأول: حيث إن الآية {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} ^(٢) نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأبلىنا ولم يفعلوا ^(٣)، وهذا لا شك أنه محرم ؛ لأنه كذب، وأما كون مخلف الوعد منافقاً فهو محمول على حالة كون الإخلاف سجية له أو

(١) الفروق ج ٤ ص ٢٥، فتح العلي المالك ج ٢ ص ١٢٩، منح الجليل شرح

مختصر خليل ج ٧ ص ٤٢٢ ، البيان والتحصيل ج ٨ ص ١٨ .

(٢) سورة الصف من الآية : ٣ .

(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١٨ ص ٧٨.

تعمداً^(١)، فكان لا بد من حمل هذه النصوص على خلاف ظاهرها وأن يجمع بين الأدلة، فوافق هذا الرأي من أوجب الوفاء بالوعد إذا كان الوعد على سبب وباشره^(٢).

بينما ناقش ابن حزم ما استدل به المالكية بقولهم: " بأنه لا وجه له ولا برهان يعضده، لا من قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا قياس، فإن قالوا قد أضر به إذ كلفه من أجل وعده عملاً ونفقة؟ قلنا: فهب أنه كما تقولون من أين وجب على من أضر بآخر، وظلمه وغره أن يغرم له مالا؟^(٣)

الرأي الثالث: وجوب الوفاء بالوعد قضاء إذا ارتبط الوعد بسبب ، سواء دخل الموعود في السبب أو لم يدخل فيه ، كما : لو قال شخص لآخر: أعدك بأن أقضك كذا لتتزوج . أو قال الموعود لغيره: أريد أن أقضي ديني أو أتزوج ، فأقرضني مبلغ كذا . فوعده بذلك ، ثم بدا له فرجع عن وعده قبل أن يباشر الموعود السبب. فإن الواعد يكون ملزماً بالوفاء ويحكم عليه به وبه قال أصبغ من فقهاء المالكية^(٤)

(١) الفروق ج ٤ ص ٢٥.

(٢) د/ محمد رضا عبد الجبار العاني :قوة الوعد الملزمة في الشريعة والقانونبحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي، العدد الخامس ج ٢ ص ٩٠٤٧.

(٣) المحلى ج ٦ ص ٢٧٨.

(٤) الفروق ج ٤ ص ٢٥، الجامع لمسائل المدونة ج ١٨ ص ٤٤٧ .

مستدلاً على ذلك: بأن ذكر السبب مرتبطاً بالوعد يتأكد به العزم على الدفع .

الرأي الرابع: الوفاء بالوعد واجب إلا لعذر وهذا قول بعض المالكية منهم ابن العربي^(١)، والإمام أحمد في رواية ثانية^(٢)، وهو قول بعض علماء السلف منهم عمر بن عبد العزيز، وإسحاق ابن رهوية^(٣)، وابن شبرمة حكاه عنه ابن حزم^(٤)، وبه قال الإمام الغزالي^(٥)

قال ابن العربي: "والصحيح عندي: أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر"^(٦). أي : ولو لم يدخله في سبب يلزم بوعده أو لم يكن مقروناً بذكر السبب^(٧).

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة :

أما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} .^(١)

(١) ابن العربي: أحكام القرآن ج ٤ ص ٢٠٧ ، هامش الفروق ج ٤ ص ٤٧ .

(٢) الاختيارات الفقهية ص ٣٣١ .

(٣) فتح الباري ج ٥ ص ٢٩٠ .

(٤) المحلى ح ٦ ص ٢٧٨ .

(٥) إحياء علوم الدين ج ٣ ص ١٣٣ .

(٦) ابن العربي: أحكام القرآن ج ٤ ص ٢٠٧ .

(٧) الشيخ محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة (١٣٦٧هـ) :

تهذيب الفروق بهامش الفروق ج ٤ ص ٤٧ .

وجه الإستدلال :

قال أبو بكر: يحتج به في أن كل من ألزم نفسه عبادة أو قرينة وأوجب على نفسه عقداً لزمه الوفاء به إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائلاً ما لا يفعل وقد ذم الله فاعل ذلك وهذا فيما لم يكن معصية فأما المعصية فإن إيجابها في القول لا يلزمه الوفاء بها. (٢)

وقال ابن كثير في معنى الآية الكريمة: "إنكار على من يعد عداً، أو يقول قولاً لا يفي به"، ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاً، سواء ترتب عليه غرم للموعد أم لا. (٣)

بينما رد ابن حزم الظاهري على الذين استدلوا بالآية الكريمة على وجوب الوفاء بالوعد: بأن المراد بها الذين يقولون ما لا يفعلون في الأمور الواجبة كإنصاف من دين، أو أداء حق فقط. (٤)

أما السنة :- فما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ). (١)

(١) سورة الصف آية ٢ .

(٢) الجصاص: أحكام القرآن ج ٥ ص ٣٣٤ .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٠٥ .

(٤) المحلى ج ٦ ص ٢٧٩، قوة الوعد الملزمة في الشريعة والقانون: الدكتور/ محمد

رضا عبد الجبار العاني: بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١٢

وجه الدلالة: دل ظاهر الحديث على وجوب الوفاء بالوعد وحرمة إخلافه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد إخلاف الوعد من خصال المنافقين وصفاتهم، والنفاق مذموم شرعاً ، فذكر إخلاف الوعد في سياق الذم دليل على التحريم. (٢)

- ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَارِضْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفْهُ). (٣)

وجه الدلالة: أفاد الحديث النهي عن إخلاف الوعد وتقدم أنه من صفات المنافقين وظاهره التحريم وقد قيده حديث أن تعده وأنت مضمّر لخلافه ، وأما إذا وعدته وأنت عازم على الوفاء فعرض مانع فلا يدخل تحت النهي. (٤)

ناقش ابن حزم هذا الاستدلال بقوله: أنهما ليسا على ظاهرهما؛ لأن من وعد بما لا يحل، أو عاهد على معصية، فلا يحل له الوفاء بشيء

(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب علامة المنافق ج ١ ص ١٦، حديث رقم (٣٣) .

(٢) الفروق ج ٤ ص ٤٣ بتصرف.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في المراء ج ٤ ص ٣٥٩ ، حديث رقم (١٩٩٥) ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.

(٤) سبل السلام ج ٤ ص ١٩٦-١٩٧ .

من ذلك، كمن وعد بزنى، أو بخمر، أو بما يشبه ذلك، فصح أن ليس كل من وعد فأخلف، أو عاهد فغدر، مذموماً، ولا ملوماً .^(١)

الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد أرى - والله أعلم - رجحان وجوب الوفاء بالوعد مطلقاً إلا لعذر ويجبر الواعد على الوفاء بوعده قضاء إذا ترتب عليه ضرر يلحق بالموعد جمعاً بين الأدلة التي استدلت بها القائلون بوجوب الوفاء بالوعد، والذين ذهبوا إلى خلاف ذلك.

قال د/ محي الدين القرة داغي^(٢): الذي يظهر لنا رجحانه هو القول بالزامية الوعد ديانة مطلقاً إلا لعذر مشروع، وبالزامية الوعد قضاء أيضاً إذا ارتبط بسبب أو ترتب عليه ضرر، فهذا هو المناسب مع مقاصد الشريعة ، وأدلتها الكثيرة في الكتاب والسنة القاضية بوجوب الوفاء بالعهود والوعد والعقود، وأن مخالفة الوعد من علامات النفاق، ولذلك استشكل الحافظ ابن حجر قول جماعة من الفقهاء حينما قالوا: " يجب الوفاء بالوعد ديانة لا قضاء فقال الحافظ: "وينظر: هل يمكن

(١) المحلى ج ٦ ص ٢٧٩.

(٢) د/ علي محيي الدين القرة داغي: الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة (الإجارة المنتهية بالتمليك) دراسة فقهية مقارنة ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١٢، ج ٢، ص ٢٢٥٣٠ .

أن يقال: يحرم الإخلاف، ولا يجب الوفاء، أي يَأْتَمُ الإخلاف وإن كان
لا يلزم بوفاء ذلك ^(١) أي في القضاء.

(١) فتح الباري ج ٥ ص ٢٩٠.

الوحدة الثالثة

التكييف الفقهي مع بيان الحكم الشرعي لصور الإجارة المنتهية بالتمليك

أهداف الوحدة الثالثة :

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على أن :

١ - معرفة التكييف الفقهي لبعض صور الإجارة المنتهية بالتمليك.

٢ - توضيح الصور الصحيحة من الصور الباطلة للإجارة المنتهية

بالتمليك .

٣ - ذكر الضوابط الشرعية لصحة الإجارة المنتهية بالتمليك .

الوحدة الثالثة:

التكييف الفقهي لصور الإجارة المنتهية بالتمليك

الصورة الأولى : حكم الإجارة المنتهية بالتمليك تلقائياً.

فى هذه الصورة تنتقل ملكية العين إلى المستأجر بمجرد الإنتهاء من دفع آخر قسط، وذلك دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد.

ويمكن صياغة هذا العقد على النحو التالى :

أجرتك هذه السلعة بأجرة فى كل شهر كذا لمدة ثلاث سنوات مثلاً، على أنك إذا وفيت بكامل هذه الأقساط، كان الشئ المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من أقساط، ويقول الآخر قبلت.

فالعقد فى هذه الصورة إجارة تنتهى بتمليك العين دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية المتفق عليها .^(١)

بالنظر إلى هذه الصورة يتضح:

١- أن العقد صيغ في البداية على أنه إجارة لوجود لفظ- أجرتك -، بالإضافة لذلك نجد أن المؤجر من حقه سحب العين المؤجرة من يد المستأجر إذا قصر فى دفع الأقساط الإيجارية المحددة، مما يدل على أنه عقد إجارة.

(١) د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهى بالتمليك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد الخامس، د/ فهد بن على الحسون : الإجارة المنتهية بالتمليك فى الفقه الإسلامى ص ١٢ .

٢- فى الوقت نفسه اجتمع مع عقد الإجارة عقد بيع، ويدل على ذلك:
- أن المستأجر ضامن لنفقات الصيانة والتأمين أي كل تبعات التلف والهلاك يتحملها المستأجر، أما فى عقد الإجارة فان يد المستأجر يد أمانة لا يضمن الا بالتعدى أو التفريط، وإذا تم سداد الأقساط فإن ملكية العين تنتقل تلقائياً للمستأجر، حيث تعتبر تلك الأقساط فى الحقيقة ثمن هذه السلعة .

- وصورة العقد بهذه الصياغة عليها عدة مآخذ:

أولاً: أن كل مبيع لا بد له من ثمن، وفى هذ الصورة لا يوجد ثمن وقت تمام البيع ، وتحويل هذه الأقساط بعد ذلك إلى ثمن للعين المؤجرة بعقد لاحق لا يسير مع القواعد الشرعية فى أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور إنعقاده .

ثانياً: أن أجرة المنفعة لتلك السلعة ليست أجرة المثل، بل روعي فيها أن تكون ثمن للسلعة .

ثالثاً: أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إيجارها.^(١)

التكييف الفقهي لهذه الصورة:

اختلف العلماء فى التكييف الفقهي لهذه الصورة وذلك على رأيين:

(١) سعد بن عبدالله السبر: التأجير المنتهي بالتمليك ص ٢٣ ، د/ خالد المشيقح: المعاملات المالية المعاصرة ص ٥٨ .

الرأي الأول: أنَّ العقد بهذه الصورة هو عقد بيع بالتقسيط، وبه قال بعض العلماء المعاصرون منهم د/ عبد الله محمد عبد الله^(١)، د/ رفيق يونس^(٢)، والشيخ إبراهيم أبو الليل^(٣)، د/ أحمد دنيا^(٤)، ووجه ذلك: إذا نظرنا إلى أنَّ العقد بهذه الصورة نجد من آثاره المِلْكِيَّة، وهي لا تكون بلا ثَمَن، والأقساط المدفوعة لا تتناسب مع أجرة المثل، بل رُوعي فيها قيمة المبيع مؤجَّلاً موزَّعة على أقساط، وأنَّ إرادة المتعاقدين في هذا العقد تتجه إلى تَمَلُّك السلعة وليس إيجارها، والذي دَفَعهما إلى جعل هذا العقد بهذه الصورة هو خَوْف المالك من عدم حصوله على ثَمَن السلعة إذا كان الثمن مؤجَّلاً، والمشتري يَرغب في شراء هذه السلعة، وهو لا يَمَلِك ثمن شرائها بالنقد، فصاغوا العقد بهذه الصُّورة؛ لحماية حقِّ المالك من نُكول المشتري من دَفْع ثَمَن السلعة،

(١) د/ عبد الله محمد عبد الله : التأجير المنتهي بالتملك والصور المشروعة فيه،

منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس ج ٢ ص ١٠٥٨٠ .

(٢) د/ رفيق يونس المصري: بيع التقسيط - تحليل فقهي واقتصادي ، بحث منشور

بمجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السادس ج ٢ ص ١١٦١٢ .

(٣) الشيخ دبيان محمد الديان : الإجارة المنتهية بالتملك نقلاً من: "البيع بالتقسيط

والبيوع الائتمانية الأخرى"، لإبراهيم دسوقي أبو الليل (ص ٣١٥ - ٣١٧ . موقع

الملئقى الفقهي .

(٤) د/ شوقي أحمد دنيا بحث منشور: الإجارة المنتهية بالتملك دراسة اقتصادية

وفقهية منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ج ٢ ص ٢٢٥٧٦ .

فلا يمكن أن يوصف العقد إلاً على أنه عقد يتملك فيه العاقد الرقبة والمنفعة، وهذا هو حقيقة البيع المقسط^(١)

الرأي الثاني: أنها تشتمل على عقدين: عقد إجارة ، وعقد بيع معلق على سداد الأجرة .^(٢)

اعترض على ذلك: بأن الذي يحول دون ذلك هو أن هذه الأقساط دُفعت على أنها أجرة للعين المؤجرة ، فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجرة في نهاية المدة ؟

فلما كان العقد بهذه الكيفية ؛ وتوارد على العين عقدان مختلفان لاختلاف حكمهما كان العقد محل خلاف بين العلماء المعاصرون على ثلاثة آراء :

الرأي الأول: عدم جواز الإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً وهو قول أكثر العلماء المعاصرون منهم: د/عبدالله محمد عبدالله^(٣)، د/ حسن

(١) الشيخ دبيان محمد الديان : الإجارة المنتهية بالتملك. موقع الملتقى الفقهي.

(٢) دورة عقد التأجير التمويلي (دراسة شرعية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي) د/ يوسف الشبيلي ص ٤ ، د/ حسن الشاذلي : الإيجار المنتهى بالتملك، عبدالله الشيخ بن بيه : الإيجار الذي ينتهى بالتملك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس.

(٣) الإجارة المنتهى بالتملك د /عبدالله محمد عبدالله - ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الاسلامي.

الشاذلي^(١) ، ود/ عبد الله الشيخ المحفوظ ابن بيه^(٢) ، د/ وهبه الزحيلي^(٣) ، د/ سعد بن تركي الحثلاثن^(٤) ، الشيخ/ حامد بن عبدالله العلي^(٥) ، د/ خالد المشيقح^(٦) .

مستدلين على ذلك:

بنفس الأدلة التي استدلت بها المانعون لاجتماع العقود والمانعين لتعليق البيع على شرط مستقبل ومنها ما يلي:

الدليل الأول: أن العقد بتلك الصورة اشتمل على بيع وإجارة في آن واحد والمعقود عليه عين واحدة، فكان ممنوعاً شرعاً^(٧) لحديث: (لَا

(١) د/ حسن الشاذلي : الإيجار المنتهي بالتمليك - ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس ج ٢ .

(٢) د/ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه: الإيجار الذي ينتهي بالتمليك: بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الخامس ج ٢ ص ١٠٦٤٤ وما بعدها .

(٣) د/ وهبة الزجلى: المعاملات المالية ص ٤١٢ .

(٤) الأجارة المنتهي بالتمليك د/عبدالله محمد عبدالله - ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الاسلامي.

(٥) الشيخ حامد بن عبدالله العلي: تيسير بعض أحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة ص ٥٦ .

(٦) المعاملات المالية المعاصرة ص ٥٧ .

(٧) اللجنة الدائمة: دورة الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض بتاريخ ٢٩/١٠/١٤١٠ هـ - موقع صيد الفوائد، د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية ص ٤٠٦ .

يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) ... وَ(نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) وهذا منه^(١).

الدليل الثاني: أن العقدان مختلفان ؛ لاختلاف أحكامهما وآثارهما ، فعقد البيع تنتقل فيه ملكية العين للمشتري والضمان عليه ، وأما عقد الإجارة فالملك للمؤجر والضمان عليه ما لم يتعد المستأجر أو يفرط . فكيف يجمع على المستأجر الضمان وهو تبعات عقد البيع – ويجمع عليه أيضاً تبعات عقد الإجارة وهو سحب السلعة إذا قصر^(٢)

الدليل الثالث: أن العقد بهذه الخصائص هو عقد غرر ومجازفة ، لأن المشتري قد يعسر في آخر قسط ، وقد دفع أقساط لا تناسب الإجارة وهي في الأصل قيمة للرقبة، فقد خسر الثمن والمثمن واللذين قد ربحهما البائع ، خلافاً للقاعدة الشرعية التي ذكرها العلماء في أن: الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد لأنه بمعنى العبث وأكل أموال الناس بالباطل.^(٣)

(١) المقدسي: الكافي في فقه ابن حنبل ج ٢ ص ٢٢ .

(٢) المعاملات المالية المعاصرة ص ٥٨ .

(٣) د/ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه: الإيجار الذي ينتهي بالتمليك: بحث منشور

بمجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الخامس ج ٢ ص ٢ ص ١٠٦٣٩ .

الدليل الرابع: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء. ^(١)

الدليل الخامس: أن من المعلوم أن ثمن المبيع إما أن يكون حالاً أو مؤجلاً عند تمام العقد والمدفوع كأقساط أخذت تحت ظل عقد الإجارة ، فهو ثمن للمنفعة التي استوفاه المستأجر، أما تحويل هذه الأقساط بعد ذلك إلى ثمن للعين المؤجرة بعقد لاحق لا يسير مع القواعد الشرعية في أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور إنعقاده .

وبالتالي فإن حقيقة العقد فيها مبهمة هل هو بيع أم إجارة؟ ^(٢)

الدليل السادس: إن عقد الإجارة في هذه الصورة حيلة على البيع بالتقسيط، والأصل أن يبنى العقد على الوضوح. ^(٣)

الرأي الثاني: جواز الإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً ودون الحاجة إلى إبرام عقد جديد وبه أفتى بعض العلماء المعاصرون منهم: الشيخ

(١) د/ سعد بن تركي الحثلاثن: فقه المعاملات المالية المعاصرة ص ١٢٥ وما بعدها .

(٢) د/ عبدالله الشيخ بن بيه: الايجار الذي ينتهي بالتملك - مجلة المجمع.

(٣) د/ عبدالله محمد: التأجير المنتهي بالتملك والصور المشروعه فيه - مجمع الفقه الإسلامي.

محمد بن جبیر^(١)، والدكتور / محمد جبر الألفي^(٢)، والدكتور / سعد بن ناصر الشثري^(٣).

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:

الدليل الأول: أن هذا العقد في حقيقته أنه بيع بالتقسيط ، وأن الصيغة في العقد، ستر للعقد الحقيقي، فهو إجارة صورية، والعبرة في العقود بالحقائق، ويترتب على هذا التكييف الفقهي للعقد انتقال ملكية الشيء من المؤجر - البائع إلى المستأجر - المشتري - بمجرد العقد .^(٤)

الدليل الثاني: بيع أدرج فيه شرط جزائي، وهو عدم انتقال الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بكافة الأقساط، وحينئذ يصبح مالكا بأثر

(١) ورقة الشيخ محمد بن جبیر: - رحمه الله - التي قدمها لهيئة كبار العلماء، مخالفاً فيها قرار الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتملك ، فتوى رقم: ٨٨٦٢. موقع الشيخ على الرابط:

<http://www.ibn-jebreen.com>

(٢) أ. د. محمد جبر الألفي : الإيجار: أهميته، مشروعيته، خصائص عقده ، موقع: <http://www.alukah.net/>.

(٣) ونصه: أن يكون عقد الإجارة ينقلب بسداد جميع الأقساط إلى كونه عقد بيع ذاتياً بلا حاجة لعقد جديد، فهذه الصورة أرى جوازها وإن كان الأغلبية يرون المنع منها . فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج ٨ ص ٣٣٨، د/ سعد ابن ناصر الشثري بتاريخ ١٤٢٥/٣/٧ هـ . موقع الملتقى الفقهي .

(٤) أ. د. محمد جبر الألفي : الإيجار: أهميته، مشروعيته، خصائص عقده ، موقع: <http://www.alukah.net> .

رجعي، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه. ^(١)
وهذا بناء على ما روي عن الإمام أحمد بجواز تعليق البيع على شرط

فقد جاء في المغني: " فإن قال بعثك على أن تتقدي الثمن إلى ثلاث
أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع الصحيح نص عليه". ^(٢)
نوقش ذلك من عدة أوجه:

الأول: أن العين المؤجرة من ضمان المؤجر، مما يدل على أن
المقصود من العقد الإجارة، وليست الإجارة صورية. ^(٣)

الثاني: أن القول بأنه بيع تقسيط مشروط بعدم نقل الملكية إلا بعد
سداد الأقساط غير مسلم به؛ لأن هذا الشرط يناقض مقتضى
العقد، فإن مقتضى عقد البيع هو نقل الملكية للمشتري بمجرد
العقد.

يجاب: بالشرط المنافي لمقتضى العقد شرط صحيح، إذا كان لأحد
المتعاقدين قصد صحيح في اشتراطه، فالمشتري ينتفع بالعين في هذه

(١) نفس المرجع السابق، د. مرضي بن مشوح العنزي : الإجارة المنتهية بالتملك،
موقع:

<http://www.alukah.net..>

(٢) المغني ج ٤ ص ١٢٩ .

(٣) دورة عقد التأجير التمويلي (دراسة شرعية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي)

د/ يوسف الشبيلي ص ٤ .

الفترة، لكنه لا يتصرف بها في بيع أو هبة فهو كرهن العين، وفيه قصد صحيح للبائع ليحفظ حقه، وشرط التجارة التراضي، فإذا رضي المشتري بذلك فهذا له، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل يمنع منه. (١)

الدليل الثالث: أن عقد الإجارة المنتهية بالتملك لا يخرج عن كونه عقد بيع بأقساط مؤجلة، ورهن للعين ، فلا يتصرف فيها المشتري ببيع أو هبة حتى يسدد كامل الثمن، وهما عقدان صحيحان لازمان. (٢)

الترجيح:

من خلال ما سبق عرضه من مسائل بنيت عليها مسألة الإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً وبيان الراجح فيها، وبيان آراء العلماء المعاصرون في ذلك وأدلة كل رأي تبين لي - والله أعلم - رجحان الرأي الأول القائل بعدم جواز عقد الإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً بتلك الصيغة السابقة

(١) مرضي بن مشوح العنزي : الإجارة المنتهية بالتملك، نقلاً من مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩ / ١٥٦ ، المناظرات الفقهية، للسعدي، ص ٨٦ موقع:

<http://www.alukah.net>

(٢) ورقة الشيخ محمد بن جبير: - رحمه الله - التي قدمها لهيئة كبار العلماء، مخالفاً فيها قرار الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتملك ، فتوى رقم: ٨٨٦٢. موقع الشيخ على الرابط: <http://www.ibn-jebreen.com>

لكن يمكن ايجاد بديل شرعي لتلك الصورة، وهو أن يفصل بين العقدين؛ بحيث يتبع عقد الإجارة عقد البيع فيستقل كل منهما عن الآخر، وذلك وفق شروط معينة ؛ لأن الأصل في المعاملات الصحة إلا إذا دل الدليل على المنع ، ولم يثبت دليل ينص صراحة على منع الإجارة المنتهية بالتملك إلا إذا كانت أحكام العقدين تسري على المعقود عليه في وقت واحد.

أما عن الشروط: فقد وضع جمع من العلماء ^(١) عدة شروط للخروج من هذه المسألة بصورة مقبولة وهي كما يلي:

١- أن يكون ضمان العين من المؤجر المالك لها، ويمكن أن يتحمله المستأجر نيابة عن المؤجر على أن يخصم من القيمة الايجارية، وليست على المستأجر الا فى حالتين: التعدى أو التقصير من المستأجر.

- وأما ما يتعلق بنفقات التشغيل فتكون على المستأجر مثل الزيت والبنزين، وما عدا ذلك فالأصل أن يكون على المالك المؤجر

(١) د/ حسن الشاذلي : الإيجار المنتهى بالتملك ، د/منذر قحف مجلة- ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، سعد بن عبدالله السبر: التأجير المنتهى بالتملك ص١٨، د/ فهد بن على الحسون: الإجارة المنتهية بالتملك في الفقه الإسلامي ص١٢، بحث الايجار المنتهى بالتملك للشاذلى - مجلة المجمع- العدد الخامس، المعاملات المالية المعاصرة للمشيقح ص٥٩- ٦٠، المعاملات المالية د.وهبة الزحيلي ص ٤٠١ وما بعدها.

للعين؛ لأنه قد سبق وأن بينت آراء الفقهاء في ضمان العين المؤجرة وأنها أمانة في يد المستأجر لا تضمن الا بالتعدي.

٢- الشرط الجزائي: للمؤجر أن يشترط على المستأجر شرطاً جزائياً تعويضاً له عن الضرر الذي يلحقه في حالة عدم الوفاء بسداد الأقساط؛ على أن يكون ذلك بقدر ما يرفع عنه الضرر؛ عملاً بالقواعد الشرعية في دفع الضرر. (١)

٣- يجب أن يكون التأمين تعاونياً اسلامياً لا تجارياً.

٤- كما يمكن صياغة العقد على أنه عقد بيع له غنمه وعليه غرمه معلق على شرط الوفاء بجميع الثمن، وفي نهاية المدة إذا تم سداد الأقساط جميعها ينطلق حق الملكية ليضاف إلى حق المنفعة الذي هو موجود عند المستأجر، ومن حق المالك إسترداد العين منه إذا لم يف بالأقساط، على أن يخصم القيمة الحقيقية لإجارة العين في تلك المدة السابقة عن الامتناع عن دفع باقى الأقساط، ويرد على المشتري ما زاد على ذلك وهو الفرق (بين ثمن المنفعة و ثمن العين) عملاً

(١) د/ حسن الشاذلي: الايجار المنتهى بالتملك بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الخامس، د/ خالد المشيقح: المعاملات المالية المعاصرة ص ٥٩-٦٠، د/ وهبة الزحيلي : المعاملات المالية ص ٤٠١ وما بعدها، د/ منذر قحف: الإجارة المنتهية بالتملك وصكوك الأعيان المؤجرة، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي، العدد الثاني عشر.

بالقواعد الشرعية في دفع الضرر (يدفع الضرر بقدر الامكان ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام).

وتعليق البيع على شرط موافق لما ذهب إليه بعض المالكية^(١)، وأحمد في رواية^(٢) من جواز اشتراط عدم نقل الملكية في عقد البيع إلا بعد الوفاء بكامل الثمن عملاً بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)^(٣)، كما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعَفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ)^(٤) فالنبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الولاية على أمر في المستقبل. ولأن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم؛ وإذا لم تكن حراماً لم تكن فاسدة ؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة .

(١) مواهب الجليل ج ٤ ص ٣٧٤ .

(٢) المغنى ج ٤ ص ١٢٤، الروض المربع ص ٣٢١، الفتاوى الكبرى ج ٥ ص ٣٨٩ ، إعلام الموقعين ج ٣ ص ٣٨٨ .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإجارة - باب أجر السمسرة ج ٣ ص ٩٢ .

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة مؤتة من أرض الشام ، ج ٥ ص ١٤٣ ، حديث رقم (٤٢٦١) .

٥ - أو أن يضاف لهذا العقد، وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة.

والعقد بتلك الشروط يحقق مصلحة مشروعة وهى ضمان حق البائع فى حصوله على ثمن السلعة، وحفظ الأموال مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى المخرج الذي يتحقق به الغرض من غير الوقوع في المحذور فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ : (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلُ تَمْرٍ خَيْبَرٍ هَكَذَا) قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ (لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا)^(١) بالرغم من أن النتيجة واحدة وهو بيع صاعين من تمر رديء بصاع واحد من تمر جيد، هي نفسها بيع الصاعين من التمر الرديء بدراهم، ثم يشتري بهذه الدراهم صاع من تمر جيد، إلا أن الأولى ممنوعة ، والثانية جائزة.^(٢)

(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير

منه ج ٣ ص ٧٧، حديث رقم (٢٢٠١) .

(٢) د/سعد بن تركي الحثلاثن : فقه المعاملات المالية المعاصرة ص ١٣٥.

الصورة الثانية : الإجارة المنتهية بالتملك بثمن أما أن

يكون بثمن رمزي أو بالبثمن الحقيقي للسلعة:

أولاً: حكم الإجارة المنتهية بالتملك بثمن رمزي:

لا خلاف بين جمهور الفقهاء الحنفية^(١)، والمالكية^(٢)، والشافعية^(٣)، والحنابلة^(٤) على أن عقد البيع إذا صدر ممن هو أهل للتصرف، وذلك بأن كان العاقد (البائع والمشتري) بالغاً، عاقلاً، مختاراً، رشيداً أى يحسن التجارة -أى الأخذ والإعطاء- وكان تصرفه فيما يملك كان عقد البيع صحيحاً، سواء كان البيع بثمن المثل أو أقل.

عملاً بعموم قول الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } .^(٥)

وإذا كان البيع بأقل من ثمن المثل بكثير كأن يبيع ما يساوى مائة بدرهم صح العقد إذا عرف العاقدان الثمن الحقيقي للعين ورضيا بذلك.

(١) بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٣٥.

(٢) مواهب الجليل، حاشية الصاوى ج ٣ ص ١٨-١٩.

(٣) المجموع شرح المذهب ج ٩ ص ١٤٩.

(٤) الإنصاف ج ٧ ص ٢٣٤.

(٥) سورة البقرة آية ٢٧٥ .

لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } .^(١)

وجه الدلالة :

قال القرطبي: إعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض، إلا أن قوله تعالى { بِالْبَاطِلِ } أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعاً من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير وغير ذلك... والجمهور على جواز الغبن في التجارة، مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي مائة فذلك جائز، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير، وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة لو وهب^(٢)، ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره .^(٣)

- أما من باع سلعته وهو غير بصير بقيمتها فقد ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة^(٤)، ومالك^(٥)، والشافعي^(١) إلى أنه لا خيار له

(١) سورة النساء آية ٢٩ .

(٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٥٢ .

(٣) اللباب في شرح الكتاب ج ١ ص ٤١٢ .

(٤) غمز عيون البصائر ج ١ ص ٢٥٧، تنقيح الفتاوى الحامدية ج ١ ص ٢٥٧ ط/ دار المعرفة ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ط/ دار الجيل-الطبعة الأولى-١٤١١هـ-١٩٩١م ، ج ١ ص ٣٦٧، ٣٦٨.

(٥) إكمال اكمال المعلم على صحيح مسلم ج ٤ ص ١٩٨-١٩٩، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٦ ص ٤٠٤ .

بالغبن، بينما المشهور من قول المالكية^(٢)، والحنابلة^(٣) : أن له القيام بالغبن غير المعتاد وحدوده الثلث - ففي حق البائع أن يبيع بما ينقص عن ثمن المثل الثلث فأكثر، وفي حق المشتري أن تزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر -، وأما ما دون الثلث فلا قيام له.

فبناء على آراء الفقهاء في صحة البيع بثمن رمزي متى صدر العقد ممن هو أهل للتصرف، مع علم المتعاقدين بالثمن الأصلي للسلعة، هل تصح الإجارة المنتهية بالتملك بثمن رمزي للعين؟ بالنظر لصورة الإجارة المنتهية بالتملك بثمن رمزي نجد:

أنه اشتمل على عقدين:

الأول: عقد إجارة ناجز قد تم فيه تحديد ثمن المنفعة، ومدة الإجارة وتوزيع الثمن على أقساط معلومة .

الثاني: عقد بيع معلق على شرط وهو سداد أقساط الإجارة في المدة المحددة .

- ولما كان الثمن الرمزي ليس هو الثمن الحقيقي للسلعة، وإنما هو جزء منه وباقي الثمن هو تلك الأقساط الإيجارية المحددة، وإرادة

(١) تكملة المجموع شرح المذهب ج ١٢ ص ٣٢٦ .

(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٦ ص ٤٠٤ .

(٣) المغني ج ٤ ص ٩٢ .

المتعاقدين تتجه إلى عقد بيع، وهى نفس الصورة السابقة إلا أنه هنا قد تحدد ثمن رمزى للعين يدفعه المستأجر فى نهاية المدة متى رغب فى شرائها، بخلاف ما لو كان الثمن الحقيقى للسلعة هو الثمن الرمزى، وأن قيمة الأقساط الإيجارية تمثل ثمن مثل المنفعة حيث لا إشكال فى ذلك كما سبق من بيان أقوال الفقهاء.

- بينما كيفه فقهاء القانون على أنه بيع مقسط فيه الثمن.

لكن الذى يمنع تكييفه بذلك فى الفقه الإسلامى: الصيغة وهى قول المالك - أجزتك - فهذا اللفظ دال على الإجارة، إلى انتهاء أجل الأقساط، ثم عقد بيع بعد القيام بالالتزامات التى أوجبها العقد .^(١)

وهى مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون على رأيين:

الرأى الأول: عدم جواز عقد الإجارة المنتهية بتمليك العين بثمن رمزى، وإليه ذهب بعض أهل العلم منهم: د/ منذر قحف^(٢)، ود/ حسن الشاذلى^(٣).

(١) د/ سعد بن عبدالله السبر: التأجير المنتهى بالتمليك ص ٢٥، د/ منذر قحف: الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة. ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد الثانى عشر .

(٢) د/ منذر قحف: الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة. ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد الثانى عشر.

(٣) د/ حسن الشاذلى: الإيجار المنتى بالتمليك ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد الخامس ج ٢ ص ١٠٦١٩ .

مستدلين على ذلك بما يلي :

الدليل الأول: أنهما عقدين وردا على عين واحدة، الأول: الإجارة، والثاني: البيع غير مستقرّ على أحدهما ، لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)^(١).

الدليل الثاني: أن العقد فيه جهالة وعَرَر؛ وذلك أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ مَعْلُوقٌ عَلَى تَمَامِ سَدَادِ أَقْسَاطِ الْإِجَارَةِ، فَإِذَا عُقِدَ الْبَيْعُ عَلَى عَيْنٍ، وَكَانَ نَفَازُ هَذَا الْبَيْعِ مُوجِبًا إِلَى بَعْدِ انْتِهَاءِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ، وَكَانَتْ مَدَّةُ الْإِجَارَةِ طَوِيلَةً بِحَيْثُ تَتَغَيَّرُ فِيهَا السَّلْعَةُ وَهَذَا التَّغْيِيرُ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْإِسْتِخْدَامِ، فَيَكُونُ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى هَذَا قَدْ أُبْرِمَ عَلَى عَيْنٍ مَجْهُولَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةِ الصِّفَةِ، مَعْرُوضَةً لِلتَّلَفِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا مِنْ غَيْرِ تَعَدُّ وَلَا تَفْرِيطٍ، مِمَّا يَجْعَلُ الْعَيْنَ مَجْهُولَةَ الصِّفَةِ، وَهَذَا مِمَّا يُبْطِلُ الْبَيْعَ.^(٢)

وقد اشترط المالكية لجواز بيع العين المستأجرة: أن يبقى من مدة الإجارة ما لا يكون غرراً يخاف تغير السلعة في مثله .

(١) سبق تخريجه .

(٢) الإجارة المنتهية بالتَّمْلِيك: الشيخ دبيان محمد الدبيان، موقع:

جاء في مواهب الجليل: "يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره إن بقي من مدة الإجارة ما لا يكون غررا يخاف تغييرها في مثله" (١) .

الرأي الثاني: ذهب جَمْع من العلماء إلى صحّة الإجارة المنتهية بتمليك العين بثمن رمزي بشروط معينة، وبه قال الشيخ عبدالله بن منيع (٢)، د/ محمد مختار السلامي (٣)، ود/ وهبة الزحيلي (٤)، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية (٥)، والهيئة الشرعية في مجموعة دلة البركة (١) .

(١) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج٧ ص ٥٢٢-٥٢٣ .

(٢) الإيجار مع الوعد بالتمليك ما له وما عليه. عبد الله بن سليمان المنيع، موقع

<http://www.feqhweb.com/> .

(٣) د/ محمد مختار السلامي: الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٤١١ .

(٤) أ.د/ وهبة الزحيلي: المعاملات المالية ص ٤٠٤-٤٠٥ .

(٥) وجاء نص الفتوى: يمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها عقارا أو آلية من الآليات كالطائرة والباخرة أو معدة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك لعدة سنوات بأجرة سنوية محددة وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة ويشترط الطرفان في عقد الإجارة أن المالك المؤجر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة بثمن يحددانه في العقد إذا وفي المستأجر بأقساط بدل الإيجار في مواعيدها وسائر التزاماته التي يوجبها عليه عقد الإجارة فترى الهيئة أن هذا الشرط مقبول ويعتبر صحيحا ملزما وفي الغرض المقصود استنادا على ما أثر لدى بعض فقهاء السلف وما نص عليه المذهب الحنبلي وفي هذه الحال يجب

بينما اشترط الدكتور/ محمد مختار السلامى لجواز تلك الصورة: تقديم الثمن الرمزي المتفق عليه حتى لا يؤول إلى تعمير ذمتين الممنوع شرعاً، فعلى المشتري (المستأجر) أن يدفع الثمن الرمزي حالاً، أو أن يدفع الثمن المتفق عليه ناجزاً أيضاً^(٢).

بالإضافة للشروط الآتية :

الشرط الأول: أن يكون عقد الإجارة عقدًا حقيقيًا مستجمعًا لأركان الإجارة وتوفّر شروطه وانتفاء موانعه، ومن ذلك أيضاً العلم بالأجرة ، وتحديد مدة الإجارة، وأن تكون العين صالحة للإجارة، وغير ذلك من الشروط ، بحيث يترتب على عقد الإجارة جميع آثاره المقررة شرعاً للمؤجر وللمستأجر، مع الوعد بالتملك بعد انتهاء مدة الإجارة.

أن يكون عقد الإجارة والبيع المشروط في المستقبل مقصوداً بهما حقيقة معناهما وآثارهما وعلى الخصوص يلتزم المالك المؤجر خلال الإيجار بتحمل تبعات الملك كتبعية هلاك العين أو نفقات التأمين عليها ونفقات الصيانة الواجبة شرعاً على المالك على أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعاً شرعياً من اشتراط جعل تكاليف الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي على عاتق المستأجر، من موقع:

<http://minhajadvisory.com>.

(١) الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة ، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة مجموعة دلة البركة ، ص ٢١٠ .

(٢) د/ محمد مختار السلامى: الإيجار المنتهي بالتملك وصكوك التأجير ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٤١١.

الشرط الثاني: أن يكون عقد البيع فى أثناء مدة الإجارة، أو بعد انتهاء مدتها حتى لا يجتمع عقدان (عقد البيع والإجارة) فى عقد واحد.

الشرط الثالث: إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. (١)

- كما اشترط بعض المعاصرين: أنه يجب على المالك للعين (وهو المصرف) أن يأخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك، فيما لو كانت العين المؤجرة من أموالهم، وإن كان ثمن العين من صناديق الاستثمار فلا بد من موافقة أصحابها على التصرف، أو وجود نص خاص بذلك فى نظامها (٢).

مستدلين على ذلك: الدليل الأول: أن الأجرة فى الإجارة والثلث فى البيع كما يجوز أن يكون أقل من المثل فكذلك يصح أن يكون بأكثر من المثل، والعبرة فى الجواز هو تراضى العاقدین واتفقهما على مقدار الأجرة، وثلث البيع، وألا يكون هناك تغرير وخداع، فإذا دخل

(١) الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة ، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة مجموعة دلة البركة، ص ٢١٠، الإيجار مع الوعد بالتملك ما له وما عليه. عبد

الله ابن سليمان المنيع، موقع : <http://www.feqhweb.com/> .

(٢) المعاملات المالية: أ.د/ وهبة الزحيلي، ص ٤٠٤-٤٠٥ .

العائد على بصيرة من أمره بمقدار الأجرة وبمقدار ثمن البيع فلا حرج في ذلك شرعاً^(١).

الدليل الثاني: أنه لا حرج على الرشيد العالم ما يفعل في الثمن الذي يرضى به في البيع ، خاصة إذا كان البائع بنك له خبراؤه، وهو حريص على ما ينفعه حرصاً تسنده الخبرة والعلم بمسار الاقتصاد لا في الدولة التي ينتسب إليها فقط ولكن في العالم خصوصاً مع وسائل الاتصال الحديثة والنشرات المتتابعة عما يجري في الأسواق^(٢).

الترجيح: بعد عرض آراء العلماء المعاصرون في تلك المسألة أرى - والله أعلم - صحة الإجارة المنتهية بتمليك العين بثمن رمزي على أن يكون عقد البيع منفصلاً عن عقد الإجارة سواء كان في أثناء مدة الإجارة، أو بعد انتهاء مدتها. مع مراعاة باقي الشروط وذلك لقوة أدلتهم وخاصة أن الثمن الرمزي ليس هو الثمن الحقيقي المقدر للسلعة وإنما هو جزء منه والباقي من الثمن هي تلك الأقساط المتفق عليها.

(١) الإجارة المنتهية بالتمليك: الشيخ ديبان محمد الديبان، موقع :

dobayan1@hotmail.com.

(٢) الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير: د/ محمد مختار السلامي، ضمن

أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٤١٠ .

ثانياً: حكم الإجارة المنتهية بالتملك بثمن حقيقى:

فى هذا العقد يتحدد الثمن الحقيقى للسلعة المؤجرة عند إبرام عقد الإجارة، أو أن يتقفا المتعاقدان على تحديده بعد الانتهاء من دفع القسط الأخير خلال المدة المحددة لذلك، ويترتب على تحديد هذا الثمن اختلاف واضح فى مقدار القسط وبذلك يتحقق للبنك -المؤجر- ما يحرص عليه من عائد تمويلي مع أخذ الأقساط الإيجارية بعين الاعتبار.

وفى هذا العقد ثمن المنفعة: -ممكّن أن يكون مثلياً أى يمثل ثمن الانتفاع بالعين فى المدة المحددة فقط، وممكن أن يكون أكثر بقليل، مما يجعل ثمن السلعة فى نهاية مدة الإجارة أقل من سعر السوق بقليل، وذلك يكون حافزاً للمستأجر لتنفيذ الوعد بالشراء.^(١)

وتكليف هذا العقد على أنه عقد إجارة فى بدايته تسرى عليه آثار عقد الإجارة وأحكامه التى قررها التشريع الإسلامى، وبعد الانتهاء من الوفاء بكافة الأقساط الإيجارية يمتلك المستأجر العين بعقد بيع بثمن حقيقى للعين وتترتب عليه أحكام عقد البيع وآثاره كما بينه التشريع الإسلامى.

(١) الإجارة المنتهية بالتملك وصكوك الأعيان المؤجرة: د/ منذر قحف، ص ١٨، الإجارة المنتهية بالتملك دراسة فقهية إقتصادية: ، د.شوقى دنيا، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد رقم ١٢ .

وهذه الصورة يمكن القول بصحتها فى الفقه الإسلامى^(١)، على أن تتضمن الإجارة فى هذه الصورة وعد بالبيع من قبل البنك المؤجر، ووعد بالشراء من قبل المستأجر.^(٢)

الصورة الثالثة : حكم الإجارة المقرونة بوعد بالبيع:

هذه الصورة - كما سبق بيانها - هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً - إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة - ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين^(٣).

التكييف الفقهي لهذه الصورة: لا يخرج التكييف الفقهي لهذه الصورة عن كونه عقد إجارة عادى خلال كامل مدة العقد، فيسرى عليه جميع

(١) الإجارة المنتهية بالتملك وصكوك الأعيان المؤجرة: د/ منذر قحف، ص ١٨، د/ حسن الشاذلى: الإيجار المنتهى بالتملك ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد الخامس .

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد الثانى عشر ج ٢ ص ٢٥٣١ .

(٣) الإجارة المنتهية بالتملك فى الفقه الإسلامى: د/ فهد بن على الحسون، ص ١٩، التأجير المنتهى بالتملك: د/ سعد بن عبدالله السبر، ص ١٣-١٤، نقلاً من الإيجار المنتهى بالتملك للشاذلى. والإجارة وتطبيقاتها المعاصرة للقرعة داغى ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامى - العدد الخامس، الثانى عشر.

أحكام الإجارة ، وذلك إلى حين تمليك المستأجر للعين فتنتقل صفته من مستأجر للعين إلى مالك لها .

الحكم الشرعي لهذه الصورة:

يبنى حكم هذه الصورة على حكم الوفاء بالوعد ، وهل هو لازم أم لا ، وسبق أن بينت آراء الفقهاء في ذلك وذكرت أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة إلا لعذر وقضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة هذا الوعد .

وبناء على ذلك فإن الوعد الصادر من المالك المؤجر للمستأجر ببيع هذه السلعة - المؤجرة - له إذا رغب في ذلك ، ودفع ثمنًا لها هو كذا - يكون وعدًا ملزمًا للمالك - ببيعها للمستأجر لها ، بعد تحقق الشرط، وهو إستيفاء جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها وإبداء رغبته في شرائها وتقديم الثمن الذي اتفق عليه، هذا إذا كان الوعد صادرًا من المالك، أما إذا كان الوعد قد صدر منهما بأن وعد المالك ببيع السلعة للمستأجر ووعد المستأجر بشراء هذه السلعة من المالك إذا تحقق الشرط وهو الوفاء بكامل الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال المدة المحددة، وحدد الثمن ، فحينئذٍ يكون كل منهما ملزم بهذا الوعد وهو إجراء هذا البيع على الوضع الذي اتفقا عليه

ولكن بشرط وجود صيغة جديدة تصدر عند الانتهاء من تحقق الشرط المعلق عليه الوعد وهو الوفاء بكافة الأقساط الإيجارية، وذلك

لعدم وجود صيغة له من قبل - أي الجواز مشروط بأن يكون عقد البيع منفصلاً عن عقد الإجارة .

وهذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة - إن شاء الله -؛ لعدم وجود المحذور الشرعي فيها^(١).

على أن يتم العقد وفق الخطوات التالية:

١- عقد شراء العين من المورد أو بتوكيل سابق مستقل للراغب في الاستئجار .

٢- يبرم عقد اجارة بشكله المستقل .

٣- بشكل متوازي مع ابرام عقد الاجارة يتم اتفاق الطرفين على كيفية نقل ملكية العين للمستأجر في نهاية الإجارة بوثيقة مستقلة سواء كان ذلك بعقد الهبة المعلق أو بالوعد بالبيع بالسعر الرمزي أو السعر المتفق عليه.

٤-تنفيذ عملية نقل الملكية بإيجاب وقبول يصدر من الطرفين في حالة وثيقة عقد الإجارة إذا اشتملت على وعد ببيع الأعيان المؤجرة.^(٢)

(١) د/ سعد بن عبدالله السبر: التأجير المنتهي بالتمليك، ص٢٦، د/ حسن الشاذلي: الإيجار المنتهي بالتمليك ،الشيخ مختار السلامي: الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه العدد الخامس والثاني عشر، الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة ، مجموعة دلة البركة ، ص ٢١٠.

(٢) المراجع السابقة.

الصورة الرابعة : حكم الإجارة المنتهية بالتملك عن طريق الهبة:

ولها صورتان :

الأولى: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجره محددة في مدة محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد وعداً ملزماً بهبة العين للمستأجر إذا وفى بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة في نهاية العقد. ^(١)

الثانية: أن يصاغ العقد على أساس أنه عقد إجارة مع عقد هبة فوري معلق على شرط سداد جميع الأقساط كأن يقول : إذا قمت بسداد جميع الأقساط المتفق عليها في المدة المحددة فإنني وهبتك هذه الدار، ووافق عليها الطرف الآخر. ^(٢)

الحكم في الصورة الأولى يدخل تحت حكم لزوم الوعد أو عدم لزومه وبناء على الراجح من آراء الفقهاء من لزوم الوفاء بالوعد ديانة إلا لعذر وقضاء إذا دخل الموعد بسببه في كلفة ، وفق الضوابط المذكورة في الصور السابقة

(١) التأجير المنتهى بالتملك لسعد بن عبدالله السبر ص ١٤ ، الإجارة المنتهية

بالتملك في الفقه الإسلامي: د/ فهد بن علي الحسونص ١٩ .

(٢) الإيجار المنتهى بالتملك وصكوك التأجير: فضيلة الشيخ محمد مختار

السلامي، الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة (الإجارة المنتهية بالتملك) دراسة فقهية

مقارنة: أ.د/ علي محيي الدين القره داغي، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه

الإسلامي العدد ١٢، ج ٢ .

وبناء على ذلك فهذه الصورة جائزة- إن شاء الله - ؛ لعدم وجود المحذور الشرعي فيها^(١).

وبالتالي: إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة، على أن ينتهي هذا العقد بملك المستأجر للمحل فإن هذا العقد يصح إذ روعي فيه ما يأتي:

أ- ضبط مدة الإجارة ، وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة.

ب- تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة.

ج- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه تنفيذاً لوعده سابق بذلك بين المالك والمستأجر^(٢) على أن يكون بإيجاب وقبول يصدر من الطرفين في حالة وثيقة وعد بالهبة.^(٣)

(١) المرجع السابق .

(٢) أ.د/ علي محيي الدين القره داغي : الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة (الإجارة المنتهية بالتملك): سعد بن عبدالله السبر، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الاسلامي- العدد الثاني عشر نقلاً من الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي ج ٤ ص ١٠٢.

(٣) الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة ، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة مجموعة دلة البركة ، ص ٢١٠، ٢١٢، ٢١٣ .

بينما الحكم في الصورة الثانية يدخل تحت اختلاف الفقهاء في حكم تعليق الهبة على شرط مستقبل، وهي مسألة اختلف فيها فقهاء السلف على رأيين :

الرأي الأول: يرى عدم جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣)، ووافقهم الظاهرية^(٤).

واستدلوا على ذلك : بأن الأصل في عقود التمليكات أن تكون منجزة^(٥)

جاء في بدائع الصنائع : أما شروط ركن الهبة فهو : ألا يكون معلقاً بما له خطر الوجود والعدم، من دخول زيد، وقدم خالد ،... ولا مضافاً إلى وقت بأن يقول : وهبت هذا الشيء منك غداً ، أو رأس شهر كذا ، لأن الهبة تمليك العين للحال، وأنه لا يحتمل التعليق بالخطر، والإضافة إلى الوقت، كالبيع^(٦).

(١) رد المحتار ج ٥ ص ٢٥٧ ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ٢ ص ٣٧٧ .

(٢) أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٧٩ .

(٣) المغني ج ٦ ص ٢٨٨ .

(٤) المحلى ج ٨ ص ٥٩ .

(٥) غمز عيون البصائر ج ٤ ص ٤١ بتصرف .

(٦) بدائع الصنائع ج ٦ ص ١١٨ .

جاء في المغني : " ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة ، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع " (١) .

الرأي الثاني: جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل وهذا قول بعض الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، ورواية لأحمد (٤)، وهو ما قال به شيخ الإسلام ابن القيم (٥).

جاء في حاشية رد المحتار : " إذا قالت لزوجها وهبت مهري منك على أن لا تظلمني فقبل صحت الهبة، فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية، وقال بعضهم: مهرها باق إن ظلمها " (٦) .

جاء في الإنصاف : "صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج. أما الزوج : فمطلقاً ، وأما الزوجة : فبعد موت زوجها ،ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض ؛ لأنها هبة مشروطة بشرط ؛ فتنتقي بانتقائه " . (٧)

واستدلوا على ذلك بالسنة :

(١) المغني ج ٦ ص ٢٨٨ .

(٢) رد المحتار ج ٦ ص ٢٨١ .

(٣) مواهب الجليل ج ٨ ص ٤ .

(٤) الإنصاف ج ٨ ص ١٥٥ .

(٥) إغاثة اللهفان ج ٢ ص ١٦ .

(٦) رد المحتار ج ٦ ص ٢٨١ .

(٧) الإنصاف ج ٨ ص ١٥٥ .

١ - فيما روي عن : أُمُّ كُثُومٍ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ : (لَهَا إِنِّي قَدْ أَهَدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكِ وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكَ) قَالَ وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ (فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ مِسْكِ وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ) .^(١)

٢ - مَا رُوي أَنَّ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أُعْطَيْتَكَ هَكَذَا ثَلَاثًا) فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُؤْفِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَّى لِي ثَلَاثًا^(٢) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده ج ٥ ص ٢٤٦ ، حديث رقم (٢٧٢٧٦)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٣: فيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه جماعة ، وبقيّة رجاله رجال الصحيح.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها - باب إذا وهب هبة أو وعد عدة ثم مات قبل أن تصل إليه ج ٣ ص ١٦٠، حديث رقم (٢٥٩٨) .

وجه الدلالة من الحديثين : دل ظاهرهما على صحة تعليق الهبة على شرط .

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائل بصحة تعليق الهبة على شرط مستقبل وذلك لقوة أدلتهم حيث أنهم استدلوا بالسنة بينما أصحاب الرأي الأول استدل بالمعقول، ولأن الهبة من عقود التبرعات، والمتبرع متفضل فله أن يتبرع كيفما شاء .

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان :

" فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط - ثم ذكر الحديثان - ثم قال فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين".^(١)

وبناء على الراجح من آراء الفقهاء فقد ذهب بعض العلماء المعاصرين^(٢) إلى جواز هذه الصورة وهي أن تشتمل صيغة الإجارة

(١) إغاثة اللهفان ج ٢ ص ١٦ .

(٢) الإيجار المنتهي بالتمليك: د/ حسن الشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير: فضيلة الشيخ محمد مختار السلامي، الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير: د/ محمد جبر الألفي، ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس والثاني عشر، الدليل الشرعي للإجارة: عز الدين محمد خوجة ، مراجعة د. عبد الستار أبوغدة ، مجموعة دلة البركة ، ص ٢١٠ ، ٢١٢ ، ٢١٣ .

على هبة السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة وسداد الأجرة المتفق عليها،
ويقبل الطرف الآخر، فتكون هبة معلقة على شرط^(١).

أهم النتائج:

وفي ضوء ما سبق ، يمكن القول بأن الإجارة المنتهية بالتملك
تُعد من العقود التي توفر التمويل اللازم للحصول على الاحتياجات
الرأسمالية التي تتلاءم مع حجم النشاط للأفراد والشركات على السواء،
ولهذا العقد العديد من المزايا لكل من المؤجر والمستأجر، مما ينعكس
بدوره على الاقتصاد الوطني ، إذا ما تم وفق الضوابط الشرعية.

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١٢ ج ٢ .

أهم الضوابط التي تحكم الإجارة المنتهية بالتملك ما يلي:

١- الالتزام بأحكام وقواعد الإجارة ، وأهمها :

- أن يكون عقد الإجارة عقدًا حقيقيًا مستجمعًا لأركان الإجارة وتوفُّر شروطه وانتفاء موانعه، ومن ذلك أيضًا العِلْمُ بالأجرة ، وتَحْدِيدُ مدَّة الإجارة، وأن تكون العين صالحة للإجارة، وغير ذلك من الشروط، بحيث يترتَّب على عقد الإجارة جميعُ آثاره المقرَّرة شرعًا للمؤجِّر وللمستأجر، مع الوعد بالتملك بعد انتهاء مدة الإجارة .

-أن تكون يد المستأجر على الأصل يد منفعة أي يد أمانة، وإذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أن يكون تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويثمله المالك المؤجر .

-الأجرة المدفوعة أثناء مدة الإجارة تعتبر ثمنًا للمنفعة التي استوفاه المستأجر، ومن ثم لا يجوز له المطالبة باستردادها إذا لم يتحقق الوعد بالتملك .

-يتحمل المستأجر النفقات الخاصة بالتشغيل .

٢- لا تُثقل ملكية الأصل المؤجر للمستأجر إلا بعد وفائه بالتزاماته والمتمثلة في الأقساط المتفق عليها .

٣-أن يكون عقد البيع في أثناء مدة الإجارة، أو بعد انتهاء مدتها حتى لا يجتمع عقدان (عقد البيع والإجارة) في عقد واحد.

٤- يتم نقل ملكية الأصل إلى المستأجر إما بعقد هبة منفصل عن عقد الإجارة وإما بعقد بيع، وفي الحالتين يكون هناك وعد بالهبة أو البيع عند إبرام عقد الإيجار.

أسئلة على هذا القسم :

أ- عرف الإجارة المنتهية بالتملك، مع ذكر الفرق بينها وبين البيع بالتقسيط.

ب- للعلماء آراء في حكم الإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً اذكرها مع الأدلة ، وذكر ما تراه راجحاً وسبب الترجيح .

ج- أكمل:

١- تُنقل ملكية الأصل للمستأجر بعد بالتزاماته والمتمثلة في الأقساط المتفق عليها.

٢- النفقات الخاصة بتشغيل العين المؤجرة تكون على

٣- ذكر بعض العلماء أن التكليف الفقهي لصورة الإجارة المنتهية بالتملك أنها عقد بيع

القسم الثاني

البطاقات الائتمانية

ويحتوي على أربع وحدات:

مقدمة :

تعد بطاقات الائتمان من أهم التطبيقات والخدمات المصرفية في السنوات الأخيرة، وقد انتشر استخدامها في جميع أنحاء العالم، وأضحت من وسائل الدفع المعاصرة في التعاملات التجارية والاستهلاكية، ولذا كان من الضروري دارستها من عدة جوانب.

وهذا الموضوع يلقي الضوء على أحكام هذه البطاقة الائتمانية من خلال التعريف بها وبيان أنواعها وتكييفها الشرعي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي، مع اقتراح بدائل شرعية لبطاقة ائتمان تتوافق مع مبادئ وقواعد الشرع الإسلامي.

الوحدة الأولى

ماهية البطاقات الائتمانية ومنافعها

المعلومات والمفاهيم

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على أن :

- ١- يعرف بطاقات الائتمان والجهات المصدرة لها وأنواعها.
- ٢- يصور الأشكال التي ترد عليها بطاقات الائتمان.
- ٣- يستخلص أثر التعامل ببطاقات الائتمان على المجتمع والاقتصاد.

تعريف بطاقة الائتمان^(١) :

أ- مفردات العنوان:

البطاقة في اللغة: البطاقة: الورقة وهي رُقعة صغيرة يُنْبَتُ فيها مِقْدَار ما تجعل فيه إن كان عيناً فوزُّهُ أو عدده وإن كان متاعاً فقيمتُه^(٢).

الائتمان : في اللغة مأخوذ من الأمان وهو ضد الخوف^(٣).

(١) ويرى بعض الباحثين أن التسمية هذه ليست دقيقة ، يقول د. عبد الوهاب أبو سليمان (بطاقات الائتمان) عنوان غير صحيح وقال : "جرت عادة الاقتصاديين والمصرفيين تقديم هذا النوع من البطاقات بعنوان (البطاقات الائتمانية) سواء في البحوث العلمية ، والإعلانات المصرفية ، وهي في نظر هؤلاء ترجمة لكلمة : (Credit Cards) في اللغة الإنجليزية ، لدى الرجوع إلى معنى هذه الكلمة (Credit) في المعجم الإنجليزي أجد أن لها عدة معان : تطلق غالباً على شرف الشخص ، واعتزازه ، وانتمائه، الاعتراف بكفاءته سمعته الطيبة ،الدرجة العلمية مرتفعة النسبة على درجة النجاح في الامتحان . والعنوان السليم المناسب لهذا النوع من البطاقات هو : (بطاقات الإقراض)؛ إذ هو الوصف المناسب الدال على حقيقتها وماهيتها ، المميز لها عن نظيراتها من البطاقات الأخرى " مجلة المجمع ١٢ع.

(٢) لسان العرب مادة بطق.

(٣) لسان العرب مادة أمن.

وفي الاصطلاح الاقتصادي : منح دائن لمدين مهلة من الوقت، يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين^(١).

ب- تعريف بطاقات الائتمان : باعتبارها مركب إضافي

في الاصطلاح الفقهي : مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدّر بالدفع ، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر^(٢).

وفي الاصطلاح الاقتصادي: بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة ، ويقوم بائع السلع ، أو الخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر الائتمان ، فيسدد قيمتها له ، ويقدم المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجمالي القيمة لتسديدها ، أو لخصمها من حسابه الجاري لطرفه^(٣)

(١) معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص ١٢.

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه بقراره رقم (٦٥ / ١ / ٧) في ٧ - ١٢ / ١١ / ١٤١٢هـ.

(٣) معجم المصطلحات التجارية والتعاونية ، د. أحمد زكي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، - بيروت ، عام ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م ، ص ٦٢.

التعريف المختار : تعريف البطاقة في الاصطلاح الفقهي وذلك: لأن هذا التعريف يشمل جميع أنواع البطاقات المصرفية ،
ويظهر من خلال ذلك أن بطاقات الائتمان ليست نقودا في حد ذاتها، بل هي وسيلة متطورة من وسائل الدفع المتعددة التي تقوم في مجملها عن النقود.

نبذة تاريخية عن البطاقة الائتمانية والجهات المصدرة لها:

أ- ظهرت الحاجة لبطاقة الائتمان في مطلع القرن العشرين في أمريكا عندما أصدرت بعض شركات البترول الأمريكية بطاقات لعملائها لشراء ما يحتاجونه ، على أن يتم تسوية هذه المشتريات من قبل العملاء في نهاية كل مدة متفق عليها .

- وأول من أصدر تلك البطاقات هو بنك ناشيونال فرانكلين عام ١٩٥٢م ثم تبعه البنك الأمريكي عام ١٩٥٨م، ثم ظهرت بطاقة الأمريكان إكسبريس عام ١٩٥٨م، لتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الفنادق والشركات مع ضمان استرداد ما تقوم بدفعه ، ثم ظهرت فكرة (بطاقة الائتمان) في عام ١٩٧٠م ونشطت نشاطا كبيرا.

- ثم تأسست جمعية بنكية بإصدار بطاقة منافسة لها ، ثم تكونت جمعية تعاونية فأصدرت البنوك بواسطتها (بطاقة فيزا)^(١).

ب- الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان:

يتولى إصدار البطاقات العالمية على اختلاف أنواعها جهتان هما: "أمريكان إكسبريس و فيزا " ويطلق عليهما البنكيون اسم (راعي البطاقة).^(٢)

(١) بطاقات الائتمان ، مجلة المجمع : د. علي القرة عيد ع ٧ ، بطاقات الائتمان

حقيقتها البنكية التجارية ، د. بكر أبو زيد ص ٢٠ - ٢٢ .

(٢) بطاقات المعاملات المالية، د. عبد الوهاب أبوسليمان، مجلة المجمع ع ١٠ .

أنواع البطاقات المصرفية :

تتنوع بطاقات الائتمان من حيث الرصيد الذي ترتبط به وشكلها إلى ما يلي:

أ-: البطاقات المصرفية من حيث الرصيد الذي ترتبط به:

تتنوع البطاقات المصرفية من حيث الرصيد الذي ترتبط به إلى نوعين:

النوع الأول: البطاقات المرتبطة مباشرة بالسحب من الرصيد وهي الأكثر من حيث التعامل والانتشار وتسمى (بطاقات الحساب الجاري)^(١)، وحامل هذه البطاقة لا يستفيد إلا من مبالغه المودعة في البنك.^(٢)

ولا تعد هذه البطاقة بطاقة ائتمان، وليست المقصودة عند الحديث عن بطاقات الائتمان.

(١) ويقصد ببطاقات الحساب الجاري أنها: أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري ، تمكّن حاملها من الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً . وهذه البطاقة التي أصدرتها الدوائر الحكومية ويستعملها في الوقت الحالي موظفي الدولة ، وأصحاب المعاشات في قبض الراتب الشهري .

(٢) البطاقات الائتمانية أ. د/ محمد محروس، مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في الهند في دورته الخامسة عشرة ، مدينة [سري نكار] عاصمة مقاطعة كشمير الهندية ١٤٢٦ هـ ص ٤ .

النوع الثاني: بطاقات الائتمان :

تنقسم إلى أقسام متعددة؛ فقد تقسم بحسب مزاياها، أو بحسب مادة تصنيعها، أو بحسب الجهة المصدرة لها، أو بحسب وجود الغطاء لها من عدمه، أو بحسب نوع العلاقة بين أطرافها،^(١) وهذا الأخير هو التقسيم المؤثر في تصوير المسألة، وتكييفها، كما أن وجود الغطاء وعدمه مؤثر كذلك في الحكم، وبقية التقسيمات لا يتعلق بها حكم.

وسوف أكتفي بهذا العرض الموجز للتفصيل في صلب البحث .

ب: البطاقات المصرفية من حيث الشكل ووصفها :

تصدر البطاقة المصرفية على عدة أشكال منها: العادية، والبطاقة الذهبية، والبطاقة البلاتينية، ولا فرق بين هذه الثلاث في آلية الإصدار والاستخدام، غير أن بعضها يتمتع صاحبها ببعض المزايا الإضافية، مثل التأمين ضد الحوادث، والحصول على تأمين طبي في السفر، و ضمانات خاصة على البضائع المشتراة بها، إلى جانب توفير مزيد في الحد الائتماني للشراء.^(٢)

(١) الجوانب الشرعية والمصرفية لبطاقات الائتمان د. محمد عبد الحليم ، ص(١٧)-

(٢٤) بطاقة الائتمان ، طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

(٢) بطاقات الائتمان ، د. نزيه حماد ، مجلة المجمع ١٢/١٣٤١.

ج- وصف بطاقة الائتمان:

هي عبارة عن قطعة من البلاستيك مستطيلة الشكل، مقاساتها طبقاً للقواعد الدوليّة كالتالي: (٨.٥٧٢) سم للطول، و(٥.٤٠٣) سم للعرض، سُمكها ٨.٠٠ مم).

ولها خصائص طبيعيّة منها: عدم قابليتها للاشتعال، ومُقاومة للمواد السامة والمنتجات الكيماويّة.

والبطاقة ذات وجهين: على الوجه الأول: اسم الجهة المصدرة، وعلامتها، واسم حامل البطاقة، ولقبه، وتاريخ إصدار البطاقة، ونهاية صلاحيتها، ورقم البطاقة الذي يشتمل على ثلاثة عشر رقماً، أو ستة عشر رقماً من اليسار إلى اليمين، **وفي خلفها** : تسجل البيانات المشفرة الخاصة بالحساب ^(١).

(١) <http://www.alukah.net>

منافع بطاقات الائتمان على أطراف البطاقة^(١) :

تقدم بطاقات الائتمان منافع لكل طرف من أطرافها، وبيان ذلك على النحو التالي.

أولاً : منافع بطاقات الائتمان لحامل البطاقة:

تقدم بطاقات الائتمان لحامل البطاقة منافع كثيرة ومنها :

- ١ - تزويد حامل البطاقة بتسهيلات نقدية له عند طلبه ذلك من أي عضو في المنظمة في أي دولة كان فيها.
- ٢ - استخدام أجهزة الصرف الآلي التابعة لأعضاء المنظمة، محلياً أو خارجياً، للحصول على مبالغ نقدية ضمن حدود تسهيلاته.
- ٣ - تقدم تسهيلات لحامل البطاقة في إجراءات حجز الفنادق وتأجير السيارات والشراء البريدي بضمان البنك المصدر .
- ٣ - إمكانية استخدامها محلياً ودولياً دون الحاجة إلى حمل النقد أو تحويل العملات.

(١) بطاقات الائتمان ، د. رفيق المصري ، ع٧ ، بحث بطاقات الائتمان المصرفية ، بيت التمويل الكويتي ، مركز تطوير الخدمة المصرفية ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع٧٤.

ثانيا : منافع بطاقات الائتمان للتاجر.

تقدم بطاقات الائتمان للتاجر منافع وهي:

- ١- جذب عملاء جدد.
- ٢- توفير ميزة تنافسية للتاجر.
- ٣- تخفف على التاجر مخاطر الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في متجره وتقلل أثر مخاطر السرقة أو السطو المسلح.
- ٤- الاستفادة من الحملات الدعائية التي ينظمها مُصدِّرو البطاقة، وذلك بإدراج اسمه في الدليل الذي يوزعه المُصدِّر على حاملي البطاقة.^(١)

ثالثا: منافع بطاقات الائتمان للبنك المصدر للبطاقة:

- ١- توظيف المصرف أمواله .
- ٢- ضم عدد كبير من الأفراد المستفيدين من البطاقة عملاء رئيسيين للمصرف يشجعون على التعامل معه ، والاستفادة من خدماته .
- ٣- اضطرار حاملها والتجار فتح حساب لدى المصرف ، وبالتالي الاستفادة من خدمات المصرف الأخرى .
- ٤- الانتشار العالمي وسمعة البنك في الخارج.^(١)

(١) بطاقات الائتمان ، د. محمد علي القري ، مجلة المجمع، ٣٠٢/٧ - ٣٠٣ .

أثر التعامل ببطاقات الائتمان على اقتصاد الفرد والمجتمع:

نتج عن التعامل ببطاقات الائتمان آثار منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي على المجتمع والاقتصاد.

فمن الإيجابيات:

أولاً: أن التعامل بالبطاقة يؤدي إلى توسع السوق وزيادة حجم الطلب على السلع والخدمات.

ثانياً: ساعدت البطاقة على توفير قدر أكبر من الأمان للأفراد لعدم تعرضهم للسرقة وضياع أموالهم.

ثالثاً: يؤدي التعامل ببطاقات الائتمان إلى زيادة حجم السيولة في الاقتصاد؛ لأنه يزيد من قدرة المؤسسات المالية (المصدرة للبطاقة) والبنوك على خلق الائتمان^(١).

وكل المنافع التي سبق أن سردتها من قبل لأطراف البطاقة تعد من قبيل الإيجابيات.

(١) بطاقات الائتمان ، حقيقتها ، حكمها د. نايف بن عمار .

(٢) بطاقات الائتمان ، د. محمد علي القرني ، مجلة المجمع، ٣٠٢/٧ - ٣٠٣.

أما السلبيات فكثيرة، ومنها:

أولاً: الوقوع في مشاكل اقتصادية كبيرة نتيجة منح الائتمان لأشخاص غير مؤهلين ائتمانيًا، وهذا له ضرر على المصارف وعلى الأفراد:

أما ضرره على المصارف فإن مثل هذا يوقع البنوك في الديون المعدومة، وهذا له أضرار اقتصادية جمة.

وأما ضرره على الأفراد فتتراكم الديون الماليّة على صاحب البطاقة، وفي حال تأخر عن سدادها تُفرض عليه غرامة ماليّة.

ثانياً: زيادة نسبة الفوائد المترتبة على القروض الخاصة بالبطاقة.

ثالثاً: إمكانية تزوير البطاقة واستخدامها استخدامًا غير قانوني يوقع المصارف في تكاليف باهظة^(١).

رابعاً: أنّ هذه البطاقات المنتشرة اليوم تُعتبر من أكبر الأسباب في توجيه الديون إلى الحاجات الاستهلاكية غير الإنتاجية، والتوسع فيها بسبب وجود هذه التسهيلات، بدلاً من صرفها على المجالات الاستثمارية المفيدة للاقتصاد والمجتمع.

(١) المعاملات المالية المعاصرة ٦٢٧/١٢.

الوحدة الثانية

أقسام بطاقات الائتمان وحكمها

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على أن :

- ١- يذكر حكم بطاقة الائتمان المغطاة.
- ٢- يستنبط الدليل على حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية.
- ٣- يفرق بين البطاقة المغطاة وغيرها .
- ٤- يستنبط أثر الشروط الباطلة على عقد البطاقة الائتمانية .

أقسام بطاقات الائتمان باعتبار نوع العلاقة :

بين أطرافها وحكمها : البطاقات الائتمانية باعتبار نوع العلاقة بين أطرافها تنقسم إلى قسمين بطاقات ائتمان مغطاة: يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات، وبطاقات ائتمان غير مغطاة: أي لا يوجد رصيد يقابل استخدامها. وسيقتصر الكلام عن بطاقات الائتمان المغطاة فقط.

بطاقات الائتمان المغطاة.

يَشْتَرُطُ مُصْدرُ البطاقةِ على حاملها أن يودع لديه مبلغاً من النقود في حساب مصرفي، ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن قيمة المبلغ المودع. ^(١)

من أبرز خصائصها:

- (أ) تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.
- (ب) توفر البطاقة لحاملها السحب النقدي، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم الخصم منه فوراً..
- (ج) لا يتحمل العميل رسوماً - مالية - مقابل استخدامه هذه البطاقة ، إلا في حال سحب العميل نقداً، أو شرائه عملة أخرى ^(٢).
- (د) تصدر هذه البطاقة برسم مالي - أو بدونه . ^(١)

(١) بطاقات الائتمان د. علي القرة عيد ، مجلة المجمع، ٢٩٥/٧ . فقه المعاملات المعاصرة د. سعد بن تركي الثخائن، ص ٢٧٣.

(٢) وقد أدخلها بعض الباحثين ضمن البطاقة الائتمانية لأنها يؤخذ على السحب النقدي بها رسوم مالية .مجلة مجمع الفقه الإسلامي :عدد ١٢ . الدورة السابعة .

سنة ١٤١٢ هـ - ١٩٨٨ م . ج ١ . ص ٧١٧

والذي يبدو من خلال ذكر خصائص بطاقات الائتمان المغطاة أنها لا تدخل ضمن التعريف الأخص للبطاقات الائتمانية وإنما تدخل فيها من باب التغليب، إذ أن حامل البطاقة يتعامل مع حسابه الموجود في البنك سواء كان ذلك عن طريق الشراء أو السحب المباشر، وبالتالي فإن البطاقات المغطاة لا تمثل أي مديونية وهي تختلف عن البطاقات غير المغطاة والتي تقوم على الائتمان الممنوح للعميل والذي يمثل جوهر البطاقة.

حكمها:

أجاز العلماء المعاصرون^(١) التعامل ببطاقات الائتمان المغطاة برصيد إذا لم يتضمن العقد شروط دفع الفائدة عند التأخر في السداد وذلك: لأن الأصل في المعاملات الإباحة^(٢) ما لم يحصل أي شرط، يترتب عليه فائدة ربوية.

(١) المعيار الشرعي رقم (٢) بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان،

<http://www.islamfeqh.com>

(٢) بطاقات الائتمان د. محمد علي ، مجلة المجمع ع ١٢، بطاقات الائتمان ، د. وهبة الزحيلي، مجلة المجمع ع ١٥/٣/٢١٩ .

(٣) وإذا كان هذا القول مبني على أن الأصل في المعاملات الإباحة لا الحظر فأذكر خلاف الفقهاء في هذه المسألة وللفقهاء خلاف على قولين.

القول الأول : يرى من ذهب إليه أن الأصل في المعاملات الإباحة وهو قول جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، واستدلوا على ذلك : الكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب فمنه قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ﴿ المائدة، جزء آية: (١). وقوله سبحانه ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ الإسراء، جزء آية: (٣٤). أما السنة فعن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إن الله فرض فرائض، فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) أما المعقول: فإن العقود هي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه؛ والأصل فيها العفو، وعدم الحظر.

القول الثاني: يرى من ذهب إليه أن الأصل في المعاملات الحظر ذهب لذلك الظاهرية. وذلك بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله - تعالى -: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ البقرة ٢٢٩. أما السنة فعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ -: (ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب البيوع ، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، ١٠٦/٢ برقم (٢١٨٦) ، ومسلم في كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق ، برقم (١٥٠٤) مجموع الفتاوى (٣٨٦/٢٨) .

الراجح : والله أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأن الأصل في المعاملات الإباحة وذلك لما يلي لقوة ما استدلوا به من أدلة ، وضعف دليل القول المخالف .ولأن الشريعة قائمة على رفع المشقة والحرص عن الأمة ؛ قال ابن تيمية: (والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه).القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ، مكتبة السنة المحمدية ، ط ١ ، ١٣٧١هـ ، ١٨٨ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٦ ، الذخيرة للقرافي ١/١٥٥ ، المحصول في علم الأصول ٩٧/٦ ، شرح الكوكب المنير ١/٣٢٥ المحلى ٤١٤/٨ .

الوحدة الثالثة

أطراف بطاقات الائتمان والتكيف الفقهي لأطراف التعاقد

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على أن :

- ١- يذكر أطراف التعاقد في بطاقات الائتمان والتكيف الفقهي..
- ٢- يفهم العلاقة التعاقدية بين أطراف البطاقة الائتمانية.
- ٣- يبين علاقة هذه النازلة بالمسائل الفقهية المدونة في كتب الفقهاء القدامى.

أطراف بطاقات الائتمان:

يتكون عقد بطاقات الائتمان من ثلاثة أطراف : (١)

الطرف الأول : وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناءً على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضواً فيها ، ويقوم بالسداد وكالةً عن حامل البطاقة للتاجر .

الطرف الثاني : حامل البطاقة، وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه، ويلتزم لمصدرها بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها.

الطرف الثالث : التاجر وهو مصطلح يُطلق على كلٍّ من المؤسسات، والشركات، والمصارف التي يتمُّ تطبيق اتفاق معهم؛ من أجل تقديم الخدمات، وقبول عمليات البيع، وتوفير النقود بموجب بطاقة الائتمان..(٢)

الطرف الرابع: المنظمة العالمية: وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة، وتقوم بالإشراف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات خاصة مع البنوك المُصدرة ، ومن أشهرها:منظمة فيزا ، ومنظمة ماستر كارد، ومنظمة أمريكان إكسبريس .

(١) بطاقات الائتمان ، د. رفيق المصري ، ٣١٦/٧ .

(٢) المرجع السابق، د. عبد الوهاب أبو سليمان ع١٠، المعاملات المالية المعاصرة١٢/٥٤٣

التكييف الفقهي لأطراف التعاقد بالبطاقات الائتمانية :

تتحصّر العلاقة بين أطراف التعاقد وبيان ذلك على النحو التالي:

التكييف الفقهي^(١) للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها:

كما سبق أن أوضحت أن من خصائص بطاقات الائتمان منح مصدر البطاقة حاملها مميزات مباحة^(٢) شرعاً.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها إلى عدة أقوال^(٣).

(١) ويعرف التكييف الفقهي بأنه تحديد لحقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة.

(٢) لا يجوز إعطاء امتيازات لحامل البطاقة تحرمها الشريعة الإسلامية، كالتأمين التجاري على الحياة، أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً، كالخمارات والمراقص ودور اللهو المجانية. بطاقات الائتمان دكتور وهبة مصطفى الزحيلي، الدورة الخامسة عشرة ٦-١١/٣/٢٠٠٤م مسقط (سلطنة عُمان)

(٣) وقد حيرت هذه العلاقة رجال القانون الغربي في البلاد التي نشأت فيها البطاقة كما حيرت الفقهاء المسلمين. دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية: د. أسامة الأشقر ص ١٢٤

ويرجع سبب الخلاف بين العلماء إلى ما يلي:-

أولاً: عدم وقوف بعض العلماء إلى حقيقة النظام الذي تقوم عليه هذه البطاقات ، وعدم تدقيقهم في العقود التي تحكم الأطراف المتعاملة بها. ...

ثانياً: إن العلاقة بين الأطراف الثلاثة في عقود بطاقة الائتمان علاقة معقدة.

ثالثاً : منهم من لا يخرج المعاملة على عقد مسمى^(١)، ويكتفي بأن الأصل في المعاملات الحل.، ومنهم من يخرج المعاملة على أنها عقد من العقود المسماة.

القول الأول : أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان^(٢) ذهب لذلك د. نزيه كمال حماد، د. محمد القري، وهي قول للشيخ علي عندليب ، والشيخ محمد علي التسخيري^(٣).

(١) العقود تنقسم من حيث التسمية إلى قسمين: عقود مسماة: وهي العقود التي نص الشارع على تسميتها، وجعل لها أحكاماً خاصة كالبيع، والإجارة، والرهن، ...، وعقود غير مسماة: وهي العقود التي لم ينص الشارع على تسميتها، وإنما استحدثت تبعاً لحاجة الناس، ولم تكن موجودة زمن التشريع، كعقود التأمين، والإجارة المنتهية بالتملك. نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع - محمد سلامة ص ١٧.

(٢) ويقصد بعقد الضمان: في اللغة يطلق على معان منها:
أ - الالتزام : تقول ضمننت المال ، إذا التزمته.

وجه كون العلاقة عقد ضمان:

حيث ضمن مصدر البطاقة - حامل البطاقة - في سداد ما عليه للتاجر ، وهذا من قبيل ضمان الحق قبل وجوبه.

وهو جائز عند جمهور الفقهاء^(١) ومنهم الحنفية ، والمالكية، الشافعية في القول الأول والحنابلة^(٢) وذلك لأنَّ الضمان من قبيل التبرُّع، والتبرُّع يصحُّ مع الجهالة.^(٣)

ب - الكفالة: تقول: ضمنته الشيء ضمانا، فهو ضامن وضمين، إذا كفله.
ج - التبرع ، تقول : ضمنته الشيء تضمينا ، إذا غرمته القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة : (ضمن) وفي الاصطلاح : إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات، حكمة مشروعيته : شرع الضمان ، حفظا للحقوق ، ورعاية للعهود ، وجبرا للأضرار ، وزجرا للجناة ، وحدا للاعتداء دليل مشروعيته :قوله تعالى: { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } سورة يوسف ٧٢: .

(١) مجلة المجمع ع٣/١٢.

(٢) وذهب الشافعي في الجدِّ والثوري، والليث، وابن أبي ليلى، إلى عدم صحة الكفالة بالدين المجهول وذلك لأن الكفالة التزام دين في الذمة، والتزام المجهول غرر ينهى عنه الشارع، فوجب أن يكون الدين معلوما حتى يكون الكفيل على بينة من أمره، ومن قدرته على الوفاء بما التزم به. نهاية المحتاج: ٤٢٥/٤؛ أسنى المطالب: ٢٣٨/٢ المغني لابن قدامة: ٧٣/٦ ، الإنصاف للمرداوي: ١٧٥/٥

(٣) حاشية الشلبي على تبیین الحقائق ١٥٢/٤ ؛ الفتاوى الهندية ٢٥٦/٣، مواهب الجليل ٩٩/٥ ، شرح منتهى الإرادات ٢٤٨/٢ .

ويناقش بأن ذلك غير مسلم من وجهين:

الوجه الأول : أن الضمان عقد تبرع محض، والجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية ليست صندوقاً خيرياً، وإنما تهدف الربح إما عن طريق الفائدة الربوية إذا لم يسدد حامل البطاقة التزاماته، وإما من التاجر حيث تأخذ منه نسبة معينة من المال المستحق له، وكل هذا مخالف للضمان في الشريعة الإسلامية.

الوجه الثاني : أن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة شرعاً، يستطيع فيها الدائن أن يطالب المكفول - حامل البطاقة - وأن يطالب الكفيل (مصدر البطاقة)، والدائن (التاجر) في هذه المعاملة لا يستطيع أن يطالب المضمون عنه - حامل البطاقة - وإنما يطالب الضامن^(٢).

وأجيب بما يلي :

أ - أن الحنفية والمالكية^(٣) أجازوا^(٤) اشتراط براءة ذمة المضمون عنه.
ب- أن الدين ينتقل إلى ذمة الضامن فالضمان يبرئ المضمون عنه^(٥) وذلك استدلالاً بالسنة والمعقول .

(١) بطاقات الائتمان غير المغطاة د. نزيه حماد ، مجلة المجمع العدد ١٢.

(٢) بطاقات الائتمان د. محمد الضرير ، مجلة المجمع ١٢/١٤٣٢ .

(٣) فتح القدير ٨/١٨٢ ، والشرح الصغير للدريدير ٣/٤٣ .

(٤) وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة .تحفة المحتاج ٥/٢٧، شرح منتهى الإرادات ٢/٢٤٦ .

(٥) فتح القدير ٦/٢٨٤ ؛ الحاوي للماوردي ٨/١١٢ ؛ المغني ٦/٨٤ ، المحلى ٨/١١٣.

(٦) بطاقات الائتمان غير المغطاة ، د. نزيه حماد، مجلة المجمع العدد ١٢.

أما السنة فمنها :

١- عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الزعيم غارم)^(١) .^(٢)

وجه الدلالة : خص النبي ﷺ الضامن بالغرم ، فافتضى ذلك أن يكون المضمون عنه بريئاً من الغرم.

٢- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ في جنازة، فلما وضعت، قال: "هل على صاحبكم من دين؟" قالوا: نعم، عليه ديناران. فعدل رسول الله ﷺ عنه وقال: "صلوا على صاحبكم". فقال علي رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن، فتقدم النبي ﷺ فصلى عليه، ثم قال لعلي: "جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك". ف قيل: يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بل للمسلمين عامة".^(٣)

وجه الدلالة : دل الحديث على براءة ذمة المضمون عنه بالضامن وذلك من وجهين:-

(١) الزعيم : الكفيل . غارم :أي ضامن.

(٢) جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب البيوع باب ما جاء في العارية برقم ١١٨٢. قال أبو عيسى: وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب.

(٣) أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب البيوع ٤٦/٣ ، وفي إسناده ضعفاء.البدري المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ٧١١/٦ .

أحدهما: أن النبي ﷺ بعد أن امتنع من الصلاة عليه صلى عليه، فدل ذلك على براءة ذمته.

ثانيهما: دل قوله ﷺ (فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك) على براءة المضمون عنه..

أما المعقول :

فإن أهل الاختصاص لا ينفون حق التاجر في مطالبة حامل البطاقة^(١).

القول الثاني : العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة حوالة^(٢) أي: أن حامل البطاقة يحيل التاجر على مصدرها ذهب لذلك جمع

(١) يقول أحد الباحثين : "لم أجد في العقود المنظمة للبطاقات ما ينص على أنه ليس للقابل أن يطالب حاملها؛ ولذا اختلف القانونيون في هذه المسألة"، وعليه فليس ثمة إشكال أصلاً. بطاقات الائتمان، د. على القري مجلة المجمع ١٢٤ ج ٣ ص ٥٤١ .

(٢) الحوالة **في اللغة :** من حال الشيء حولا وحوؤلا : تحول . وتحول من مكانه انتقل عنه وحولته تحويلا نقلته من موضع إلى موضع. لسان العرب مادة حول. المصباح المنير مادة حول.

وفي الاصطلاح : نقل الدين من ذمة إلى ذمة. مغني المحتاج ١٩٣/٢ .
والدليل على مشروعيتها : عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ » أخرجه مسلم في صحيحه ، ٣٤/٥ ، ٤٠٨٥ . وقد حكى ابن قدامة الإجماع على جوازها فقال :وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة .

من العلماء المعاصرين منهم د. الصديق محمد الأمين الضرير، د. وهبة الزحيلي وهو قول للشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري، د. رفيق المصري، والشيخ عبد الله بن منيع.^(١)

وجه هذا القول: أن حامل البطاقة هو المحيل ، والتاجر هو المحال، ومصدر البطاقة هو المحال عليه.

وبيان ذلك: أن يحيل حامل البطاقة التاجر بدينه على مصدر البطاقة، ويقبل المحال عليه أداء الحوالة، وإذا كانت العلاقة من قبيل الحوالة ، فالحوالة جائزة وتعد من قبيل الحوالة بأجر.

ويناقش: أن هذا القول غير مسلم من وجهين:^(٢)

الوجه الأول: أن عقد البطاقة ليس فيها ما يشير إلى عقد الحوالة، والاتفاقيات تعقد بشكل منفصل بين حامل البطاقة والبنك المصدر لها من جهة ، ثم بين التاجر ومصدر البطاقة من جهة ثانية.

الوجه الثاني: بأنه لا دين للمحيل (حامل البطاقة) على المحال عليه (البنك)، ومن شروط الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال^(٣) ولو

(١) بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي ، بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مسقط ، سلطنة عمان ٦ : ١١-٣-٢٠٠٤م، بطاقات الائتمان غير المغطاة ، الشيخ محمد علي تسخيري مجلة المجمع العدد ١٢.

(٢) بطاقات الائتمان ، مجلة المجمع ، د. محمد علي القري ، العدد ١٢.

(٣) قال الخرشي في سياق الحديث عن الحوالة : (ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه وإلا كانت حمالة عند الجمهور).شرح الخرشي علي مختصر خليل ١٧/٦ .

بدين حوالة سابقة^(١)، ولو كانت حوالة من شخص ليس مدينًا ، لصارت حوالة على مقرض، وهذا غير جائز، لأن فيه شبهة الربا^(٢).

وأجيب عن ذلك : بأن الحوالة لا يشترط فيها أن يكون المحيل مدينا للمحال عند الحنفية ومن وافقهم من الفقهاء ؛ فتكون الحوالة داخلة في عموم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « مَطْلُ^(٣) الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ »^(٤) .^(٥)

الثالث: القول بأن العقد عقد حوالة يتعارض مع أخذ مصدر البطاقة من حاملها أجرا على الخدمات ، فإذا أخذ مصدر البطاقة رسوم من

(١) اختلف الفقهاء في صحة الحوالة إذا كان المحال عليه غير مدين للمحيل ولهم في ذلك قولان: القول الأول: الحَوَالَةُ صحيحة، وهذا مذهب الحنفية، والقول الأول للشافعية، واختاره ابن الماجشون من المالكية، القول الثاني: أن هذا من قبيل الضمان ، وليس من الحوالة في شيء ، ولو استعمل لفظها ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنَّ المحال عليه احتمل سداد الدَّيْن عن المُحِيل، وهذا هو الراجح. بدائع الصنائع ١٦/٦، شرح الخرشي علي خليل ١٧/٦، مغني المحتاج ١٢٤/٢، المغني ٥٧/٥.

(٢) بطاقات الائتمان ، د. رفيق المصري مجلة المجمع العدد ٧.

(٣) المطل: التأخير؛ أي: تأخير الغني الواجد للمال قضاء ما عليه من الدين .

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الاستقراض: باب مطل الغني ظلم ٥٧/٥ حديث ٢٤٠٠، ومسلم في صحيحه ، كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني ٣٤/٥ ، برقم ٤٠٨.

(٥) بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مسقط ، سلطنة عمان ٦ : ١١-٣-٢٠٠٤م

حامل البطاقة؛ فيكون أخذ زائداً عن حقه وهذا يخل بشروط الحوالة.^(١)

القول الثالث : للبطاقة حالان: حال قبل استخدامها من قبل حاملها وهي في هذه الحالة تكون كفالة، وبعد استخدامها تنقلب إلى حوالة وهو قول د. عبد الستار أبو غدة.^(٢)

وجه هذا القول:

أن المصرف يتكفل تجاه التجار ومقدمي الخدمات بأداء ما في ذمة حامل البطاقة ، وبعد قيام حامل البطاقة باستخدام البطاقة ينشأ دين للتاجر (المحال) لدى حامل البطاقة (المحيل) فتنحول العلاقة بين أطراف البطاقة من كفالة إلى حوالة.

ويناقش :

(١) قال ابن قدامة: (ومن شرط صحة الحوالة شروط ثلاثة. أحدها: تماثل الحقيين في أمور ثلاثة: الجنس فيحل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة، ، الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر، وإن أحال من لا دين له عليه رجلا على آخر له عليه دين فليس ذلك بحوالة بل هي وكالة، وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة أيضا نص عليه أحمد فلا يلزم المحال عليه الأداء ولا المحتال قبول ذلك لأن الحوالة معاوضة ولا معاوضة هاهنا وإنما هو اقتراض لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين، الشرط الثالث: أن تكون بمال معلوم..) المغني لابن قدامة ٥/٥٥.

(٢) بطاقات الاعتماد، مجلة المجمع ، ع ١٢٤.

بأن الكفالة لا تكون إلا بدين ثابت ، وقبل استخدام البطاقة لم يثبت دين في ذمة حاملها ، وأما بعد الاستخدام فالقابل لها لا يطالب حاملها ، وإنما يطالب المصدر وهذا معنى الائتمان ^(١).

القول الرابع : أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة وكالة ^(٢).

وهو قول الشيخ علي عندليب، والشيخ محمد علي التسخيري ^(٣).

(١) بطاقات الائتمانية ، د. صالح بن محمد الفوزان، موقع صيد الفوائد.
(٢) الوكالة :في اللغة : الحفظ .وفي الاصطلاح : إقامة الغير مقام نفسه - ترفها أو عجزا - في تصرف جائز معلوم. الدليل على مشروعيتها الكتاب، والسنة ، والإجماع والمعقول .

أما الكتاب : فمنه قول الله سبحانه : {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} [الكهف: ١٩]
أما السنة فمنها: عن عروة بن أبي الجعد البارقى رضي الله عنه أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشتري له به شاتين، فباع إحداها بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لريح فيه أخرجه البخاري في صحيحه ، باب سؤال المشركين ١٣٣٢/٣ .

أما الإجماع :فقد حكى الإجماع ابن قدامة وقال أجمع الفقهاء على جواز الوكالة ومشروعيتها منذ عصر رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا ، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين وأما المعقول : فلأن الحاجة داعية إلى مشروعية الوكالة، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه فدعت الحاجة إليها . حاشية ابن عابدين ٤٠٠/٤ المغني ٨٧/٥، الإجماع لابن المنذر ٧٠/٢.

(٣) بطاقات الائتمان ، مجلة مجمع الفقه ١٢ع.

وجه هذا القول :

أن حامل البطاقة وكل (مصدر البطاقة) أن يسدد عنه، ثم يقضيه ، ويعتبر هذا التوكيل توكيلاً مطلقاً ^(١).^(٢).

ويناقش هذا القول من أوجه:

الأول: أن العلاقة في الوكالة بين طرفين هي الموكل والوكيل ، أما في البطاقة فإن العلاقة بين ثلاثة أطراف حامل البطاقة ، والتاجر، والمصدر.

الثاني: يجوز في الوكالة مطالبة كلا من الموكل والوكيل بالدين ، وفي دين البطاقة لا تجوز مطالبة الموكل ، بل يطالب الوكيل فقط.^(٣)

القول الخامس : أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة وكالة، وحوالة ، وكفالة، وقرض حسن وهو قول بعض العلماء المعاصرين.^(٤)

-
- (١) بطاقات الائتمان ، د. عبد الوهاب أبو سليمان، مجلة مجمع الفقه ع ١٠.
- (٢) فيصبح مصدر البطاقة وكيلاً عن حامل البطاقة في تسديد قيمة مشترياته مجلة المجمع ، بطاقات المعاملات المالية ع ١٠.
- (٣) بطاقات الائتمان ، الشيخ الصديق الضير، مجلة مجمع الفقه ، ع ١٠.
- (٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، الدورة السابعة ، العدد السابع ، عام ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م ، ج ١ ، ص ٦٥٧ - ٦٥٩.

وجه هذا القول :

أن البطاقة تقوم أساسًا على الحوالة مع جزء من الوكالة ، وفيها ضمان من مصدر البطاقة لحاملها ، كما أنها تصبح قرضًا حسنًا بالنسبة للبنوك الإسلامية.

ويناقش : سلمنا القول بأن هذا العقد يتضمن الوكالة والضمان، أما عقد الحوالة فإنه لا يسلم ؛لأن عقد الحوالة يتضمن شروط خاصة، غير موجودة في بطاقة الائتمان.^(١)

القول السادس: العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة إقراض فهي قرض ربوي بفوائد معجلة ومؤجلة وهو قول د. بكر أبو زيد^(٢).

وجه هذا القول:

أن مصدر البطاقة يوفر لحاملها التصرف في حدود مبلغ يحدده له، ثم يأخذ زيادة على المبلغ المحدد ، فهو قرض بزيادة، والزيادة ربا.^(٣)

(١) بطاقات المعاملات د. عبد الستار أبوغدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة،

ع ١٠ .

(٢) بطاقة الائتمان د. بكر أبو زيد، ص ٢.

(٣) بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي ، بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه

الإسلامي الدولي مسقط ، سلطنة عمان ٦ : ١١-٣-٢٠٠٤م

ويناقش من أوجه :

الأول : أن حقيقة القرض : هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ،
بينما عقد الائتمان قد يوجد ولا يوجد القرض ^(١).

الثاني : القول بأن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة بين
مقرض ومقترض، يقتضي هذا أن مصدر البطاقة لا يكون
مسئولا ولا ضامنا للبضاعة المعيبة التي يشتريها حامل
البطاقة من التاجر. ^(٢)

الثالث : أن القرض من عقود الإرفاق والبنوك ليست محلا لمثل ذلك
، بل تهدف جميع البنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقة
الائتمانية الحصول على أرباح ^(٣).

القول السابع: أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها معاملة مستجدة
تدرج تحت مسمى (العقود غير المسماة) وهو قول بعض العلماء
المعاصرين ^(٤).

(١) تكييف بطاقات الائتمان ، د. دبيان محمد الديبان،المقال العاشر ، القصيم ،
العدد ١٣٠ ، رمضان ١٤٢٩.

(٢) بطاقات المعاملات المالية ص٥٦.

(٣) تكييف بطاقات الائتمان ، د. دبيان محمد الديبان،المقال العاشر ، القصيم ،
العدد ١٣٠ ، رمضان ١٤٢٩.

(٤) المرجع السابق.

وجه هذا القول:

أن عقد البطاقة الائتمانية عقد جديد على الفقه الإسلامي، لا يندرج في صورته الكلية تحت عقد واحد من عقود المعاملات الشرعية المعروفة، ولا يصح تكييفه في صورته الكلية بعقد واحد، حوالة، أو جعالة، أو ضمان، أو وكالة، أو عقدين معاً: كالوكالة والكفالة، أو الوكالة والجعالة.^(١)

القول الراجح :

والله أعلم - هو القول الذي يرى أصحابه أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة مستجدة تدرج تحت العقود غير المسماة، والعقود الأصل فيها المشروعة إن لم يوجد فيها مخالفات شرعية ؛ وذلك لأن هذا العقد إذا اندرج تحت عقد من جانب تخلف من جانب آخر. والعقود الجديدة تكون مشروعة ما لم تعثرها مخالفات شرعية.

(١) البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية، عبد الرحمن الحجي ص ١٤٩.

التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر :

اختلف العلماء المعاصرون في تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر ولهم ستة أقوال.

القول الأول : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر هي علاقة كفالة مقترنة بالحوالة ^(١).

وجه هذا القول :

أن الغرض من اشتراط الكفالة مع أن الحوالة وحدها توصل التاجر إلى حقه - هي استمرار التزام مصدر البطاقة بالأداء للتاجر، دون الرجوع على المحيل (حامل البطاقة) في حالة (الإفلاس).

القول الثاني : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر : وكالة بأجر ^(٢). ^(٣).

وجه هذا القول : أن البنك المصدر للبطاقة وكيلاً للتاجر في قبض استحقاقات قيمة المبيعات من حامل البطاقة، والوكالة بأجر وبغير أجر جائزة ^(٤).

فإن قيل : أن ذلك من قبيل ضع وتعجل. ^(١)

(١) بطاقات الائتمان ، د. عبد الستار أبو غدة مجلة المجمع، العدد ١٢ .

(٢) والوكالة بأجر لها حكم الإجازات، وبغير أجر هي معروف من الوكيل.

(٣) بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي ، بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه

الإسلامي الدولي مسقط ، سلطنة عمان ٦ : ١١-٣-٢٠٠٤م.

(٤) حاشية الدسوقي ٣/٣٩٧ ، الحاوي ٨/٢٥٥ ، المغني ٥/٢١١ .

(١) مسألة (ضع وتعجل) وهي أن يُصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً وفيها خلاف بين الفقهاء على قولين القول الأول : يرى تحريم التعامل بها وإليه ذهب الحنفية ،والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الأولى وذلك استدلالاً بحديث المقداد بن الأسود قال: أسلفت رجلاً مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ فقلت له: عجل تسعين ديناراً، وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: ((أكلت ربا يا مقداد، وأطعمته)) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب البيوع ، برقم ١٠٩١٤، وفي سننه ضعف . وجه الدلالة :سمى رسول الله ﷺ هذه المعاملة ربا، والربا هنا ربا النسيئة ولا خلاف في تحريمه. ومن الأثر : عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعْ لَكَ، فَتَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: «نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالْدِّينِ» مصنف عبدالرزاق (٨ / ٧٢) وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان (٢ / ١٢). كما استدلوا بالمعقول ومنه : أن الحطيطة في الدين المؤجل عوض عن التأجيل وهو لا يجوز، فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض كزيادة الأجل مقابلة زيادة العوض.

القول الثاني : يرى من ذهب إليه جواز الوضع والتعجل وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشوكاني، وقد أخذ به مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بجدة، فقد نص على ما يلي:(الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية). وذلك استدلالاً بحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما أمر النبي ﷺ بإخراج بني النضير من المدينة، وفيه قوله ﷺ: ضعوا وتعجلوا". رواه الحاكم في المستدرک (٢ / ٦١) والدارقطني في السنن (٣ / ٤٦٥) وضعفه البيهقي في

أجيب: بأن القول بأن هذه العلاقة من قبيل (ضع وتعجل) غير مسلم؛ لأن تسديد البنك المصدر للبطاقة فوري، عند تسليم سندات البيع الصحيحة من التاجر.

القول الثالث : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة حوالة فالبنك محال عليه والتاجر محال، وحامل البطاقة محيل^(١).

وجه هذا القول :

أن حامل البطاقة عندما يشتري سلعة يتعلق بذمته قيمتها للتاجر، فالتاجر دائناً له بذلك المبلغ فيحيله على مصدر البطاقة .
ويناقش: بأن أخذ العوض على الحوالة لا يجوز مطلقاً، سواء كانت الحوالة من قبيل بيع الدين بالدين، أو من قبيل استيفاء الحق وليست بيعاً.

القول الرابع : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة سمسرة^(١) وقال بهذا التخرج الدكتور رفيق المصري ، د. وهبة الزحيلي ،

السنن الكبرى(٤٦/٦) ، والذهبي ومن أراد المزيد فليراجع: تكملة فتح القدير ٣٩٧/٧ المدونة ١٧٣/٩، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١٦٥/٢، مغني المحتاج ١٢٩/٢، المغني ١٧٤/٤، كشف القناع ٣٤٢/٣ ، الاختيارات الفقهية ص ١٣٤، إغاثة اللهفان ١٢/ ٢.

(١) الضوابط الشرعية في البطاقات الائتمانية الشيخ محمد الباشا ، بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي ، بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مسقط ، سلطنة عمان ٦ : ١١-٣-٢٠٠٤م

د.محمد تقى العثماني ، د.عبد الستار أبو غدة ، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين^(٢)

وجه ذلك :

أن المُصَدِّر يرسل حاملي البطاقات إلى التاجر على أن يتقاضى منه أجراً عن مشتريات كل حامل للبطاقة يشتري من التاجر بالبطاقة الائتمانية ، كما أنه يوفر بعض الخدمات للتاجر مثل تحصيل فواتير الشراء، وخدمة الإيداع المباشر في الحساب، ونحو ذلك.

القول الخامس: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة الكفالة والوكالة:

وجه ذلك :

أن الجهة المصدرة للبطاقة تعد ضامن للتاجر للوفاء بمستحقاته من قبل حامل البطاقة ، كما أن تحصيل هذه المستحقات للتاجر من قبل حاملي هذه البطاقات ووضعه في حسابه.

(١) السمسار : هو المتوسط بين البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر. حاشية ابن عابدين ٥/٥٦٥ .

(٢) بطاقات الائتمان لرفيق المصري مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١/٧/٤١٠ . ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، البحرين نص المعيار .٢٨

القول السادس : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة مستدة الأصل فيها الإباحة وهو قو د. أسامة الأشقر .

الراجع : القول السادس^(١).

(١) يراجع الترجيح في العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها .

التكييف الفقهي للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر:

اختلف العلماء المعاصرون في تكييف العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر ولهم في ذلك قولان .

القول الأول : العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر لا تخرج عن عقدين فإما أن تكون علاقة بيع أو علاقة إجارة.^(١)

وجه هذا القول : أن العقد إن كان عقد تمليك فهو عقد بيع ، وإن كان من قبل تقديم خدمات معلومة فهو عقد إجارة ، ويحيل حامل البطاقة التاجر على مُصدِر البطاقة لاستيفاء الثمن أو الأجرة.

القول الثاني : العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر هي علاقة شبيهة بخصم الأوراق التجارية^(٢).

(١) بطاقات الاعتماد، د. وهبة الزحيلي ، بحث الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مسقط ، سلطنة عمان ٦: ١١-٣-٢٠٠٤ م . بطاقات الانتماء غير المغطاة د. نزيه حماد ، مجلة المجمع العدد ١٢.

(٢) ويقصد بخصم الأوراق التجارية أنها عملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى المصرف قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف لصرف قيمتها له بعد خصم مبلغ معين نظير ذلك التعجيل. حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد، د. علي أحمد السالوس، مجلة المجمع ٢.

وجه هذا القول : أن الفاتورة التي وقّع عليها حامل البطاقة هي بمثابة كمبيالة مستحقة الدفع، يقوم التاجر بخصمها لدى البنك "المصدر للبطاقة" مقابل نسبة معلومة ^(١).

القول الراجح :

يبدو لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الأول فإن كان العقد عقد تمليك للسلع فهو من عقود البيع، أو كان من قبيل تقديم خدمات معلومة فهو من عقود الإجارة، ويشترط لصحة البيع والإجارة اكتمال شروطهما وانتفاء موانعهما.

(١) الضوابط الشرعية في البطاقات الائتمانية الشيخ محمد الباشا ، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:

العلاقة بين المنظمة الراعية^(١) وأطراف البطاقة .

تغطي المنظمة العالمية مصاريفها من خلال:

• إيرادات الاشتراك (العضوية) للأعضاء.

• الإيرادات ربع السنوية.

• ثمن بعض البرامج التي تقدمها المنظمة.

• الرسوم على بعض الخدمات.

تخريج العلاقة بين المنظمة الراعية وأطراف البطاقة .

العلاقة بين المنظمة الراعية وأطراف البطاقة علاقة (سمسرة) وبه قال د. عبد الستار أبو غدة ، د. وهبة الزحيلي ، والشيخ دبيان محمد الديبان.^(٢)

(١) منظمة " الفيزا " هي عبارة عن ناد يضم في عضويته جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء والتي تلتزم باللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه المنظمة مع عدم التعارض مع النظام الداخلي للعضو المشترك في هذه المنظمة. التكيف الشرعي لبعض الجوانب الإجرائية لبطاقة فيزا التمويل، مجلة المجمع ع٧.

(٢) بطاقات الائتمان تصورها ..، د. عبد الستار أبو غدة ، مجلة المجمع ع١٢/٢/٤٨٦، د. وهبة مجلة المجمع، ٥٣/٣/١٥ ، بطاقات الائتمان والتكيف الفقهي لها، الشيخ دبيان ، المقال العاشر ، القصيم ، العدد ١٣٠ ، رمضان ١٤٢٩.

ووجه ذلك: أن المنظمة هي صاحبة الحق المعنوي في البطاقة (الترخيص أو الامتياز). وتنشئ المنظمة علاقة بينها وبين البنوك والمؤسسات المالية التي تصدر البطاقة، حيث تزود المنظمة تلك البنوك بالخبرة الفنية والإدارية في إدارة نشاط إصدار البطاقة.

الوحدة الرابعة

الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة أن يكون /تكون قادرا على:

- ١ - يصور كيفية شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان.
- ٢ - إدراك الحكم الشرعي للعمولة التي يتقاضاها مصدر البطاقة.
- ٣ - استثمار الثقافة الدينية في ترسيخ القيم والأخلاق في المجتمع.
- ٤ - تحديد البدائل الشرعية لبطاقات الائتمان غير المغطاة.

الأحكام الفقهية المتعلقة ببطاقات الائتمان:

يتعلق ببطاقات الائتمان عدة أحكام أعرضها على النحو التالي أولاً:
أحكام العمولات (رسم مالي) التي يتقاضاها مصدر البطاقة
يشترط مصدر بطاقة الائتمان شروط عديدة منها شروط باطلة ،
وشروط صحيحة، وشروط مختلف فيها:

الشروط الصحيحة :

كاشتراط فتح حساب بالبنك المصدر للبطاقة .

الشروط الباطلة منها:

- ١ - فرض نسبة معينة عقوبة على تأخير السداد .
- ٢ - دفع نسبة معينة على الشراء بالبطاقة بأكثر من المبلغ المسموح به
قرضاً حسب الاتفاقية .
- ٣ - فرض نسبة معينة على تحويلات العملات الأجنبية .
- ٤ - فرض نسبة معينة على تسديد الدفع للعمليات النقدية، تحسب من
يوم الشراء.

الشروط المختلف فيها :

- ١ - حصول مصدر البطاقة من حامل البطاقة على رسوم الإصدار
والتجديد والاستبدال.

٢- المدفوعات التي يأخذها المصدر من التاجر ، وبيان الحكم الشرعي لهذه الشروط المختلف فيها على النحو التالي.

العمولات (رسم مالية) التي يتم تحصيلها من حامل البطاقة

وتتمثل العمولات في الآتي :

١- رسوم العضوية: يحصل هذا الرسم مرة واحدة عند الموافقة على طلب العميل للحصول على البطاقة أول مرة.

٢- رسوم التجديد : يحصل هذا الرسم عند تجديد صلاحية البطاقة وإصدار أخرى للعميل بدلا عنها بعد انتهاء مدتها المقررة السابقة (سنة واحدة أو سنتين).

٣- رسوم الاستبدال: يحصل هذا الرسم عند ضياع البطاقة عن حاملها أو تلفها أو سرقتها، فيصدر البنك بدلا عنها عند إبلاغه بذلك.^(١)

٤- رسوم السحب النقدي .

واختلف الفقهاء المعاصرون على حكم أخذ مصدر البطاقة رسوم الإصدار أو التجديد من حامل البطاقة ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

(١) مجلة المجمع ، بطاقات الائتمان ، د. عبد الستار أبو غدة، العدد ١٢.

القول الأول : يحرم أخذ رسوم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان ذهب لذلك ، د. محمد القري، د. عبد الله بن بية ، د. علي السالوس^(١).

القول الثاني : يجوز أخذ رسوم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان وقد ذهب إليه أكثر الباحثين ومنهم د. رفيق المصري ، د. ونزيه حماد ، د. عبد الوهاب أبو سليمان، د. عبد الستار أبو غدة، الشيخ محمد تقي الدين العثماني ، د. عبد الله بم منيع، د. إبراهيم الدبو ، د. بكر أبو زيد ، د. محمد مختار السلامي^(٢)

القول الثالث : التفصيل بين الرسوم فمنها رسوم محرمة كرسوم الضمان^(٣) ، ورسوم غير محرمة كأجور الخدمات المقدمة لحامل البطاقة وهو ما رجحه بعض العلماء المعاصرين.^(٤)

الأدلة والمناقشة :

(١) بطاقات الائتمان ، مجلة المجمع ، ع ٣٩٠/١/٧ ، ع ٥٩٦/٢/٨ ، ع ٦٤٢/٣/١٢ ، ع ٦٤٠/٣/١٢ ، ٦٦٤ ، ٦٤٨ ، ٦٤٢ ص ٣/١٢ ،

(٢) بطاقات الائتمان ، مجلة المجمع ، ع ٦٧٤/١/٧ ، ٣٩٠ ، الجوانب الشرعية د. محمد عبدالحليم عمر ص ٧٦ ، ، الوثيقة رقم (١) في مجلة مجمع الفقه : ع ٧ ج ١ ص ٤٦٧ من إعداد مركز تطوير الخدمة المصرفية في بيت التمويل، قرارات وتوصيات ندوة البركة : ص ٢٠٣

(٣) أي أجرا على ضمان الائتمان لا الخدمات الفعلية وقد اتفق الفقهاء على تحريم أخذ الأجر على الضمان .

(٤) البطاقات الائتمانية د. محمد صالح الفوزان ، www.saaid.net

أدلة القول الأول : المعقول ووجه الاستدلال به وجهين:

أحدهما: أن الصمان الذي يقدمه مصدر البطاقة لحاملها شبيه بالقرض ، فما يأخذه من رسوم فيه شبهة الربا؛ باعتباره من المنفعة المشروطة في القرض، فيحرم سدا للذريعة^(١).
ويناقش من وجهين:

الوجه الأول: بأنه لا علاقة بين القرض وبين هذه الرسوم ، فالرسوم تُقرض ولو لم تستخدم البطاقة، ثم إن الرسوم تكون عند الإصدار، أي قبل وجود القرض الذي لا يحصل إلا باستخدام المشترك للبطاقة^(٢).

الوجه الثاني: أن سد الذريعة لا يجوز التوسع فيه لدرجة الوقوع في الحرج.

ثانيهما: أن تكلفة الرسوم لا تتناسب مع تكلفة إصدار البطاقة.

ويناقش: سلمنا تحريم الزيادة في الرسوم ، ولا يعني ذلك تحريم كل رسم في أي بطاقة ؛ لأن قيمة الخدمات المصرفية يصعب تحديدها بدقة والغرر^(٣) اليسير معفو عنه^(١).

(١) د. علي القري، مجلة المجمع ، ٧٤.

(٢) د.تقي الدين العثماني ، مجلة المجمع ٧٤.

(٣) الغرر : فالغرر في اللغة: الخطر ،وهو الذي لا يُدرى أيكون أم لا، وغرر بنفسه وماله تغييراً عرضهما للهلكة.لسان العرب ١٣/٥.

أدلة القول الثاني : القياس والمعقول

أما القياس : فقياس أخذ رسوم البطاقة على حكم أخذ الرسوم المتعارف عليها في المرافق العلمية والاجتماعية ؛ إذ المقصود منها تغطية نفقات الأعمال الإدارية ، والأدوات المكتبية^(١).

وأما المعقول فوجه الاستدلال به:

أن الرسوم مقابل خدمات فرسم الاشتراك بمثابة أجر مقطوع لأصل الخدمة المصرفية المرتبطة بالبطاقة لقاء إجراءات قبول طلب العميل للحصول على البطاقة. ^(٢) فهي عبارة عن وكالة بأجر على عمل أو منفعة يؤديه مصدر البطاقة لحامل البطاقة^(٣)

ويمكن أن يُناقش:

بأن مجموع الرسوم قد يزيد كثيراً على هذه التكاليف خاصة مع كثرة البطاقات المصدرة ؛ فيشترط أن تكون الرسوم في مقابل التكلفة

والغرر في الاصطلاح:"ما يكون مجهول العاقبة.مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٩/٢٢.
(١) أجمع العلماء على أن يسير الغرر لا يؤثر وممن نقل الإجماع الجصاص، وابن العربي، والنووي .أحكام القرآن، للجصاص ٢ / ١٨٩، المسالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي ٦ / ٨٣، المجموع، للنووي ٩ / ٥٨.

(٢) مجلة المجمع ع ١٠.

(٣) الشيخ حسن الجواهري ، مجلة المجمع ع ٨.

(٤) مجلة المجمع : ع ١٢ ج ٣ ، ٥٠٩.

الفعلية، خروجاً من شبهة الأجر على الضمان والمنفعة المشروطة في القرض فيما زاد عن التكلفة ربا.^(١)

أدلة القول الثالث : المعقول ووجه الاستدلال به.

أن الرسوم إن كانت واردة على التكاليف والنفقات الفعلية ، فهي جائزة أما رسوم الضمان فيحرم أخذ الأجر على الضمان ، وكذا أجور الخدمات المقدمة لحامل البطاقة ، وهذه في الواقع تابعة للضمان ؛ لذا لا يجوز أخذها ؛ للقاعدة الفقهية (التابع تابع).^(٢)

الراجع :

بعد عرض أقوال العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني : القائلون بجواز أخذ رسوم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان. لأن هذا مقابل خدمات فعلية ، وذلك لرفع الحرج عن جميع الأطراف ولضمان استمرارية هذه الخدمات، ولما فيه من التوسط بين تحريم القول الأول وإطلاق الثاني. وهذا الجواز مقيد بشرطين.^(٣)

(١) البطاقات الائتمانية ، د. محمد صالح الفوزان ، www.saaaid.net

(٢) المرجع السابق، منظمة المؤتمر الإسلامي ، مجمع الفقه الإسلامي ، قرارات وتوصيات ، ٢٧.

(٣) البطاقات البنكية ، د. عبد الوهاب أبو سليمان، مجلة مجمع الفقه ع ١٠.

الشرط الأول: أن يكون المبلغ ثابتاً؛ أما جعله بنسبة مئوية تتزايد بزيادة المبلغ^(١) فيه شبهة الربا .

الشرط الثاني: أن يكون المبلغ مقابل خدمة فعلية حقيقية؛ فلا يجوز زيادة المبلغ فوق هذا.

(١) فمثلاً أن تكون النسبة ٢% فيكون على سحب الألف عشرة جنيهاً ، والألفين عشرين وهكذا ، أما المبلغ الثابت فلا يتزايد بزيادة السحب كعشرة جنيهاً على عملية السحب أياً كان المبلغ المسحوب .

العمولات التي يقطعها مصدر البطاقة من التاجر:

يترتب على العقد المبرم بين مصدر البطاقة والتاجر رسوم يحصلها البنك من التاجر.

تنقسم الرسوم إلى قسمين :

القسم الأول : رسوم مقطوعة يأخذها البنك مقابل خدمات معلومة مباحة ، ونحو ذلك، فهذه الرسوم لا خلاف في أخذها.

القسم الثاني: رسوم متعلقة في عملية البيع والشراء عن طريق بطاقات الائتمان، وذلك بخصم نسبة معينة من قسائم البيع لصالح مصدر البطاقة ، وتُعد هذه العمولة التي يأخذها البنك المصدر والتي تتراوح ما بين ٢ إلى ٥ % من قيمة الفاتورة حسب الاتفاق بينه وبين التاجر من أهم مصادر الربح للبنوك في نظام البطاقات^(١).

صورة المسألة: إذا كانت المشتريات بمائة جنية - مثلاً - علي حاملها، فإن التاجر يستوفي من البنك خمسة وتسعين جنيهاً، وخمسة جنيهاً تكون للبنك، عمولة علي التسديد عن حاملها، والترويج للتاجر وما يلزم ذلك من دعاية. فما مدى مشروعية أخذ البنك لهذه الرسوم؟^(٢)

(١) البطاقات البنكية، د. عبد الوهاب أبو سليمان، مجلة مجمع الفقه ١٠ع .

(٢) المعاملات المالية المعاصرة د. ديبان محمد ٨٦٨/١٢.

واختلف العلماء المعاصرون على حكم العمولة التي يُحصلها البنك من التاجر بنسبة معينة من فاتورة البيع ولهم في ذلك قولان:

القول الأول : العمولة التي يحصلها البنك من التاجر جائزة ذهب لذلك د. عبد الستار أبو غدة ، د. الصديق محمد الأمين الضير ، علي القري عيد ، د. نزيه حماد ، د. محمد علي داغي ، د. حسن الجواهري.^(١)

القول الثاني : العمولة التي يحصلها البنك من فاتورة التاجر غير جائزة ذهب لذلك: الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخير ، الشيخ إبراهيم الدبو ، الشيخ حمادي ، د. بكر أبو زيد، د. عبد الستار أبو غدة.^(٢)

الأدلة والمناقشة.

(١) بطاقات الائتمان، د. عبد الستار أبو غدة ، ندوة فقه بطاقات الائتمان/ البحرين - سبتمبر ١٩٨٨م ص ٢٩، مجلة المجمع، ع ١٢، مناقشات مجلة المجمع د.علي داغي ، ع ١٢ ، التكليف الشرعي لبطاقة الائتمان د.نواف باتوبارة، ص ١٧٣، ١٧٤. د. نزيه حماد قضايا فقهية معاصرة ص ١٥٣، د.حسن الجواهري، مجلة المجمع، ٦٢٠/٢/٨ .

(٢) بطاقات الائتمان ، مجلة مجمع الفقه ، ع ٨، ع ١٢، مناقشات المجمع، مجلة المجمع، ع ٨، مناقشات المجمع مجلة المجمع، ع ١٢، بطاقات الائتمان د.بكر أبوزيد ص ٥٩ .

أدلة القول الأول : المعقول، ووجه الاستدلال به .

الأول : العمولة التي يحصلها البنك من التاجر، هي أجرة السمسرة التي يقوم بها البنك للتجار لحاملي البطاقات ، وكذلك مقابل الأجهزة والنشرات والملصقات. ^(١).

ويناقش: بأن تخريج العمولة على أنها سمسرة غير مسلم؛ لأن السمسار يقوم ببيع أشياء معينة ومعروفة، ومصدر البطاقة قد لا يعلم بهذه السلع التي تباع عند التجار ، إلا إذا جاءه التاجر ببطاقات البيع ^(٢) .

الثاني : العمولة التي يحصلها البنك من التاجر من باب المصالحة على الدين ، بين مصدر البطاقة والتاجر ، بناء على ما ذكره الحنفية من جواز رجوع الضامن على المكفول بما ضمن لا بما أدى ^(٣) . ^(٤).

(١) بطاقات الائتمان، د. عبد الستار أبو غدة ، مجلة المجمع، العدد ١٢.

(٢) مناقشات مجمع الفقه الإسلامي، مجلة المجمع، العدد ١٢.

(٣) مثال ذلك : يفترض أن حامل البطاقة اشترى بقيمة ألف جنيه ثم أحال حامل البطاقة التاجر على مصدر البطاقة ، وتم الاتفاق بين المصدر والتاجر على نسبة خصم معينة، كأن تكون ٣% من قيمة الفاتورة، فيدفع المصدر للتاجر ٩٧٠ جنيهًا فقط بموجب الاتفاق ، ويحق للمصدر الرجوع على حامل البطاقة بما ضمن أي بالآلف كاملة لا بما دفعه للتاجر.

(٤) بطاقات الائتمان غير المغطاة، د. نزيه حماد ، د. محمد علي القري ، مجلة المجمع، العدد ١٢.

ويناقش: بأن هذا القياس مع الفارق؛ لأن الصورة الحاصلة بين العميل والبنك والتاجر، تختلف عن صورة رجوع الضامن على المكفول بما ضمن؛ لأن البنوك تلتزم بالدفع والأداء عن العميل قبل معرفة المال المطلوب وقبل الأجل، وبذلك تكون البنوك مقرضة، ثم تأخذ من العميل القرض الذي أدته عنه، مقابل الزيادة وهي ما خصمته من التاجر.

الثالث : العمولة التي يحصلها البنك من التاجر، عبارة عن أجر على وكالة ووساطة بين التاجر وبين حامل البطاقة، من ترويج التعامل معه ودعاية له وتأمين زبائن وتسهيل تحصيل قيمة بضائعه^(١).

أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن العمولة التي يحصلها البنك من التاجر محرمة بالمعقول ووجه الاستدلال به.

الأول : أن بنك التاجر^(٢) إذا قام بتسديد المبالغ المستحقة للتاجر حالا، ثم رجع بها على المصدر مع خصم عمولته وعمولة المصدر، فقد قام

(١) الأسئلة الموجهة إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، في بيت التمويل الكويتي، مجلة المجمع، العدد ٧ ، بطاقات الائتمان، د. عبد الستار أبو غدة ، مجلة المجمع، العدد ١٢.

(٢) بنك التاجر: الذي يقوم بمتابعة تسديد فواتير البيع للتجار مع البنوك المصدرة للبطاقة المستخدمة في عملية البيع.

بإقراض التاجر بالفائدة المثوية؛ لأنه يحصل هذه المبالغ كاملة من المصدر، والمصدر يحصلها من حامل البطاقة، فالعملية تصير قرضاً جر نفعاً، وهو حرام، وليس مجرد وكالة من التاجر^(١).

ويناقش: بأن أخذ البنك المصدر للبطاقة نسبة من ثمن البضاعة أجراً على قبول البنك ضمان الدين الذي في ذمة العميل للتاجر ، وعلى هذا فلا توجد عملية إقراض للتاجر؛ بل هي عملية إقراض للعميل^(٢).

الثاني : إن نسبة الخصم الذي يأخذها البنك من التاجر تشبه (خصم) الأوراق التجارية وخصم الأوراق التجارية محرم فتكون النسبة محرمة^(٣).

الراجع : بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم يبدو لي - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأن العمولة التي يحصلها مصدر البطاقة من التاجر جائزة وذلك لما يلي:

إما أن يكون هو نفس البنك الذي أصدر البطاقة، أولاً ، فقد يكون البنك الذي أصدر البطاقة بنكاً محلياً أو بنكاً أجنبياً في بلد آخر، وبالتالي فإن التاجر سوف يقدم فاتورة البيع إلى البنك الذي يتعامل معه، والذي بدوره يقدم هذه الأوراق إلى البنك الذي أصدر البطاقة إن كان بنكاً محلياً، ، وسوف يتقاسم بنك التاجر مع البنك المصدر للبطاقة العمولة التي تؤخذ من التاجر.

(١) بطاقات الائتمان والتكليف الفقهي لها ، د. دبيان محمد الديبان

(٢) بطاقات الائتمان ، الشيخ حسن الجواهري ، مجلة المجمع ، ٨ع.

(٣) بطاقات الائتمان ، د. محمد القرني عيد ، مجلة المجمع ، ٧ع.

١ - دفعا للخرج فالخرج مرفوع بنصوص الشريعة وهذه النسبة التي تحدد تكون مقابل الخدمات المقدمة للتاجر، والمتمثلة في تحصيل فواتير الشراء، وجذب العملاء إليه، وتسهيل تعامله معهم.

٢- أن الدعاية والترويج ، وتأمين الزبائن وتحصيل قيمة البضائع بحاجة إلى الإنفاق الكبير ، بالإضافة إلى تخصيص موظفين لتحصيل قيمة المبيعات من قبل حاملي البطاقات ، وهو جهد وخدمة تحتاج للمال.

٢- أن حقيقة عمل البنك هو الوكالة في تحصيل الدين وتوصيله، وعلى هذا فإن النسبة التي يأخذها البنك إنما هو أجره على الوكالة في تحصيل الدين وتوصيله، والوكالة بأجر جائزة .

عمولة السحب النقدي ببطاقات الائتمان:

تعريف بالسحب النقدي بالبطاقة: هو عبارة عن سحب حامل البطاقة نقودا من البنك المصدر عن طريق مكائن السحب الآلي مقابل عمولة^(١).

صورة المسألة : أن يقوم العميل بسحب مبلغ معين من رصيده ببطاقة الائتمان فيخصم من رصيده مبلغا من المال كرسوم على الخدمة، كأن يسحب حامل البطاقة ١٠٠٠ ج فيصم منه ١٠١٠ ج فالعشرة زيادة على السحب^(٢).

أنواع السحب النقدي : للسحب النقدي نوعان:

الأول: السحب اليدوي : يحصل بإبراز البطاقة لموظف البنك والحصول على النقود مناولاً ، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ أي رسوم في مقابل السحب؛ لأن ذلك يكون ربا ، فهذه الرسوم لا يقابلها تكاليف فعلية .

وأكدت فتاوى الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية على حرمة استخدام البطاقة الائتمانية في السحب اليدوي من البنوك الربوية ؛ لأن

(١) بطاقات الائتمان غير المغطاة د. نزيه حماد ع ١٢.

(٢) الموسوعة الميسرة ، المعاملات ٣٧٧/١.

هذه البنوك تحتسب فائدة ربوية عبارة عن نسبة مئوية من المبلغ المسحوب^(١) .

الثاني: السحب الآلي : وهو ما يكون عن طريق أجهزة الصراف الآلي، وهذا النوع من السحب عادةً ما يكون له تكاليف من أجهزة وصيانة واستئجار مواقع.

حكم العمولة على السحب النقدي الآلي :

اختلف العلماء المعاصرون: في حكم الرسوم المأخوذة على السحب النقدي الآلي ببطاقة الائتمان ولهم قولان في ذلك.

القول الأول : يرى من ذهب إليه عدم جواز تحصيل البنك عمولة على السحب النقدي ، وهذا قول د.محمد القري ، د. عبد الستار أبوغدة ، د. عبد الوهاب أبو سليمان^(٢) .

القول الثاني : يرى من ذهب إليه جواز السحب النقدي لقاء عمولة وللقائلين به ثلاث اتجاهات .

الاتجاه الأول : جواز أخذ الرسوم سواء كانت نسبة مئوية من المبلغ المسحوب أم كانت مبلغاً مقطوعاً^(٣) .

(١) البطاقات الائتمانية د. صالح الفوزان ، <http://www.islamfeqh.com>

(٢) مجلة المجمع : ع ١/٧ ، البطاقات الافتراضية، د. عبد الوهاب ص ١٥٧ .

الاتجاه الثاني: يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً لا نسبةً مئويةً. والمبلغ المقطوع يكون في مقابل النفقات الفعلية لعملية الإقراض ، ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية .وهو قول كثير من العلماء المعاصرين. ^(٢)

وهذا ما صدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي^(٣)، جاء في قرار الهيئة العمولة المشار إليها: هي أجر على الوكالة لقضاء الدين المترتب على العميل جرّاء سحب المبالغ في الخارج بواسطة البطاقة وهي جائزة شرعاً.

الاتجاه الثالث: يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون هناك تغطية في حساب حامل البطاقة، لوقوع المقاصة بين الدينين فوراً. ^(٤)

الأدلة والمناقشة :

(١) هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي مجلة مجمع الفقه (الوثيقة رقم ١) ع ٧ ج ١ ص ٤٧٢ ، فتوى ندوة البركة قرارات وتوصيات الندوة : ص ٢٠٦ . د.عبد الستار أبو غدة، ، مجلة المجمع ع ١/٧ ، ع ٢/١٢٠ .

(٢) د.نزيه حماد د. علي السالوس، د. أحمد بن علي سير المباركي، مجلة المجمع ع ١/٧ ، د. خالد المشيقح ، مجلة لواء الشريعة ، دروس الدورة العلمية بجامع الراجحي ببريدة لعام ١٤٢٥ هـ .

(٣) بطاقات الائتمان المصرفية والتكيف الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي إعداد مركز تطوير الخدمة المصرفية بيت التمويل الكويتي مجلة المجمع ع ١/٧ .

(٤) بطاقات الائتمان غير المغطاة، د. نزيه حماد ، ع ١٢٠ .

أدلة القول الأول المعقول وهو : أن عملية السحب قرض ، والزيادة على القرض ربا. ^(١)

ويناقد: بأن ذلك غير مسلم؛ فأى زيادة لا تعد من الربا ؛ فقد تكون الزيادة من تكلفة القرض ، فالسحب يتطلب أجهزة ، كما يتطلب إجراء اتصالات ونحو ذلك وهذا بتكاليف مالية ، أما المنفعة المحرمة هي المنفعة الزائدة المشروطة للمقرض ^(٢) .

أدلة القول الثاني : المعقول

أولاً: الاتجاه الأول: أن رسوم السحب النقدي عبارة عن أجر على الخدمة المصرفية التي يقدمها مصدر البطاقة لحامل البطاقة. ^(٣).
ويناقد : بأن حامل البطاقة قد يستخدمها في الحصول على بعض الخدمات كالاستعلام عن الرصيد ونحوه فهي كالسحب النقدي من حيث التكلفة ، وهذا يدل على ارتباط هذه الرسوم بالقرض ^(٤).
ثانياً: أدلة الاتجاه الثاني المعقول من أوجه:

(١) د. محمد علي القري ، مجلة المجمع ع ٣٩٣/١/٧.

(٢) البطاقات الائتمانية ، موقع صيد الفوائد.

(٣) هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي مجلة مجمع الفقه (الوثيقة

رقم ١) ع ٤٧٢/١/٧ .

(٤) البطاقات المصرفية ص ١٨٤.

الأول : أن أخذ رسم المالي متغير بتغير المبلغ المسحوب فيه شبهة الربا، وهذا غير متحقق في حالة كون الرسم مبلغاً مقطوعاً في كل حالة من حالات السحب .

الثاني : أن السحب النقدي من حامل البطاقة في حقيقته اقتراض من (مصدر البطاقة) ، فما يأخذه مصدر البطاقة من زيادة ربا محرم شرعاً ، ويستثنى من ذلك التكلفة الفعلية للإقراض فهي غير داخلة في المنفعة المحرمة ^(١).

ويناقش: بأن هذا العقد عقد مركب من عقدين: أحدهما: القرض، والآخر: الإجارة، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد الإجارة، فأخذ العمولة على هذا القرض من قبيل الربا المحرم. ^(٢)

أدلة الاتجاه الثالث المعقول وهو :

أن أخذ الرسوم من حامل البطاقة مقابل السحب النقدي في مقابل تقديم هذه الخدمة، هي أجرة على توصيل النقود إلى حيث يريد حامل البطاقة سحبها ^(٣).

(١) د. نزيه حماد : ع ٥٢١/٣/١٢ .

(٢) بطاقات الائتمان ، الشيخ محمد الديبان، <http://www.alukah.net>

(٣) بطاقات الائتمان غير المغطاة، د. نزيه حماد ، ع ١٢٤ .

الرأي الراجح :

بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم يبدو لي . والله أعلم . أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني - الاتجاه الثالث - وذلك لما فيه من الاحتياط والحذر من أكل الربا.

ومما تجدر الإشارة إليه : أن بعض الهيئات الشرعية رأّت أن تضع صندوقا خاصا لهذه الفوائد المحتسبة، ثم تتخلص منها في وجوه الخير.

يقول الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله - : "هذه المشكلة قد تدوركت بأن البنك الإسلامي الذي يريد أن يصدر بطاقة يشترط عليه أن ينشئ صندوقا خاصا لديه لتلك الفوائد التي تحتسب له رغما عنه، وليس بطلب منه، وتأتيه على المبالغ التي استعملت فيها البطاقة، وهذا الصندوق ما يتجمع فيه يوجه إلى جهات الخير الإسلامية شأن سائر الفوائد التي تحتسب لبعض المودعين في البنوك، ولا يريدون أن يقعوا في المحرم، فهم يصرفونها كما في فتوى المجمع الفقهي في مكة".^(١)

(١) بطاقات الائتمان ، الشيخ دبيان محمد الديان،

شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان :

صورة المسألة:

يذهب حامل بطاقة الائتمان إلى محل الحلي ، ثم يشتري الحلي الذي يرغب فيه ، وبدلاً من دفع الثمن نقداً يقدم بطاقة الائتمان للبائع لدفع ثمن الحلي ، ويقوم البائع بالتأكد من صلاحية البطاقة ، ثم يدون بعض المعلومات المتعلقة بالبطاقة.

ويوقع حامل البطاقة على السند الذي يختمه البائع ثم يعيد البائع البطاقة إلى صاحبها مع صورة من السند الذي يحتفظ بنسخة منه ، ويبعث النسخة الثالثة لمصدر البطاقة ليحصل التاجر على قيمة السند.

شروط صحة بيع النقد بمثله :

اشتراط جمهور الفقهاء^(١) لصحة بيع النقد بمثله شرطان: **الشرط الأول:** التماثل إذا اتحد الجنس كأن يكون ذهباً بذهب، إذا اختلف الجنس كبيع الذهب بالفضة، فإنه يصح البيع والشراء بالزيادة على قيمته أو بنقصها بشرط التقابض في مجلس العقد، وذلك لما روى عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: "الذهب بالذهب،

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢١٥/٥، فتح القدير ٢٥٩/٦ ، والقوانين الفقهية ص ٢٥١ ، جواهر الإكليل ١٠/٢ ، مغني المحتاج ٢٥/٢ ، المغني لابن قدامة ٤١/٤ ، كشف القناع ٢٦٦/٣.

والفضة بالفضة.. مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" (١)

فقوله ﷺ : " يدا بيد " دليل صريح على اشتراط التقابض بين البائع والمشتري قبل أن يتفرقا.

الشرط الثاني: التقابض^(٢) في مجلس العقد ، وعدم تأجيل أحد البادئين إلى وقت آخر^(٣) وذلك استدلالاً:

١ - بحديث عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلى فأخبرنى فقلت هذا أمر لا يصلح. قال قد بعته فى السوق فلم ينكر ذلك على أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبى - ﷺ - المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال " ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا " (٤).

٢ - وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله - ﷺ - قال " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الربا، باب الصرف ٤٢/٥ .
(٢) القبض في اصطلاح الفقهاء: حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد، أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه، وهو ما يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي.
(٣) بدائع الصنائع ٢١٥/٥ ، فتح القدير ٢٥٩/٦ ، والقوانين الفقهية ص ٢٥١ ، جواهر الإكليل ١٠/٢ ، مغني المحتاج ٢٥/٢ ، المغني لابن قدامة ٤١/٤ ، كشف القناع ٢٦٦/٣ .

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الربا، باب النهي عن بيع الورق، ٤٢/٥.

تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
ولا تبيعوا منها غائباً بناجز^(١).

والإجماع قال ابن المنذر : (وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم
أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف^(٢) فاسد^(٣)).

حكم شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان :

اختلف العلماء المعاصرون في حكم استخدام بطاقة الائتمان
لشراء النقدين ولهم في ذلك ثلاثة أقوال.

القول الأول : يصح استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين لا فرق
بين كون البطاقة مغطاة، أو ليست مغطاة ذهب لذلك د. عبد الستار

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الربا، باب النهي عن بيع الورق ٤٢/٥.

(٢) الصرف : في اللغة يقال: صرفت الدراهم بالدنانير. وبين الدرهمين صرف، أي
زيادة ومنه سميت العبادة النافلة صرفاً ، يأتي الصرف بمعنى التحويل، قال
تعالى: (وتصرف الرياح) [البقرة: ١٦٤]

وفي الاصطلاح: مبادلة الأثمان بعضها ببعض. أي بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو
بغير جنس: أي بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة،
مصوغاً أو نقداً. بدائع الصنائع ٢١٥/٥. وفي الاقتصاد: مبادلة عملة وطنية
بعملة أجنبية.

(٣) الإجماع ص ٧٩.

أبو غدة، د.نزيه حماد، د. يوسف الشبيلي ^(١) وبه صدرت فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

القول الثاني : لا يصح استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة ذهب لذلك الشيخ عبد الرحمن بن عقيل، الشيخ المختار السلامي ، الشيخ عبد الرحمن السحيم ، الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير. ^(٢)

القول الثالث : يصح استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين إذا كانت البطاقة مغطاة ذهب لذلك د. محمد عثمان شبير، د. وهبة الزحيلي، د.عبد الستار أبو غدة ^(٣)

(١) بطاقات الائتمان مجلة المجمع ع٦٦٣/١/٧، ع١٢، قضايا فقهية معاصرة د. نزيه حماد ص ١٦٠.

(٢) مناقشات بطاقات الائتمان ، مجلة المجمع، ع١٢

<http://al-ershaad.com>

(٣) بطاقات الائتمان د. وهبة مصطفى الزحيلي، ع٢٧/٣/١٥، ٦، ١١: ٣-٢٠٠٤م . مسقط سلطنة عُمان، ، المعاملات المالية المعاصرة ، دار الفكر، ٥٤٥ ،

المعاملات المالية المعاصرة ، د.محمد عثمان شبير ، دار النفائس، ص١٩٣ ، بطاقات الائتمان تصورها والحكم عليها د. عبد الستار أبو غدة ع٢/١٢. ،البند

(٤) من قرار رقم ١٠٨ المتخذ في دورته الثانية عشرة في الرياض التي انعقدت

في الفترة من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى ١ رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢٣ -

٢٨ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٠

سبب الخلاف :

يرجع سبب الخلاف بين العلماء المعاصرين إلى أمرين:

الأول: اختلافهم في ماهية القبض هل مجرد قبول الجهاز للبطاقة ، وتوقيع العميل على عملية الشراء يعد قبضاً حقيقياً أم لا؟^(١)

الثاني: الشراء ببطاقة الائتمان هل يعد من قبيل الصرف أم لا .

الأدلة والمناقشة :

أدلة القول الأول: استدل القائلون بجواز شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقاً مغطاة أم لا بالمعقول، وذلك من وجهين:

الأول : أن تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة يعد قبض حكي، كقبض الشيك ، وقد ذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى القول بأن الشيك إذا كان محرراً من قبل البنك، فإنه يقوم مقام قبض محتواه^(٢)، وصدر قرار مجمع

(١) والذي يجري في واقع البنوك أن عمليات البيع والشراء ببطاقات الصرف الإلكتروني، والبطاقات الائتمانية المقاصة آلياً من البنوك في نهاية اليوم، وبالتالي لا يدخل المبلغ في حساب التاجر إلا بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، فهل يعد هذا امتداداً لمجلس العقد حتى يعتبر قبضاً حكماً؟ التقابض في الفقه الإسلامي ، مجلة المجمع ع٤٥٩/١/٧ .

(٢) (البطاقة الائتمانية د. يوسف الشبيلي، مجلة المجمع ع١٢ .

الفقه الإسلامي) بجواز شراء الذهب والفضة بالشيك على أن
يتم التقابض في المجلس).^(١)

ويناقد: بأن الشيك أداة وفاء في الحال، فيكون قبضه قبضا حكما
لمحتواه، وبطاقة الائتمان أداة وفاء في المستقبل؛ لأن التاجر لا
يستطيع أن يحصل على ثمن الذهب الذي اشتري بها إلا بعد فترة
من الزمن.^(٢)

الثاني : أن التاجر عند تمرير البطاقة على الجهاز الآلي، يقوم على
الفور بقراءة شريط المعلومات فيها، وتوصيل هذه المعلومات
إلى الحاسب الآلي في البنك المصدر ، الذي يتولى قيد المبلغ
على حساب العميل ، وتحويل المبلغ إلى حساب التاجر.^(٣)

(١) قرار رقم ٨٤ (٩/١) بشأن تجارة الذهب (الدورة التاسعة - أبو
ظبي/أبريل ١٩٩٥م)، التقابض في الفقه الإسلامي د. علاء الدين عبد الرزاق
ص ٢٧٠.

(٢) بطاقة الائتمان الشيخ الصديق محمد الضرير ، مجلة المجمع ع ٢١ .

(٣) التكيف الشرعي لبطاقة الائتمان لنواف باتويارة ، ص ١٨٦ ، بطاقة الائتمان د.
يوسف الشبيلي، مجلة المجمع ع ١٢ .

أدلة القول الثاني : السنة والمعقول

أما السنة : فعن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).^(١)

وجه الدلالة: دل الحديث على أن التقابض الفوري في النقيدين شرط، وإن كل تأخير في أحد البديلين مخالف لنص الحديث ؛ فيكون استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقيدين غير جائز.^(٢)

ويناقش :

بأن قوله ﷺ : (يداً بيد) لا يدل على اشتراط القبض باليد ، وإنما المقصود أن يتم القبض الحكمي في المجلس.^(٣)

أما المعقول فوجه الاستدلال به :

أن شرط القبض المأمور به شرعاً غير متحقق؛ فإن التقابض شرط في شراء الذهب والفضة، وتسديده بواسطة البطاقة لا يتم في الحال.^(٤)

(١) سبق تخريجه.

(٢) مناقشات بطاقات الائتمان، الشيخ عبد الرحمن بن عقيـل، مجلة المجمع ع١٢٤.

(٣) القبض وصوره ، وبخاصة المستجدة منها ، وأحكامها، د. علي محيي الدين القره داغي، مجلة المجمع ع٦٤.

(٤) مناقشات بطاقات الائتمان ، الشيخ المختار السلامي ، مجلة المجمع ع١٢٤.

ويناقش :

بأن القسيمة تصرف فوراً حال تقديمها إلى البنك المصدر للبطاقة.

وأجيب :

بأن شرط التقابض في المجلس لا يكون متحققاً؛ لأن حامل البطاقة عندما يقدم البطاقة للتاجر يتسلم الذهب، ويوقع على القسيمة، ولا يدفع الثمن للتاجر، والذي يدفع الثمن للتاجر هو البنك المصدر للبطاقة عندما يقدم التاجر إليه القسيمة بعد فترة يتفق عليها^(١). أدلة القول الثالث: المعقول ووجه الاستدلال به.

أن الشراء بالبطاقة المغطاة فيه تقابض حكمي معتبر شرعاً، إذا دفع البنك المصدر المبلغ إلى التاجر بدون أجل، على أنه وكيل للمشتري^(٢).

أما شراء الذهب ببطاقة الائتمان غير المغطاة؛ فلا يجوز ؛ لعدم تحقق القبض في مجلس العقد.

(١) مناقشات بطاقات الائتمان ، الشيخ الصديق محمد الضير ، مجلة المجمع ، ١٢٤ .

(٢) بطاقات الائتمان، الدورة الخامسة عشرة: ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م . مسقط سلطنة عُمان، الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي

فإن قيل: إن وجود فاتورة الدفع الموقعة من قبل حامل البطاقة قبض حكمي.

أجيب: بأن التاجر بهذه القسيمة ضمن حقه فقط، ولم يقبض المال، إنما يقبضه بعد فترة، وضمان الحق لا يعني القبض.

ويرد : التفريق بين أن تكون البطاقة مغطاة أو غير مغطاة، هذا لا تأثير له في حقيقة القبض، فالبنك لم يكن مجرد كفيل في هذه المعاملة، بل هو كفيل ووكيل بالدفع، وخضم المبلغ لمصلحة البائع، لا يختلف بين أن يكون الرصيد مغطى أم لا ^(١).

الراجع :

بعد عرض أقوال العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن القول
الراجع هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بجواز شراء
الذهب ببطاقة الائتمان مطلقا مغطاة أم لا ، وذلك لما يلي:

أولا: أن القبض ببطاقة الائتمان قبض حكمي صحيح ، لأن القبض
هو إثبات اليد، والقبض يستند في كثير من أحكامه إلى العرف.

ثانيا: أن البطاقة الائتمانية أصبح لها من القبول عند الناس ما يفوق
الأوراق النقدية والتجارية.

(١) بطاقات الائتمان ، الشيخ محمد الديان، <http://www.alukah.net>

البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان غير المغطاة:

اقترح العلماء المعاصرون بديل شرعي يحقق ما تحققه بطاقات الائتمان لحاملها ولمصدرها ؛ والغرض من ذلك:

- ١- اجتناب المحظور في المعاملة، وتنقيتها من المحاذير الشرعية
- ٢- الدعوة إلى إيجاد حلٍ ، بعيداً عن التبعية الأجنبية .
- ٣- محاولة تحويل هذه المعاملة من القرض بفائدة إلى معاملة معاصرة أبحاثها بعض الهيئات الشرعية: كالبيع بالتقسيط، أو تطور الصيغة المقترحة إلى المرابحة للأمر بالشراء، أو تطور أكثر إلى التورق المنظم .

وبيان هذه البدائل على النحو التالي:

أولاً : بطاقة البيع بالتقسيط : بأن ينشئ البنك الإسلامي متاجر للبيع بالتقسيط على الانفراد أو المشاركة ، ويستفيد من ربح البيع، والفارق بين البيع الحال والمقسط .^(١) وهذا البديل لا يصلح في الحصول على النقود (السحب الآلي) .^(٢)

(١) العقود المالية المركبة، للعمرائي، ص ٣٧٧ ، مجلة البحوث الفقهية ع ١٤ / ١٩٨ .

(٢) بطاقات الائتمان د. الصديق الضير ، مجلة المجمع ع ١٢ .

ثانياً: بطاقة المرابحة للآمر بالشراء: بأن يوكل البنك العميل بأن يشتري ويقبض عنه، ويسدد البنك، ثم يبيع على العميل بزيادة.^(١)

وهذا البديل لا يسهم في توفير خدمات كثيرة؛ كخدمات المطاعم والفنادق؛ حيث أن العميل ينتفع بالخدمة قبل السداد.^(٢)

ثالثاً : بطاقة (الخصم) الشهري : وهي البطاقة التي تصدرها المصارف الإسلامية على أن يتم تحديد قيمة المسحوبات بالبطاقة بمقدار الراتب الشهري ، على ألا يستوفي المصرف أي فائدة بنكية على ذلك.

فتقوم على أساس الوكالة إذا كان حساب العميل يفي بجميع المبلغ الذي تم سحبه عن طريق بطاقة الائتمان.، أما إذا كان حساب العميل لا يفي بالمبلغ، فإن المصرف يقوم بتسديده على أساس القرض الحسن الذي يقدمه المصرف لعميله، بضمان الراتب الشهري ، وهذا مشروع ومندوب إليه.^(٣)

(١) وقد طرحه د. وهبة الزحيلي، ومحمد القري، مجلة المجمع، العدد ١٢، (٦٣٣/٣) .

(٢) بطاقات الائتمان ،د. وهبة الزحيلي ، الدورة الخامسة عشرة ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م . مسقط (سلطنة عُمان)، محمد القري بن عيد ، مجلة المجمع ع٦/٣/٦٣٣ .

(٣) بطاقات الائتمان ،د. وهبة الزحيلي ، الدورة الخامسة عشرة ٦: ١١-٣-٢٠٠٤م . مسقط (سلطنة عُمان).

رابعاً : تجديد الدين عن طريق التورق^(١) المصرفي^(٢): حيث يأخذ العميل مبلغاً يسدد عن طريقه مديونية البطاقة، ويسدد للمصرف مديونية التورق.^(٣) في حالة تأخر العميل عن السداد، يقوم البنك ببيع سلعة بثمن أكبر من المديونية على العميل، ثم يبيعها عنه لطرف آخر (غير المشتري منه)، ويسدد القرض الأول، ويجدول الدين الثاني الأكثر إلى أقساط جديدة.^(٤)

وهذه البدائل لم تسلم من الخلل من الجهة الشرعية، ومن عدم القدرة على تلبية احتياجات أطراف البطاقة في الواقع العملي.

(١) التورق في اللغة: التورق طلب الورق أي الدراهم. مختار الصحاح ٢٩٩. وفي الاصطلاح الفقهي لم يذكر الفقهاء تعريفاً للتورق، وإن كان هذا المصطلح قد شاع عند الحنابلة ويراد به: أن يشتري المرء السلعة نسيئة، ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد. الانصاف ١٩/١١.

(٢) التورق المصرفي : اتجهت كثير من المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إلى التعامل بالتورق المصرفي المنظم، كبديل شرعي للقرض الربوي الذي تقدمه البنوك التقليدية. التورق المصرفي وتطبيقاته:

<http://www.alukah.net/>

(٣) بطاقة الائتمان المتجدد .. البدائل الشرعية، عثمان ظهير ، مجلة المجمع ١٥ع، ١٠٨/٣ . <http://muntada.islammessage.com>

(٤) وقد نوقش في المجمع، العدد ١٥، ١٠٨/٣.

ويوجد الآن أنموذجين لبطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية وهما^(١):

الأول :- فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي بهذا الاسم.

الثاني :- فيزا الراجحي التي أصدرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

ملخص الموضوع :

- ١- عرف علماء مجمع الفقه الإسلامي بأنها: بطاقات الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع.
- ٢- تحقق بطاقات الائتمان منافع لمصدرها وحاملها والتاجر .
- ٣- بطاقة الائتمان لها أثر إيجابي وآخر سلبي على الفرد والمجتمع وعلى الفرد الموازنة بين المصالح والمفاسد .
- ٤- لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

(١) بطاقات الائتمان، د. وهبة الزحيلي، الدورة الخامسة عشرة ١١: ٦-٣-٢٠١٤م. مسقط (سلطنة عُمان).

٥- يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

٦- جواز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد إذا كان أجرا فعليا على الخدمات المقدمة منه.

٧- جواز أخذ مصدر البطاقة من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة هو السعر الذي يبيع به بالنقد.

٨- السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيل ذلك الرسوم المقطوعة، وكل زيادة علي الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا.

٩- لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

١٠- اجتهد العلماء في إيجاد بدائل الشرعية للمحاذير التي ترد في بطاقات الائتمان.

نماذج أسئلة :

س ١: اذكر أطراف بطاقة الائتمان ،مع بيان المنافع التي تقدمها بطاقة الائتمان لحاملها، والجهات المصدرة لها.

س ٢ : بين حكم العمولة التي يأخذها مصدر البطاقة من حاملها مقابل السحب النقدي، مع بيان أنواعه.

س ٣ : وضح الحكم فيما يأتي مع التعليل

- ١ - العمولة التي يأخذها البنك من حامل البطاقة على السحب النقدي
- ٢ - اشتراط مصدر البطاقة عند إصدارها أن له الحق في إلغائها.

س ٤ : أكمل مكان النقط :

١ - يتولى إصدار بطاقات الائتمان العالمية جهتان رئيسيتان هما
.....،.....

٢ - من المنافع التي تقدمها بطاقة الائتمان لحاملها.....،.....،.....

٣ -تخرج العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر على أنها.....،.....،.....

القسم الثالث

الشرط الجزائي (غرامات التأخير)

ويحتوي على وحدتين :

مقدمة :

لم يدون مصطلح الشرط الجزائي في كتب الفقهاء المتقدمين لعدم قيام الحاجة إليه في ذلك الوقت، لكن في هذا الزمن أصبحت الحاجة إليه ملحة جدًا؛ لأن تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته في مواعيدها المشروطة مضر بالطرف الآخر في وقته وماله أكثر مما كان عليه في الزمن الماضي.

وهذا الموضوع يلقي الضوء على التعريف بالشرط الجزائي والتكييف الشرعي له ، وأنواعه وحكم كل نوع .

الوحدة الأولى

تعريف الشرط الجزائي، والعوامل التي ساعدت على العمل به، وصورة

المعلومات والمفاهيم:

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة قادرا على:

- ١ - ذكر أقوال العلماء في الشرط الجزائي.
- ٢ - فهم العوامل التي ساعدت على العمل بالشرط الجزائي.
- ٣ - اكتساب الطالب ملكة قياس الفروع على الأصول.
- ٤ - يترسخ لديه مبدأ إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر.
- ٥ - إجابة استخدام الوسائل الحديثة في استقصاء آراء المعاصرين في الشرط الجزائي.
- ٦ - استشعار وجوب الاجتهاد في بيان الحكم الشرعي لهذه القضايا المعاصرة.

تعريف الشرط الجزائي :

أولاً : تعريف الشرط وأقسامه، وبيان معنى الجزاء.

تعريف الشرط :

لغة : إلزام الشيء والتزامه ، والجمع شروط ، والشرط بالتحريك : العلامة.

قال الفيروز آبادي هو: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، وجمع الشرط الشروط، وجمع الشريطة: الشرائط. (١)

الشرط في اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لذاته. (٢)

تقسيم الشروط من حيث الحكم

تنقسم الشروط من حيث الحكم إلى قسمين:

الأول: الشرط الصحيح: (٣) وينقسم إلى ثلاثة أقسام.

أحدهما : شرط يقتضيه العقد. بأن كان لهذا الشرط أثر في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد، كاشتراط تسليم المعقود عليه، أو رده

(١) لسان العرب مادة شرط، القاموس المحيط، ص ٨٦٩.

(٢) حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٢٠ .

(٣) الموافقات، الشاطبي، ١/ ٢٨٣ - ٢٨٥ .

بالعيب علي صاحبه، و نحو ذلك فهذا الشرط صحيح ، ويجب الوفاء بمقتضاه، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء.

الثاني : شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة مباحة في المعقود عليه فهذا الشرط صحيح باتفاق الفقهاء.

الثالث : شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافياً فإن الفقهاء اختلفوا في حكم العقد مع هذا الشرط فمنهم من يري عدم صحة العقد والشرط في هذه الحالة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأن هذا الشرط مفسد للعقد من يري صحة العقد مع الشرط الذي اقترن به ^(١).

الثاني : الشرط الباطل: وهو الشرط الذي لا يقتضيه العقد، بل هو أمر زائد عليه، ولا يلائمه ولا وَرَدَ به نص، ولا جرى بع عرف، ولا منفعة فيه لأحد ^(٢).

ثانياً:تعريف الجزاء :

وهو المكافأة على الشيء ، جزاه به وعليه جزاء ، والجزاء يكون ثواباً ويكون عقاباً ويستعمل في الخير والشر ^(٣).

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع ٥ ، الشروط المقترنة بالعقد ، د. عبد الفتاح

إدريس. <http://massai.ahram.org.eg>

(٢) المذهب، الشيرازي، ١/٤٠٤ .

ثالثا : تعريف الشرط الجزائي باعتباره مركبا إضافيا.

مصطلح الشرط الجزائي من المصطلحات المعاصرة التي لم يرد ذكره عند الفقهاء القدامى ، وقد أخذت قوانين البلاد العربية هذا التعبير عن القوانين الغربية ، وأدخلت عليه بعض التعديلات.^(١)

ويعرف بأنه : اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم التنفيذ، أو التأخير فيه"^(٢)

وعرفه علماء المجمع الفقهي: بأنه اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه، من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه.^(٣)

(١) لسان العرب ١/٢٤٣ .

(٢) الشرط الجزائي د. محمد الأمين الضرير ، مجلة مجمع الفقه ع ١٢/٤٩١ .

(٣) النظرية العامة للالتزامات، الأحكام، د.عبدالمنعم البدرابي ، ص ٨٠ .

(٤) مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، قرار رقم ١٠٩ (١٢/٣)

صور الشرط الجزائي وشروطه

أولاً : صور الشرط الجزائي:

ذكر الدكتور السنهوري صوراً للشرط الجزائي، ومنها :

١ - المقابلة : شروط المقابلة قد تتضمن شرطاً جزائياً يلزم المقاتل بدفع مبلغ معين عن كل يوم أو أسبوع يتأخر فيه المقاتل عن تسليم العمل .

٢ - لائحة المصانع قد تتضمن شروطاً جزائية ، تقضي بخصم مبالغ معينة من أجرة العامل ، جزاء له على الإخلال بالتزاماته المختلفة.

٤ - اشتراط حلول جميع أقساط الدين إذا تأخر المدين في دفع قسط منها.^(١)

ثانياً :العوامل التي أدت إلى العمل بالشرط الجزائي:

ساعد على العمل بالشرط الجزائي عدة عوامل منها:

- ١ - تطور أساليب التجارة الداخلية والصنائع.
- ٢ - أصبحت القيمة المالية للمشاريع كبيرة جداً مما يضاعف الخسائر عند التأخر ، أو الإخلال بالعقد حيث تكون الخسائر فادحة.

(١) الوسيط القسم الثاني نظرية الالتزام ص ٨٥٢ ف ٤٧٧ .

٣- اتساع دائرة التجارة بين الأفراد والدول حيث أصبحت العقود تتم بين ناس بعيدين لا يعرفون بعضهم مما يزيد الحاجة إلى وجود شروط جزائية تعطي المشتري طمأنينة إلى التزام الطرف الآخر بالعقد وأنه سيحصل على التعويض المناسب عند الإخلال .

٤- ظهور عدد كبير من العقود والحقوق الجديدة كعقود الامتياز ، والاستصناع الحديثة ، والنقل الجوي والبحري والتوريد ، والمقاولات وغيرها مما يحتاج معه إلى تضمين العقود شروطاً جزائية.

٥- أن المماثلة أصبحت سمة كثير من الناس بحيث لم يعد المتعاقدان يطمئنان إلى بعضهم البعض^(١) .

ثالثاً: شروط تطبيق الشرط الجزائي:

يشترط لتطبيق الشرط الجزائي شروط منها:

١- ثبوت الضرر^(٢) : فالتعويض المستحق بسبب الشرط الجزائي لا يكون إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر .

(١) الشرط الجزائي د. محمد بن عبد العزيز اليمني ، رسالة ماجستير ، جامعة الإمام محمد ، السعودية ص ٢٦/٢٧ .

(٢) جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي في البند الخامس الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاتته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي.

٢- ألا يكون في الشرط الجزائي مبالغة ، فإذا كان الشرط الجزائي مبالغاً فيه بالنسبة لقيمة الالتزام الأصلي ، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من قيمة الالتزام الأصلي .

٣- ارتكاب المدين خطأ أو غشاً جسيماً تسبب في ضرر ويتمثل الخطأ في عدم تنفيذ الالتزام ، أو التأخير فيه أو تنفيذه معيباً^(١) .

٤- إغذار المدين^(٢): أي التنبيه عليه بالتنفيذ.

رابعاً: الأحوال التي لا ينفذ فيها الشرط الجزائي، وهي كما يلي:

١- إذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فلا يعمل به ، ويرجع في تقدير الضرر إلى أهل الخبرة والشأن في ذلك ، ولا بد من مراعاة قواعد العدل ورفع الضرر عن الناس، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار) .^(٣)

٢- إذا كان هنالك عذر في الإخلال بالالتزام فيكون العذر الشرعي مسقطاً لوجوبه حتى يزول العذر .

(١) الشرط الجزائي ، د. محمداتي شبيها العين ، مجلة مجمع الفقه ع ١٢ .

(٢) ماهية الإغذار : دعوة يوجهها الدائن للمدين تتضمن مطالبته بتنفيذ التزامه فوراً بحيث يعد المدين متأخراً بعد هذه الدعوى.

(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه، ٧٨٤/٢ ، وقال البوصيري في الزوائد (حديث عبادة بن الصامت إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع .

وهذا ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء جاء فيه ما نصه : "أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول.

وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى : { وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } (سورة النساء : الآية ٥٨). وقوله سبحانه : { وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ } (سورة المائدة : الآية ٨) وبقوله ﷺ " لا ضرر ولا ضرار .

الوحدة الثانية

التكييف الفقهي للشرط الجزائي وذكر أنواعه وحكمه

المعلومات والمفاهيم :

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على :

- ١ - إدراك التكييف الفقهي للشرط الجزائي.
- ٢ - يفرق بين الشرط الجزائي في الأعمال والديون.
- ٣ - الافتخار بشمول أحكام الشريعة لهذه القضايا مع حدوثها.
- ٤ - الاعتزاز بشمولية أحكامها لكل المستجدات.

التكييف الفقهي للشرط الجزائي:

اختلف العلماء المعاصرون في التكييف الفقهي للشرط الجزائي ولهم في ذلك اتجاهان:-

الاتجاه الأول: الشرط الجزائي من العقود المسماة له ما يشبهه في الفقه فيخرج عليه ولهم في ذلك تخريجان .

التخريج الأول: أن الشرط الجزائي شبيه بالعربون.^(١)

التخريج الثاني: الشرط الجزائي شبيه بالرهن.^(٢)

الاتجاه الثاني: الشرط الجزائي ليس من العقود المسماة فهو معاملة مستجدة ليس لها ما يشبهها في الفقه^(٣) وبيان ذلك على النحو التالي.

أولا : أدلة الاتجاه الأول:

التخريج الأول :الشرط الجزائي شبيه بالعربون.^(٤)

(١) الوسيط للسنهوري: ٩٠/٤ ، اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الشرط الجزائي مجلة البحوث الإسلامية ع ٢ ص ١٣٨ والمدخل الفقهي د. الزرقا ١/٥٦٥ - ٥٦٦ .

(٢) قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة القرار رقم ٢٥ ، تاريخ ١٣٩٤/٨/٢١ .

(٣) الشرط الجزائي ، د. محمد الضير ، مجلة مجمع الفقه ١٢٤ .

(٤) تعريف العربون : لغة : بفتح العين والراء هو: أن يشتري الرجل شيئا أو يستأجره ويعطى بعض الثمن أو الأجرة ثم يقول إن تمّ العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منك، وسمى بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة

وجه الشبه بين الشرط الجزائي والعربون من وجهين:

الأول: أن كلا منهما تقدير للتعويض ، فالشرط الجزائي تقدير للتعويض في حالة الإخلال بالعقد ، والعربون تقدير للتعويض في حالة العدول عن العقد .

ويناقش :

فساد لئلا يملكه باشرائه. المصباح المنير ٤٠١/٢ شرعا: لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

صوره : ذكر الفقهاء لبيع العربون صورتان.

الأولى : وهي أن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال على أنه إن أمضى البيع احتسبه من الثمن، وإن لم يمضه أخذ ما دفعه فهذا بيع صحيح والضرر الذي فيه مغتفر .

الثانية : أن يشتري الرجل شيئاً فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئاً على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة وإن لم ينفذ ترك المشتري ذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به. وللفقهاء في هذه الصورة قولان القول الأول : عدم صحة البيع ذهب لذلك جمهور الفقهاء ومنهم المالكية ، والشافعية ، وأبو الخطاب من الحنابلة ، والزيدية ووافقهم بعض العلماء المعاصرين. القول الثاني: جواز هذه الصورة من بيع العربون وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ورجح العمل به من المعاصرين د.مصطفى الزرقا ، د. السنهوري د. وهبة الزحيلي، والراجح القول الثاني وذلك: لما في ذلك من تحقيق مصالح العباد وخاصة أنه لم يثبت النهي عن بيع العربون عن الرسول ﷺ ، وعملا بالعرف. بداية المجتهد ١٦٣/٢ نهاية المحتاج ٤٧٦/٣، الفروع ٦٢/٤، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، ط(٤) ، ٢٠٠٤م ، ٣٤٣٥/٥ .

بأن قياس الشرط الجزائي على بيع العربون قياس مع الفارق،

والفرق بين الشرط الجزائي وبيع العربون ما يلي :

أولاً : العربون هو المقابل لحق عدول المشتري عن العقد ، أما الشرط الجزائي فهو تعويض عن ضرر وقع فعلاً .

ثانياً : العربون يدفع عند عدول المشتري ولو لم يترتب على العدول ضرر ؛ لأنه مقابل العدول ، أما الشرط الجزائي فلا يستحق إلا إذا وقع ضرر عظمى على الدائن ، لأنه تقدير للتعويض عن الضرر .

ثالثاً : العربون لا يجوز تعديله من القاضي ، والشرط الجزائي يجوز تخفيضه وزيادته حتى يكون متناسباً مع الضرر .^(١)

الثاني : أن الشرط الجزائي يشبه بيع العربون في أن كلا منهما يوجب على من أخل بالشرط عقوبة مالية.^(٢)

ويناقش :

(١) الشرط الجزائي ، د. محمد الضير ٤٩١/١٢ الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله ص ١٨٩ .

(٢) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نقلاً عن الشرط الجزائي د. الضير ، مجلة المجمع ع ١٢ .

بأن هذا القول إذا صح بالنسبة للعربون؛ فإنه لا يصح بالنسبة للشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي ليس عقوبة، وإنما هو تقدير للتعويض^(١).

التخريج الثاني: الشرط الجزائي شبيه بالرهن.^(٢)

وجه الشبه بين الشرط الجزائي والرهن: أن الرهن والشرط الجزائي يؤكدان موجب العقد ولا يستقلان عنه؛ لأنهما تابعان.

ويناقدش :

بأن كون الشرط الجزائي من مصلحة العقد لا نزاع فيه، ولكن تشبيهه بالرهن غير مسلم؛ لأن الرهن ليس فيه تعويض عن ضرر.^(٣) فظهر أن القياس مع الفارق من عدة أوجه وبيانها على النحو التالي:

(١) الشرط الجزائي د. الضرير، مجلة المجمع ١٢ع.

(٢) الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، والرهن والمُراهنة المُخاطرة، ويأتي بمعنى الحبس يقال هذا رهنك أي دائم محبوس عليك. شرعا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء حكمه: الرهن مشروع وثبتت مشروعيته بقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة} سورة البقرة ٢٨٣ وأن النبي ﷺ: (اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد) أخرجه البخاري في صحيحه، باب شراء النبي ٧٢٩/٢ برقم ١٩٦٢. وقد أجمعت الأمة على مشروعية الرهن، وتعاملت به من لدن عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا، ولم ينكره أحد وحكى ابن قدامة الإجماع فقال: (لا نعلم خلافا في ذلك، لأنه وثيقة بدين) لسان العرب ١٨٨/١٣. نهاية المحتاج ٢٣٣/٤، المغني ٣٦٢/٤.

أولاً: الشرط الجزائي تعويض عن الضرر فهو مرتبط بوقوع الضرر ،
خلافًا للرهن الذي لا علاقة له بالتعويض بالضرر .

ثانياً : أن الرهن عين يستوفى منها الدين أو من ثمنها ، بينما الشرط
الجزائي في غالب الأمر مبلغ مقدر مسبقاً .

ثالثاً: أن الرهن عين معلومة مقبوضة قبل المماطلة في السداد ،
والشرط الجزائي ليس متقدماً بل ظهوره يكون عند الإخلال
بالعقد.^(٢)

وبهذا يظهر أن لا يمكن تكييف الشرط الجزائي كعقد رهن.

(١) الشرط الجزائي د. محمد الضير ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ع ١٢.

(٢) الشرط الجزائي وأثره ، د. محمد بن عبد العزيز اليماني ، جامعة الإمام محمد بن
سعود ، المملكة العربية السعودية ، ١٤٢٥-١٤٢٦ ، ص ١٤٧ .

أدلة الاتجاه الثاني : الشرط الجزائي معاملة مستجدة .^(١)

وجه كون الشرط الجزائي معاملة مستحدثة:

أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ، ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه.

قال ابن القيم: (الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح، فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله،... فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم^(٢).

الراجع في تخريج الشرط الجزائي :

بعد عرض أقوال العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن الشرط الجزائي معاملة مستحدثة وذلك لما يلي:

أولاً: أن الشرط الجزائي إن وجد بينه وبين بعض العقود وجه شبه ، فإنها أوجه شبه ظاهرية لا يمكن تكيف الشرط الجزائي عليها.

(١) الشرط الجزائي د. الضير ، مجلة المجمع ع ١٢ ، الشرط الجزائي وأثره ،

د. محمد اليميني ، ص ١٥٩.

(٢) إعلام الموقعين ١/ ٣٤٤ .

ثانياً: أن الشرط الجزائي من المعاملات ، والمعاملات (الأصل فيها الإباحة) فيباح التعامل به؛ لأن الشروط الجزائية تعتبر من مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له ، وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد ، وسبب من أسباب الحث على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } سورة المائدة : الآية(١)

أنواع الشرط الجزائي وحكمه:

الشرط الجزائي نوعان:

الأول : نوع على التأخير في العمل والتتفيذ.

الثاني نوع على الديون.

وبيان ذلك على النحو التالي:

أولاً: الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال وحكمه

صور الشرط الجزائي على تأخير الأعمال من أهمها^(١) :

١ - عقد الاستصناع: ^(٢) يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً

جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان.

(١) مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السابع بالقرار رقم ٧/٣/٦٥ ،

مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة القرار رقم ٦/٢/٥١ ، في

قرارات المجمع رقم (٤٠-٤١) في دورة مؤتمره الخامس (١٩٩٨م).

(٢) الاستصناع في اللغة: طلبُ صنْعِ الشيء وعملهُ لأنه غير موجود. لسان العرب

مادة صنع .وهو في الاصطلاح الفقهي: عقد على مبيع في الذمة يُطلب عمله.

بدائع الصنائع ٢/٥ وعقد الاستصناع مما انفرد الحنفية في القول به، وفي

تسميته " الفقهية " ، وميزوه عن عقد السلم في كون الشيء مستصنعاً من آدمي

كالأواني، والأسلحة، والأحذية، لا كونه موجوداً بخلق الله تعالى وإيجاده

كالحبوب.

٢- عقد البيع : إذا كان المبيع عينا له منفعة كالعقارات والآلات ، فيجوز للمشتري أن يشترط على البائع إذا لم يسلم المبيع في الوقت المحدد ، فعليه كذا عن كل يوم تأخير .

٣- الاعتماد المستندي : تشترط المصارف إذا ألغى العميل استيراد البضاعة ، وقد فتح له البنك اعتمادا وفي حالة الإلغاء أن يتحمل العميل تكاليف فتح الاعتماد .

٤- عقد الشركة والإجارة : إذا أخل الشريك أو الأجير في استمرارية العقد واشترط المؤجر عليه شرطا جزائيا وجب الشرط الجزائي على المشروط عليه إذا لحق الشرط ضررا .

٥- عقود التوريد : وذلك بتقديم المواد الأولية للمصانع كالحبوب الغذائية للمصانع الغذائية ، ولوازم الدوائر الحكومية والشركات والمعامل والمدارس والملابس العسكرية للتكنات . . . ، يجوز الشرط الجزائي على المشروط عليه إذا لحق الشرط ضررا فعليا بسبب إخلال أو إهمال المشروط عليه .

٦- عقود النقل وعقود العمل ما دام الشرط لا يخالف الشرع ، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا .^(١)

(١) الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، إعداد الدكتور ناجي شفيق عجم، جامعة الملك عبد العزيز - جدة، مجلة المجمع ع١٢٠١٢.

٧- الشرط الجزائي المقترن بعقد المقاوله، المتضمن دفع مبلغ محدد عن كل يوم، أو شهر من التأخير عن الموعد المحدد للتنفيذ والتسليم.

ب- حكم الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال.

اختلف العلماء المعاصرون في حكمه ولهم في ذلك قولان.

القول الأول : يرى من ذهب إليه جواز الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال ذهب لذلك بعض من العلماء المعاصرين وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المنعقدة ما بين ٥- ٢٢/٨/١٣٩٤، قرار دار الإفتاء المصرية ، فتوى الهيئة الشرعية لبیت التمويل الكويتي ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي. ^(١)

القول الثاني : يرى من ذهب إليه عدم جواز الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال ذهب لذلك بعض من العلماء المعاصرين. ^(٢)

(١) قرار هيئة كبار العلماء قرار رقم (٢٥) بتاريخ ٢١/٨/١٣٩٤ هـ .

(٢) الشرط الجزائي د. السالوس مجلة مجمع الفقه ٥٢٧/١٢ع ، الشرط الجزائي مجلة مجمع الفقه د. التسخيرى ٨١/١٢ع ، أحكام عقود التأمين للشيخ محمود آل زيد ص ٧٥ ، مصادر الحق ١٦٨/٦، الضمان للشيخ على الخفيف ص ١٧، النظريات الفقهية د. الدريني ص ١٩٦ ، النظرية العامة للالتزام د. شفيق شحاته ص ٩١ .

الأدلة والمناقشة :

أدلة القول الأول : الكتاب والسنة والآثار والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }
الآية.(١)

وجه الدلالة :دلت الآية على وجوب الوفاء بالعقود ، والشرط الجزائي
سبب من أسباب الوفاء بالعقود .

أما السنة : فعن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن
جده: أن رسول الله ﷺ قال (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم
حلالاً أو حل حراماً) .^(١)

وجه الدلالة : دل الحديث لى وجوب التزام المسلمين بشروطهم ،
والشرط الجزائي شرط من الشروط فكان تنفيذه مباحا .

أما الأثر فمنه:

١- عن عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب واختصم
إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها قال عمر

(١) أخرجه الترمذي في سننه ، باب ما ذكر في الصلح قال أبو عيسى هذا حديث
حسن صحيح ٦٣٤/٣ .

لها شرطها قال رجل لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته فقال عمر المسلمون عند مشارطتهم عند مقاطع حدودهم.^(١)

٢- وعن ابن سيرين أن رجلاً قال لكريه^(٢) : أدخل ركابك^(٣) فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح : من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه^(٤).

٣- عن ابن سيرين : أن رجلاً باع طعاما وقال : إن لم آتكَ الأربعاء فليس بيني وبينك بيع ، فلم يجئ ، فقال شريح للمشتري : أنت أخلفت ، فقاضى عليه^(٥) .

وجه الدلالة : دلت الآثار بمجموعها على مشروعية الشرط الجزائي لوجوب التزام المسلمين بشروطهم.

أما المعقول فمن أوجه :

(١) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا، ٩٨١/٢، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الشرط في النكاح، ٢٢٧/٦.

(٢) لكريه : الذي أكرهه و المكاري الذي يؤجر الدواب للسفر.

(٣) ركابك : الإبل التي يسافر عليها.

(٤) ووجه ذلك : أن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع تاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهياً للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف بالوعد . فتح الباري ٣٢٤/٥.

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، ٩٨١/٢.

الأول : أن الأصل في الشروط الصحة ، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً^(١).

الثاني : أن الشرط الجزائي من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ إذ هو حافظ لإكمال العقد في وقته المحدد له^(٢).

أدلة القول الثاني : السنة والمعقول.

أما السنة فمنها.

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة)^(٣).

وجه الدلالة : دل الحديث على النهي عن بيع بيعتين في بيعة^(٤)، والشرط الجزائي من قبيل ذلك لأنه اشتمل على بيعتين في بيعة واحدة.

ويناقش : بأن الاستدلال غير مسلم: لأن الشرط الجزائي ليس من قبيل بيعتين في بيعة ، فليس من قبيل "بعثك على أن تقرضني أو تزوجني أو تؤجرني"؛ لأن كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع

(١) قرار هيئة كبار العلماء قرار رقم (٢٥) وتاريخ (١٣٩٤/٨/٢١ هـ).

(٢) المرجع السابق.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه ، باب النهي عن بيعتين في بيعة ، ٥٣٣/٣ ، قال أبو

عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.

(٤) تحفة الأحوذى ٣٥٨/٤ .

مستقلا عن العقد الأصلي بخلاف الشرط الجزائي فإنه لا يقع مستقلا^(١).

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله ﷺ عن بيع وشرط).
وجه الدلالة :

دل الحديث صراحة على النهي عن بيع وشرط في بيعة ،
والشرط الجزائي من قبيل ذلك؛ لأنه اشتمل على بيع وشرط فيكون فاسدا.

٣- عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده : أن رسول الله ﷺ قال (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما)^(٢).

وجه الدلالة : دل الحديث على عدم مشروعية الشرط الذي يحل حراما، والشرط الجزائي يحل الربا المحرم فكان محرما.
أما المعقول :

فإن الشرط الجزائي يترتب عليه التزام منفعة زائدة في العقد ،
وزيادة منفعة مشروطة لأحد المتعاقدين تكون ربا؛ لأنها زيادة لا

(١) الشرط الجزائي د. الرويشد ص ٦١٨.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه ، باب ما ذكر في الصلح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ٦٣٤/٣ .

يقابلها عوض، والعقد الذي فيه ربا أو شبهة الربا فاسد لأن شبيهه الربا كحقيقته. ^(١)

الراجح :

بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم أرى - والله أعلم - أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون بجواز الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال، وذلك لما يلي:

- ١ - لقوة أدلتهم ، وضعف دليل القول المخالف .
- ٢ - يحقق ضمانا لعاقدي العقود ، أو التي يتعهدون بها ، مخافة نكول أحدهم عما عقد عليه أو التزمه أو تعهد به.
- ٣ - الشرط الجزائي يحقق مصلحة، ويسد أبواب الفوضى، والتلاعب بحقوق العباد، وإلحاق الضرر بهم.
- ٤ - عملاً بقوله ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) فمفهوم الضرر عام وشامل لكل ما يتأذى به المرء في كل حقوقه التي كفلها له الشارع.
- ٥ - جريان العرف بالتعامل بالشرط الجزائي والعادة محكمة، وإذا كان الأمر كذلك، ولم يكن في هذا الشرط ما يوجب تحريمه من ربا، أو ظلم، أو ميسر، فلا وجه لتحريمه، بل هو جائز وصحيح.

(١) دراسات ميسرة في قضايا معاصرة د. علي محمد قاسم ص ٢٦٣.

الشرط الجزائي على التأخير في سداد الديون :

العقود التي يكون الالتزام فيها بالشرط الجزائي ديناً ثلاثة :

أولاً: عقد القرض.

ثانياً: عقد البيع بالتقسيط .

ثالثاً: عقد السلم .

وقبل بيان حكم الشرط الجزائي في الديون أعرض بصورة موجزة حقيقة الدين والمدين، وصور الشرط الجزائي في الديون وذلك على النحو التالي:

حقيقة الدين والمدين .

الدين لغة : دان الرجل (يدين) (دينا) من المداينة وأيضاً (دان) الرجل إذا استقرض فهو (دائن) .^(١)

اصطلاحاً : الدين لزوم حق في الذمة^(٢).

فالمال الثابت في الذمة يسمى ديناً، سواء كان بدلاً من: مبيع أم من قرض، أم من مال أهلكه أو استهلكه ، أو كان التزاماً مالياً أثبتته الشرع

(١) المصباح المنير ٢٠٥/١ .

(٢) فتح الغفار شرح المنار ط . مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٥٥هـ، ٢٠/٣ .

كالمهر^(١) أو اقتضته الضرورة مع نية الرجوع على المنتفع، وأكثر ديون المصارف الإسلامية ناتجة عن البيوع الآجلة: كبيع المrabحة بالتقسيط، والسلم، والقرض الحسن، ويسمى مستحق المال الثابت في ذمة الآخر دائناً، ومن ثبت في ذمته المال مديناً، والمال الثابت ديناً^(٢).

المدين: وهو إما أن يكون المدين معسراً أو موسراً.

أما المعسر : وهو الشخص الذي لا يجد ما يقضي به دينه عديماً كان أو ممن يضر به الأداء.^(٣)

واتفق الفقهاء^(٤) على وجوب إنظار^(٥) المعسر استدلالاً بقوله تعالى: { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } من الآية ٢٨٠ من سورة البقرة.

(١) صيانة المديونيات، د. محمد عثمان شبير ص ٨٤٠ ، الشرط الجزائي في الديون ، د. علي محمد الحسين الصوا،

<http://www.islamfeqh.com>.

(٢) الشرط الجزائي في الديون ، د. علي محمد الحسين الصوا،

<http://www.islamfeqh.com> .

(٣) قوانين الأحكام الشرعية ، ص ٣٣٢ ، ٣٣٣ .

(٤) المبسوط ١٦٤/٢ ؛ الحاوي ٨٦٨/١٥ ، شرح منتهى الإرادات ١٥٨/٢ .

(٥) ضابط الإعسار: أن لا يكون له مال فائض عن حوائجه الأصلية يفي به دينه.

د. رفيق المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٦٤٣/٧.

ولحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قال له بكل يوم صدقة قبل ان يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة) .^(١)

وأما الموسر : وهو المدين القادر على الوفاء ولكنه يماطل فهو ظالم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال (مَطْلُ الْغَنِيِّ ^(٢) ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ) ^(٣) .

(١) أخرجه أحمد في المسند ، ٦٣٠/٥ . قال الهيثمي روى ابن ماجه طرفا منه . رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٣٥/٤ .

(٢) مطل : المطل التسويف وعدم القضاء . (الغني) المتمكن من قضاء ما عليه .

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ، باب تحريم مطل الغني ، ٣٤/٥ ، برقم (٤٠٨٥) .

تعريف الشرط الجزائي في الديون وخصائصه:

ويعرف الشرط الجزائي في الديون: بأنه اتفاق مقترن بعقد، يحدد بموجبه العاقدان مسبقاً مبلغاً من المال، عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه. -كفرض غرامة على سداد دين مثل أقساط بيع سيارة ونحو ذلك.

خصائص الشرط الجزائي في الديون.

من خصائص الشرط الجزائي في الديون ما يلي:-

- ١ - الشرط الجزائي تقدير جزافي لمبلغ من المال، عن ضرر قد يلحق بالدائن عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه، وقد يكون المبلغ أكبر من الضرر، أو مساوياً له، أو أقل منه^(١).
- ٢ - الشرط الجزائي في الديون: اتفاق بين الدائن والمدين في ذات العقد أو في عقد لاحق ، يرتب على المدين عند إخلاله بالتزامه دفع مبلغ مالي يحدده العاقدان بعد وقوع الضرر^(٢).

(١) الوسيط د. السنهوري ٨٥٢/٢ .

(٢) الشرط الجزائي د. الرويشد ص ١٢١ .

حكم الشرط الجزائي في الديون:

يختلف حكم الشرط الجزائي في الديون تبعاً لصوره وفي ذلك مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون مبلغ الشرط مستحقاً عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه دون أن يتوقف ذلك على شريطة أخرى، كأن يقول: إذا لم يوفه دينه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا من المال، ولا خلاف بين الفقهاء على تحريم هذا الشرط وأنه مبطل للعقد لأن ذلك ربا صريح، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } . سورة آل عمران: ١٣٠.

دلت الآية على تحريم الزيادة على أصل الدين قال ابن العربي: (إن الناس في الجاهلية كانوا يتبايعون ويربون، وكان الربا عندهم معروفاً يبايع الرجل الرجل إلى أجل. فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلاً آخر. فحرم الله تعالى الربا وهو الزيادة) ^(١).

وأما السنة: فحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية

(١) الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار، دار الكتب العلمية، بيروت ط ١

سنة ٢٠٠٠، ٦/٤٨٨ .

موضوعة^(١) وربما الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع^(٢) (٣)

قال النووي:

(في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيعوها، وقوله في الربا إنه موضوع كله، معناه الزائد على رأس المال، كما قال تعالى "وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم" [البقرة: ٢٧٥]، لأن الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة، والمراد بالوضع الرد والإبطال^(٤)).

أما الإجماع:

فقد حكى الإجماع ابن عبد البر فقال: (أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو: أن يأخذ الدائن لتأخير دينه بعد حلوله عوضاً عينياً أو عرضاً، وهو معنى قول العرب: إما أن تقضي وإما أن تربي^(٥)).

(١) أي الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوع لا حكم لها ولا قصاص ولا دية ولا شيء.

(٢) كل ربا الجاهلية موضوع أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما أبطل من الربا ربا أقاربه ربا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه غنياً يراي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رباة كله.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة الوداع ٣٩/٤ برقم ٣٠٠٩.

(٤) شرح صحيح مسلم ١٨٢/٨.

(٥) أحكام القرآن لابن العربي ٣٢١/١ .

وقال النووي: (أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر).^(١)

ولا خلاف بين العلماء المعاصرين على تحريم الشرط الجزائي مقابل التأخير في سداد الديون: إذا كان مبلغ الشرط مستحقاً عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه ، دون أن يتوقف ذلك على شريطة أخرى.^(٢)

وقد صدرت عدة فتاوى شرعية صادرة عن المصارف الإسلامية، تؤكد حرمة الشرط الجزائي على الديون، وتعدده ربا نسيئة^(٣).

(١) المجموع ٤٤٢/٩ .

(٢) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، عدد(٢) مجلد(٢) ، ص ٩٥ ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، عدد(١) مجلد(٣)، ص ١١٢ سنة ١٤٠٥ هـ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، عدد(١) مجلد(٣)، ص ١١٢ سنة ١٤٠٥ هـ. منهج الفقه الإسلامي في عقوبة المدين المماطل، د. زكي الدين شعبان ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٤، ص ٢٢ ، ٢٣ ، المعاملات المالية المعاصرة د. وهبة الزحيلي ، ص ١٧٨ ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي الشيخ الزرقاء مجلد (٢) عدد (٢)، ص ١٥٤ . نظرية الالتزام في الشريعة والتشريعات العربية، عبد الناصر العطار، ص ٢٣١ ، ٢٣٢ ، د. علي جمعة جريدة الراية القطرية. نقلا عن د. على الصوا، الشرط الجزائي في الديون.

<http://www.islamfeqh.com>

(٣) الفتاوى الشرعية، ج ٢ ، ص ١٦ ، طبعة سنة ١٩٩٤م، الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ج ١، إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة.، فتاوى هيئة الرقابة الشرعية مصرف قطر الإسلامي، فتوى رقم (١٨). فتاوى هيئة

المسألة الثانية: أن يتضمن العقد شرطاً يلزم المدين المماطل بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً .

ويثار تساؤل: هل يحق للبنوك أو الشركات أو المؤسسات أو الأفراد توقيع شرط جزائي أو غرامة التأخير في حالة التأخير عن سداد الديون في المدة المحددة لسداد الدين أم لا ؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة ولهم في ذلك قولان.

القول الأول : يرى من ذهب إليه جواز اشتراط الشرط الجزائي عن الضرر الواقع فعلاً، وإلزام المدين المماطل بالوفاء به^(١). ^(٢) ذهب

الرقابة الشرعية، بنك فيصل الإسلامي المصري، فتوى رقم (١٤). هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان.، نقلا عن د. على الصوا، الشرط الجزائي في الديون.

(١) ولكن بشرط نص في العقد بأن هذه الغرامة سوف تصرف في وجوه الخير وهذا يؤصل فقهيًا بالتزام الشخص بالتبرع طوعاً فيكون ملزماً بما التزم به وهذا مبني على رأي للمالكية أجازوا الالتزام بالتطوع والخير، د. على القرة داغي ، حكم غرامات التأخير ، <http://www.qaradaghi.com>

(٢) صيانة المديونيات، محمد شبير، ص ٨٦٣، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد (٢)، مجلد (٢)، ص ٩٧، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد ١ مجلد ٣ ، ص ١١٢ ، أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت ٣٠-٣١ أكتوبر ١- نوفمبر ١٩٩٥م ، ص ٢٢٣ ، ٢٣٨ ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد ١ مجلد ٣، ص ١١٢، أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت ٣٠-٣١ أكتوبر ١- نوفمبر ١٩٩٥م ، ص ٢٢٣ ، ٢٢٨ ، المصرف الإسلامي الدولي - مصر - فتوى رقم ٣، ٤ ،

لذلك د. مصطفى الزرقاء، د. الصديق الضير، د. عبد الله بن منيع، وأفتى به علماء لجنة الفتوى في المصرف الإسلامي الدولي بمصر، ولجنة الفتوى في مجموعة دلة البركة الفتوى ، كما صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حيث جاء فيها ما نصه : (إن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له^(١) . كما أجازت التعويض التأخيري: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية^(٢).

القول الثاني: يرى من ذهب إليه تحريم^(٣) الشرط الجزائي عن الضرر الواقع فعلا في الديون، وبه قال الشيخ علي الخفيف، د. زكي الدين شعبان، د. نزيه حماد، د. محمد شبير، د. وهبة الزحيلي^(٤).

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، مجلد ١، ص ٢١٤ . دار أولي النهى - الرياض، ط ٢ سنة ١٩٩٢م..نقلا عن الشرط الجزائي د. علي الصوا ،

<http://www.islamfeqh.com>.

(١) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، مجلد ١، ص ٢١٤ . دار أولي النهى - الرياض، ط ٢ سنة ١٩٩٢م.

(٢) معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية والإسلامية ص ١٧١ .

(٣) أيدهم في ذلك من الاقتصاديين د. رفيق المصري، د. عبد الناصر العطار.

(٤) الضمان في الفقه الإسلامي، الشيخ علي الخفيف ص ١٩، ٢٠، قضايا فقهية

معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد، دار القلم - دمشق ط ١، ٢٠٠١ ،

الأدلة والمناقشة

أدلة القول الأول : السنة والأثر والمعقول .

أما السنة فمنها : -

١- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (مطل الغني ظلم).^(١)

وجه الدلالة :

دل الحديث على أن المدين المماطل ظالم ، فهو بامتناعه عن سداد الدين مع القدرة عليه كالغاصب فوجب تحمله الشرط الجزائي عند المماطلة في السداد.^(٢)

ويناقش : بأن الأصول الشرعية تقضي بأن أخذ المال لا يكون إلا تبرعاً، أو في مقابلة مال، وإلا كان أكلاً له بالباطل؛ لأن أصل التعويض في نظر فقهاء الشريعة هو مقابلة المال بالمال^(٣).

٢- وعن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال « لِيُ الْوَّاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ^(١) وَعُقُوبَتَهُ^(٢) ».

ص ٣٥١ ، المعاملات المالية المعاصرة د. شبير، ٢، ٨٧٣ نقلا عن الشرط الجزائي د. علي الصوا ،

<http://www.islamfeqh.com>.

(١) سبق تخريجه.

(٢) لجنة الفتوى في المصرف الإسلامي الدولي سابقا.المصرف المتحد حاليا.

(٣) الضمان، الشيخ علي الخفيف ، ص ٢٠ .

وجه الدلالة: دل الحديث على أن المدين الغني المماطل ظالم يحل عرضه وعقوبته ، والعقوبة لفظ يشمل: الحبس والضرب ونحو ذلك، فيقاس على ذلك الغرامة المالية.

وتناقش جهة الاستدلال بالحديث بما يلي:

أن مقصود قوله ﷺ "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" أي شكايته وحبسه لا تغريمه بالمال؛ لأن التغريم من الربا الحرام وهو ربا النسئة^(٣)

قال النووي: "قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني ومطلني وعقوبته الحبس والتعزير" ^(٤).

٣- عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قضى أن (لا ضرر ولا ضرار). ^(٥)

(١) يحل عرضه: يغلظ له وعقوبته يحبس له.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه ، باب الحبس في الدين ، ٣٤٩/٣. قال ابن الملقن هذا الحديث صحيح، رواه أحمد في «مسنده» ، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي في سننهم من حديث عمرو بن (الشريد) البدر المنير ٦/٦٠٦.

(٣) صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠/٢٢٧ .

(٤) المعاملات المالية المعاصرة د. وهبة الزحيلي ص ١٧٩.

(٥) أخرجه ابن ماجه في سننه ، ٧٨٤/٢ ، وقال البوصيري في الزوائد (حديث عبادة بن الصامت إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع .

وجه الدلالة : دل الحديث على النهي عن الضرر والضرار ، ومطل الغني يضرّ بالبنك الدائن ضرراً كبيراً حيث يحبس ماله عن الاتجار فيه، لذلك يمكن أن يؤخذ بالغرامة المالية لمنع هذا الضرر، لأن القاعدة تقضي بأن الضرر يزال، وإزالة هذا الضرر إنما يتحقق بالتعويض عنه وذلك يتم عن طريق الغرامة المالية^(١).

ويناقش : بأن وجه الاستدلال غير مسلم: - لأن قواعد إزالة الضرر هي العموم الذي لا يتعارض مع أساس الشريعة القائم على منع الربا ، وإن تضرر الدائن^(٢).

أما الأثر : فعن ابن سيرين: أن رجلاً قال لِكَرِيه: أرجل ركابك، فإن لم أرجل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح "من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه"^(٣).

أما المعقول فمن أوجه.

الأول : تعويض الدائن عن ضرره الناتج عن التأخير مبدأ مقبول شرعاً؛ لأنه لا ينافي نصوص الشريعة ومقاصدها العامة.^(٤)

(١) تأصيل غرامة التأخير والشرط الجزائي ، موقع ملتقى أهل الحديث:

www.ahlalhdeth.com.

(٢) المعاملات المالية المعاصرة د. وهبة الزحيلي ص ١٧٩.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد (٢) ، مجلد (٢) ، ص ٩٧ .

الثاني : قياس وجوب تضمين المدين على تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة ^(١)، إذ لكل منهما مال أزيلت عنه يد مالكه بغير حق ^(٢).

ويناقد : بأن هناك فروقاً جوهرية بين النقود وبين الأعيان من عدة أوجه من أهمها: أن الأعيان يمكن الاستفادة من منافعها كالسكنى في العقارات والركوب في الحيوانات ولذلك يجوز تأجيرها بمال، ولكن النقود ليست لها منافع بذاتها، ولذلك لا يجوز تأجيرها.

الثالث : أن الشرط الجزائي في مقابلة الإخلال بالالتزام، حيث إن الإخلال به مظنة الضرر وتقويت المنافع، وفي القول بصحة الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد، وسبب من أسباب الحث على الوفاء بالعقود ^(٣).

أدلة القول الثاني : استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم جواز الشرط الجزائي في الديون بالسنة والمعقول .
أما السنة فأحاديث منها :

(١) ذهب لذلك جمهور الفقهاء وخالفهم الحنفية في ذلك .

(٢) تأصيل غرامة التأخير والشرط الجزائي ، www.ahlalhdeth.com ،

(٣) أبحاث هيئة كبار العلماء، ١/٢١٤.

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة)^(١)

وجه الدلالة:

دل الحديث على النهي عن بيع بيعتين في بيعة ، والشرط الجزائي من قبيل ذلك لأنه اشتمل على بيعتين في بيعة واحدة .

ويناقش:

بأن الاستدلال غير مسلم :لأن الشرط الجزائي ليس مستقلا عن العقد الأصلي، وإنما هو من قبيل الاحتياط في إكماله بالوفاء بالشرط.

٢- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ (نهى عن بيع وشرط).^(٢)

وجه الدلالة :

دل الحديث دلالة صريحة على النهي عن بيع وشرط؛ لأنه بيع فاسد؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن ، والنهي يقتضي تحريم المعاملة ولما كان الشرط الجزائي تابعا للعقد؛ فإنه يكون منهي عنه .

ويناقش من وجهين:

(١) أخرجه الترمذي في سننه ، باب النهي عن بيعتين في بيعة ، ٥٣٣/٣، قال أبو

عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط/٤/ ٣٣٥ ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد/٤/ ١٥٢

، وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال.

الوجه الأول : أن الحديث في إسناده مقال، قال ابن حجر: "واستغربه النووي وقال غريب"^(١).

الوجه الثاني : أن اجتماع البيع والشرط يؤدي إلى الربا أو الغرر ، واشتراط الشرط الجزائي لا يترتب عليه ذلك ؛لأن الشروط الصحيحة التي لا يؤدي اجتماعها مع البيع إلى ربا أو غرر، فإنها تبقى صحيحة ويصح معها العقد.^(٢)

أما المعقول:

فإن الشرط الجزائي نوع من أنواع ربا النسيئة المحرم، لأنه يترتب عليه التزام منفعة زائدة في العقد ، وزيادة منفعة مشروطة لأحد المتعاقدين ربا، لأنها زيادة لا يقابلها عوض^(٣).

ويناقش من وجهين :

الأول : أن هناك فرق بين الشرط الجزائي والفائدة الربوية منها :

١ - أن الفوائد الربوية مثبتة في البداية، فالمدين يدفع الزيادة على أصل الدين ولو لم يتأخر ، أما الشرط الجزائي فيدفع عند التأخير والمماطلة في السداد.

(١) التلخيص الحبير لابن حجر ٣/٣٢ .

(٢) الشرط الجزائي، د. علي السالوس ، مجلة مجمع الفقه ١٢ع.

(٣) دراسات ميسرة في قضايا فقهية معاصرة ، د. علي محمد قاسم ص ٢٦٣.

٢- أن الفوائد الربوية تلزم المدين مطلقاً سواء كان معسراً أو موسراً ،
أما الشرط الجزائي فلا يلزم إلاّ عند المماطلة إذا كان المدين
موسراً.

وأجيب : بأن هذه الفروق ليست جوهرية وغير مؤثرة في الحكم
الشرعي.

الثاني: أن الفوائد الربوية في المداينات تعقد من البداية، فتكون طريقاً
استثمارياً أصلياً يلجأ إليها المرابون، مما يخل بالتوازن
الاقتصادي بين العاقدين، بخلاف الشرط الجزائي، فإنه ليس
طريقاً استثمارياً، وإنما هو إعادة لتوازن العقد الأصلي الذي أخل
به المدين المماطل^(١).

الراجع :

بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم يبدو لي - والله أعلم - أن
الرأي الراجع هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلون بتحريم
الشرط الجزائي في الديون وذلك لأن: الشرط الجزائي في الديون ربا؛
لأن كل زيادة في الدين مشروطة هي ربا صريح ، ولأن مشكلة تأخر

(١) الحكم على المدين المماطل بالتعويض، منشور بمجلة الاقتصاد ص٩٦،
صيانة المديونيات، د. محمد شبير، ص٨٧٢ .

الديون ليست وليدة عصرنا، بل كانت موجودة، ومع ذلك لم ينقل إلينا أن أحداً أجاز اشتراط الزيادة على الديون، والبدائل الشرعية كثيرة^(١).

ملخص الموضوع :

١- الشرط الجزائي هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له، وذلك عن الضرر الفعلي الذي يلحقه، إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.

٢- الشرط الجزائي من العقود المستحدثة، والأصل في العقود الجواز ، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه.

٣- أن الشرط الجزائي لا يستحق إلا إذا تحققت شروط استحقاق التعويض.

(١) وضع الإسلام تدابير وضمانات عديدة لحفظ أموال الدائنين من ماطلة المدينين ، وذلك من غير حاجة إلى التعامل بغرامة تأخير وفاء الدين، لما فيها من أضرار ومفاسد ومن البدائل ما يلي : إنظار المدين إذا كان معسرا، تعاون البنوك الإسلامية فيما بينها في المعلومات المتوافرة عن المستثمرين والاتفاق على جعل المدين المماطل في القائمة السوداء، إشهار اسم المماطل في وسائل الإعلام، الأخذ بالوسائل الفنية للجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة، الأخذ ضمانات كافية من الكفالة والرهن ونحوهما. غرامة تأخير وفاء الدين وتطبيقاتها المعاصرة د. عبد الستار أبو غدة ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة <http://www.fiqhia.com.sa> ، دراسة فقهية لغرامات التأخير والبدائل د.

داغي www.aaoifi.com/aaoifi

٤- يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض، إذا وجدت مبرراً لذلك.

٥- الشرط الجزائي نوعان نوع على التأخير في الأعمال وهو جائز بضوابط .

النوع الثاني على التأخير في الديون وهو محرم لا يجوز العمل به.
والله سبحانه أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نماذج أسئلة :

س ١ : اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي للشرط الجزائي وضحي ذلك مع ذكر الأدلة وبيان الرأي الراجح.

س ٢ : أكمل مكان النقط :

١- من العوامل التي ساعدت على العمل بالشرط الجزائي

..... ،.....

٢- الشرط الجزائي هو.....

س ٣ : عين الصواب مع تصحيح الخطأ وتعليل الصواب :

١- الشرط الجزائي لا يطبق إذا كان مبالغاً فيه.

٢- للقاضي سلطة في تعديل الشرط الجزائي.

القسم الرابع

عقود التوريد

المعلومات والمفاهيم:

يتوقع أن يكون الطالب / الطالبة أن يكون قادرا على أن:

- ١- يعرف عقد التوريد وتحديد ماهيته وصوره.
- ٢- إبراز حكم عقد التوريد في الشريعة الإسلامية وتكييفه الفقهي، وأدلة مشروعيته.
- ٣- فهم الطرق التي يتم بها عقد التوريد.
- ٤- العمل على تحقيق جانب اقتصادي وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- ٥- تنمية مدارك الطلاب من خلال معرفة سبب الخلاف في عقد التوريد والأدلة والمناقشة والترجيح.
- ٦- التواصل مع المجتمع الخارجي للتوعية بالأحكام الشرعية المتعلقة بعقد التوريد.

المبحث الأول:

وفيه سبعة مطالب

المطلب الأول: فى تعريف عقد التوريد

العقد لغة: يطلق على معان متعددة من أهمها : الربط والشد والإحكام والتوثيق والعهد والإلزام ، وعقدت الحبل والبيع والعهد فانهقد، وعهدت إلى فلان في كذا أي ألزمته ذلك ^(١)، والعقد : هو وصل الشيء بالشيء على سبيل الاستيثاق والإحكام ^(٢) . قال الألويسي: أصل العقود الربط محكمًا ثم تُجوز به عن العهد الموثق ^(٣).

والعقد اصطلاحًا: يطلق على معنيين : معنى عام ومعنى خاص.

فأما المعنى العام فهو : التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرًا ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول أو ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعًا ^(٤) . قال القرطبي : (كل ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة ..) ، وقال الجصاص : (العقود : هي عموم في

(١) لسان العرب ج٤ ص٣٨٦ م عقد ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ج١ ص ٣٣٧ فصل العين باب الدال .

(٢) التفسير الكبير للفخر الرازي ج١١ ص ٩٧ ، أحكام القرآن للجصاص ج١ ص ٥٨٠ .

(٣) تفسير روح المعاني للألويسي ج٦ ص ٤٨ .

(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر تعريب فهمي الحسيني ج١ ص ٩١ - المادة ١٠٣ طبع دار الكتب العلمية . بيروت ، التعريفات للجرجاني باب العين فصل القاف ص ١٥٣ .

إيجاب الوفاء بجميع ما يشترط الإنسان على نفسه (^(١)) . فهو كل ما ينتج التزاماً شرعياً فيشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كما يشمل التصرفات التي تتم من طرف واحد كالوقف والطلاق والهبة .

وأما العقد بمعناه الخاص فهو : ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ، ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب (^(٢)) للآخر (^(٣)) .

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٦ ص٢٣ ، أحكام القرآن للجصاص ج٢ ص٤١٩ .

(٢) مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان لمحمد قدري باشا ص٧٢ المادة ٢٦٢ - طبع الدار العربية . عمان .

(٣) العقد بمعناه العام أقرب إلى المعنى اللغوي وهو أعم وأشمل من المعنى الخاص ؛ وذلك لإطلاقه على جميع الالتزامات الشرعية سواء أكانت اتفاقاً بين طرفين أم كانت التزاماً من شخص واحد . وهذا ما أيده فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية ؛ لكن العقد بمعناه الخاص هو الشائع عند الفقهاء ، ولذا عرفوه بأنه : (ربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما ينشأ عنه أثره الشرعي ، أو التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراً .

البنية شرح الهداية للعيني ج٨ ص٤ طبع دار الكتب العلمية - بيروت ، حاشية الدسوقي لأحمد الدردير ج٣ ص٣ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ج٢ ص٣٤ - طبع المكتبة التوفيقية ، المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج٥ ص٢٤٤ - طبع دار الحديث ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج٤ ص٥٩ طبع دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان .

وأما التوريد لغة: مصدر ورّد، يقال ورّد فلان ورودًا: حضر، وأورده غيره واستورده أى أحضره، واستورد السلعة ونحوها جلبها من خارج البلد^(١).

والتوريد اصطلاحًا : عرّف الباحثون التوريد بتعريفات متعددة منها:

١- أنه اتفاق يتعهد فيه أحد الطرفين أن يورّد إلى الآخر سلعا موصوفة ، على دفعة واحدة ، أو عدة دفعات، فى مقابل ثمن محدد ، غالبًا ما يكون مقسطا على أقساط ، بحيث يدفع قسط من الثمن كلما تم قبض قسط من المبيع^(٢).

٢- هو عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد محددة الأوصاف فى تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على أقساط^(٣) .

٣- هو اتفاقية بين الجهة المشترية والجهة البائعة ، على أن الجهة البائعة تورد إلى الجهة المشترية سلعا أو مواد محددة الأوصاف

(١) لسان العرب ج٦ ص٤٢٦ م ورد ، القاموس المحيط ج١ ص٣٥٨ فصل الواو ، باب الدال ، المعجم الوسيط ص٤١٠٢ .

(٢) هذا تعريف د . رفيق يونس المصرى من مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد ١٢ ص٧٨٥ ضمن المكتبة الشاملة .

(٣) عقود التوريد والمناقصات للشيخ حسن الجواهرى ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد ١٢ ص٧٥٤ ضمن المكتبة الشاملة .

فى تواريخ مستقبلة معينة لقاء ثمن معلوم متفق عليه بين الفريقين^(١).

٤- هو عقد على عين موصوفة فى الذمة بثمن مؤجل معلوم ، إلى أجل معلوم فى مكان معين . (هذا تعريف د . عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان) ، وقد عرفه تعريفًا آخر بمفهومه التجارى المتداول فقال: هو إحضار سلع من خارج حدود البلاد السياسية ، وترتيبها الوطنية للراغبين فيها . تتكفل بها مكاتب متخصصة ، أصحابها ذوو خبرة واسعة بمواقع السلع ومصادرها يبرمون عقودًا فى داخل بلادهم مع التجار الراغبين فيها ، يقومون بهذا الأمر إما بصفتهم وكلاء عن المصانع والشركات الخارجية حيناً ، أو أنهم يمثلون الطرف الأول (بائعاً) فى العقد ، والتجار المحليون (مشترون) طرفًا ثانيًا حيناً آخر^(٢).

٥- وعرفه السنهوري بأنه : عقد يلتزم به أحد المتعاقدين أن يورد للمتعاقد الآخر شيئاً معيناً ، يتكرر مدة من الزمن^(٣) .

(١) عقود التوريد والمناقصات للقاضى محمد تقى العثمانى مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد ١٢ ص٦٧١ ضمن المكتبة الشاملة .

(٢) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية د . عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد ١٢ ص٦٩٠ ضمن المكتبة الشاملة .

(٣) الوسيط لعبد الرزاق السنهورى ج٦ ص١٦٧ .

٦- وعرفه مصطفى أحمد الزرقا بأنه عقد من العقود المستمرة التي يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن ؛ بحيث يكون الزمن عنصراً أساسياً في تنفيذها (١) .

٧- هو اتفاق بين شخص معنوى من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوى لازمة لمرافق عام مقابل ثمن معين وهذا ما عرفته به محكمة القضاء الإدارى (٢) .

(٢) المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا ج١ ص ٦٤ طبع دار العلم - دمشق.

(٣) العقود الإدارية وعقد البوت د. أحمد سلامة بدر ص ١٤٥ . مكتبة دار النهضة العربية. طبع سنة ٢٠٠٣ .

المطلب الثانى

فى أهمية عقد التوريد

أفرزت التقنيات الحديثة عقوداً من المعاملات لم يكن للأمم بها سابق عهد. ومن أبرز هذه العقود وأوسعها انتشاراً (عقد التوريد) حيث تمارسه الدول والشركات والمؤسسات والتجار فى كل بلاد العالم نظراً لأنه يدخل فى كافة أنواع المتطلبات الحياتية والمعيشية للأفراد والدول. وأنه عصب الحركة التجارية محلياً ودولياً ؛ فهو عقد يرمى إلى أن يطمئن المشتري إلى ضمان حصوله على السلعة التى يريدّها فى الموعد الذى يريده ، وأن يطمئن البائع إلى أن ما سينتجه من سلع أو بضاعة قد بيع بالفعل، وسيتم تسليمه إلى المشتري فى الميعاد المتفق عليه ^(١). فهو لا يختص بسلعة دون سلعة ولا بوقت دون وقت ولكن يشمل كافة أنواع السلع المنقولة فى كافة النواحي الاقتصادية والصناعية والزراعية ، وكافة القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والنقل والمواصلات والاتصالات ؛ فكل ذلك يحتاج إلى آلات ومواد : مثلاً قطاع الصحة يحتاج إلى مبان ومستشفيات ومعامل ومختبرات وهذه تحتاج إلى أدوات وتجهيزات وأجهزة متنوعة ثم تحتاج بعد ذلك

(١) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية د . عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٧٠١ بالمكتبة الشاملة . نقلاً عن عقد التوريد د . منذر قحف ، عقد التوريد والمناقصات د . رفيق يونس المصرى بمجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٧٨٥ بالمكتبة الشاملة .

إلى تغذية وأدوية وإعاشة . والحاجة إلى عقد التوريد ليست خاصة بأمة دون أمة ؛ بل أصبح حاجة الأمم والشعوب فى كافة أقطار الدنيا . فكل ذلك يتم عن طريق عقود التوريد ، وكذلك تصريف المنتجات وما يتطلبه ذلك من النقل والتخزين والتوزيع وغيره مما يتطلب الارتباط بعقود التوريد (١) .

(١) عقد التوريد حقيقته وأحكامه في الفقه الإسلامي د . عادل شاهين محمد شاهين ج ١ ص ١٠ (رسالة دكتوراه) الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية . طبع دار كنوز أشبيليا . (رسالة دكتوراه) الطبعة الأولى سنة ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.

المطلب الثالث:

في سبب ظهور عقد التوريد والغرض من إبرامه

إن حياة المسلمين كانت تقوم على بعض أنواع العقود التي نظمها الفقه الإسلامي كالبيع والمضاربة والسلم وغيرها ، وكانت تلك العقود كافية للوفاء بحاجات الناس وتنظيم المعاملات بينهم وضبط الحقوق والالتزامات . إلا أن هذه الصيغ وتلك العقود لم تعد كافية فاحتاج الناس إلى نوع من المعاملات التي تضم عقوداً مركبة، فالباعث إلى مثل هذه العقود المستجدة هو حاجة الناس^(١). وأيضاً : دخول الآلة في حياة الناس ، فلما دخلت الآلة في الإنتاج وصحبتها الطاقة أصبحت القدرة على الإنتاج تتضاعف تضاعفاً يعجز عنه من يستخدم الآلة ، كما أن ما تحتاجه الآلة من مواد أولية لا يستطيع المستخدم توفيره وتخزينه وشراءه.

وأيضاً : تنظيم الدول لميزانياتها تنظيمًا محكمًا في بداية كل سنة ؛ فإن الدول تعرف ما هي في حاجة إليه من ثياب ومن أحذية للجيش ، ومن تجهيزات للمستشفيات والمعاهد والكليات ؛ فهذه الحاجات لا يمكن أن تتبع سعر السوق نزولاً وهبوطاً ، ولكن الميزانية لابد أن تبني على أمر ثابت حتى توزع توزيعاً عادلاً حتى تكون صالحة للتطبيق

(١) عقد التوريد في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة " نمر صالح محمود دراغمة رسالة ماجستير . جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين سنة ٢٠٠٤ م ص٤٧ ، ٤٨ منشورة .

لأن الدول لا تختزن كامل الميزانية فى أول السنة حتى تستطيع أن تشتري سلماً ؛ وإنما هى تحصل على الواردات شيئاً فشيئاً وتدفع الأثمان شيئاً فشيئاً . فكان عقد التوريد الذى تنشئه الدول هو الحل ؛ لذلك فإن عقد التوريد هو عقد فرض نفسه على الساحة الإسلامية بسبب تراكم الصناعات وكثرة الحاجة إليها .

الغرض من إبرام عقد التوريد:

أن يطمئن المشتري إلى حصوله على السلعة التى يريدتها فى الميعاد الذى يريده فى المستقبل ، وأن يطمئن البائع إلى أن ما سينتجه من بضاعة قد بيع فعلاً ، وسيتم تسليمه إلى المشتري فى الميعاد المضروب ^(١) . وهو بذلك يقلل من مخاطر كساد بضاعته ؛ لأنه ينتجها بعد أن يتعاقد عليها . وإذا كان الثمن محدداً سلفاً ، عند العقد ، فإن المشتري يعرف مسبقاً ثمن الشراء ، ويحدد تكاليفه وأثمان منتجاته ، والبائع يعرف مسبقاً ثمن المبيع ، ويحدد إيراداته ^(٢) .

(١) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية د . عبد الوهاب أبو سليمان عدد ١٢ ص ٧٠١

نقلاً عن عقد التوريد د . منذر قحف ص ٥ .

(٢) عقد التوريد فى الفقه الإسلامى نمر صالح ص ١٩ .

المطلب الرابع

في أركان^(١) عقد التوريد وشروطه

لا يتحقق عقد التوريد إلا بوجود ثلاثة أركان عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هم : المتعاقدان ، والمعقود عليه (الثلث والتمثّل) والصيغة (الإيجاب والقبول)^(٢) .

(١) الأركان جمع مفردة ركن والركن لغة : الركن بالضم الجانب القوى . والركن هو الناحية القوية .

واصطلاحاً : ما يتوقف عليه الشيء وكان داخلاً في ماهيته . لسان العرب ج٣ ص ١٨٥ م ركن ، القاموس المحيط ج٤ ص ٢٣١ فصل الرأء ، باب النون ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوى ج٣ ص ٣٤٤ .

(٢) الإيجاب لغة : من وجب البيع والحق يجب وجوباً ، وسمي الإيجاب إيجاباً لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر حق القبول واصطلاحاً : هو ما يصدر أولاً من أحد المتعاقدين بلفظ يدل عليه كأجرتك ، واستأجرتك وأكريتك ، وجاء في المادة ١٠١ من مجلة الأحكام العدلية أن الإيجاب : هو أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف .

والقبول لغة : التصديق ، والتلقي والأخذ .

واصطلاحاً : أنه ثاني كلام يصدر من أحد المتعاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإيجاب هو ما صدر من العاقد المملّك للمنفعة وهو البائع أو المؤجر ، والقبول : هو ما صدر من المتملك وهو المشتري أو المستأجر . درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج١ ص ٩١ ، الهداية شرح بداية المبتدى ج٣ ص ٣١ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٣ ص ٣ ، مغنى المحتاج ج٢ ص ٣ ، المغنى لابن قدامة ج٣ ص ٥٦١ .

وذهب الحنفية إلى أن أركان العقد هي الإيجاب والقبول فقط ؛ لأن وجودهما يستلزم وجود غيرهما مما لا يتحقق العقد إلا به. إذ لا يُتصور تحقق الإيجاب بدون موجب ولا قبول بغير قابل ، كما أن الإيجاب والقبول يقتضى وجوب محل يجرى التعاقد عليه ^(١) .

وعقد التوريد كغيره من عقود المعاوضات لابد فيه من عاقلين يباشرانه ويصدر منهما الإيجاب والقبول .

والعاقدان فى التوريد هما: المورد والمستورد .

فالمورد: هو الطرف الذى يلتزم بإحضار السلعة ، أو تقديم الخدمة المتفق عليها ، وتسليمها للمستورد وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها ، مقابل ثمن معين يدفعه للمورد .

والمستورد: هو الطرف الذى يملك السلعة أو الخدمة فى مقابل ثمن معين يدفعه للمورد ^(٢) .

(١) بدائع الصنائع ج٥ ص ١٣٣ ، الهداية شرح بداية المبتدى ج٣ ص ٢١ ، مواهب الجليل فى شرح مختصر الشيخ خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الشهير بالحطاب ج٥ ص ٢٤٦ ، مجلة مجمع الفقه الإسلامى الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامى العدد ٦ ج٢ ص ٨٣٩ سنة ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م .

(٢) عقد التوريد حقيقته وأحكامه فى الفقه الإسلامى د . عادل شاهين محمد شاهين نقلاً عن العقود الإدارية لحمدى عكاشة ص ٤٩٥ ، عقود التوريد للمطلق ص ٣٩ .

وقد يكون العاقدان كل منهما شخصاً منفرداً أو متعدداً ، كما لو تخرج فريق من الورثة مع أحدهم ، أى تعاقدوا معه على أن يدفعوا لكل واحد منهم .

وقد يكون العاقدان أصيلين أو نائبين عن غيرهما فى العقد كالوكيلين .
وقد يكون أحدهما أصيلاً عن نفسه والآخر وكيلاً عن غيره ^(١) .
ويشترط فى العاقلين البلوغ والعقل والاختيار .

والمعقود عليه وهو : السلعة التى أبرم العقد لأجل توريدها وهو ما وقع عليه التعاقد ، وظهرت فيه أحكام العقد وآثاره ^(٢) ^(٣) .

ويشترط فى المعقود عليه أن يكون معلوماً بذكر الجنس والوصف وأن يكون المبيع والثلث مقدراً بما يرفع الجهالة ، وأن يعين أجل التسليم فى كل من البضاعة والثلث ، وأن يكون المعقود عليه موجوداً غالباً وقت حلول الأجل وكذا ثمنه ^(٤) .

وأما الصيغة : فهى الإيجاب والقبول وهما شقى الصيغة وهى الوسيلة التى يعبر بها العاقدان عن إرادتهما ورغبتهما ، ولا بد أن تكون صريحة

(١) المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا ص ٤٠٠ .
(٢) اختلف الفقهاء فى تحديد المعقود عليه ، فيرى جمهور الفقهاء أن المعقود عليه هو الثمن والمثلث معاً . وقصره الحنفية على المبيع فقط لأنه المقصود الأصلي من العقد . رد المختار على الدر المختار لابن عابدين ج ٤ ص ٣٨٠ وما بعدها ، الفواكه الدواني للنفاوى ج ٢ ص ٢٣٩ ، نهاية المحتاج للرملى ج ٣ ص ٣٨٠ ، كشف القناع للبهوتي ج ٣ ص ١٥٢ .

(٣) عقود التوريد والمناقصات للشيخ حسن الجواهرى العدد ١٢ ص ٧٥٧ .

(٤) المدخل الفقهي العام ص ٤٠٠ ، عقد التوريد لعمر بن عبد الرحمن العمر ص ٣ (بحث منشور) .

واضحة بذاتها أو بالقرائن فى الدلالة على التعبير عما هو مقصود .
عن طريق الألفاظ الدالة على إنشاء العقد وقبوله . ويجرى عليها
الشروط العامة فى صيغ العقود ^(١) ، والإيجاب يكون من البائع وهو
المورد بتمليك سلعة موصوفة فى الذمة إلى الآخر بثمن معين فى
الذمة والقبول يكون من المورد إليه بقبوله لإيجاب البائع ^(٢) .

شروط عقد التوريد

يشترط فى عقد التوريد عدة شروط منها:

(١) أن يكون المورد مالكا للسلعة ، أو وكيلاً لها ولديه القدرة على
تسليمها للمستورد فى الزمان والمكان المعيّنين ^(٣)؛ فقد تكون
السلعة المعقود عليها مملوكة للمورد كبضائع التجار الموجودة فى
مستودعاتهم ، أو غير مملوكة للمورد ولكنه وكيل لها كوكلاء
السيارات والسلع المختلفة ^(٤) .

(١) فقه المصارف الإسلامية . الإجارة على منافع الأشخاص د . على القرة داغى
ص ١٠ .

(٢) عقود التوريد والمناقصات للشيخ حسن الجواهرى . مجلة مجمع الفقه الإسلامى
عدد ١٢ ص ٧٥٢ بالمكتبة الشاملة .

(٣) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية د / عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - مجلة
مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٦٩٩ بالمكتبة الشاملة .

(٤) عقد التوريد حقيقته وأحكامه فى الفقه الإسلامى د / عادل شاهين ج ١ ص ١٩٤ .

- (٢) أن تكون السلع محل التوريد يباح الانتفاع بها شرعاً . فلا يصح العقد على توريد سلع محرمة كالخمر والميتة والخنزير وآلات اللهو ونحوها مما ثبت ضرره وحرمة (١) .
- (٣) أن تكون السلعة معلومة علماً يرفع الجهالة المفضية إلى النزاع ويحصل ذلك بوصف السلعة وصفاً منضبطاً بذكر جنسه ونوعه وقدره وحجمه وتاريخ إنتاجه وعناصره وجودته (٢) .
- (٤) أن تكون السلعة موجودة غالباً وقت حلول الأجل (٣) .
- (٥) أن يكون الثمن معلوماً جنساً ونوعاً وقدرًا وصفة والعلم بالثمن كالعلم بالمبيع لأنه أحد العوضين فاشتراط العلم به كما يشترط ذلك في عقود المعاوضة (٤) .

(١) المرجع السابق نفسه ، عقد التوريد لعمر بن عبد الرحمن العمر (التعليم الموازي) الفقه المقارن ص ٢ " بحث منشور " .

(٢) عقد التوريد لعمر بن عبد الرحمن العمر ص ٣ .

(٣) عقد التوريد في الفقه الإسلامي لنمر صالح ص ١٥ .

(٤) عقد التوريد لعادل شاهين ج ١ ص ١٩٦ ، ١٩٧ .

المطلب الخامس

في أقسام عقد التوريد

ينقسم عقد التوريد إلى عدة أقسام منها:

١ . عقد التوريد الإدارى:

وهو العقد الذى تكون الجهة الحكومية أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيه ، ويتصل بمرفق عام من مرافق الدولة ، وأمثله كثيرة منها توريد الملابس للعسكريين أو المرضى أو الرياضيين من موظفى الحكومة ، وتوريد الإعاشة للمستشفيات الحكومية ونحو ذلك .

٢ . عقد التوريد الخاص:

هو العقد الذى يكون طرفاه من الجهات الخاصة من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الخاصة . ومن أمثله اتفاق مستشفى خاص مع مشغل للملابس على توريد ملابس للأطباء والمرضى والمرضات والعمال ، أو اتفاق شركة مطاعم مع شركة لحوم على توريد لحوم متنوعة مما تحتاج إليه المطاعم ، أو اتفاق فرد مع مؤسسة أو شركة لتحلية وتعبئة المياه على توريد كمية محدودة من الماء إلى منزله بصفة دورية ، ونحو ذلك ^(١) .

(١) عقد التوريد للمطلق ص ٣٢ ، عقد التوريد والمقاوله فى ضوء التحديات

الاقتصادية المعاصرة حمد شويح - عاطف أبو هرييد ص ٤ ، عقد التوريد لعادل

شاهين ج ١ ص ١١٤ ، ١١٥ .

٣ . عقد التوريد الموحد :

هو العقد الذى يكون لأحد طرفيه وضع شروط التعاقد مقدماً دون أن يعطى الطرف الآخر الحق فى مناقشتها ؛ لأنه فى موقف المذعن^(١) المحتاج الذى تُملَى عليه الشروط فلا يملك إلا أن يقبل بها لحاجته للتعاقد ؛ ومن أمثلتها عقود توريد خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف.

٤ . عقد التوريد الحر :

هو العقد الذى يتمتع فيه كل من طرفيه بحريته التامة فى إنشاء العقد وتحديد شروطه ، وغالبية عقود التوريد تندرج تحت هذا النوع^(٢).

(١) الإذعان لغة : أذعن له خضع وذل وأقر وأسرع فى الطاعة وانقاد . القاموس

المحيط ج٤ ص ٢٢٧ فصل الدال والذال . باب النون .

واصطلاحاً : هو مصطلح قانونى حديث يشعر بمعنى الاضطرار فى القبول ، وهذا النوع من العقود ينحصر القبول فيه بمجرد التسليم بمشروع عقد ذى نظام مقرر يضعه الموجب ، ولا يقبل فيه مناقشة ، وذلك كالاشتراك فى خدمات الكهرباء والمياه؛ حيث يتضمن شروطاً تملئها الشركة، ولا يسع المشترك إلا أن يوافق عليها جملة أو يدع الاستفادة من تلك الخدمة، وغالباً ما يكون ذلك فى الحاجات الأساسية التى لا يستغنى عنها أحد . الوسيط للسهنورى ج١ ص ٢٢٩ ، المدخل الفقهى العام للزرقا ج١ ص ٣٣٠ ، عقد التوريد لعادل شاهين ج١ ص ١٢١ .

(٢) عقد التوريد للمطلق ص ٣٢ ، عقد التوريد والمقاوله لحمد شويديح - عاطف أبو

عربيد ص٤ .

٥ . عقد التوريد العادى:

هو العقد الذى يكون عمل المورد فيه هو تسليم الطرف الآخر منقولات متفق على مواصفاتها مقدماً ولا تتطلب صناعة ، ويكون للمورد الحرية فى اختيار المصدّر الذى يحصل عليها منه . مثل توريد ملابس أو لحوم أو أثاث (١) .

٦ . عقد التوريد الصناعى:

هو العقد الذى يكون موضوعه عبارة عن تسليم منقولات يصنعها المورد ، وقد يكون للإدارة المستوردة حرية التدخل أثناء تصنيع المنقولات ؛ كما هو الشأن فى توريد الأثاث المكتبى لبعض الدوائر الحكومية (٢) .

٧ . عقد التوريد المحلى:

هو العقد الذى يجرى التعاقد فيه بين طرفين موجودين فى دولة واحدة، وقد يكونان فى مدينة واحدة (٣) .

٨ . عقد التوريد الدولى:

(١) عقد التوريد للمطلق صد٣٣ ، عقد التوريد لعادل شاهين نقلاً عن الأسس العامة للعقود الإدارية للطماوى صد١٣٩ .

(٢) المرجعان السابقان .

(٣) عقد التوريد للمطلق صد٣٢ .

هو العقد الذى يجرى التعاقد فيه بين طرفين أحدهما في دولة والآخر في دولة أخرى ، وتتعامل به الدول فيما بينها ، كما تتعامل به الأفراد^(١).

٩ . عقد توريد السلع :

وهو ما كان محل العقد فيه سلعاً منقولة؛ ومن أمثلته توريد الأغذية والأدوية والملابس والوقود ، للمستشفيات والمدارس والمطارات وغيرها.

١٠ . عقد توريد الخدمات:

وهو ما كان محل العقد فيه سلعاً خدمية معينة؛ كتوريد الماء والكهرباء والغاز ، وتوريد الصحف والمجلات والعمال وغيرها ^(٢) .

موضوع عقد التوريد :

هو عموم السلع الغذائية والدوائية والصناعية من الأثاث والملبوسات، والأدوات والآلات، والمواد الأولية والمصنوعة وغيرها من المتطلبات الضرورية والحاجية والكمالية، الموجودة أعيانها ، المملوكة لبائعها ، أو ما يكون للبائع القدرة على إحضارها في الزمان والمكان المُعَيَّن^(٣).

(١) عقد التوريد د . رفيق يونس المصري مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص

٧٨٥ بالمكتبة الشاملة ، عقد التوريد لعادل شاهين ج١ ص ١٢٣ .

(٢) المرجعان السابقان .

(٣) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - مجلة

مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٧٠٠ بالمكتبة الشاملة .

المطلب السادس

في صور عقد التوريد

هناك صور شائعة لعقد التوريد في المعاملات التجارية المعاصرة منها:

١- أن يكون دفع الثمن مؤجلاً بحيث يتزامن وتسليم السلعة ، أو يتقدم أحدهما على الآخر في التأجيل حسب شروط العقد .

٢- أن يدفع المشتري عربوناً أو تأمييناً ، أو ضماناً يحسب من ثمن السلعة المؤجل تسليمها .

٣- أن يدفع كل من المتعاقدين مبلغاً من المال يحسب على أساس نسبة الثمن لضمان الالتزام لكل منهما بالعقد وتنفيذه ، ويودع لدى طرف ثالث ، أو إدارة السوق كي تضمن تنفيذ العقد من الطرفين ، ويعاد للبائع ما دفعه عند التنفيذ ، ويحسب ما دفعه المشتري جزءاً من الثمن الكلي . إن القصد الأساسي من إبرام العقد في صورته السابقة التبادل الفعلي للسلع ، وحصول المشتري على السلعة المطلوبة لتلبية احتياجاته ، والبائع على الربح وتسويق منتجاته هو الباعث لكلا المتعاقدين .

٤- تسليم السلعة على دفعات متفاوتة، ودفع الثمن مؤجلاً .

٥- إن بعض صور عقود التوريد يحتاج فيها العاقد السلعة على فترات متفاوتة منتظمة حسب احتياجه على أن يتم دفع الثمن كله ، أو بعضه مؤجلاً في وقت محدد بعد استيفاء كامل للدفعات المطلوبة كما هو الحال في عقود التغذية في الملاجئ والمستشفيات ، والمطارات ، وغيرها من العقود المشابهة التي يستوفي لها كافة الصفات وتسلم حسب جدول زمني معين^(١) . وهو ما يسمى بعقود التوريد الإدارية^(٢) . وهي تلك العقود التي يكون أحد طرفيها جهة إدارية حكومية.

(١) المرجع السابق نفسه ص ٧١١ ، ٧١٢ .
(٢) عقد التوريد عمر بن عبد الرحمن العمر ص ٤ ، العقد الباطن في الفقه الإسلامي لسامي الماجد ص ٣١١ (رسالة دكتوراه) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المملكة العربية السعودية سنة ١٤٢٨ .

المطلب السابع

في مميزات عقد التوريد

وما ينفرد به عن غيره من العقود

لعقد التوريد بعض المميزات كغيره من عقود المعاوضات، منها:

١ - أن عقد التوريد دائماً ما يكون على أشياء منقولة فلا يرد على عقار أو غيره (١) .

٢ - أنه عقد رضائي يتم بموافقة الطرفين على مضمونه ؛ فالتراضي وحده هو الذي يكوّن العقد . ولكنه يأخذ بعض الصور كأن يستقل أحد العاقلين بوضع شروطه مسبقاً وليس للطرف الآخر إلا أن يقبل العقد كاملاً أو يرفضه كاملاً دون أن يكون له الحق في تعديل شروطه مثل توريد الماء والكهرباء ونحوهما (٢) .

٣ - أنه عقد ملزم للطرفين وهو كل عقد يتضرر كل واحد من العاقلين بفسخه دون رضاه وهو الذي ينشئ التزامات متقابلة في نمة كل من المتعاقدين. كالبيع يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع في مقابل أن يلتزم المشتري بدفع الثمن (٣) ، ولكن يظل العقد

(١) العقود الإدارية وعقود البوت د. أحمد سلامة بدر ص ١٤٦ .

(٢) عقد التوريد ، تعريفه وتكييفه وأركانه لهاياوي . جامعة الإمام محمد بن سعود قسم الفقه المقارن . المعهد العالي للقضاء ص ٧ (بحث منشور) .

(٣) عقد التوريد د. عادل شاهين محمد شاهين ص ٤١١ ، عقد التوريد في الفقه الإسلامي لنمر صالح ص ٥٥ .

غير لازم حتى يوفى البائع بكافة الصفات المشروطة في البيع وهو مما اختص به عقد التوريد دون غيره من عقود المعاوضات^(١).

٤ - أنه عقد معاوضة يتم فيه مبادلة سلعة معلومة بثمن معلوم ويقصد به طرفيه الحصول على منفعة .

٥ - أنه عقد محدد يستطيع فيه العاقدان (المورد والمورّد إليه) أن يحددا محل العقد تحديداً ينفي الجهالة^(٢) .

٦ - أنه عقد مؤقت ، إذ يعد الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، فهو من العقود المستمرة ، وأهم ما يميزه عن غيره من العقود أنه يتم فيه تسليم السلعة في زمن مستقبلي محدد في العقد سواء أكان ذلك دفعة واحدة أم على دفعات في آجال معلومة محددة ، فهو ليس عقداً من العقود الفورية من حيث تسليم المعقود عليه^(٣) .

٧ - أنه عقد ناقل للملكية : ينقل عقد التوريد الملكية بمجرد التعاقد ولو لم يقترن ذلك بالتسليم شأنه شأن عقد البيع .

٨ - أنه عقد تجاري : يعد عقد التوريد عملاً تجارياً بالنسبة للمورد بشرط أن يكون في إطار مشروع ، أي أن يمارس بمعرفة مورّد

(١) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية لعبد الوهاب أبو سليمان . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٧٠١ - المكتبة الشاملة .

(٢) عقد التوريد لهاياوي ص ٧ ، عقد التوريد لنمر صالح ص ٥٤ .

(٣) الوسيط للسنهوري ج١ ص ١٦٧ ، عقد التوريد حقيقته وأحكامه في الفقه الإسلامي عادل شاهين محمد شاهين ص ٤٢٠ .

محترف ، وكذلك بالنسبة للمورّد إليه إذا كان تاجرًا وتعاقدًا على التوريد لحاجات تجارية^(١).

٩- أنه عقد جديد . فالتوريد بصورة المنتشرة الآن عقد جديد لم يكن معروفًا عند فقهاءنا الأوائل وإن كانوا قد بحثوا مسائل تشبه بعض صورته^(٢).

مميزات ينفرد بها عقد التوريد :

ينفرد عقد التوريد عن غيره من البيوع بما يلي:

- ١ . غياب المبيع عن مجلس العقد، والاكتفاء برؤية متقدمة له ، أو وصفه أو نموذج منه .
- ٢ . تأجيل الثمن كله حتى استلام المبيع كاملاً ، أو تقسيمه حسب دفعات تسليم المبيع^(٣) .

(١) عقد التوريد في الفقه الإسلامي لنمر صالح نقلاً عن أساسيات القانون التجاري والقانون البحري لمصطفى كمال طه ص ٢٩٧ .

(٢) عقد التوريد لهاياوي ص ٧ .

(٣) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية د . عبد الوهاب أبو سليمان مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٧٠١ .

المبحث الثاني:

في التكييف الفقهي لعقد التوريد وحكمه تفصيلاً وإجمالاً

عقد التوريد في جوهره ومضمونه من عقود المعاوضات التي تنتهي بتمليك السلعة للمشتري والثلث للبائع بصورة مؤبدة ، وهو من العقود المستجدة والتي لم ينص عليها الفقهاء . وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه ؛ تبعاً لاختلافهم في التكييف الفقهي لهذا العقد، ولهم فيه ستة آراء:

الرأي الأول: أن عقد التوريد عقد جديد مستقل في ذاته وصفاته ، وهو من العقود المستحدثة التي لم ينص عليها الفقهاء ، وهو عقد جائز ومشروع بشرط خلوه من المحظورات الشرعية فيما يتعلق بالعاقدين ، والعوضين ، وصفة العقد وألا يتعارض مع نص من الكتاب والسنة أو القواعد الشرعية المقررة . وبهذا قال د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ^(١) في أحد قوليه و د . مصطفى الزرقا ، والشيخ

(١) قال د . عبد الوهاب أبو سليمان : " يمكن أن ينظر إلى مشروعية هذا العقد من عدمها من خلال أصلين شرعيين وتنزيله على أحدهما أو على كليهما إن أمكن هذا . الأصل الأول : تنزيله على عقد هو أكثر شبهاً به واتفاقاً معه في حقيقته وأخص صفاته . وهو (عقد البيع على الصفة أو بيع الصفات) .

الأصل الثاني : أن يعد عقداً جديداً في ذاته وصفاته ، يخضع أولاً لقاعدة " الأصل في المعاملات الإباحة...) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية د . عبد الوهاب أبو سليمان مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٦٩١ .

حسن الجواهري وعبد السميع إمام ، والصاديق الضرير ^(١) في أحد
قوليه ود . وهبة الزحيلي ^(٢) .

أدلة هذا الرأي:

استدل أصحاب هذا الرأي بالكتاب والسنة :

أما الكتاب :

١ . فقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ ^(٣) .

وجه الدلالة : أمرت الآية الكريمة بالوفاء بالعقود أمراً عاماً ومطلقاً
دون تعيين لنوع العقد ، سواء أكان عقداً عقده الله تعالى علينا وألزمنا
به ، أو عقداً يقع بين الناس بعضهم مع بعض ما دام هذا العقد غير
ممنوع شرعاً ولا يتعارض مع قواعد الشريعة وأصولها ^(٤) .

(١) عقود التوريد والمناقصات للشيخ حسن الجواهري . مجلة مجمع الفقه الإسلامي
عدد ١٢ ص ٧٥٢ ، وما بعدها ، عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية لعبد الوهاب
أبو سليمان - مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٧٤٣ ، عقود التوريد
والمناقصات لرفيق يونس المصري مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص
٧٩٦ .

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٨٢ " المناقشة " .

(٣) سورة المائدة من الآية ١ .

(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٦ ص ٢٤ ، عقود الصيانة وتكييفها الشرعي
لآية الله محمد علي التسخيري ، مرتضى الترابي منشور بمجلة مجمع الفقه
الإسلامي عدد ١١ ج ٢ ص ٣٥٩ .

٢ . قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (١) .

٣ . قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾ (٢) .

وجه الدلالة من الآيتين:

أن هذا العقد يطلق عليه العرف بأنه تجارة عن تراض من الطرفين يدخل تحت عموم الآية السابقة ، وعلى هذا فسوف يكون كل عقد عرفي ولو كان جديداً لم يكن متعارفاً عليه عند نزول النص يجب الوفاء به إذا كان مشتملاً على الشروط التي اشترطها الشارع في الثمنين أو المتعاقدين أو العقد (٣) .

وما دام يصدق على هذه المعاملة أنها عقد وتجارة وبيع فتشملها العمومات المتقدمة (٤) .

كما أن الأصل في ثبوت الحق في مال الغير هو رضا صاحب هذا المال ، إذا كان ذلك على سبيل التجارة والمعاوضة ، وهذا أصل شرعي عام ؛ فالتجارة شاملة لكثير من التصرفات والمعاملات التي

(١) سورة البقرة من الآية ٢٧٥ .

(٢) سورة النساء من الآية ٢٩ .

(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٨١٢ المناقشة والتعقيب .

(٤) عقود التوريد والمناقضات للشيخ حسن الجواهري عدد ١٢ ص ٧٥٢ .

تنشئ التزامات ، ومنها عقد التوريد الذي يكون عن تراض بين المورد والمورد له ، ويبغى كل واحد منهما الكسب والريح ^(١) .

وأما السنة:

١ . فقوله ﷺ : " المسلمون عند شروطهم " ^(٢) .

وجه الدلالة : ظاهر قوله ﷺ يقتضي لزوم الوفاء لكل شرط إلا ما خص بدليل ، وأن كل اتفاق تتوافر فيه الشروط التي يقرها الفقه الإسلامي يكون عقدًا مشروعًا ^(٣) .

٢ . قوله ﷺ : " إنما البيع عن تراض " ^(٤) .

وجه الدلالة : أن عقد التوريد ، إذا وقع برضا العاقلين ، ولم يتضمن ما حرم الله ورسوله كتوريد الخمر ونحوها ؛ فإنه يكون جائزًا صحيحًا ^(٥) .

وأما المعقول:

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٥ ص ٩٩ ، عقد التوريد في الفقه الإسلامي لنمر صالح ص ٦٥ .

(٢) سنن الترمذي . كتاب الأحكام . باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس ج٣ ص ٧٣ برقم ١٣٥٧ ، سنن ابن ماجه . كتاب الأحكام . باب في الصلح حديث رقم ٢٣٥٣ .

(٣) مصادر الحق في الفقه الإسلامي عبد الرزاق السنهوري ص ٨١ .

(٤) سنن ابن ماجه . كتاب التجارات . باب بيع الخيارات ج٢ ص ٧٣٧ برقم ٢١٨٥ ، سنن البيهقي . كتاب البيوع . باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره ج٦ ص ٢٩ برقم ١١٠٧٤ .

(٥) عقد التوريد لعادل شاهين ج١ ص ٤٣٢ .

١ . فإن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه ^(١) والأصل في المعاملات هو إمضاء ما تعارف بين الناس من أصناف المعاملات والتجارات والحكم بصحته إلا ما ورد فيه نهي من الشرع كالغرر ^(٢) ونحوه . قال الإمام الشافعي ^(٣) : " فأصل البيوع كلها مباح ، إذا كانت برضا المتبايعين ، الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهي عنه رسول الله ﷺ منها ، وما كان في معنى ما نهي عنه رسول الله ﷺ محرم بإذنه داخل في معنى المنهي عنه ^(٤) .

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٧٣ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٣ .
(٢) الغرر : هو الذي لا يستطيع فيه أحد المتعاقدين أن يحدد عند العقد مقدار غنمه و غرمه بمقتضى العقد ، وإنما يتحدد ذلك في المستقبل تبعاً لأمر مجهول وغير محقق الحصول كبيع اللبن في الضرع . والغرر : ما كان له ظاهر يغمر المشتري وباطن مجهول . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج ٢ ص ٢٩٨ ، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي الصديق الضير ص ٥٣ ، ٥٤ .
(٣) الشافعي : هو حبر الأمة و سلطان الأئمة ، أبو عبد الله محمد بن إدريس . . . ينتهى نسبه إلى عبد مناف جد النبي ﷺ ، ولد بمدينة غزة على أصح الروايات وقيل غير ذلك سنة ١٥٠ هـ فى العام الذى توفى فيه الإمام أبو حنيفة فكان عوضاً عنه ، نشأ بمكة وتعلم بها ، وأذن له شيخه مسلم بن خالد بالفتوى وهو ابن عشرون سنة ، وقدم بغداد سنة ١٩٥ هـ وألف بها كتبه القديمة ، ثم رحل إلى مصر سنة ١٩٩ هـ واستقر بها وأملى على تلاميذه المصريين كتبه الجديدة التى يعبر عنها بالقول الجديد ، توفى رحمه الله بمصر سنة ٢٠٤ هـ .
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ١ ص ١٩٢ طبع عيسى الحلبي ، طبقات الشافعية للأسنوى ج ١ ص ١١ طبع دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان ، طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني ص ١١ طبع دار الأفاق الجديدة . بيروت . لبنان .

(٤) الأم للشافعي ج ٣ ص ٢ .

٢ . أن الحاجة داعية في هذا العصر إلى التعامل بعقد التوريد، بل الحاجة إلى ذلك عامة ، وليست خاصة، وهي مما عمت به البلوى ، فلا توجد مؤسسة تجارية على المستوى المحلى أو الدولي إلا ولها حاجة واقعية للتعامل بعقد التوريد ، إما توريدًا أو استيرادًا .

ومن القواعد الفقهية المقررة: (أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة)^(١).

٣ . قال الإمام السرخسي^(٢): " تعامل الناس من غير نكير ، أصل في الشرع " ^(٣) .

فالعرف له مكانته في الأحكام وبخاصة في المعاملات ، وهو وإن لم يكن دليلاً قائماً بنفسه إلا أنه يعد دليلاً كاشفاً عن الحكم مظهرًا له ^(٤).

٤ . أن عقد التوريد لا يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ؛ لأنه يقوم على رعاية مصالح الناس العامة ، وتسهيلاً وتيسيراً عليهم . ورفعاً للحرص والمشقة التي تلحق بهم في حالة الجمود والركود

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ج ١ ص ١٧٢ .

(٢) السرخسي : هو محمد بن محمد رضي الدين السرخسي ، فقيه من أكابر الحنفية أقام مدة في حلب وتعصب عليه بعض أهلها فسار إلى دمشق وتوفى فيها . من مؤلفاته : المبسوط وغيره . الجواهر المضيئة ج ٢ ص ١٢٨ ، الأعلام للزركلي ج ٧ ص ٢٤٩ .

(٣) المبسوط للسرخسي ج ١٣ ص ٧٧ .

(٤) عقد التوريد لعادل شاهين نقلاً عن رفع الحرج في الشريعة الإسلامية د . يعقوب باحسن ص ٥١٧ ، العرف والعادة لأبي سنة ص ٣٨ .

الاقتصادي ، فهو يعمل على تنشيط الحركة التجارية والصناعية. لذا فإنه عقد جائز^(١) .

الرأي الثاني:

أن عقد التوريد إذا كان على سلعة تتطلب صناعة فيأخذ حكم الاستصناع^(٢) ، وقد أجاز الحنفية الاستصناع مع عدم ضرورة تعجيل الثمن^(٣). وقرر مجمع الفقه الإسلامي أنه "إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه وبهذا قال القاضي محمد تقي العثماني^(٤) في أحد تخريجه^(٥) .

(١) عقد التوريد في الفقه الإسلامي لنمر صالح ص ٦٨ .

(٢) **الاستصناع لغة** : مصدر من استصنع الشيء : أي دعا إلى صنعه والاستصناع : افتعال من الصنعة ، يقال : اصطنع فلان خاتماً : إذا سأل رجلاً أن يصنع له خاتماً .

واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه عقد على مبيع في الذمة ، وقال بعضهم : هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل . والصحيح هو القول الأخير لأن الاستصناع طلب الصنع . لسان العرب ج ٤ ص ٧٧ م صنع ، بدائع الصنائع ج ٥ ص ٣٣ .

(٣) ذهب الحنفية عدا زفر إلى جواز عقد الاستصناع وهو عقد مستقل شأنه في ذلك شأن العقود المسماة كالسلم وغيره

قال الكاساني : " وأما جوازه فالقياس ألا يجوز ؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم .. ويجوز استحساناً لإجماع الناس على ذلك لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير .. والقياس يترك بالإجماع .

وذهب جمهور الفقهاء إلى إلحاق الاستصناع بالسلم .

بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢ ، المدونة ج ٤ ص ١٩ ، تحفة المحتاج للهيتمي ج ٥ ص ١٩ ، ٢٠ ، والمغني والشرح الكبير ج ٦ ص ٣٦٧ .

(٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٦٧٩ ، ٨١١ .

(٥) قال القاضي محمد تقي العثماني : " إن كان محل التوريد شيئاً يقتضي صناعة فإن عقد التوريد يُخرَج على أساس الاستصناع ، ويكون عقداً بائناً ، وتجري عليه أحكام الاستصناع .

الأدلة على ذلك:

استدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بالمعقول وهو :

أ- إذا صح عقد الاستصناع مع تأجيل الثمن صح عقد التوريد كذلك^(١).

ب- أن هناك أوجه شبه بين عقدي التوريد والاستصناع في الأحكام والشروط؛ كما تقدم أن من أنواع عقود التوريد عقد التوريد الصناعي مما يدل على تقاربهما، ومن أوجه الشبه بينهما ما يلي:

١- أن كلا منهما من عقود المعاوضات المالية ؛ حيث يتم فيها التعاقد على سلعة محددة الصفات في مقابل ثمن محدد ، ففي عقد التوريد السلعة المنقولة التي يراد توريدها ، والثمن المتفق عليه مقصودان لكل من المستورد والمورد^(٢). وفي عقد الاستصناع السلعة المصنعة التي يراد تصنيعها ، والثمن مقصودان لكل من المصنع والصانع^(٣).

وإن كان محل التوريد شيئاً لا يقتضي صناعة ، فإنه لا يكون عقدًا باتاً ، وإنما يكون مواعدة لإنجاز العقد في تاريخ لاحق، ثم يتم العقد في حينه بإيجاب وقبول.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٦٧٩ ، ٨١١ .

(١) المرجع السابق نفسه ص ٧٥٦ .

(٢) عقد التوريد د . عادل شاهين نقلاً عن القانون التجاري السعودي للجبر ص ٦٧ ، عقد التوريد الإداري ص ١١٣ .

(٣) فتح القدير ج ٥ ص ٣٥٥ .

٢ . أن المعقود عليه في بعض صور عقد التوريد يكون موصوفاً في الذمة كذلك عقد الاستصناع (١) .

٣ . أن الثمن في كلا العقدين يمكن تعجيله أو تأجيله أو تقسيطه ولا يشترط القبض في مجلس العقد (٢) .

٤ . أن كلا منهما عقد لازم لا يقبل الفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ (٣) (٤) .

من ذلك يتبين أن العقدين يتفقان في كثير من الخصائص ؛ لذا فإن عقد التوريد إذا كان على سلعة تتطلب صناعة فهو عقد استصناع يأخذ حكمه من حيث الجواز والمشروعية . إلا أنه يوجد بعض الأمور التي يختلف فيها عقد التوريد عن عقد الاستصناع وهي : أن عقد التوريد لا يرد إلا على المنقولات سواء أكانت تتطلب صناعة أم لا ولا يرد على العقار بحال أما عقد الاستصناع فلا يرد إلا على سلعة تتطلب صناعة ويرد على العقار والمنقول .

وقد يرد عقد التوريد على سلع تتطلب صناعة كصناعة الأثاث وتوريده للمدارس والجامعات والشركات .

(١) عقد التوريد د. عبد الوهاب أبو سليمان مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٧٠١ .

(٢) البحر الرائق ج ٦ ص ٢٨٠ ، عقد التوريد لعادل شاهين ص ٢٨٠ .

(٣) مجلة الأحكام العدلية لعلی حیدر ج ١ ص ٣٦١ مادة ٣٩٢ ، المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ج ١ ص ٥٣٢ ، ٥٣٣ طبع دار القلم .

(٤) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢ ، عقد التوريد لعادل شاهين ج ١ ص ٢٨١ .

الرأي الثالث:

إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم المورد بتسليمها عند الأجل ، فيعد ذلك عقدًا معجل الثمن في مجلس العقد ، وليس مجرد مواعدة ، فهذا العقد يأخذ حكم السلم ؛ لأن حقيقة السلم : بيع موصوف في الذمة مؤجل بأجل معلوم ، بثمن مقبوض بمجلس العقد ، وهذه الحقيقة منطبقة على عقد التوريد المعجل الثمن فيجوز بشروط السلم المعتبرة شرعاً^(١) وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي^(٢) وهو رأي د. رفيق يونس المصري^(٣) .

(١) **السلم لغة** : هو اسم من أسلمت، وهو يرد بمعنى الإعطاء ، يقال أسلم الثوب للخياط أي أعطاه إياه، والسلم : السلف أي : القرض ، فالسلم والسلف لفظان يدلان على معنى واحد .
واصطلاحاً : عرفه الحنابلة بأنه عقد على موصوف في الذمة ، مؤجل ، بثمن مقبوض في مجلس العقد .

ولقد اتفق الفقهاء على مشروعية عقد السلم وجوازه إذا ما توافرت فيه الشروط المعتبرة في السلم من أن يكون رأس المال معلوماً يقبضه المسلم إليه في مجلس العقد ، وأن يكون المسلم فيه ديناً في الذمة معلوماً ، مؤجلاً بأجل معلوم ، مما يغلب وجوده عند حلول الأجل . . . وغير ذلك. لسان العرب ج٣ ص ٣٢٧ م سلم ، والقاموس المحيط ج٤ ص ١٣١ فصل السين . باب الميم ، التعريفات للرجاني ص ١٢٠ ، بدائع الصنائع ج٥ ص ٢٠١ ، شرح الخرشى على مختصر خليل ج٥ ص ٢١٤ ، مغني المحتاج ج٢ ص ١٠٢ ، المغني مع الشرح الكبير ج٦ ص ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، شرح منتهى الإرادات ج٢ ص ٢١٨ ، المحلى لابن حزم ج٩ ص ١٠٥ ، ج ١٠ ص ١٠٩

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٨٥٠ بالمكتبة الشاملة .

(٣) عقود التوريد والمناقصات د. رفيق يونس المصري مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٧٨٦ .

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بهذا الرأي بما يلي:

أن عقد التوريد يشبه عقد السلم في أمور كثيرة منها:

- ١ . أن كلا منهما يكون المبيع فيه مؤجل ، موصوف في الذمة .
- ٢ . أن كلا منهما عقد لازم ، إذا جاء مطابقاً للمواصفات المطلوبة (١).
- ٣ . أن كلا منهما من عقود المعاوضات المالية ، يتم فيهما بيع سلعة محددة الصفات في مقابل ثمن معين (٢) .
- ٤ . أن كلا من العقدين لا يجوز في العقار ولا يرد إلا على المنقول فقط (٣) .
- ٥ . أن كلا من العقدين يشترط فيه أن يكون المبيع مما يغلب على الظن وجوده عند حلول أجله حتى تحصل القدرة على تسليمه (٤) .
- ٦ . أن عقد السلم يكون الثمن فيه مقبوضاً في مجلس العقد ، وكذلك عقد التوريد في بعض صورته (٥) .

(١) المرجع السابق نفسه .

(٢) اعتبار أوجه الشبه بين التوريد والسلم أدلة " هذا من عند الباحثة " .

(٣) عقد التوريد د . منذر قحف ص ٨ ، عقد التوريد لعادل شاهين . نقلا عن الأسس العامة لعقود التوريد للظماوي ص ١٣٥ .

(٤) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢١١ ، المغني مع الشرح الكبير ج ٦ ص ٤٠٦ ، عقد التوريد لمندّر قحف ص ٢٢ ، عقد التوريد لعادل شاهين ج ١ ص ٢٥٥ .

(٥) عقد التوريد لعادل شاهين ج ١ ص ٢٥٥ .

أوجه الاختلاف بين عقد التوريد وعقد السلم :

هناك اختلاف بين عقد التوريد وعقد السلم منها :

- ١ . أن عقد التوريد الغالب فيه أن يكون الثمن مؤجلاً ، أما عقد السلم فإنه يشترط فيه أن يكون الثمن مقبوضاً في مجلس العقد .
- ٢ . المعقود عليه في عقد السلم سلعة ، وقد يكون منفعة وهو السلم في المنافع وهو ما عليه الجمهور خلافاً للحنفية إذ المنافع عندهم لا تعد مالا ^(١) . أما عقد التوريد فالمعقود عليه دائماً سلع منقولة فلا يرد على المنافع ^(٢) .

المناقشة:

نوقش الاستدلال بأن عقد التوريد يشبه عقد السلم بما يلي :

قال الشيخ حسن الجواهري : " عقد التوريد عقد جديد ليس بسلم ولا نسيئة ، لأن السلم يتقدم فيه الثمن ويتأجل المثلّث ، والنسيئة يتقدم فيها الثمن ويتأخر المثلّث ؛ أما هنا فالثمن والمثلّث يتأجلان ^(٣) .

(١) فتح العزيز للرافعي ج٩ ص ٢١٠ ، شرح منتهى الإرادات ج٢ ص ٣٦٠ .
(٢) عقد التوريد لعادل شاهين نقلاً عن الأسس العامة للعقود الإدارية للطماوي ص ١٣٥ ، عقد التوريد د. عبد الوهاب أبو سليمان مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٧٤٦ .

(٣) عقود التوريد والمناقصات للشيخ حسن الجواهري . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٧٥٤ .

الرأي الرابع:

أن عقد التوريد ينزل على عقد من العقود المسماة ^(١) الأكثر شبيهاً به وهو عقد البيع على الصفة ، أو ما يسمى (بيع الصفات) ^(٢) . وهو ما قال به د. عبد الوهاب أبو سليمان في تخريجه الآخر .

(١) العقود المسماة : هي التي نص عليها في الشرع ، وورد لها اسم خاص يدل على موضوعها وأحكام تترتب على انعقادها مثل البيع والإجارة ، والهبة وغير ذلك . والعقود غير المسماة : هي التي لم ينص عليها في الشرع بخصوصها ، ولم يرد لها أحكام خاصة بها ، وهي كثيرة يصعب حصرها ؛ لأنها تنشأ حسب الحاجة وتطور الحياة . المدخل الفقهي العام للزرقا ج١ ص ٦٣٢ .

(٢) عقد البيع على الصفة : هو عقد على عين معينة مملوكة غير مرئية للعاقدين أو لأحدهما ، موصوفة بصفات تكفي في السلم . وهو نوعان : الأول : بيع عين معينة . الثاني : بيع موصوف في الذمة .

وبيع العين المعينة : كأن تكون العين غائبة عن مجلس العقد سواء أكانت داخل البلد أم خارجها في مجلس العقد أم بعيدة . ويمثل لها ببضائع التجار المعينة الموجودة في مستودعاتهم .

أو تكون العين حاضرة في مجلس العقد وتعذرت رؤيتها، ومثل لها الفقهاء بالجارية المنتقبة ، ويمثل لها في الوقت الحاضر : بالسلع الموجودة في الصناديق والعلب ونحوها . أما : بيع الموصوف في الذمة : فهو ما يجب وصفه بصفات تكفي في السلم إن كان مما يصح السلم فيه .

حكم البيع على الصفة: اختلف الفقهاء في حكم بيع العين الغائبة على الصفة إلى قولين . الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في القديم والحنابلة في الصحيح من مذهبهم، والظاهرية إلى جواز عقد البيع على الصفة " وهو الراجح " .

الثاني : ذهب الشافعية في الجديد ، والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجوز البيع على الصفة . سبب الخلاف : يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء إلى التفاوت بين العلم بالمبيع عن طريق الرؤية وبين العلم به عن طريق الصفة، فهل هذا التفاوت

الأدلة والمناقشة:

استدل د. عبد الوهاب أبو سليمان على ما ذهب إليه بأن عقد البيع على الصفة يشبه عقد التوريد بأدلة من المعقول منها :

١ . أن عقد التوريد يشبه عقد البيع على الصفة ، إذ يتفق معه في الأهداف والوسائل ، في الطريقة بدءاً وتاماً ، وأن العقد في كليهما قائم على أساس التوصيف الكامل للسلعة، أو رؤية سابقة لها، أو مشاهدة عينة أو أنموذج منها .

٢ . غياب السلعة عن مجلس العقد في كلا العقدين (وينفرد عقد التوريد بعدم وجود السلعة في الخارج حال العقد ؛ ولكنها تصنع ، أو تستتبت بعد تمام العقد ، وقد تكون موجودة ولكن في بلد ناء ، غير أن البائع أو الوكيل يضمن حضورها سليمة في المكان والزمان والمواصفات المتفق عليها) .

٣ . موضوع العقدين هو عموم السلع الضرورية ، والحاجية ، والتكميلية والتحسينية .

يعد من الجهل المؤثر في بيع العين الغائبة فيكون من الغرر الكثير ؟ أم أنه غير مؤثر فيكون من الغرر اليسير المعفو عنه؟ المبسوط ج١٣ ص٦٨ ، بداية المجتهد ج٢ ص١٥٥ ، ١٥٦ ، حاشية الدسوقي ج٣ ص٢٥ ، المجموع ج٩ ص٣٠١ ، المغني مع الشرح الكبير ج٦ ص٣٣ ، الإنصاف للمرداوي ج٤ ص٢٩٦ ، المحلي ج٨ ص٣٣٧ وما بعدها ، عقد التوريد لأبي سليمان ١٩ عدد ١٢ ص٦٩١ ، عقد التوريد لعادل شاهين ج١ ص٢٨٥ .

٤ . القصد الأساسي من العقد هو التبادل الفعلي للسلع بحصول المشتري على السلعة المطلوبة لتلبية احتياجاته أو احتياجات السوق ، وحصول البائع على الربح لتسويق منتجاته ، واطمئنان كل منهما على ما يتم عليه العقد بالصفات وفي الزمان، والمكان المحددين في العقد .

٥ . كلا العقدين يحققان مفهوم عقد البيع شرعاً فهما من بيوع الصفات.

٦ . لا حضور للعوذين الثمن والمثمن أثناء العقد ، وإنما يتم تسليم الثمن كله ، أو دفعه على أقساط بعد استلام المشتري للبضاعة ^(١) .

إلا أن عقد التوريد يختلف عن عقد البيع على الصفة في أن المعقود عليه في عقد التوريد هو السلع المنقولة فلا يرد على العقار ، أما في بيع الغائب على الصفة فيرد على العقار ^(٢) .

مناقشة هذا الدليل :

نوقش ذلك بأن بيع الصفة على العين الخارجية قد يتأجل فيه العوضان عن مجلس العقد ، وهو بيع صحيح ، بخلاف عقود التوريد التي يكون فيها تأجيل الثمن والمثمن في متن العقد ، فلا يصح الاستدلال به ^(٣) .

(١) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ج١٢ ص٦٩١ ، ٦٩٢ ، ٧٤٤ بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ المكتبة الشاملة ،

عقد التوريد د. عادل شاهين ج١ ص٢٩٧ ، ٢٩٨ .

(٢) عقد التوريد د. عادل شاهين ج١ ص٢٩٨ .

(٣) هذا كلام الشيخ حسن الجواهري ردًا على د. عبد الوهاب أبو سليمان .

٧ . أن المقتضى لهذا العقد فى صيغته السليمة الخالية من المحظورات يحقق مصالح متعددة لأطراف متعددين : البائع ، المشتري ، المصدر ، المستورد ، والمجتمع .

٨ . أن الحاجة إلى عقد التوريد ليست خاصة بأمة دون أمة بل أصبح حاجة الأمم والشعوب فى كافة أقطار الدنيا والقاعدة " أن الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة " (١) (٢) .

مناقشة هذا الدليل :

ناقش الشيخ حسن الجواهري هذا الدليل قائلاً : " لا أرى من الصحة جعل الحاجة والضرورة إلى عقد التوريد دليلاً لصحته ؛ لأن الحاجة والضرورة إنما تصح العقد ، ويكون الحكم ثانوياً مقيداً بها (٣) .

مناقشة باقى الأدلة :

وُجّه بعض المناقشات لتلك الأدلة بأن هناك محاذير ومحظورات على ذلك منها:

١ . أن البعد المكاني يؤدي إلى تغير الصفات، ويعرض السلعة للهلاك .

مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٨٢٧ .

(١) عقد التوريد د. عبد الوهاب أبو سليمان عدد ١٢ ص ٦٩٤ .

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١ ، والأشباه والنظائر للسيوطى ج ١ ص ١٧٢ .

(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٨٢٨ التعقيب والمناقشة .

أجيب عن ذلك:

بأن التحوط لهذا الأمر وجيه ، ووضعه في الاعتبار الفقهي في الماضي منطقي ومنسجم مع الوضع الاجتماعي ، والتجاري ، والأمني السابق ، أما وقد زالت أسبابه في الوقت الحاضر بسبب التطور في وسائل النقل ، وأساليب الحفظ ، ووجود مؤسسات التأمين لضمان سلامة البضائع ، فقد أصبح اعتبار هذا وافترضه غير وارد ، وغير مؤثر في صحة العقد إذا انتفى وجوده ، بل إنه مرتفع عن كلا العقدين (البيع على الصفة . التوريد) في العصر الحديث .

٢ . أن العدول عن الرؤية إلى الوصف غرر ومخاطرة ، ويفضي إلى المنازعة ^(١).

أجيب عن ذلك:

بأن الفقهاء قد ذكروا من الشروط والقيود ، والآثار المترتبة على عدم الرؤية للمبيع ما يحفظ حق الطرفين ويمنع أسباب النزاع بينهما ، وما دام الوصف في العقد يمنع الجهالة والغرر ، ويسد باب المنازعة بين الطرفين فلا يؤثر ذلك على صحة العقد ^(٢) .

(١) عقد التوريد د . عبد الوهاب أبو سليمان عدد ١٢ ص ٦٩٢ .
(٢) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية د . عبد الوهاب أبو سليمان عدد ١٢ ص ٦٩٢
مجلة مجمع الفقه الإسلامي بالمكتبة الشاملة .

وعليه فإنه يمكن إلحاق عقد التوريد بعقد البيع على الصفة فيأخذ حكمه من حيث الجواز والأحكام^(١) .

الرأى الخامس:

أن عقد^(٢) التوريد ينطبق عليه ما أسماه فقهاء الحنفية بيع الاستجرار^(٣) . فالآن أغلب الموظفين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن

(١) يقول د . عادل شاهين : " قد أغفل المجمع فى قراره المتعلق بعقد التوريد هذه الصورة من صور عقد التوريد حيث اقتصر فى قراره على صورتى السلم والاستصناع " . عقد التوريد د . عادل شاهين ج١ هامش ص٢٩٩ .

(٢) هذا رأى د . وهبة الزحيلي وقال : إن الأدق أن يُقال لعقود التوريد " إتفاق التوريد " ثم ينقلب الأمر من اتفاق إلى عقد عند التنفيذ .

مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص٨٢ " المناقشة " .
(٣) **الاستجرار لغة** : مأخوذ من الجر وهو الجذب والسحب والتأخير والتتابع واستدامة الأمر ، يقال جررت الحبل وغيره أجره جراً ، أى جذبته .
لسان العرب ج١ ص٤٠٤ م جرر ، القاموس المحيط ج١ ص٤٠٢ فصل الجيم .
باب الرأى .

واصطلاحاً : لم يضع الفقهاء القدامى لهذا البيع تعريفاً اصطلاحياً معروفاً ولكن وردت له صور وأحكام من خلالها يمكن تعريفه بأنه : " أخذ مشتر من بائع دائم العمل ما يحتاجه شيئاً فشيئاً فى مقابل ثمن " . ولقد أطلق المالكية على بيع الاستجرار " بيعة أهل المدينة " = لاشتهارها بينهم ، وفيها كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئاً معلوماً ويشرع فى الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء ، وكذلك كل ما يباع فى الأسواق ولا يكون إلا بأمر معلوم يسمى ما يأخذ كل يوم وكان العطاء يومئذ مأموناً ولم يروه ديناً بدين . . . قال مالك : ولا أرى به بأساً إذا كان العطاء مأموناً ، وكان الثمن إلى أجل .

وأطلق عليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم " البيع بالسعر " . البحر الرائق ج٥ ص٢٧٩ ، مواهب الجليل ج٥ ص٣٥٨ ، نهاية المحتاج ج٣ ص٣٥٧ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ج٢٩ ص٢٣٢ .

حكم بيع الاستجرار :

إذا كان الثمن معيناً ومؤجلاً بأجل معلوم ومتفقاً عليه بين العاقدین فإن هذا البيع جائز بلا خلاف ، وهو ما أجمع عليه أهل المدينة . أما إذا كان الثمن مؤخراً وغير معلوم كأن يحاسب فى نهاية الشهر مثلاً بثمن المثل فقد اختلف الفقهاء فى ذلك ما بين مانع ومجيز ؛ ومن أجاز هذه الصورة متأخري الحنفية فقد أجازوها

السلعة على الفور ، فيتفقون مع البقاليات ومع الجزارين ومع باعة الخُضَر والفواكه فى أن يقدم لهم يوميًا أو فى كل فترة زمنية أشياء معينة وفى نهاية الشهر يتم الحساب . فالجهالة تزول بالمواصفات ، فهو بيع شىء موصوف وهناك مواصفات معينة دقيقة للأمور التى يقدمها المورد من خلال الاتفاق العام الذى تم مع هذه الجهة ؛ فينقلب هذا من اتفاق إلى بيع مفصّل ودقيق وهذا ما ذهب إليه د . وهبة الزحيلي ^(١) ، وسبق إليه د . مصطفى الزرقا ^(٢) .

الأدلة على ذلك :

استدل أصحاب هذا الرأى على أن عقد التوريد يشبه عقد الاسترجار بالمعقول وهو :

١ . أن عقد التوريد تنظمه الأعراف المعاصرة الآن ، ولا أجد أى إشكال فى جوازه ؛ لأنه لا يتحقق فيه غبن أو ضرر ، وكل ذلك يتم بالتراضى والاتفاق الشامل . فهو مجرد اتفاق أولى بين الجهة المستفيدة والجهة المقدمة لهذه الخدمات .

استحسنًا وابن تيمية وابن القيم والإمام الغزالي من الشافعية ، ومنع ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد فى رواية والظاهرية . البحر الرائق ج٥ ص ٢٧٩ ، مواهب الجليل للحطاب ج٤ ص ٤٧١ ، مغنى المحتاج ج٢ ص ٤٩ ، المجموع ج٩ ص ٣٣٣ ، المغنى ج٦ ص ٣٦ ، المحلى لابن حزم ج٩ ص ١٥ ، ٢٣ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ج٢٩ ص ٢٣٢ .

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٨٢ ، ٨٢٥ بالمكتبة الشاملة .

(٢) المرجع السابق نفسه ص ٨٣٣ .

وعقد التوريد بيع من البيوع المتعارف عليها والمتفق عليها ولا إشكال فيه من الناحية الشرعية (١) .

٢ . أن هناك أوجه اتفاق بين عقد التوريد وعقد الاستمرار منها:

(أ) أن كلا العقدين فى بعض صورهما يرد على مبيع موصوف فى الذمة .

(ب) أن الثمن فى العقدين مؤخر .

(ج) أن كلا العقدين من عقود المعاوضات المالية؛ حيث يتم فيهما مبادلة سلعة فى مقابل ثمن (٢) .

أوجه الاختلاف بين عقد التوريد وبيع الاستمرار :

يختلف عقد التوريد عن بيع الاستمرار فى أمور منها :

١- أن عقد التوريد يتم تسليم المبيع فيه على دفعة واحدة أو على دفعات أما بيع الاستمرار فهو يتم على دفعات دورية منتظمة ويؤخذ فيه المبيع شيئاً فشيئاً.

(١) المرجع السابق نفسه ص ٨٢٤ ، ٨٢٥ .
(٢) المبسوط للسرخسى ج ١٢ ص ١٢٧ ، مواهب الجليل ج ٥ ص ٥٣٨ ، المجموع ج ٩ ص ١٦٣ ، شرح منتهى الإرادات ج ٢ ص ٢١٨ ، ٢١٩ ، عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية د . عبد الوهاب أبو سليمان بمجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٦٩٩ ، عقد التوريد لعادل شاهين ج ٢ ص ٣٢ .

٢- أن عقد التوريد يرد على سلعة موصوفة في الذمة أو غائبة .
أما بيع الاستمرار فإنه يرد على سلعة حاضرة مرئية للعاقدين ،
فيأخذها المشتري ثم يدفع ثمنها بعد ذلك (١) .

الرأى السادس:

قال الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير فى حكم عقد التوريد " إنى متوقف فى هذا الحكم حتى يتبين لنا فائدة هذا العقد ، وأن مبدأ الحاجة ينطبق عليه انطباقاً كاملاً (٢) .

(١) البحر الرائق ج٥ ص ٢٧٩ ، منح الجليل ج٥ ص ٣٨٤ ، المجموع ج٩ ص ١٦٤ ،
عقد التوريد لمنذر قحف ص ٨ ، عقد التوريد لعادل شاهين ج١ ص ٣٢٣ ،
مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٨٣٠ المناقشة .
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٨٤٧ المناقشة .

حكم عقد التوريد إجمالاً

للفقهاء فى عقد التوريد ستة آراء سأوردها إجمالاً حتى يسهل الوقوف على الحكم لطالبه:

الرأى الأول: عقد التوريد عقد جديد مستقل فى ذاته وصفاته وهو من العقود المستحدثة التى لم ينص عليها الفقهاء ، وهو عقد جائز إذا خلا من المحظورات الشرعية المتعلقة بالعاقدين ، والعوضين ، وصفة العقد ، وألا يتعارض مع نص من الكتاب أو السنة أو القواعد الشرعية المقررة . وبه قال كثير من العلماء المعاصرين منهم د . عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، و د . مصطفى الزرقا وغيرهم (١) .

الرأى الثانى: أن عقد التوريد إذا كان على سلعة تتطلب صناعة فيأخذ حكم الاستصناع، وقد أجاز الحنفية الاستصناع مع عدم ضرورة تعجيل الثمن، وقرر مجمع الفقه الإسلامى أن محل عقد التوريد إذا كان سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناعاً تنطبق عليه أحكامه ، وبهذا قال القاضى محمد تقى العثمانى (٢) .

الرأى الثالث: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهى موصوفة فى الذمة يلتزم المورد بتسليمها عند الأجل فهذا العقد يأخذ

(١) بدائع الصنائع ج٥ صه ، المدونة ج٤ ص١٩ ، تحفة المحتاج ج٥ ص١٩ ، ٢٠ ، المغنى والشرح الكبير ج٦ ص٣٦٧ ، مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص٦٧٩ ، ٨١١ .

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص٦٧٩ ، ٨١١ .

حكم السلم ^(١). وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي، وبه قال رفيق
يونس المصري ^(٢).

الرأى الرابع : إن عقد التوريد يُنزل على عقد من العقود المسماة
الأكثر شبهاً به وهو عقد البيع على الصفة ، أو ما يسمى "بيع
الصفات" ^(٣) .

وهو ما ذهب إليه د . عبد الوهاب أبو سليمان فى أحد تخريجه ^(٤) .

الرأى الخامس : أن عقد التوريد ينطبق عليه ما أسماه فقهاء الحنفية
بيع الاستجرار ^(٥) وبه قال د. وهبة الزحيلي ، وسبق إليه د . مصطفى
الزرقا ^(٦) .

(١) ولقد اتفق الفقهاء على مشروعية عقد السلم إذا ما توافرت فيه الشروط المعتبرة
فى السلم. بدائع الصنائع ج٥ ص ٢٠١ ، شرح الخرشي على مختصر خليل
ج٥ ص ٢١٤ ، مغنى المحتاج ج٢٢ ص ١٠ ، المغنى مع الشرح الكبير
ج٦ ص ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، المحلى لابن حزم ج٩ ص ١٠٥ ، ج١٠ ص ١٠٩ .

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٨٥٠ .

(٣) البيع على الصفة من العقود التى اختلف فيها الفقهاء ما بين مانع ومجيز . فأكثر
الفقهاء على جواز البيع على الصفة ، ومنعه الشافعية فى الجديد والحنابلة فى
رواية . المجموع ج٩ ص ٣٠١ ، المغنى مع الشرح الكبير ج٦ ص ٣٣ .

(٤) عقد التوريد لعبد الوهاب أبو سليمان عدد ١٢ ص ٦٩١ .

(٥) بيع الاستجرار أجازة متأخرو الحنفية استحساناً وابن تيمية وابن القيم والغزالي .
البحر الرائق ج٥ ص ٢٧٩ ، مواهب الجليل ج٤ ص ٤٧١ ، المجموع
ج٩ ص ٣٣٣ ، المغنى ج٦ ص ٣٦ ، المحلى ج٩ ص ٣١ ، مجموع فتاوى ابن
تيمية ج٢٩ ص ٢٣٢ .

(٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٨٣٣ .

الرأى السادس: توقف الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير فى حكم عقد التوريد وقال : (إنى متوقف فى هذا الحكم حتى يتبين لنا فائدة هذا العقد ، وأن مبدأ الحاجة ينطبق عليه انطباقاً كاملاً ^(١) .

الرأى الراجع:

بعد عرض آراء الفقهاء المعاصرين وأدلتهم ومناقشة هذه الأدلة فإنى أميل إلى ترجيح الرأى الأول الذى ينص على أن عقد التوريد من العقود المستجدة التى فرضت نفسها على الساحة وأفرزتها المعاملات المعاصرة ، وهو عقد مستقل فى ذاته وصفاته وهو عقد جائز ؛ لأنه يعد عصب الحركة التجارية محلياً ودولياً وقد فرض هذا العقد وجوده فى المجتمعات الإسلامية ؛ ولذلك فإنه جائز لحاجة الناس إليه ولأن الأصل فى المعاملات الإباحة بشرط خلوه من المحظورات الشرعية فيما يتعلق بأركانه وألا يتعارض مع نص من الكتاب أو السنة أو القواعد الشرعية المقررة وهو ما نص عليه كثير من العلماء المعاصرين منهم د/ عبد الوهاب أبو سليمان ، د/ مصطفى الزرقا ، والشيخ حسن الجواهري ، وعبد السميع إمام ، والصديق الضرير ، د/ وهبة الزحيلي فى أحد قوليه ، وغيرهم.

(١) المرجع السابق نفسه عدد ١٢ ص ٨٤٧ .

المبحث الثالث

وفيه سبعة مطالب

المطلب الأول

في ضوابط عقد التوريد

إن الشريعة الإسلامية قد وضعت لعقد التوريد وغيره من العقود المستجدة بعض الضوابط التي تجعل العقد غير مخالف لما هو مباح من قواعد المعاملات ومن هذه الضوابط :

١- أن يكون الغرض من هذا العقد سد حاجة مشروعة وتحقيق مصلحة معتبرة لأطرافه .

٢- أن يخلو العقد من الغرر الفاحش ، ومن الغش والتدليس والربا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وألا يؤدي إلى ضرر بالآخرين ، أو إلى حرمان ذي حق من حقه المشروع .

٣- أن يخلو هذا العقد من معارضة نص صريح أو إجماع أو قاعدة شرعية ثابتة أو قصد من مقاصد الشريعة ^(١) .

٤- أن يتوفر فيه رضا المتعاقدين حيث إن رضا المتعاقدين ^(٢) أصل في العقود . قال تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

(١) عقد التوريد في الفقه الإسلامي لنمر صالح ص٤٧ .

(٢) عقد التوريد لعادل شاهين ج١ ص٢١٦ .

مِّنْكُمْ»^(١)، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾^(٢). فلم يشترط سبحانه وتعالى فى التجارة إلا التراضى .

وكذلك فإن طيب النفس هو المبيع لأكل الصداق . فإذا كان التراضى هو المبيع للتجارة وطيب النفس هو المبيع لأكل الصداق . فقد ثبت حل ذلك بدلالة القرآن^(٣) .

٥- أن يُعتبر العُرف فى هذا العقد ما لم يخالف نصاً وأصلاً من أصول الشرع^(٤) .

(١) سورة النساء من الآية ٢٩ .

(٢) سورة النساء من الآية ٤ .

(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ج٢٩ ص١٥٥ .

(٤) عقد التوريد لعادل شاهين ج١ ص٢١٨ .

المطلب الثانى

في العناصر المؤثرة فى صحة العقد

وبعض المحاذير على عقد التوريد

أولاً: العناصر المؤثرة فى صحة عقد التوريد:

١- أن السلعة غير موجودة فى مجلس العقد ، وقد تكون معدومة فى البلد المصدر لها لأنها مما يصنع حسب الطلب ، وهذا هو الغالب .

٢- أن العقد يتم على أساس الوصف ، أو مشاهدة عيّنة ^(١) لها .

٣- أن المشتري لا يدفع الثمن حالاً ، ولكن يدفعه لدى تسليمه السلعة إما دفعة واحدة ، أو على أقساط ^(٢) .

ثانياً: بعض المحاذير الواردة على عقد التوريد:

ذكر د . عبد الوهاب أبو سليمان بعض المحاذير على عقد التوريد منها:

■ البعد المكانى يؤدى إلى تغير الصفات ويعرض السلعة للهلاك.

(١) العيّنة لغة : هى جزء من المادة يؤخذ منها نموذجاً لسائرهما ، وتُجمع على عينات. المصباح المنير ص ٦٢ .

(٢) عقد التوريد دراسة فقهية مقارنة د . عبد الوهاب أبو سليمان . مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٦٩٠ المكتبة الشاملة .

■ أن العدول عن الرؤية إلى الوصف غرر ومخاطرة ويفضى إلى المنازعة ^(١) .

وأجاب عن ذلك الشيخ عبد الله بن منيع :

بأن اختلاف الصفة لمشتري سلعة بالصفقة إذا اختلفت الصفة فله خيار الصفة ، وفي نفس الأمر كذلك له خيار الرؤية ^(٢) .

(١) عقد التوريد . مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد ١٢ ص ٤٤ " المناقشة " .

(٢) المرجع السابق نفسه .

المطلب الثالث

في التزامات كل من المورد والمستورد

عقد التوريد ذو طبيعة خاصة ؛ إذ هو من العقود التي تُنفذ في المستقبل ^(١) سواء أكان هذا التنفيذ على دفعة واحدة أو كان على دفعات دورية؛ ولذلك يجب على كل من المورد والمستورد الالتزام بالشروط التي ارتضاها كل منهما .

أولاً : التزامات المورد :

١ . التسليم في المواعيد المحددة في العقد .

يجب على المورد الالتزام التام بالمدة المحددة في العقد ؛ بحيث يقوم بتجهيز السلعة فيقوم بتصنيعها إذا كانت مما يصنع أو جلبها من منتجها إذا كان وكيلاً لها ^(٢) .

٢ . التزام المورد بالشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد .

(١) قال القاضي محمد تقي العثماني : " أن عقد التوريد عقد مضاف إلى المستقبل ومنعه الجمهور وهذا إشكال في هذا العقد . وأجاب عن ذلك : الشيخ حسن الجواهري فقال : " ليس عقد التوريد عقد يضاف إلى المستقبل ، أي ليس عقدًا معلقًا ، بل هو عقد ناجز ؛ إذ قد ملك كل من المتعاملين شيئًا في ذمة الآخر عند تمامية الإيجاب والقبول . أما ما منعه الجمهور فهو عبارة عن كون التملك معلقًا ونفس التملك مضافًا إلى المستقبل لا ما نحن فيه . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢ ص ٨٢٩ - المناقشة .

(٢) عقد التوريد لعادل شاهين نقلًا عن عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة) لعاطف سعدي ص ٤٥٦ .

٣ . التزام المورد بتنفيذ العقد بنفسه .

يجب على المورد أن يقوم بتنفيذ العقد بنفسه سواء أكان المورد فردًا أو مؤسسة أو شركة إذا ما تم الاتفاق على ذلك .

ثانيًا : التزامات المستورد:

١ . تمكين المورد من تنفيذ العقد .

فيجب التعاون التام بين المورد والمستورد حتى يتمكن المورد من تنفيذ العقد على الوجه الذي تم الاتفاق عليه .

فإذا كان العقد على خدمات كالكهرباء والغاز ونحوهما فإن تنفيذ هذه العقود من قبل المورد كشركة الكهرباء أو الغاز يقتضي من المستورد تهيئة المكان والمباني التي تورّد إليها هذه الخدمات ، فيخصص المستورد غرفة للكهرباء في عمارته أو منزله ونحو ذلك .

٢ . التزام المستورد بدفع الثمن المتفق عليه للمورد .

٣ . التزام المستورد باستلام السلعة ، إذا جاءت في موعدها وكانت مطابقة لما هو متفق عليه ، وليس له الامتناع عن ذلك ^(١) .

(١) عقد التوريد لعادل شاهين ج٢ ص ٥٨٩ - ٥٩٢ .

المطلب الرابع

في عقد التوريد من الباطن وأركانه وصورة

تعريف التوريد من الباطن هو : عقد يتعهد بمقتضاه طرف بتسليم سلع معلومة مؤجلة ، بصفة دورية ، خلال مدة معينة بمبلغ معين مؤجل كله أو بعضه ، لطرف آخر قد أبرم عقداً مماثلاً مع طرف ثالث^(١).

أو : أن يتقبل شخص من المورد الأصلي تنفيذ عقد التوريد أو بعضه بعقد يبرمه معه ، ويعمل مستقلاً عن المورد الأصلي ، ثم يسلم العمل بعد إنجازه^(٢) .

أركان عقد التوريد من الباطن

تقدم أن أركان عقد التوريد الأصلي عاقدان وهما المورد والمستورد ومعقود عليه وهو السلعة المراد توريدها . أما عقد التوريد من الباطن فأركانه : مستورد أصلي ، ومورّد أول ، ومورّد ثان من الباطن وأوسطهم وسيط بين العقدين ، يمثل طرفاً في كلا العقدين فهو في

(١) العقد من الباطن في الفقه الإسلامي لسامي بن عبد العزيز الماجد ص ٣٠٨ رسالة دكتوراه . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . كلية الشريعة . قسم الفقه ١٤٢٨ هـ / ١٤٢٩ .

(٢) عقد التوريد للمطلق ص ٥١ ، عقد التوريد الإداري ص ٣٧٠ .

عقد التوريد الأصلي مورد ، وهو في عقد التوريد من الباطن مستورد وأما الآخرا فلا يجمعهما أي عقد مباشر ^(١) .

صور التوريد من الباطن:

هناك صورٌ عديدة لعقد التوريد من الباطن، منها:

(١) أن يبرم أحد الموردّين عقد توريد مع جهة ما ، ليورد لها سلعة معينة، ثم يتعاقد من الباطن مع مورّد آخر، ليورد ما التزم هو بتوريده بعقد التوريد الأصلي ويكون ذلك بإذن صريح من المستورد ، أو بما يتضمن الإذن عرفا ؛ كأن يكون عقد التوريد كبيرا ، ويعلم المستورد أن المورد لا يستطيع أن يفي بأعبائه وحده ، ولابد أن يستعين بمورد من الباطن .

(٢) وهناك توريد بدون إذن المستورد كأن يشترط المستورد على المورد ألا يعهد بتوريد المادة المطلوبة إلى غيره من الموردّين ، فيخالف شرطه ^(٢) .

(١) المرجع السابق نفسه ص ٣٢٨ : ٣٣٠ .
(٢) العقد الباطن في الفقه الإسلامي ص ٣١٦ .

المطلب الخامس

في حكم التوريد من الباطن

ينطبق على التوريد من الباطن حكم التوريد الأصلي وهو الجواز إذا ما توافرت في التوريد من الباطن الضوابط التالية : (١)

١ - ألا يكون المستورد الأصلي قد اشترط على المورد الأول أن يورد المطلوب بنفسه .

٢ - ألا يكون العمل المعقود عليه مما يختلف باختلاف الموردين .

٣ - ألا يكون عقد التوريد من الباطن عقدًا صوريًا تحايلًا على الربا وحتى لا يكون العقد كذلك فلا بد أن يكون عقد التوريد من الباطن منفصلًا عن عقد التوريد الأصلي وأن يكون المورد من الباطن مستقلًا تمامًا عن المستورد الأصلي ، غير تابع له .

وأن يتحمل المورد الأول ما عليه من تبعات عقد التوريد الأصلي من الالتزام بتسليم العين الموردة في المدة المحددة دون أن يحيل الأمر برمته إلى المورد من الباطن .

(١) هذه الضوابط يتميز بها عقد التوريد من الباطن عن عقد التوريد الأصلي .

المطلب السادس

في الفرق بين التوريد من الباطن والتنازل عن العقد^(١)

هناك فرق كبير بين التوريد من الباطن والتنازل عن العقد ؛ فالتوريد من الباطن يبقى أحد أطراف العقد (الطرف المشترك) المورد الأول محتفظاً بحقوقه أو متحملاً لالتزاماته تجاه الطرف الأصلي ، وفي الوقت نفسه تصير له حقوق وعليه التزامات تجاه الطرف الآخر في العقد من الباطن ، ويظل المتعاقد من الباطن غيراً بالنسبة للطرف الآخر في العقد الأصلي ، وليست بينهما علاقة عقدية ، ولا يسأل أمامه ، وإنما يبقى الطرف المشترك هو المسئول عن التزاماته تجاه الطرف الآخر في العقد الأصلي، والعقد من الباطن.

أما التنازل عن العقد فيختلف عن العقد من الباطن في كل هذه الوجوه؛ ففي التنازل عن العقد يوجد تنازل عن الصفة التعاقدية .وهناك عقدان أحدهما العقد الذي يبرم أساساً لإنشاء التزام بعمل أو بإعطاء ثم يأتي في وقت لاحق عقد آخر هو عقد التنازل محله "التنازل عن العقد" هذا العقد يختلف تماماً في محله عن العقد الأول ويقصد

(١) التنازل عن العقد " مصطلح قانوني " وهو عبارة عن اتفاق يراد به نقل حقوق أحد المتعاقدين ، والتزاماته الناشئة عن عقد ما ، إلى طرف ثالث يسمى المتنازل له .

العقد الباطن في الفقه الإسلامي نقلاً عن عقد الإيجار د . بدر اليعقوب ص ١٧٠ ، عقد المقاوله من الباطن د . مصطفى الجارحي ص ٢٤ ، ٢٥ .

الأطراف في عقد التنازل أن يحل المتصرف إليه محل المتصرف في العقد في جميع حقوقه والتزاماته ، وأن يخرج المتصرف نهائياً من دائرة العقد . ويترتب على التنازل عن العقد أن تنشأ علاقة مباشرة ومتبادلة فيما بين المتنازل لديه (المالك الأصلي) والمتنازل له دون تدخل المتنازل ويكيّف القانونيون هذا الرأي على أنه حوالة لحق وحوالة للدين في آن واحد ؛ حيث يحيل فيه المتنازل حقوقه والتزاماته إلى شخص ثالث يسمى المتنازل له ؛ إلا أنه يوجد قاسم مشترك أو وجهي شبه بين التعاقد من الباطن ، والتنازل عن العقد ، وهو أن كلا العقدين ينشأ عن عقد سابق . وأن المتعاقدين (المورد والمستورد) مثلاً إذا اتفقا على عدم التعاقد من الباطن (كأن يعمل المورد بنفسه) أو عدم التنازل عن العقد فلا يجوز للمستورد أو المتنازل أن يورد من الباطن أو أن يتنازل عن العقد ^(١) ؛ فقد جعل القانون حظر أحدهما حظراً للآخر.

(١) عقد المقابلة من الباطن د. مصطفى الجارحي ص ٢٤ - ٢٦ ، التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن د. إسماعيل المحاقري كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء - مجلة البحوث القضائية. العدد ٧ - يونيو ٢٠٠٧ ص ١٦٨ - ٧١ ، حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والإيجار من الباطن لمحِب النبي .

المطلب السابع

في انتهاء عقد التوريد

هناك عدة أسباب ينتهي بها عقد التوريد، منها:

١ . عقد التوريد كغيره من العقود ينتهي نهاية طبيعية بتمامه ووفاء كل من المورد والمستورد بالتزاماتهما ، وذلك بالتزام المورد بتسليم السلعة للمستورد بالصفات المحددة سواء أكانت دفعة واحدة أو دفعات في مواعيد محددة . كما يلتزم المستورد بدفع الثمن المعين المتفق عليه .

٢ . انتهاء المدة المحددة للعقد .

إن عقد التوريد ينتهي بانتهاء المدة المحددة له ، وعقد التوريد في ذلك كعقد الإجارة ، فإذا استأجر داره لمدة سنة فإن العقد ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها.

٣ . انتهاء التوريد بالإقالة ^(١) .

يعد عقد التوريد من عقود المعاوضات التي يتم فيها مبادلة مال بمال ويكون التوريد محتملاً للإقالة كما في عقد البيع والإجارة .

(١) الإقالة لغة : من قال البيع وأقاله إقالة ، وتقابل البيعان : تفاسخا صفقتهما ، وتقايلا إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه ، والثنن إلى المشتري ، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما .

واصطلاحاً : رفع أثر عقد وإزالته بتراضى طرفيه .
لسان العرب ج٥ ص ٣٥٥ م قيل ، بدائع الصنائع ج٦ ص ٨٠ ، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج٢ ص ٥١٠ .

وقد أجاز الفقهاء الإقالة مستدلين بحديث المصطفى ﷺ أنه قال : " من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة " (١) .

وتكون الإقالة سبباً من أسباب انتهاء عقد التوريد ؛ فلو أقال المورد أو المستورد صاحبه من إكمال تنفيذ العقد وقبل الآخر بالإقالة . صحت الإقالة وانفسخ العقد ولو لم يحصل قبض للسلعة سواء أكانت غائبة أو في الذمة ؛ لأن الإقالة فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض (٢) .

٤ . انتهاء عقد التوريد بهلاك المعقود عليه :

ينفسخ عقد التوريد بهلاك المعقود عليه وتلفه بأفة سماوية تذهب به ويكون تلفه حينئذ تلفاً لا ضمان فيه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إذا تلف المعقود عليه قبل التمكين من القبض تلفاً لا ضمان فيه انفسخ العقد ، وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار " (٣) .

٥ . انتهاء عقد التوريد بمخالفة المعقود عليه للمواصفات والشروط المتفق عليها .

إذا جاءت السلعة معيبة بعيب مؤثر في قيمتها بأن ينقص من قيمتها ولم يرض به المستورد ولم يكن بمقدور المورد إصلاحه فإنه ينفسخ عقد التوريد وعلى المورد كامل الثمن إذا كان قد قبضه كله أو جزءاً منه ، فإن لم يكن قبضه فلا يحق له المطالبة به حينئذ كذلك إذا

(١) سنن ابن ماجه . كتاب التجارات . باب الإقالة ج٣ ص ٣٦ .

(٢) المغني والشرح الكبير ج٦ ص ٢٠٠ ، كشف القناع ج٣ ص ٢٤٨ ، ٢٤٩ .

(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ج٣ ص ٢٦٧ .

جاءت السلعة مخالفة للمواصفات إما بتخلف وصف اشتراطه المستورد فإن له فسخ العقد والرجوع على المورد بالثمن (١) .

٦ . انتهاء عقد التوريد بالموت :

عقد التوريد إما أن يكون العاقد فيه شخصية اعتبارية أو شخصيته عادية ؛ فإن كان العاقد شخصية اعتبارية فلا يرد عليه هذا الأمر وهو الموت . أما إذا كان العاقد شخصيته عادية ، فإذا كان المورد أو المستورد من الأفراد الطبيعية ، فإذا مات كل منهما أو أحدهما فإن عقد التوريد من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع والإجارة كما تقدم وعليه فإن عقد البيع متى لزم فإن ما ينشأ عنه من التزامات لا تبطل بموت أحد المتعاقدين أو كليهما . فإن مات البائع قام ورثته مقامه بإيفاء ما عليه من التزامات تجاه المشتري ، وإذا مات المشتري قام ورثته بإيفاء ما عليه من التزامات تجاه البائع وهذا ما اتفق عليها الفقهاء (٢) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن مات المتبايعان ، فورثتهما بمنزلتهما .. ، لأنهم يقومون مقامهما في أخذ ما لهما ، وإرث حقوقهما ، فكذاك ما يلزمهما أو يصير لهما " (٣)

(١) عقد التوريد د / عادل شاهين ج٢ ص ٧١٦ .

(٢) المبسوط ج١٣ ص ٣٢ ، ٣٣ ، المدونة ج٤ ص ٩٣ ، المجموع ج٩ ص ٢١١ ،

المغني ج٦ ص ٢٨٦ ، عقد التوريد لعادل شاهين ج٢ ص ٧٠٢ .

(٣) المغني ج٦ ص ٢٨٦ ، عقد التوريد لعادل شاهين ج٢ ص ٧٠٢ .

القسم الخامس

في أحكام المناقصات في الفقه الإسلامي

ويحتوي على ثلاث وحدات:

الوحدة الأولى :

في بيان مفهوم المناقصة وإجراءاتها والأسس التي تقوم عليها

أهداف الوحدة الأولى:

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على أن :

١ - معرفة مفهوم المناقصة.

٢ - الالمام بإجراءات المناقصات، والأسس التي تقوم عليها.

١- توضيح طرفي التعاقد في المناقصات، وأنواعها المتعددة.

-٢-

الوحدة الأولى:

في بيان مفهوم المناقصة، وإجراءاتها، والأسس التي تقوم عليها، وأنواعها

أولاً: مفهوم المناقصة:

المناقصة لغة : يقال نقص الشيء نقصاً ونقصاناً، وانتقص المشتري الثمن أي استحط، والنقيصة : العيب، والنقص : الخسران في الحظ، والنقصان اسم للقدر الذاهب من المنقوص، وتناقص الشيء أي نقص شيئاً فشيئاً^(١).

والمناقصة عكس المزايدة، وهي تنافس في عرض أقل الأسعار، وهي طرح مشروع بناء أو شراء بضائع أو غيرها فيقع الالتزام على من قدم أحسن الشروط من ناحية الخدمة المطلوبة وأرخص الأسعار^(٢).

المناقصة اصطلاحاً : نظراً لأن المناقصة من العقود الحديثة لم أجد لها تعريفاً في كتب الفقهاء القدامى بينما عرفها بعض العلماء المعاصرين :

فقد عرفها الدكتور عاطف أبو هريبد^(١) : هي إجراء بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنة عنه بالتعاقد مع صاحب عرض العوض الأقل من

(١) الصحاح في اللغة ج ٢ ص ٢٢ ، القاموس المحيط ج ١ ص ٨١٧ ، المصباح

المنير ج ٢ ص ٦٢١ ، المعجم الوسيط ج ٢ ص ٨١٥ .

(٢) معجم اللغة العربية المعاصرة ج ٢ ص ١٠١٥ ، ٣ ، ٢٢٦٩ .

عروض المتنافسين للفوز فيه ، نظير الوفاء بما التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة .

شرح التعريف:

إجراء: يشمل كل إجراء سواء كان إجراء تعاقدى أو غير تعاقدى ، وسواء تضمن التزاماً أو لم يتضمن .

بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنه عنه : وهذا قيد يخرج من التعريف كل إجراء لا يتضمن إلتزاماً ويبقى الإجراء الذي يقتضي التزاماً ، وإسناد الإلتزام للجهة المعلنه بيان لأحد أركان المناقصة .

بالتعاقد: قيد يخرج كل إجراء يتضمن التزاماً مستقلاً عن إرادة الغير ، لكون العقد إرتباط بين إرادتين .

مع صاحب عرض العوض الأقل من عروض المتنافسين للفوز فيه: هذا قيد يبين أنه عقد من عقود المنافسة سواء كان عقد مناقصة أو عقد مزايده ، وتقييد التعاقد بصاحب عرض العوض الأقل يخرج عقد المزايدة وهذا يعد ركناً من أركان المناقصة.

نظير الوفاء بما التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة: هذا قيد يبين أن العوض الذي تقدم به صاحبه إنما هو مقابل ما التزم به سواء كان هذا الإلتزام توريداً أو مقاوله أو غير ذلك ، بحيث يكون هذا

(١) عقود المناقصات في الفقه الإسلامى للشيخ عاطف أبو هرييد .

الالتزام مطابقاً للشروط والمواصفات المحددة من الجهة المعلنة للمناقصة.

بينما عرفها الدكتور/ رفيق المصري بأنها: طريقة نظامية خاضعة لنظام محدد، لشراء سلعة أو خدمة تلتزم فيها الإدارة (الجهة الإدارية)، بدعوة المناقصين لتقديم عطاءاتهم (عروضهم) وفق شروط ومواصفات محددة، لأجل الوصول إلى أرخص عطاء، بافتراض تساوي العطاءات في سائر المواصفات والشروط ^(١) .

وقيل هي طريقة تتبعها جهات تريد شراء سلع أو خدمات بأقل ما يعرض عليها من سعر ^(٢)، وهى عكس المزايدة .

فالمناقصة يجريها المشترون، ويطلبون العروض من البائعين، ويرسون العطاء على من يتقدم بأقل الأسعار .

أما المزايدة: فالذي يجريها البائعون، فهم يريدون أن يعقدوا البيع بأعلى سعر يتقدم به المشاركون، إذن فالمناقصة نجد أن الجهة الداعية لإجرائها ترغب بأقل سعر سواء كانت في شراء سلع أو في تقديم خدمة، وبالتالي فهي تجرى إما في عقود المقاولات عندما يتعلق الأمر بالإجارة أو الاستصناع- فالمقولة : هي أن يتعهد أحد

(١) د/ رفيق المصري: (مناقصات العقود الإدارية - عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة -)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع ج ٢ ص ١٨٨.

(٢) د/ محمد تقي العثماني : (عقود التوريد والمناقصة)، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر .

المتعاقدين بأن يصنع شيئاً للطرف الثاني، مقابل ثمن معين، فإن تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة كان مقولة في العرف، واستصناعاً في الشرع، وإن تعهد بتقديم العمل، كان مقولة في العرف، وإجارة في الشرع - أو في عقود التوريدات^(١) عندما يتعلق الأمر بسلعة^(٢).

والمناقصة تختلف عن الشراء المباشر حيث إن هناك إجراءات تسبقها وتمهد لها.

ثانياً: إجراءات المناقصات:

عندما تحتاج جهة إدارية ما إلى سلع للتوريد أو أعمال للتنفيذ فإن تلك الجهة في البداية تقدر القيمة التقريبية للتوريد أو للمشروع، وتتأكد من وجود الاعتماد اللازم للموازنة، ثم تشكل لجنة لوضع المواصفات والشروط مثل شرط التسليم في محل البائع أو في ميناء

(١) عقد التوريد: هو عقد بين جهة إدارية عامة ومنشأة خاصة (أو عامة)، على توريد أصناف (سلع، مواد) محددة الأوصاف، في تواريخ معينة، لقاء ثمن معين، يدفع على نجوم (أقساط)، د/ رفيق المصري: (مناقصات العقود الإدارية-عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع .

(٢) د/ محمد تقي العثماني: (عقود التوريد والمناقصة)، د/ رفيق المصري : (مناقصات العقود الإدارية-عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة-)، الشيخ/ مصطفى كمال التارزي (الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر) ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، والثاني عشر، والسابع، د/ سعد بن ترك : المعاملات المالية المعاصرة ص ١٩٠-١٩١ .

الشحن على ظهر المركب، أو في ميناء الوصول أو في مستودعات
الجهة الإدارية صاحبة المناقصة... إلخ .

خاصة أن هذه الشروط لها أثر في الثمن وفي تحديد الجهة
(البائع، المشتري) التي تتحمل المصاريف المختلفة كالشحن، والتفريغ،
والتأمين، والرسوم الجمركية... إلخ ^(١).

بعد وضع المواصفات والشروط، تجرى الدعوة إلى المناقصة عن طريق:-

١- الإعلان من خلال الصحف الكثيرة الانتشار - إذا كانت المناقصة
عامة- ويحدد في الإعلان الصنف أو العمل المطلوب، وقيمة دفتر
الشروط، وآخر موعد لتقديم العروض.

٢- يشترط للاشتراك في المناقصة شراء دفتر الشروط والذي يحتوي
على المعلومات التي أعدتها الجهة الإدارية حول المشروع ^(٢) .

٣- بعد الحصول على دفتر الشروط يدرس الراغبون في المشاركة في
المناقصة هذه الشروط فإذا وجدوا في أنفسهم القدرة والرغبة تقدموا
بعروضهم إلى الجهة الإدارية حسب المواعيد المحددة، على أن تقدم
هذه العروض في مظاريف مختومة (بالشمع الأحمر) وموقعة ولا

(١) د/ رفيق المصري: (مناقصات العقود الإدارية- عقود التوريد ومقاولات الأشغال

العامة -)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع ج ٢ ص ١٩٠.

(٢) د/ حسن الجواهري: (عقود التوريد والمناقصات)، د/رفيق المصري: المرجع

السابق: ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: التاسع ، والثاني

عشر.

يجوز فتحها إلا في الموعد المحدد لذلك، وليس للمناقصين بعد تقديم عروضهم تعديل الأسعار بالزيادة أو النقصان لما في هذا من الإخلال بمبدأ المساواة بين المناقصين ومبدأ السرية في المناقصات.

٤- تشكل لجنة لفتح المظاريف بعد التأكد من سلامة الأختام في موعد محدد بحضور المناقصين أو مندوبيهم .

٥- تشكل لجنة لفحص العروض، والتأكد من توافر الشروط الشكلية في العروض، ومطابقتها للشروط والمواصفات.

٦- تشكل لجنة للبت في العروض، ولا يحال إلى هذه اللجنة إلا العروض التي توافرت فيها الشروط، مثل تقديم الضمان الابتدائي، وصورة من شهادة السجل التجاري وبطاقة الاشتراك في الغرفة التجارية، أو الصناعية... إلخ حيث تقوم اللجنة باختيار العرض الأقل سعراً، وتعد محضراً توصي فيه بقبول هذا العرض وأسبابه^(١).

ثالثاً: الأسس التي تقوم عليها المناقصات:

المناقصات تقوم على مبدأين رئيسيين هما المنافسة والمساواة .

أولاً : مبدأ المنافسة: يراد بذلك إتاحة الفرصة لكل من تتوفر فيه شروط المناقصة أن يتقدم بعبائه وذلك حتى يكون المجال مفتوحاً للإدارة في اختيار من تراه مناسباً.

(١) المرجع السابق.

وهذا المبدأ يتطلب ضرورة الإعلان عن المناقصة حتى يتمكن كل من يرغب فيها أن يكون بين المتنافسين، وبالتالي لا تستطيع الإدارة منع أحد من التقدم إلى المناقصة المعلن عنها ما دام قد استوفى الشروط المطلوبة ، وللاعلان عن المناقصة فوائد كثيرة منها :

- ١- تجنب الإدارة أجواء الشك والريبة في التعامل النزيه في إبرام العقود.
 - ٢- إيجاد منافسة مشروعة بين الراغبين في التعاقد مما يؤدي إلى اختيار أفضل العقود.
 - ٣ - تأكيد مبدأ حرية التجارة والعمل والمساواة بين الأفراد في ذلك^(١).
- ثانياً مبدأ المساواة:

يعد من أهم الأسس التي تقوم عليها المناقصات وتتجلى مظاهر هذه المساواة من خلال ما يلي :

- ١- الإعلان عن المناقصة حتى يعلم بها أكبر عدد ممكن ، على أن يكون الإعلان في صحف واسعة الانتشار .
- ٢- تجنب ذكر مواصفات أو شروط تنطبق على بلد أو مُورد أو مقال بعينه.
- ٣- منح الجميع مهلة كافية للتقدم بالعروض.

(١) د/محمد الزيني : المناقصات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي ص١٦ ، الطبعة الأولى ١٤٢٣-٢٠٠٣م نقلاً من مراجع مختلفة.

٤- عدم إجراء أي تعديل في الشروط أو في المواصفات لمصلحة أحد المناقصين أو بعضهم، ولا استبعاد عطاءات البعض بقرارات عامة أو فردية، وأن تكون معايير قبول أو استبعاد العطاءات وفحصها و البت فيها واحدة للجميع.

٥- عدم العدول عن التعاقد مع صاحب العطاء الأقل سعراً، إلا بقرار مسبب وواضح.

٦- المساواة بين الجميع من حيث المعلومات والفرص واحترام المواعيد وإجراءات التسليم والصرف والضمان والغرامة وسحب العمل .

٧- في حالة التساوي بين عرضين أو أكثر يلجأ إلى التفاوض فلو بقى التساوي قائماً بعد التفاوض تقسم الكمية بينهما إذا أمكن ذلك، وإلا اختير أحدهما بالقرعة .

٨- وجود رقابة فعالة لمنع أي تجاوزات أو محاباة أو رشوة أو إفشاء للسرية لصالح أحد المناقصين أو بعضهم^(١).

(١) (مناقصات العقود الإدارية - عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة -)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد رقم ٩ ج ٢ ص ١٩٤ وما بعدها ، المناقصات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي ص ١٧ .

رابعاً: أطراف المناقصة وأنواعها:

للمناقصة طرفان:

الطرف الأول: الجهة الإدارية (صاحبة المناقصة) وهي التي تقوم بطرح المناقصة والإعلان عنها ، وهذه الجهة قد تكون مصلحة حكومية أو شركة من الشركات .

الطرف الثاني: الموردون أو المقاولون المشتركون في المناقصة^(١)، ودائماً يتنافس هؤلاء في الوصول إلى الفوز بالتعاقد مع الجهة الإدارية من خلال طرح أقل عطاء من وجهة نظره .

ثانياً: أنواع المناقصات : للمناقصات أنواع وتقسيمات لكنها لا تؤثر في تغيير الحكم الشرعي لها:

للمناقصات أنواع متعددة وباعتبارات مختلفة:

أولاً: باعتبار نظامها : تنقسم المناقصات باعتبار نظامها إلى مناقصات عامة ومناقصات محدودة:

أ- مناقصات عامة: وهي الأصل، بخلاف المحدودة، فالقاعدة العامة في تنفيذ المقاولات والتوريدات الحكومية هي أن تتم عن طريق مناقصة عامة توجه الدعوة للمشاركة فيها لعدد غير محدود من

(١) د/ رفيق المصري: (مناقصات العقود الإدارية - عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة -)، بحث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد رقم ٩ ج ٢ ص ١٨٩.

المناقصين وبالتالي تخضع لمبدأ العلانية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، ويعلن عنها في الصحف الرسمية^(١).

ب- المناقصة المحدودة : توجه الدعوة للمشاركة فيها إلى عدد محدود من المقاولين أو الموردين عن طريق الرسائل لمن تتوافر فيهم أهلية الاشتراك في المناقصة من حيث كفاءتهم المالية والفنية وأن يتوافر بشأنهم حسن السمعة، ويتوقع أن يكون عددهم قليلاً بالنظر إلى الإمكانيات الفنية والمالية المطلوبة، ويلجأ إليها استثناءً لتحقيق مصلحة مالية عامة تتمثل في الاقتصاد في تكاليف المناقصات العامة ولا فرق بين النوعين من الناحية الشرعية .

ثانياً: مناقصات باعتبار حدودها وتنقسم إلى مناقصات داخلية ومناقصات خارجية :

أ- المناقصة الداخلية: التي يقتصر الاشتراك فيها على من هم داخل البلد، ويكتفي فيها بالإعلان الداخلي .

ب- المناقصة الخارجية : هي التي يشترك فيها موردون ومقاولون من خارج البلد، ويعلن عنها بداخل البلد وخارجه^(٢).

(١) المرجع السابق ص ١٩٨، د/ محمد تقي العثماني: (عقود التوريد والمناقصة)

المرجع السابق عدد رقم ١٢ ج ٢ .

(٢) المرجع السابق ص ١٩٨، فضيلة الشيخ حسن الجواهري: (عقود التوريد والمناقصة) العدد الثاني عشر، ج ٢.

ثالثاً: مناقصات باعتبار طرق اجرائها وتنقسم إلى مناقصات علنية ومناقصات سرية:

المناقصات العلنية: وذلك باعتبار حضور المناقصين في المناقصة، وتقديم عروضهم بصورة علنية، ويتناقصون في السعر إلى أن ترسو على صاحب السعر الأقل ، ومن مميزاتها أن أسعار المتنافسين فيها مكشوفة ، وهم يتنافسون على بيئة فيكون عرض كل واحد معروفاً للآخرين .

والمناقصات السرية هي السائدة حديثاً، إلا أن الواضح أن المناقصات العلنية تحقق الغرض منها وهو التنافس بين المشتركين فيها للوصول إلى أفضل عرض .

أما عن الهدف من سرية المناقصات الحديثة هو: أن المناقصات الحديثة، مناقصات فنية معقدة يحتاج تقديم العروض فيها إلى دراسة، وقد يكون الهدف من سرية المناقصة أنها تتطوي على كميات كبيرة من السلع أو الخدمات وقد يخشى لسبب أو لآخر في العلانية أن يندفع البعض للنزول إلى أسعار غير معقولة، فيتعثر التوريد أو التنفيذ، أما إذا كان السعر مدروساً وعادلاً وبعيداً عن حرارة المنافسة العلنية فإن المتقدم للمناقصة يستطيع أن يضع لنفسه حداً من الربح يعينه على تنفيذ التزاماته^(١).

(١) د/ رفيق المصري: مرجع سابق ص ١٩٩ - ٢٠٠ بتصرف .

رابعاً: مناقصات باعتبار موضوعها وهي تنقسم إلى:

أ- مناقصات موضوعها الشراء: وذلك حينما تحتاج إدارة ما إلى شراء ما تحتاجه بمواصفات معينة فتسعى من أجل ذلك لإجراء مناقصة لتصل من خلالها إلى أقل الأسعار .

ب - مناقصات موضوعها الإجارة: وهي تتعلق بإجارة أشياء تستعين بها الإدارة في القيام بأعمالها أو إنشاء مشروع معين على أن تكون مواد المشروع من الجهة الداعية لإجراء المناقصة .

ج- مناقصات لأجل الاستثمار: كما في حالة تعلق المناقصة بالمضاربة أو بالمزراعة أو بالمساقاة ، فإن الممول في المضاربة الشرعية ، وصاحب الأرض والبذر الذي يريد زراعة أرضه بنسبة من الربح، وصاحب الأصول الذي يرغب في أن يسقي غيره أصوله المغروسة قد يعقدون مناقصة لمن يكون شريكاً لهم في الربح، فيعلن (المضارب والمزارع والمساق) رغبته للتعاقد مع أفضل من يتقدم للشركة معه^(١).

(١) الشيخ حسن الجواهري: المناقصات (عقد الاحتياط ودفع التهمة) مرجع سابق، العدد التاسع ج ٢ ص ٢٦٣.

الوحدة الثانية

في الأحكام الشرعية للمناقصات

أهداف الوحدة الثانية :

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على أن :

- ١- فهم التكيف الفقهي للمناقصات .
- ٢- التمييز بين المناقصات وبين بعض البيوع المنهي عنها والتي قد تلتبس بها .
- ٣- توضيح المقصود بدفتر الشروط وحكم بيعه .

الوحدة الثانية

الأحكام الشرعية للمناقصات

أولاً: التكييف الفقهي للمناقصات:

تعد المناقصات من المعاملات المستجدة التي لم يرد لها نص صريح خاص بها في الشرع، وقد اجتهد العلماء المعاصرين في بيان تكييفها الفقهي بإلحاقها بإحدى المعاملات المنصوص عليها والتي تتوافق مع طبيعة عقود المناقصات.

وقد اختلف هؤلاء المعاصرون في تكييفها على عدة آراء هي: الرأي الأول: يرى أصحابه أن المناقصة كالمزايدة (١) ينطبق عليها ما ينطبق على المزايدة، والاختلاف بينهما في الشكل فقط حتى أن معظم أحكامهما تنظمها لائحة واحدة، وبه قال الدكتور رفيق المصري في

(١) وسوف أبين حكم المزايدة بعد بيان آراء العلماء في التكييف الفقهي للمناقصة.

قول له (١)، والدكتور علي السالوس (٢)، والدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (٣)، والدكتور محمد المختار السلامي (٤).

الرأي الثاني: المناقصة تشبه عقد المسابقة في الإسم والمضمون، وبه قال الدكتور رفيق المصري في قول ثان له (٥) ، فالمناقصة مسابقة بين المناقصين على الفوز بعقد التوريد، أو المقولة ويشترط فيها ما يشترط في المسابقة من حيث المساواة بين المشتركين في كل شيء، في المعلومات، وفي الفرص، وفي سائر الشروط والمواصفات.

الرأي الثالث: المناقصات تختلف باختلاف موضوع المناقصة وأن الدعوة إلى المناقصة في أي عقد يجوز إنجازها شرعاً على الفور هي دعوة إلى هذه العقود ، فمثلاً إن كان موضوع المناقصة عقد البيع

(١) مناقصات العقود الإدارية (عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة) : للدكتور/ رفيق يونس المصري ص ٤٢.

(٢) مداخلة للدكتور في أثناء مناقشة عقد المناقصة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن.

(٣) عقد المزايدة بين الشريعة الإسلامية والقانون-دراسة مقابلة-مع التركيز على بعض القضايا المعاصرة: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي .

(٤) بيع المزايدة: للشيخ محمد المختار مفتي الجمهورية التونسية، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي .

(٥) مناقصات العقود الإدارية (عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة) دكتور، رفيق يونس المصري ص ٤٣.

للمبيعات الموجودة عند البائع ، أو عقد الإجارة ، أو عقد الاستصناع أو المقاوله ، فالدعوة إلى المناقصة في هذه العقود دعوة إلى هذه العقود وهو ما قال به الدكتور/ تقي العثماني (١)، ويوافقه الشيخ حسن الجواهري (٢) بقوله: أن المناقصة من مصاديق البيع والتجارة، وهي مشروعة، لما يلي:

١- قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٣)، وقوله تعالى: لِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٤)، وقوله تعالى: لِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ (٥).

وجه الاستدلال: أن المعاملة الجارية بصورة المناقصة هي بيع أو إجارة أو مزارعة أو مضاربة أو غير ذلك، فالدليل الذي دل على صحة هذه العقود من الأدلة العامة أو الخاصة هو نفسه الدليل على صحة هذه المناقصة بشرط أن تسلم أصول العقد وتحقق أغراضه.

(١) عقود التوريد والمناقصة للقاضي/ محمد تقي العثماني ، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي .

(٢) المناقصات(عقد الاحتياط ودفع التهمة) الشيخ حسن الجواهري ، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي .

(٣) سورة البقرة: ٢٧٥ .

(٤) سورة المائدة: ١ .

(٥) سورة النساء: ٢٩ .

٢- إن المناقصات تستهدف في حقيقتها المحافظة على المنافسة الشريفة في خفض الأسعار لصالح طالب السلعة ، أو خفض الأجرة لصالح طالب العمل، وهذا العمل قد يتعين في الشريعة الإسلامية إذا كان الغرض منه الشراء للأيتام بواسطة الحكام أو الوصي أو القيم، لما فيه من توقع الشراء بأقل ودفع التهمة.

كما قد يتعين هذا العمل في الشراء أو إنجاز العمل لمؤسسات الدولة كالأوقاف والمؤسسات العامة كالمدارس، وإن لم يتعين فلا أقل من استحبابه في مثل الصورة المتقدمة لما فيه من تحقيق المصلحة العامة أو مصلحة المتولى عليه أو دفع التهمة على المباشر في بعض الصور.

ونوقش: بأن هذا التكييف لا يستقيم؛ لأن المراد هو تكييف المناقصة من حيث هي أي ذات المناقصة، والتي تقوم على اختيار صاحب العطاء الأقل للتعاقد معه وفق إجراءات معينة وليس تكييف ما تؤول إليه، إذ إنها قد تؤول إلى بيع أو استصناع أو إجارة.

الرأي الرابع: المناقصة منظومة عقود، أي يدخل فيها عدة عقود؛ لاشتمالها على عقد بيع دفتر الشروط ، وعقد الضمان بنوعيه ، ثم تنتهي المناقصة بإبرام عقد يؤول إما إلى عقد توريد سلع، أو عقد مقالة للقيام بخدمات أو أعمال، وهذا العقد المركب، الإيجاب فيه يصدر من المناقص عند تقديمه العطاء وهو ملزم له، والقبول فيه يصدر من المناقص له عند إبرامه العقد مع صاحب العطاء الأقل

سِعراً والذي رست عليه المناقصة. وهو ما قال به رفيق المصري في قول له (١)

الرأي الخامس: المناقصة ما هي إلا إجراءات للدخول في العقد، وليست عقداً، وبه قال الشيخ عبدالله بن منيع (٢)، والدكتور / القره داغي (٣)، وغيره من العلماء المعاصرين (٤).

نوقش: بأن المناقصة ليست إجراءات فقط بل هي عقد تام، إذ تقديم المناقص العرض يعد إيجاباً، وهذا الإيجاب يُعتبر ملزماً له، لا يرجع عنه حتى ترسو المناقصة على غيره، وإبرام العقد بعد رسو المناقصة

(١) مناقصات العقود الإدارية (عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة) دكتور، رفيق يونس المصري ص ٤٣. ط، دار المكتبي سورية، الطبعة الاولى ١٤٢٠ - ١٩٩٩ م

(٢) أورد رأيه في المناقشات حول موضوع المناقصات، وقد جاء قوله: "وعقود المناقصات والمزايدات إنما سميت عقوداً على سبيل التجاوز وإنما هي إجراءات لعقود". مجلة مجمع الفقه الاسلامي - العدد التاسع.

(٣) أورد رأيه في المناقشات حول موضوع المناقصات، وقد جاء قوله: "وبخصوص تكييف عقد المناقصة على أساس أنه عقد، أنا أرى أن المناقصة نفسها ليست عقداً وإنما هي إجراءات للدخول في العقد". مجلة مجمع الفقه الاسلامي - العدد التاسع.

(٤) ومنهم من أورد رأيه في المناقشات حول موضوع المناقصات، وقد جاء قوله: "أرى أن مثل هذه القضايا ومنها قضية المناقصات هي قضية إجرائية أكثر منها قضية عميقة وأصل المسألة... من الناحية الفقهية ليس هنالك ما يمنعه". مجلة مجمع الفقه الاسلامي - العدد التاسع.

يعتبر قبولاً، وتنتهي المناقصة بإبرام العقد بين المناقّص له وبين المناقّص صاحب العطاء الأقل سعراً ، وهذا هو القبول الذي وافق الإيجاب السابق، وهما من أركان أي عقد، وما تضمنه من وجوب الالتزام من كلا الطرفين. (١).

الرأي الراجح:

بعد عرض أقوال العلماء في بيان التكبير الفقهي للمناقصات أرى - والله أعلم - أن أقرب التخرجات الفقهية للمناقصة:

١- أنها تشبه عقد المزايدة في الكثير من الإجراءات مع مراعاة التقابل بينهما.

٢- أنها منظومة عقود وليست عقداً واحداً مثل:

- عقد بيع كراسة الشروط

- عقد الضمان

- العقد الذي يتعلق بموضوع المناقصة كعقد توريد سلع وهو عقد بيع أو بيع منفعة أو عقد استصناع.

(١) عقود المناقصات في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير للباحث/ عاطف محمد

حسين أبو هرييد، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بغزة، ص ٩١.

ثانياً: حكم بيع المزايدة:

ولكي يتضح حكم المناقصة في الشرع لا بد وأن أبين حكم بيع المزايدة، وحكم تلك العقود التي خرجت عليها المناقصة والتي تعتبر أساس في المناقصات:

تعريف المزايدة:

المزايدة لغة: زيادة : نافسه في الزيادة وفي ثمن السلعة، زاد فيه على آخر، زيد: الزاي والياء والدادل أصل يدل على الفضل، والمزاد: موضع الزيادة.

وبيع المزاد: البيع الذي يتم بطريق الدعوة إلى شراء الشيء المعروض ليرسو على من يعرض أعلى ثمن، وثمن المزاد هو الثمن الذي رسا به على المزايد. ^(١)

المزايدة في اصطلاح الفقهاء: عرفها ابن حزي بقوله: أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها ^(٢).

وعرفها الزيلعي بقوله: أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا بالبيع فيأتي آخر فيزيد عليه ^(٣).

(١) مقاييس اللغة ج ٣ ص ٤٠، المعجم الوسيط ص ٨٤٨ - ٨٤٩ .

(٢) القوانين الفقهية ص ١٨٣ .

(٣) تبين الحقائق ج ٤ ص ٦٧ .

آراء الفقهاء في حكم بيع المزايدة:

اختلف الفقهاء في حكم بيع المزايدة على ثلاثة أراء :

الرأي الأول: أن بيع المزايدة جائز مطلقاً وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية^(١)، والمالكية^(٢)، والشافعية^(٣)، والحنابلة^(٤)، ووافقهم الظاهرية^(٥)، والزيدية^(٦).

واستدلوا على ذلك بالسنة والأثر والإجماع والمعقول :-

أما السنة فمنها ما يلي:

١- روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَأَحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ (ﷺ) فَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. (٧)

(١) البحر الرائق ج ٦ ص ١٠٨، تبیین الحقائق ج ٤ ص ٦٧ ط/ دار الكتاب الإسلامي،

شرح فتح القدير ج ٦ ص ٤٧٩ ط/ دار الفكر.

(٢) المنتقى شرح الموطأ ج ٥ ص ١٠١ ، ط / دار الكتاب الإسلامي، الفواكه الدواني

ج ٢ ص ٧٢ ط دار الفكر ، حاشية العدوي ج ٢ ص ١٨٩ ط/ دار الفكر .

(٣) تكملة المجموع شرح المذهب ج ١٣ ص ١٩ ، أسنى المطالب ج ٢ ص ٣٩ ط/دار

الكتاب الإسلامي ، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٩٠ ط/ دار الكتب العلمية، الحاوي

الكبير ٤ ص ٧٦٩ .

(٤) المغني ج ٤ ص ١٤٩ ، كشف القناع ج ٣ ص ١٨٣ ط/ دار الكتب العلمية.

(٥) المحلي ج ٧ ص ٣٧٠ ط/ دار الفكر.

(٦) سبل السلام ج ٢ ص ٣٠ ط /دار الحديث .

(٧) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب البيوع - باب بيع المزايدة ج ٣ ص ٦٩ ،

حديث رقم (٢١٤١) .

وجه الاستدلال: دل ظاهر الحديث على جواز بيع المزايدة .

نوقش: بأنه ليس في قصة المدبر بيع المزايدة؛ فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمناً ثم يعطي به غيره زيادة عليها . (١)

أجاب ابن بطال: بان شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي) قال فعرضه للزيادة ليستقضى فيه للمفلس الذي باعه عليه . (٢)

٢- ما رواه أنس بن مالك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ^(٣) وَالْقَدَحَ^(٤)) فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): (مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ) فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهِمَيْنِ (فَبَاعَهُمَا مِنْهُ)^(٥).

(١) ابن حجر: فتح الباري ج ٤ ص ٣٥٤ .

(٢) ابن بطال: شرح صحيح البخاري ج ٦ ص ٢٦٩ .

(٣) الحلس: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله، والجمع (أَخْلَاسٌ) و(الحِلْسُ) بساط يبسط في البيت . المصباح المنير ج ١ ص ١٤٦ .

(٤) القدح: هو الذي يُؤْكَلُ فيه، قيل: يُجْمَعُ على قَدَحٍ وهو السَّهْمُ الذي يُرْمَى به عن القَوْسِ، يقال للسَّهْمِ أَوَّلٌ ما يُقَطَّعُ: قِطْعٌ ثم يُنَحْتُ وَيُبْرَى فَيُسَمَّى بَرِيًّا ثم يُقَوِّمُ فَيُسَمَّى قِدْحًا ثم يُرَاشُ وَيُرَكَّبُ نَصْلُهُ فَيُسَمَّى سَهْمًا. النهاية في غريب الأثر ٣٩/٤ .

(٥) أخرجه الترمذي في جامعه - كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع من يزيد ، ج ٣ ص ٥١٤ ، حديث رقم (١٢١٨) ، وقال: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث: الأخضر بن عجلان .

وجه الدلالة: دل ظاهر قوله (ﷺ): (مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مِّنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ) على جواز بيع المزايدة ، وهو البيع على الصفة التي فعلها (ﷺ)؛ إذ لم يجب من أعطى درهماً^(١).

قال الكاساني في التعليق على الحديث : وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليبيع بيعاً مكروهاً. ^(٢)

أما الأثر: فمنه ما رواه ابن أبي شيبه عن سفيان عن سمع مجاهدًا وعطاء قالوا: لا بأس من بيع من يزيد ^(٣).

وجه الدلالة: دل ظاهر قول مجاهد وعطاء على إباحة بيع المزايدة . أما الإجماع: فقد نقل الإجماع على جواز بيع المزايدة ابن قدامة في المغني: قال: وهذا أيضاً إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة^(٤).

أما المعقول: فلان الحاجة ماسة اليه، فهو بيع الفقراء والمحتاجين ومن كسدت تجارته، فلو ترك الناس هذا البيع لما استطاع الفقراء أن

(١) تكملة المجموع ج ١٣ ص ٩ .

(٢) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢٣٢ ط/ دار الكتب العلمية .

(٣) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه - كتاب البيوع والأقضية- باب في بيع من يزيد ج ٤ ص ٢٨٧ أثر رقم (٢٠٢٠٥)، الناشر/ مكتبة الرشد، الرياض.

(٤) المغني ج ٤ ص ٣٠٠ ط/ دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون للدكتور/ محمد عثمان شبير - مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية ص ٣٣٩٠٣٤٠، الناشر جامعة الكويت .

يصلوا إلى حاجاتهم، ولو ترك الناس الزيادة في السلعة المعروضة لدخل الضرر على الباعة. ^(١) كما قال الإمام مالك : في أن العلة في تقييد النهي عن السوم على السوم في كونه بعد رضا المتعاقدين بقوله: " أما قبل التراكن والتقارب فجائز ؛ لأنه لو ترك ذلك لدخل الضرر على الباعة في سلعهم ؛ لأنه يؤدي إلى بخسها وبيعها بالنقص" ^(٢).

الرأي الثاني: عدم جواز بيع المزايدة إلا فيما يحصل عليه عن طريق الميراث والغنيمة وهذا قول الأوزاعي وإسحاق بن راهوية ^(٣).

واستدلوا على ذلك بالسنة والأثر:

أما السنة: فيما رواه ابنُ لهيعةَ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ) ^(٤).

(١) عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون للدكتور/ محمد عثمان شبير - مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية ص ٣٤٠:٣٣٩، الناشر جامعة الكويت.

(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج ٦ ص ٩٦ .

(٣) فتح الباري لابن حجر ج ٤ ص ٣٥٤، نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٣٣ ، تحفة الأحوذى ج ٤ ص ٣٤٤ .

(٤) أخرجه أحمد في مسنده ج ٥ ص ٥٤ ، حديث رقم (٥٣٩٨)، إسناده صحيح، قال الهيتمي في مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٥٠ : "هو في الصحيح، خلا قوله: إلا

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على النهي عن بيع المزايدة إلا في الغنائم والمواريث، وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث الدال على الجواز .

قال ابن حجر: " أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغنم والمواريث "(١) .

أما الأثر فمنه ما يلي:

١- روى ابن أبي شيبة عن الحسن وابن سيرين أنهما: كرها بيع من يزيد إلا بيع المواريث والغنائم(٢).

٢- روى ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة أنه: باع المغنم فيمن يزيد(٣).

وجه الدلالة: دل ظاهر الأثرين على جواز بيع المزايدة في الغنائم والمواريث دون غيرهما .

الغنائم والمواريث"، ثم قال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح".

(١) فتح الباري لابن حجر ج ٤ ص ٣٥٤ .

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب البيوع - باب في بيع من يزيد - ج ٥ ص ٢٩ أثر رقم ٧ .

(٣) المرجع السابق أثر رقم ٩ .

نوقش ما استدل به أصحاب الرأي الثاني من وجهين :

الأول: أن ذكر المغانم والمواريث في الحديث ليساً قيداً فيه ، وأن ذكرهما خرجا مخرج الغالب على ما كانوا يعتادون فيه البيع مزايمة ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم. بدليل أن البيع مزايمة وقع في غيرهما (١)

الثاني: أن الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. (٢)

الرأي الثالث : كراهة بيع المزايمة وهذا قول إبراهيم النخعي. (٣)

واستدل على ما ذهب إليه بالسنة :

١- روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) (٤)

وجه الدلالة: دل ظاهر الحديث على النهي عن السوم في البيع ، والسوم، الزيادة .

(١) نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٠١ ، تحفة الأحوزي ج ٤ ص ٣٤٤ ط/ دار الكتب العلمية - بيروت.

(٢) طرح التثريب ج ٦ ص ١٠٧ .

(٣) فتح الباري ج ٤ ص ٣٥٤ ، نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٧٠ - ٢٧١ .

(٤) أخرجه مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، ج ٣ ص ١١٥٤ ، حديث رقم (١٥١٥).

نوقش: بأن المراد بالنهي عن السوم بعد رضا البائع، وقبوله الثمن الذي عرضه المشتري عليه، أما السوم في السلعة، أي التي تباع لمن يزيد فلا يحرم. (١)

٢- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ): (يُنْهَى عَنِ الْمَزَايِدَةِ). (٢)

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على النهي عن بيع المزايدة ، والنهي يحمل على الكراهة لما قد يسببه هذا البيع من إثارة الحقد والبغضاء (٣) كما أنه يعارضه ما ورد عنه (ﷺ) قولاً وفعلاً في الحديث الذي رواه أنس السابق .

الترجيح: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات في حكم بيع المزايدة يتبين لي أن الرأي القائل بالجواز هو الراجح لقوة ما استدلووا به من أدلة، ولتعلق حاجة الناس بهذا النوع من البيوع في معاملاتهم دون التقييد بكون المبيع من ميراث أو غنيمة . والله أعلم.

(١) نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٧٠ .

(٢) أخرجه البزار في كشف الأستار ج ٢ ص ٩٠، حديث رقم (١٢٧٦)، مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٥١، حديث رقم (٢٨٢٦)، وقال: رواه البزار وإسناده حسن، وفي تحفة الأحوذى: إسناده ضعيف.

(٣) عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون للدكتور/ محمد عثمان شبير - مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ص ٣٤١ .

ثالثاً: بيع منهي عنها تلبس بالمناقصات:

ما يتم في المناقصة طبقاً لمبدأ المساواة بين المناقصين أن ينقص المناقص عن الشخص الذي ناقص قبله فهل هذه العملية تدخل تحت النهي عن البيع على البيع، والسوم على السوم، والنجش؛ وذلك للتشابه بين المناقصات وبين هذه البيوع التي ورد النهي عنها فكان لا بد من التعرض لهذه البيوع وبيان معانيها وأدلة تحريمها ثم المقارنة بينهما وبين المناقصات .

بيع الرجل على بيع أخيه .

معناه: بأن يتراضيا أي البائع والمشتري على ثمن سلعة فيجيء آخر قي زمن الخيارين فيقول للمشتري : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن فيضر بصاحب السلعة^(١).

أو أن يقول: أنا أبيعك خيراً منها بثمنها ، أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري، فيفسخ البيع، ويشترى هذه .

وفي معنى البيع الشراء على الشراء: وهو أن يجيء مشتري آخر إلى البائع قبل لزوم العقد فيدفع في المبيع أكثر من الثمن الذي اشتري به المشتري الأول. ^(٢)

(١) شرح فتح القدير ج ٦ ص ٤٧٧، ط/ دار الفكر .

(٢) المغني ج ٤ ص ٣٠٠.

حكمه: يحرم بيع الرجل على بيع أخيه عند جمهور الفقهاء المالكية^(١)،
والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣)، ووافقهم الظاهرية^(٤) .

بينما خالفهم الحنفية حيث ذهبوا إلى أنه مكروه تحريماً^(٥).

واستدلوا على ذلك: بما رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
أَخِيهِ)^(٦).

لكن اختلف الفقهاء في صحة هذا العقد على رأيين:

الرأي الأول : صحة بيع الرجل على بيع غيره مع لحوق المشتري
الإثم وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية^(٧) ، والمالكية في قول^(٨) ،

(١) التاج والإكليل ج ٦ ص ٢٥٤ ط/ دار الكتب العلمية .

(٢) أسنى المطالب ج ٢ ص ٣٩ ط/ دار الكتاب الإسلامي .

(٣) كشف القناع ج ٣ ص ١٨٣ ط/ دار الكتب العلمية ، مطالب أولي النهي ج ٣
ص ٥٥ ط/ منشورات المكتب الإسلامي بدمشق .

(٤) المحلى ج ٧ ص ٣٧٠ ط / دار الفكر .

(٥) رد المحتار ج ٥ ص ١٠١ ط / دار الكتب العلمية .

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب البيوع- باب لا يبيع على بيع أخيه ولا
يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، ج ٣ ص ٦٩، حديث رقم (٢١٣٩).

(٧) البحر الرائق ج ٦ ص ١٠٧ ط/ دار الكتاب الإسلامي، الجوهرة النيرة ج ١
ص ٢٠٦ ط/ المطبعة الخيرية .

(٨) التاج والإكليل ج ٦ ص ٢٥٤ ، الفواكه الدواني ج ٢ ص ١٠٨-١٠٩ .

والشافعية ^(١) ، والحنابلة في رواية ^(٢) ، ووافقهم الزيدية ^(٣) ، وهو الراجح في نظري - والله أعلم - لأنه عقد مكتمل الأركان والشروط، والنهي الوارد في ذلك لأمر خارج عن عقد البيع.

الرأي الثاني : بطلان بيع الرجل على بيع أخيه وهذا قول ثاني للمالكية ^(٤) ، والحنابلة في ظاهر المذهب ^(٥) ، ووافقهم الظاهرية ^(٦) لأنه منهي عنه ؛ والنهي يقتضي الفساد. ^(٧)

وقد وضع الفقهاء شروطاً لتطبيق منع بيع الرجل على بيع أخيه:

١ - أن يقع البيع من غير إذن البائع، أو أن يقع الشراء من غير إذن المشتري، فلو أذن المتضرر منهما في العقد لم يحرم البيع؛ وذلك لأن الحق لهما وقد أسقطاه ^(٨).

(١) تكملة المجموع شرح المذهب ج ٣ ص ٣٠٨ ط/ المطبعة المنيرية ، تحفة المحتاج ج ٤ ص ٣١٤ ، الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣٤٤ .

(٢) كشف القناع ج ٣ ص ١٨٣-١٨٤ ، الإنصاف ج ٤ ص ٣٣٢ ط/ دار إحياء التراث العربي، المغني ج ٤ ص ٣٠٠ .

(٣) التاج المذهب ج ٣ ص ٣٨٧ .

(٤) بداية المجتهد ج ٢ ص ١٣٣ .

(٥) الإنصاف ج ٤ ص ٣٣١ ط/ دار إحياء التراث العربي، المغني ج ٦ ص ٣٠٦ .

(٦) المحلى ج ٧ ص ٣٧٠ .

(٧) مطالب أولي النهى ج ٣ ص ٥٥ .

(٨) أسني المطالب ج ٨ ص ٥٩ ، روضة الطالبين ج ٤ ص ٤٢٨ .

٢- أن يقع البيع مع رضا المتعاقدين على الثمن بخلاف ما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر، فهو يعتبر في هذه الحالة بيع من يزيد وهو حائز .

٣- أن يقع البيع على البيع قبل اللزوم أي في زمن الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط لتمكنه من الفسخ فإذا وقع البيع بعد مضي زمن الخيار، ولزوم البيع فلا حرمة وذلك لعدم تمكن أحد المتعاقدين من فسخ العقد ^(١).

٤- أضاف بعض الشافعية: أن لا يكون المشتري مغبوناً غبناً فاحشاً، وإلا جاز البيع على البيع، لأن الدين النصيحة ^(٢).

الفرق بين المناقصة، ومنع البيع على البيع:

فالشروط التي وضعها الفقهاء لمنع البيع على البيع لم تتوافر في المناقصة، فالمناقصة لا تدخل تحت النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه؛ وذلك لأن الراغب في الاشتراك في المناقصة يتقدم بعطاءه وليس معنى تقدمه بالعطاء الموافقة عليه من الطرف الآخر للمناقصة، ولم يحصل ركون أو ميل من الطرف الآخر لإبرام العقد فلا تدخل المناقصة تحت النهي .

(١) كشف القناع ج ٩ ص ١٣، مطالب ج ٣ ص ٥٥، المغني ج ٦ ص ٣٠٦ .

(٢) تكملة المجموع شرح المذهب ج ١٣ ص ١٨ .

ثانياً : السوم على السوم:

فالسوم: هو الذهاب في ابتغاء الشيء، والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبها المشتري بثمن دونه.

السوم على السوم معناه: أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدها فيقول آخر لصاحبها أنا أشتريها بأكثر أو للراغب أنا أبيعك خيراً منها بأرخص وهذا حرام بعد استقرار الثمن.(١)

والفرق بين البيع على بيعه والسوم على سومه: أن في البيعة على بيعه تم العقد إلا أن بين المتعاقدين خيار شرط أو مجلس، أما في السوم على سومه : فهو بعد الاتفاق وقبل العقد(٢).

حكمه: يحرم سوم الرجل على سوم أخيه عند جمهور الفقهاء(٣) ما عد الحنفية(٤) حيث ذهبوا إلى أنه مكروه تحريماً .

والحكمة من تحريم ذلك: لما في ذلك من إخلال بالمروءة، وإيغار للصدور، وزرع للبغضاء، وإثارة للنزاع والشحناء، وإفساد للمجتمعات

(١) عمدة القارئ ج ١١ ص ٢٥٧.

(٢) منحة العلام في شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ/ عبدالله بن صالح الفوزان ج ٦ ص ١٠٤، ط/ دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.

(٣) حاشية العدوي ج ٢ ص ١٨٩، الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣٤٤، المغني ج ٦ ص ٣٠٧، المطلى ج ٧ ص ٣٧٠- ٣٧١ .

(٤) مجمع الأنهر ج ٢ ص ٧٠ ط/ دار إحياء التراث العربي، العناية شرح الهداية ج ٦ ص ٤٧٧ ط/ دار الفكر .

بقطع الصلات ، مما يتنافى مع حرص الإسلام على تآلف المجتمعات، وتحسين الصلات(١) .

وقد وضع الفقهاء عدة شروط لمنع السوم على السوم :

أن يكون سوم الغير بعد استقرار الثمن .

وأن يكون السوم بعد حصول التراضي بين المتعاقدين، أو ركون كل منهما إلى الآخر (٢).

عدم الإذن من المتضرر منهما ، فإن أذن البائع أو المشتري بالسوم لم يدخل تحت النهي .

الفرق بين المناقصات والسوم على السوم:

في سوم الرجل على سوم أخيه نجد أن السوم الثاني ورد بعد استقرار الثمن ورضا المتعاقدان، ولم يتبقى إلا أن يأخذ العقد شكله الأخير، أما المناقصات فهي قبل استقرار الثمن؛ إذ يتقدم الراغب بعطاءه، ولما لم يرتض الطرف الآخر بالعطاء أو يركن إليه، ووجد الإذن من صاحب المناقصة بالسماح لمن يرغب في الاشتراك التقدم بعطاءه،

(١) الفقه المنهجي على مذهب الاكام الشافعي للدكتور/ مصطفى الخن وآخرون ج ٦ ص ٤٣ ، ط/ دار القلم دمشق.

(٢) العناية شرح الهداية ج ٦ ص ٤٧٧، تحفة المحتاج ج ٤ ص ٣١٤ ، الفواكه الدواني ج ٢ ص ١٠٨ ، الإنصاف ج ص ٣٩٥ ، التاج المذهب.

اكتسبت المنافسة بالنقصان في العطاءات الجواز والصحة، فلم تدخل المناقصة تحت النهي عن السوم على السوم.

ثالثاً: النجش:

النجش لغة: الاستتار لأنه يستر قصده ويخفيه ومنه يقال للصائد نَاجِشٌ لاستتاره. ^(١)

وشرعاً: أن يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتريها لنفسه ولكن ليسمع غيره فيزيد في ثمنها. ^(٢)

الناجش لا يريد شراء السلعة ، ويزيد فيها لينتفع البائع ويضر المشتري حيث يظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك .

ومن صورته أيضاً ذلك الذي يمدح سلعته ويطري في مدحها بالكذب ليغر غيره ويخدعه. ^(٣)

حكمه: ذهب جمهور الفقهاء المالكية ^(٤)، والشافعية ^(١)، والحنابلة ^(٢)، ووافقهم الظاهرية ^(٣)، والزيدية ^(٤)، إلى حرمة النجش

(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج ٢ ص ٥٩٤.

(٢) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢٣٣ .

(٣) فيض القدير ج ٦ ص ٣٨١ ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى.

(٤) المنتقى شرح الموطأ ج ٥ ص ١٠٧ ط/ دار الكتاب الإسلامي .

بينما ذهب الحنفية: إلى أنه مكروه تحريماً فيما لو بلغت السلعة قيمتها، أما إذا لم تبلغ قيمتها فلا كراهة لانتقاء الخداع والتدليس.^(٥)

ومما ورد في النهي عن النجش من الكتاب: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} ^(٦).

وجه الدلالة:

قال القرطبي: أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفعال والأقوال القبيحة، كالبهتان والتكذيب الفاحش المخلوق^(٧). فتغريز المشتري أو الغير يدخل تحت عموم الآية .

ومن السنة: مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ) ^(١) فالحديث بمنطوقه دل على حرمة النجش .

(١) أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٠ ، حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٢ ص ٢٢٩ ، الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣٤٣ .

(٢) المغني ج ٦ ص ٣٠٤ .

(٣) المحلى ج ٧ ص ٣٧٢ .

(٤) التاج المذهب ج ص

(٥) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٢٣٣ .

(٦) سورة الأحزاب آية ٥٨ .

(٧) تفسير القرطبي ج ١٤ ص ٢٤٠ .

بينما اختلف الفقهاء في حكم البيع إذا وقع مع النجش على ثلاثة آراء:
الرأي الأول : صحة البيع ولزومه وعصيان الناجش وهذا قول الحنفية^(٢)، ووجه للشافعية^(٣)، والمختار عند الإباضية^(٤).

واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)^(٥)، والنهي في الحديث عائد إلى الناجش وليس إلى العقد فلم يفسد ؛ لأن النهي المقتضي للفساد هو النهي لأمر يتعلق بالعقد، لا لأمر خارج^(٦).

كما أن النجش ليس بعيب في نفس البيع، وإنما هو خديعة في الثمن^(٧)، ولأن المشتري زاد في الثمن عن اختياره وإرادته^(٨).

الرأي الثاني : البيع صحيح ويثبت فيه الخيار للمشتري إذا كان بمواطأة البائع وهذا ما ذهب إليه المالكية في قول^(٩)، والشافعية في

(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، ج ٣ ص ٦٩، حديث رقم (٢١٤٢).

(٢) شرح فتح القدير ج ٦ ص ٤٧٦ ، البحر الرائق ج ٦ ص ١٠٧ .

(٣) إحكام الأحكام ج ٢ ص ١١٣-١١٤ ، الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣٤٣ .

(٤) شرح كتاب النيل .

(٥) سبق تخريجه .

(٦) المغني ج ٤ ص ٣٠٠ .

(٧) شرح ابن بطال ج ١١ ص ٢٧٩ .

(٨) الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣٤٣ .

(٩) التمهيد ج ١٣ ص ٣٤٨ ط/مؤسسة القرطبه ، حاشية الصاوي ج ٣ ص ١٠٦ .

وجه خلاف الأصح^(١)، ورواية الحنابلة^(٢)، ووافقهم الظاهرية^(٣)،
والزيدية^(٤)، والإباضية في قول ثاني^(٥) .

بينما أضاف الحنابلة^(٦): أن الخيار يثبت للمشتري إذا غبن غبناً غير
معتاد، وإن لم يكن بمواطأة البائع وإلا فالخيار له .

واشترط الظاهرية لثبوت الخيار: أن لا يكون المشتري قد اشترط على
البائع السلامة في العقد، فإن اشترط ووقع البيع، ولم يعلم قدر الغبن ،
لكن علمه غيره فهو بيع باطل مفسوخ ومضمون ضمان الغصب،
وإن علمه ثبت له الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه .^(٧)

واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول:

أما السنة: فما روي أن ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ
اشْتَرَى غَنَمًا مُصْرَاةً ^(٨) فَاخْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا

(١) المجموع ج ١٣ ص ١٥، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٩٢ .

(٢) المغني ج ٦ ص ٣٠٥ ، الإنصاف ج ٤ ص ٣٩٦ .

(٣) المحلى ج ٧ ص ٣٧٢ .

(٤) التاج المذهب ج ص .

(٥) شرح كتاب النيل ج ص .

(٦) المغني ج ٦ ص ٣٠٥ .

(٧) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٥٩ .

(٨) المصراة : أن يريد بيع الناقة أو الشاة فيحجن اللبن في ضرعها أياماً لا يختلبه
ليرى أنها كثيرة اللبن. الفائق في غريب الحديث و الأثر ج ٢ ص ٢٩٣ .

فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ^(١) . في الحديث جعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم لمشتري المصرة الخيار إذا علم بعيب التصرية ، ولم يقضي بفساد البيع ، ومعلوم أن النجش مثل التصرية لما في ذلك من مكر وخديعة، وبالتالي فالنجش يصلح فيه البيع ويكون المشتري بالخيار من أجل ذلك قياساً ونظراً . ^(٢)

نوقش: بأن النجش ليس بعيب في نفس المبيع كالمصرة المدلس بها وإنما هو كالمدح وقد كان يجب على المشتري التحفظ وأن يستعين بأهل الخبرة . ^(٣)

أما المعقول فمنه وجهين:

الأول: أن في البيع مع النجش تغرير بالعاقد، فإذا كان مغبوناً ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان. ^(٤)

الثاني: أن النهي عن النجش لحق الآدمي فلم يفسد العقد ؛ لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار. ^(٥)

الرأي الثالث: البيع باطل وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه ^(١)

(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب إن شاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر، ج ٣ ص ٧١، حديث رقم (٢١٥١).

(٢) التمهيد ج ١٣ ص ٣٤٨ بتصرف .

(٣) المرجع السابق ص ٣٤٩ .

(٤) المغني ج ٦ ص ٣٠٥ .

(٥) المرجع السابق .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

ما رَوَتْهُ السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)^(٢).

دل ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث على أن البيع مع الخديعة باطل مردود .

- روى ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ)^(٣) والنهي يقتضي الفساد فكان البيع مع النجش باطلاً^(٤).

- فقد روى ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بعث عمرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد، فلما فرغ جاءه فقال له عمر: كيف كان البيع اليوم ؟ فقال: إن البيع كان كاسداً يا أمير المؤمنين لولا أنني كنت أزيد عليهم فأنفقه ، فقال عمر: (كنت تزیده عليهم ولا تريد أن تشتري) ؟ فقال: نعم، قال عمر: (هذا

(١) الإنصاف ج ٤ ص ٣٩٥ ، المغني ج ٦ ص ٣٠٥ .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ونقض

محدثات الأمور ج ص ٣٨٠ حديث رقم (١٧١٨)

(٣) سبق تخريجه .

(٤) المغني ج ٦ ص ٣٠٥ بتصرف .

نجش، والنجش لا يحل ، ابعث يا عمرة منادياً ينادي ألا إن البيع مردود وإن النجش لا يحل).^(١)

وجه الدلالة: دل ظاهر فعل عمر رضي الله عنه على حرمة النجش وبطلان البيع معه .

الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو القول بصحة البيع مع ثبوت الخيار للمشتري وذلك لقوة أدلتهم، ولأن النهي إنما ورد لأمر خارج عن العقد، فهو عقد كامل الأركان والشروط ، لكن يثبت الخيار للمشتري جبراً للغبن الذي قد يقع فيه متى كان ذلك بمواطأة البائع ، ووقع البيع بأكثر من قيمته، ولأنه --صلى الله عليه وسلم- (قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) فيما رواه عنه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.^(٢)

الفرق بين المناقصة وبين النجش:

صورة النجش قد توجد في المناقصة لكن معكوسة، وذلك كأن تتواطأ الجهة الإدارية الداعية لإجراء المناقصة مع أحد المشتركين

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب البيوع - باب في بيع من يزيد ج ٥ ص ٢٩ أثر رقم ٣ .

(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، ج ٣ ص ٤٣٠ ، حديث رقم (٢٣٤٠).

فيها بأن يتقدم بعبء يعرض فيه ثمن أقل من ثمن السوق وهو غير مريد للبيع حقيقة، وإنما خدمة للجهة الداعية للمناقصة، فالعلة التي نهى عن النجش لأجلها متحققة في المناقصة وهي الخديعة للغير والإضرار به، فلو تقدم أحد المشاركين في المناقصة بعرض فيه تنقيص في الثمن وهو لا يريد بيعاً، لحق مقدم العطاء الإثم ، وإن لم يوجد تواطؤ من الطرف الآخر، وعليه فإن المناقصة تشترك مع النجش في صورة تنقيص الثمن، ولكنها تختلف عنه في انتفاء قصد البيع من الناجش^(١)

رابعاً: حكم بيع كراسة الشروط:

المعمول به في المناقصات أن تصدر الجهة الإدارية للمناقصة ما يسمى بكراسة الشروط وهي تشتمل على تفاصيل العقد ومواصفاته وتطرح للبيع عند الإعلان عن المناقصة فما حكم بيع هذه الكراسة؟ وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من توضيح العناصر المؤثرة في تكاليف إجراء المناقصة وهي على النحو التالي :

- ١ - المجهود الذهني المبذول في دراسة المشروع وإعداده .
- ٢ - تكاليف إعداد الخرائط والرسوم والمخططات اللازمة للمشروع .

(١) د/ عاطف محمد حسين: عقود المناقصات في الفقه الإسلامي ، موقع :

٣- تكاليف الخدمات والاستشارات الهندسية.

٤- قيمة الأوراق المتعلقة بالمشروع.

٥- حصة من المصاريف الإدارية، تقدر بنسبة ١٠، من مجموع العناصر السابقة. (١)

أما عن يتحمل تلك التكلفة فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على أربعة آراء :-

الرأي الأول: جواز بيع كراسة الشروط لمن يرغب المشاركة في المناقصة وهو ما ذهب إليه فضيلة الشيخ مختار السلامي (٢)، ود/ عبد الله المنيع (٣)، أبو سليمان في قول ثان له، وفضيلة الشيخ حسن الجواهري (٤)

واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية:

الأول: أن كراسة الشروط تحتوي على معلومات يجوز بيعها على من يريد أن يقتنيها للدخول في المناقصة عملاً بعموم الأدلة التي تدل

(١) د/ رفيق المصري: (عقد التوريد والمناقصات) بحث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢ .

(٢) فضيلة الشيخ مختار السلامي: بيع المزايدة ، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن ج ٢ ص ١٦٠٩٧

(٣) حيث أورد رأيه في المناقشة وليس في بحث. المرجع السابق العدد الثامن ج ٢ .

(٤) الشيخ حسن الجواهري: المناقصات (عقد الاحتياط ودفع التهمة)، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع .

على مشروعية البيع^(١)، منها قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا} (٢)، كما يشملها مشروعية التجارة عن تراض في قوله
تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} (٣)

الثاني: أن كراسة الشروط وثيقة مادية مسعرة بسعر محدد لم يلزم بها
أي مشتر إلزاماً ظالماً.

الثالث: إن القصد من شراء كراسة الشروط هو أن يكون كل مشارك
في المناقصة على بينة من أمره في شروط العقد وضوابطه وليس
القصد بيعه؛ لأن تفاهة قيمته بالنسبة للمبيع لا تجعله مقصوداً
بالثمن^(٤)

(١) الشيخ حسن الجواهري: المناقصات (عقد الاحتياط ودفع التهمة)، بحث منشور
بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع .

(٢) سورة البقرة: ٢٧٥ .

(٣) سورة النساء: ٢٩ .

(٤) فضيلة الشيخ مختار السلامي: بيع المزايدة بحث ضمن مجلة مجمع الفقه
الإسلامي العدد الثامن، ج ٢ ص ١٦٠٩٧

نوقش ذلك :

بأن الأعيان والمنافع التافهة القيمة لا تعد من الأموال المتقومة مثل قطرة الماء وحبّة القمح، ولكن هل ثمن دفتر الشروط من هذا القبيل؟^(١).

الرابع: أن قيمة كراسة الشروط إنما هي تمثل قيمة ما أنفق على إعدادهِ وإن كانت تلك القيمة لا تمثل إلا جزءاً قليلاً من ثمنه فإن الغرض من ذلك هو أن لا يدخل في المناقصة من ليس أهلاً لها فتضيع الفرصة ثم يرجع إلى الذي يليه كما أنه يبين جدية المناقص في الاشتراك في المناقصة، وبالتالي فقد يكون بيعه بتلك القيمة من المصالح المعتبرة^(٢).

نوقش: بأن الجدية في الإقدام على المشاركة في المناقصة لا تتعلق بدفتر الشروط وإنما تتعلق بالضمان^(٣).

الخامس: إن اشتراط الحصول على كراسة الشروط بثمن يُعتبر شرطاً سائغاً ليس له تأثير في العقد؛ ولذلك فلا مانع منه.^(١)

(١) د/ رفيق المصري: (عقد التوريد والمناقصات) بحث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر ج ٢ .

(٢) د/ عبد الله المنيع: حيث أورد رأيه في المناقشة وليس في بحث . المرجع السابق العدد رقم ٨ ج ٢ .

(٣) د/ رفيق المصري: (عقد التوريد والمناقصات) ، مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، العدد الثاني عشر.

السادس: أن من لم يرس عليه العطاء مستفيد أيضاً من دفتر الشروط وذلك؛ بمعرفة مدى إمكانية إنجازهِ للمطلوب، فلا يدخل مغامراً دون معرفة قدراته وإمكاناته في تنفيذ مشروع معين، مما يساعده على الفوز في مناقصات مستقبلية؛ إذ يحفزهُ هذا على رفع كفاءته، وتطوير قدراته ، وتحسين أدائه. (٢)

الرأي الثاني: إن الذي يتحمل قيمة كراسة الشروط هو المناقص الذي رست عليه المناقصة، وبه قال الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان (٣).
مستدلاً على ذلك بما يلي:

أولاً: أن ما تشتمل عليه كراسة الشروط من مواصفات ودراسات ستوفر على المتقدم في المناقصة الكثير، بحيث لا يحتاج إلا للتنفيذ بموجبها عندما يرسو عليه العطاء، وإذا كان هذا معلوماً لديه مسبقاً فإنه يحتسب تكلفة تلك الدراسات ضمن تكاليف المشروع .

(١) عقود المناقصات في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير للباحث/ عاطف محمد

حسين أبو هريبد، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بغزة، ص ٩٥.

(٢) نقله الدكتور/ رفيق المصري عن الشيخ: أبو سليمان بقوله: " لقد نشر أبو سليمان بحثه هذا أيضاً في مجلة : (البحوث الفقهية المعاصرة) إلا أنه غير رأيه:" (عقد التوريد والمناقصات)، مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، العدد الثاني عشر.

(٣) عقد المزايدة بين الشريعة الإسلامية والقانون دراسة مقابلة مع التركيز على بعض القضايا المعاصرة للدكتور/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، مجلة المجمع ، العدد الثامن.

ثانياً: إن المناقصين الذين لم يرس عليهم العطاء يدفعون تلك الرسوم دون مقابل، وأن العدل والانصاف يقضي أن تكون مسئولية دفع التكاليف جميعها من قبل من ظفر بالمناقصة، وبهذا نستطيع أن نخلص معاملاتها من شبهة أكل أموال الناس بغير حق.

الرأي الثالث: وجوب بذل كراسة الشروط بالمجان، وعلى الجهة المصدرة له أن تتحمل تكلفة إعدادها، لكن يجوز أخذ تأمين من طالب الدفتر على أن يُرد إليه إذا رد دفتر الشروط؛ لعدم اشتراكه في المناقصة، أو لعدم رسوها عليه، أو لإلغاء المناقصة. وهذا قول د/ رفيق المصري^(١).

مستدلاً على ذلك بالأدلة الآتية:

الأول: إن الجهة المصدرة له هي المستفيدة منه فهي التي اختارت إجراء المناقصة وحددت شروطها ، وبالتالي فمن له الغنم كان عليه الغرم .

الثاني: إن المناقصين لو حُمِّلوا بثمن دفتر الشروط فإن واحداً منهم فقط هو الذي سيفوز بالعقد برسو المناقصة عليه، وليس هناك من وجه لتحميل سائر المناقصين تكلفة دفتر الشروط.

الثالث: إن أخذ المناقص له مقابلاً لدفتر الشروط أشبه بالضريبة؛ لذلك يجب بذله بالمجان لمن يطلبه.

(١) المرجع السابق .

الرابع: أما بالنسبة لأخذ الجهة الداعية للمناقصة تأميناً نقدياً فإنما هو لحماية دفتر الشروط ممن يأخذه وهو غير جاد فلا ينتفع به هو أو ينتفع به غيره. (١).

الرأي الرابع: جواز بيع كراسة الشروط إذا كانت مشتملة على دراسات فنية ورسم خرائط على أن تكون القيمة تمثل قيمة تكاليف إعدادها بخلاف ما لو كانت كراسة الشروط مشتملة على مجرد شروط العقد؛ لأنه بمنزلة بيان شروط العقد من أحد العاقدين وهذا قول د/ محمد تقي العثماني. (٢).

وذلك لأنه إذا كان مشتملاً على دراسات فنية ورسم خرائط فذلك يتطلب جهداً ومالاً، كما أنه من ناحية أخرى يخفف العبء على المشاركين في المناقصة؛ لأنه لولا إصداره لاحتاج كل واحد من المناقصين إلى إجراء هذه الدراسة بنفسه فيحتاج لبذل الجهد والمال. (٣)

الترجيح:

بعد عرض آراء العلماء أرى جواز بيع كراسة الشروط لمن يرغب المشاركة في المناقصة وذلك لقوة ما استدلوا به ؛ ولأن في شرائها

(١) عقود المناقصات في الفقه الإسلامي ص ٩٤، رسالة ماجستير للباحث / عاطف محمد حسين أبو هريدي ، د. رفيق المصري مجلة .مجمع الفقه الإسلامي.

(٢) د/ محمد تقي العثماني: (عقد التوريد والمناقصة) المرجع السابق العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٨٧٥

(٣) د/ محمد تقي العثماني : المرجع السابق العدد الثاني عشر ج ٢ ص ٢٢٨٧٥ .

تحصيل منفعة للمشاركة في المناقصة، كما أن المناقص له بذل مجهوداً يستحق عليه أخذ العوض؛ وعليه فهو يحقق مقصد الشارع في عدم أكل أموال الناس بالباطل.

كما أنه شرط سائغ لا تأثير له في صحة في العقد، وقد قال صلى الله عليه وسلم : "المسلمون على شروطهم" - والله أعلم -

الوحدة الثالثة

الضمان في المناقصات

أهداف الوحدة الثالثة :

حصيلة التعلم:

يتوقع أن يكون الطالب/ الطالبة قادرا على أن :

- ١- معرفة الحكم الفقهي للمطالبة بالضمان.
- ٢- الالمام بما يتعلق بكتاب الضمان المصرفي من حيث: التعريف به، وذكر أنواعه، وفائدة إصداره، وكيفية الإصدار له وحكم الضمان به .
- ٣- شرح المقصود بعمولة إصدار كتاب الضمان، وتوضيح الحكم الفقهي لذلك .
- ٤- توضيح الالتزامات المترتبة على عقد المناقصة، وحكم العجز عن التنفيذ .

-٥-

الوحدة الثالثة:

الضمان في المناقصات

أولاً: حكم المطالبة بالضمان:

أولاً: تعريف الضمان هو: هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق . فيثبت في ذمتها جميعاً ، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منها ، واشتقاقه من الضم ^(١) .

وهو جائز شرعاً ودليل مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب : فقوله تعالى : { وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } ^(٢).

أما السنة : فَمَا رَوَى أَبُو أَمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ) ^(٣).

أما الإجماع : فقد نقله ابن قدامه في المغني بقوله : وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة ^(٤) .

(١) المغني ج ٥ ص ٧٠ .

(٢) سورة يوسف الآية ٧٢ .

(٣) أخرجه الترمذي في جامعه - كتاب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة ج

٣ ص ٥٥٧ ، حديث رقم (١٢٦٥) ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب .

(٤) المغني ج ٥ ص ٧٠ .

ثانياً: حكم المطالبة بالضمان:

الراغب في المشاركة في المناقصة عندما يتقدم بعبائه لا بد وأن يقدم معه ضماناً وهو ما يعرف بالضمان الابتدائي ، ويهمل كل عرض لا يصاحبه ضمان، ويرد الضمان الابتدائي إلى أصحاب العروض الذين لم ترس عليهم المناقصة، أما من رست عليهم المناقصة فإما أن يستكمل الضمان الابتدائي باعتبار أن نسبته أقل من الضمان النهائي، أو يسترد الضمان الابتدائي، ويقدم ضماناً نهائياً^(١).

وعلى ذلك فالضمان المطلوب من المناقصين ينقسم إلى قسمين:-

القسم الأول: الضمان الابتدائي: الهدف منه التأكد من جدية المناقصين وصدق رغبتهم في الاشتراك في المناقصة، والتزامهم بالتعاقد في حالة إرساء العطاء على أحدهم .

حكمه: لا مانع شرعاً من المطالبة بالضمان الابتدائي بناءً على ما سبق من أدلة مشروعية الضمان، وعملاً بقوله -صلى الله عليه

(١) د/ محمد تقي العثماني : (عقد التوريد والمناقصة) العدد رقم ١٢ ج ٢، د/رفيق

المصري : (مناقصات العقود الإدارية عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة)

أبحاث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد رقم ٩ ج ٢ ص ٢٢٦ .

وسلم - : (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)^(١)، وهو يعد أمانة في يد المناقص له، يرد إلى من لم ترس عليهم المناقصة،

أما إذا سحب المناقص عطاءه قبل إرساء المناقصة فإن مبلغ الضمان لا يرد لصاحبه.^(٢)

وهذا يشبه صورة من صور بيع العربون، وهو أن يشتري أو يكتري سلعة ويعطيه شيئاً من الثمن على أنه - أي المشتري - إن كره البيع تركه للبائع وإن أحبه حاسبه به أو تركه.^(٣)

وهذه الصورة من صور بيع العربون اختلف فيها الفقهاء على رأيين: الرأي الأول: منع بيع العربون وهذا قول جمهور الفقهاء المالكية^(٤)، والشافعية^(٥)، ورواية للحنابلة^(٦).

واستدلوا على ذلك بالسنة والأثر والمعقول :

(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإجارة - باب أجر السمسرة ج ٣ ص ٩٢
(٢) د/ محمد تقي العثماني : (عقد التوريد والمناقصة) المرجع السابق العدد رقم ١٢ ج ٢، د/ رفيق المصري : (مناقصات العقود الإدارية عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة)، أبحاث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد رقم ١٢ ج ٢ ، العدد رقم ٩ ج ٢ ، د/ محمد الزيني : المناقصات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي ص ٨٥

(٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك ج ٣ ص ١٠٠ .

(٤) حاشية الصاوي ج ٣ ص ١٠٠ ، منح الجليل ج ٥ ص ٤٦ .

(٥) مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٩٥ ، أسنى المطالب ج ٢ ص ٣١ .

(٦) الإنصاف ج ٤ ص ٣٥٨ ، .

أما السنة: فما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال :
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان) (١) .

وجه الدلالة: دل ظاهر الحديث على تحريم البيع مع العربان ؛ ولما
فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل (٢).

أما الأثر: فقد روى ابن أبي شيبة عن عطاء وعن ابن طاوس عن
أبيه: أنهما " كرها العربان في البيع " (٣).

وجه الدلالة: دل ظاهر الأثر على منع بيع العربون .

أما المعقول: فمن عدة أوجه:

الأول : أنه يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل (٤) .

الثاني : لأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه
لأجنبي .

(١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب العربان ج ٥ ص ٣٦١، حديث
رقم (٣٥٠٢) ، وجاء في التعليق عليه: وقال الحافظ ابن عدي في "الكامل ج ٤
ص ١٤٧١: والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور".

(٢) سبل السلام ج ٢ ص ٢٢ بتصرف .

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب البيوع - باب في العربان في البيع -
ج ٥ ص ٣٩٢ أثر رقم ٩ .

(٤) حاشية الصاوي ج ٣ ص ١٠٠ .

الثالث : لأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد البيع من غير ذكر مدة ، فلم يصح كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهماً^(١).

الرأي الثاني : صحة بيع العربون وهو الصحيح من مذهب أحمد^(٢).

واستدل على ذلك بالأثر ومنه ما يلي :

١ - روى عبد الرحمن بن فروخ : أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان^(٣) .

٢ - روي عن ابن سيرين أنه كان : لا يرى بأساً أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول : إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك^(٤) .

٣ - روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول : إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، قال : فإن لم يجئه فهو له^(٥).

(١) المغني ج ٤ ص ٣١٢ .

(٢) الإنصاف ج ٤ ص ٣٥٨ ، مطالب أولي النهى ج ٣ ص ٧٧ .

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب البيوع - باب في العريان في البيع -

ج ٥ ص ٣٩٢ أثر رقم ٧ .

(٤) المرجع السابق أثر رقم ٤ .

(٥) المرجع السابق أثر رقم ٨ .

وجه الدلالة :

دل ظاهر الآثار على جواز بيع العربون سواء فيما فعله نافع بن عبد الحارث في عقد البيع أو فيما روى عن ابن سيرين.

الترجيح:

بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لي - والله أعلم - أن الرأي الأولى بالقبول هو ما قال به جمهور الفقهاء أصحاب الرأي الأول وهو منع بيع العربون وذلك لقوة أدلتهم، ولأنه يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل لقوله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }^(١).

وبناء على ذلك فإن مصادرة الضمان المالي الابتدائي هو يعد من قبيل بيع العربون في صورة من صورته فلا يحق لصاحب المناقصة أخذه سواء ظفر المناقص بالعقد أم لا^(٢).

القسم الثاني: الضمان النهائي:

وفيه يقدم المناقص الذي رست عليه المناقصة خلال مدة محددة من تاريخ إصداره برسو المناقصة عليه والتزامه بالتعاقد.

(١) سورة البقرة آية ١٨٨.

(٢) د/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: عقد المزايدة بين الشريعة والقانون، دراسة مقابلة مع التركيز على بعض القضايا المعاصرة، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن ج ٢ ص ١٦١٥٤.

حكمه: يباح للجهة الداعية للمناقصة المطالبة بالضمان النهائي ولا يختلف حكمه عن الضمان الابتدائي، فالغاية منه هو التزام المناقص بتنفيذ كافة شروط العقد في المدة المحددة له دون تأخير أو مخالفة، كما أن مصادرته كمصادرة الضمان الابتدائي لا يجوز إلا إذا لم يف صاحبه بواجبه تجاه تنفيذ العقد وترتب على عدم وفائه ضرر مالي للمناقص له، وفي تلك الحالة يمكن المقاصة بين مبلغ الضمان النهائي وبين ما يجب على المناقص المتعهد من تعويض مالي^(١).

(١) انظر بحث د/ تقى عثمانى - عقود التوريد والمناقصة - مجلة المجمع ، العدد الثاني عشر .

ثانياً: الضمان بـ خطاب ضمان مصرفي:

مفهومه:

يعد خطاب الضمان المصرفي صورة من صور الضمان، وهو عبارة عن: تعهد كتابي بناء على طلب العميل يلتزم فيه المصرف لصالح العميل في مواجهة شخص ثالث بدفع مبلغ معين في وقت معين^(١).

بينما عرفه د/ بكر أبو زيد بقوله: هو تعهد قطعي مقيد بزمان محدد غير قابل للرجوع يصدر من البنك بناء على طلب طرف آخر (عميل له) - بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ويرجع البنك بعد ذلك على العميل بما دفعه عنه للمستفيد^(٢).

فائدة خطاب الضمان:

لخطاب الضمان المصرفي أهمية كبيرة في حماية المستفيد من تنفيذ المشاريع أو تأمين المشتريات وفق شروط محددة، وفي أوقات

(١) د/ خالد المشيقيح: المعاملات المالية المعاصرة ص ٦٢ .

(٢) د/ بكر أبو زيد: فقه النوازل (قضايا فقهية معاصرة) ص ٢٠١ ط/ مؤسسة الرسالة .

محددة، بالإضافة إلى أنه لا يقبل إصدار خطاب الضمان إلا إذا توافرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية.^(١)

حيث يتقدم أصحاب رؤوس الأموال إلى المصارف لأخذ خطاب ضمان في حالات منها:

عند طرح المناقصات أو المزايدات يتقدم من يرغب من أصحاب الشركات وغيرهم في المشاركة فيها عند ذلك تطلب منهم الجهة المنظمة للمناقصة أو المزايدة ضماناً ، لكن بدلاً من أن يضع المناقص نقوداً تحجز عليه ولا يستفيد منها لمدة معينة ، لأنه إذا لم يتمكن من هذه المناقصة يأخذ فترة طويلة لكي يسترجع هذه النقود، يتوجه إلى المصرف لأخذ خطاب ضمان، فيعطيه المصرف خطاب بأنه ضامن لهذا العميل بمبلغ كذا وهو المبلغ الذي تطالبه به الجهة الإدارية^(٢).

وفي حالة الاشتراك في المناقصات الدولية تقوم خطابات الضمان بدورها حيث إنها توفر على مقدم الضمان القيام بإجراءات تحويل العملة واستردادها، وتحميه مما قد يتعرض له من خسائر نتيجة لاحتقال هبوط أسعار العملة^(٣).

(١) د/ بكر أبو زيد : فقه النوازل (قضايا فقهية معاصرة) ص ٢٠٢ .

(٢) المشيقيح : المعاملات المعاصرة ص ٦٢ .

(٣) مجلة البحوث الإسلامية ج ٨ ص ١٠١ نقلاً من البنوك التجارية، المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي ص ١٢٨ .

أقسامه: ينقسم خطاب الضمان المصرفي إلى أقسام متعددة تبعاً لاعتبارات مختلفة:

أولاً : خطاب الضمان من حيث الغطاء وعدمه وينقسم إلى قسمين :

أ- أن يكون الغطاء كاملاً : بحيث يمثل الغطاء نفسه قيمة الخطاب .
مثاله: كأن يطلب العميل من المصرف خطاب ضمان بمليون جنيه، ويكون قد دفع للمصرف غطاء بمليون جنيه أو دفع أسهماً أو عقارات أو وثائق بقيمة ذلك.

ب- أن يكون الغطاء جزئياً: هو يمثل بعض قيمة الضمان .

مثاله: أن يطلب العميل من المصرف خطاب ضمان بمائة ألف ويكون قد دفع للمصرف خمسين ألفاً أو أسهماً بقيمة ذلك .

ثانياً: من حيث الغرض منه ينقسم إلى قسمين:

خطاب ضمان ابتدائي: وهو لا يختلف عن الضمان من المنافص له كما سبق، وهو يمثل نسبة ضئيلة من حجم المشروع لا تتجاوز عشرة في المائة .

خطاب ضمان نهائي: وهو تعهد من المناقص بعد التعاقد لتأكيد التزامه بتنفيذ العملية وفق الشروط والمواصفات المحددة، كما سبق.^(١)

كيفية إصدار البنك لخطاب الضمان :

يتقدم طالب خطاب الضمان بطلب للبنك يحدد فيه مبلغ الضمان ومدته والجهة المستفيدة والغرض منه، ويجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره الضمان المذكور، القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان كبيراً فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك إما أن تكون رهناً عقارياً مسجلاً أو رهن أسهم في شركات أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقود فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الضمان - مع خطاب من مودعها بالتنازل عنها إذا اقتضى الأمر أو كفالة بنك خارجي معروف، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالى ٢٥ % من قيمة الضمان وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات يقوم البنك بإصدار خطاب الضمان^(٢).

(١) المشيخ : المعاملات المالية المعاصرة ص ٦٢ ، د/ وهبة الزحيلي : الفقه

الإسلامي ج ٥ ص ٤١٦ .

(٢) فقه النوازل : مرجع سابق ص ٢٠٣ .

أما عن الحكم الشرعي لخطاب الضمان :

قبل بيان الحكم الشرعي لا بد وان نبين العلاقة بين مصدر خطاب الضمان وبين كل من المناقص والمناقص له وعلى أساس ذلك يتضح الحكم الشرعي

أولاً: علاقة المصدر لخطاب الضمان وهو البنك وبين الجهة المستفيدة من الخطاب وهو المناقص له علاقة ضمان وكفالة ، والضمان جائز ومشروع وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.

ثانياً: علاقة المصدر لخطاب الضمان والمناقص تختلف على حسب كون الخطاب له تغطية كاملة أم لا

حكمه: بالنظر إلى أقسام خطاب الضمان نجد أنها لا تخالف الضمان الذي ثبتت مشروعيته من خلال الأدلة السابقة فقد تحقق فيها شروط الضمان التي ذكرها الفقهاء المتقدمين من رضا الضامن، وكونه أهلاً للتبرع ، وكون المضمون معلوماً حالاً أو مآلاً^(١)، أما الضمان بخطاب الضمان الابتدائي فهو ضمان لدين لم يجب، حيث أن المناقص الذي يستخرج خطاب الضمان الابتدائي من البنك لكي يقدمه مع العرض للجهة الإدارية وهو ليس مديناً لها بشيء وبالتالي فإن ضمان البنك

(١) انظر شرح مختصر خليل ج ٦ ص ٢٢ ، نهاية المحتاج ج ٤ ص ٤٣٣ وما بعدها، حاشية البيجرمي ج ٣ ص ١٢١ ، مطالب أولي النهى ج ٣ ص ٣٠٠.

لهذا المناقص يعد ضماناً لما سيجب وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء والراجح فيها قول جمهور الفقهاء^(١) حيث ذهبوا إلى جوازه للحاجة الداعية إليه .

أما حكم أخذ المصرف عمولة لإصداره خطاب الضمان:

فهي مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: لا يجوز للمصرف أن يأخذ مقابل على إصدار خطاب الضمان سواء كان له غطاء أم لا، وهذا قول لبعض العلماء المعاصرين.^(٢)

واستدلوا على ذلك بالمعقول من عدة أوجه :

الأول: أن خطاب الضمان المصرفي يعتبر عقد كفالة وهو عقد من عقود الإرفاق والإحسان ولا يجوز أخذ الأجر عليه^(٣).

(١) شرح مختصر خليل ج ٦ ص ٢٤ ، نهاية المحتاج ج ٤ ص ٤٣٩ ، المغني ج ٥ ص ٧١ ، مطالب أولي النهى ج ٣ ص ٣٠٠ .

(٢) د/ بكر أبو زيد : (خطاب الضمان) ، د / عبد الستار أبو غدة : (خطاب الضمان) أبحاث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد رقم ٢ ج ٢ ، د/خالد بن علي المشيقح : المعاملات المالية المعاصرة ص ٦٣ ، د/ ياسر بن طه : المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي ص ١٢٩ ، أبحاث هيئة كبار العلماء ج ٥ ص ٢٨٣ .

(٣) المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي ص ١٢٩ .

الثاني: أن حقيقة الكفالة أنها دين على المكفول وهو المدين فإذا رده مع الزيادة فهو رباً ؛ لأن المصرف سيدفع إلى الجهة الإدارية للمناقصة وسيأخذ زيادة على ذلك، فهو يعتبر قرض جر نفعاً^(١).

الثالث: أن المصرف قد ينتفع بمبلغ الغطاء لخطاب الضمان، والغطاء من باب الرهن، فكان انتفاع الضامن به محرماً حيث أنه ليس بظهر يركب بنفقتة ، أو ذا در يحلب بنفقتة^(٢).

الرأي الثاني: يجوز للمصرف أخذ مقابل على إصداره لخطاب الضمان على اعتبار أنه عقد وكالة وهو ما قال به بعض العلماء المعاصرون منهم د/ زكريا البري^(٣) وزير الأوقاف الأسبق.

وذلك لأن الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم وهذا موجود في خطاب الضمان ، فالعميل يوكل المصرف في أن يسدد عنه إذا لم يتم بتنفيذ العملية أو نحو ذلك ، وأخذ الأجرة على الوكالة جائز .

كما أن المصلحة تقتضي إباحة أخذ الأجرة عليه، وإذا كان مقتضى الضمان المصرفي إلزام المصرف بالمغارم التي تترتب على

(١) د/ خالد بن علي المشيخ : المعاملات المالية المعاصرة ص ٦٣ وما بعدها.

(٢) أبحاث هيئة كبار العلماء ج٥ ص ٢٨٣ .

(٣) د/ زكريا البري: (خطاب الضمان) بحث منشور بمجلة الفقه الإسلامي العدد الثاني ج ٢ .

هذا الضمان ، تنفيذاً للالتزامه ، فلم لا يكون للمصرف غنم من المضمون، يؤديه العميل للمصرف الضامن نتيجة الاتفاق والرضا^(١) .

الرأي الثالث : فرق بين ما إذا كان خطاب الضمان له غطاء أم لا فإذا كان له غطاء جاز للمصرف أخذ الأجر نظير إصداره لخطاب الضمان، وإن لم يكن له غطاء لم يجز للمصرف أخذ مقابل لأجل إصداره لخطاب الضمان لكن يجوز أخذه تكاليف الإصدار فقط أي بمقدار جهده وإجراءات عمله - التكلفة العملية - دون ربط الأجر بمقدار المبلغ الصادر به خطاب الضمان وهي ما يقدره المختصون وهذا قول لبعض العلماء المعاصرين^(٢) .

واستدلوا على ذلك :

أن خطاب الضمان الذي له غطاء يعد كفالة ووكالة معاً : كفالة بالنسبة لعلاقة المصرف بالمستفيد (الطرف الثالث) ، ووكالة بالنسبة لعلاقة المصرف مع العميل والوكالة تجوز بأجر وبغير أجر وقد نوه بعض العلماء بما قاله ابن قدامة في المغني : ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيساً في إقامة

(١) المرجع السابق .

(٢) د/ على السالوسي : المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي ص ١٤٣ ، ط/ دار الاعتصام ، د/ حسن عبد الله الأمين ، د/ أبو بكر زيد، د/ وهبه الزحيلي : المعاملات المالية المعاصرة ص ٤٧١-٤٧٢ ، المناقصات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي ص ٨٥ .

الحد، وعروة في شراء شاة ، وعمراً وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل أي بغير أجر . وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ، ويجعل لهم عمالة . ولهذا قال له ابنا عمه : لو بعثتنا على هذه الصدقات ، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس، ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العمالة . فإن كانت بجعل ، استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل .

أما خطاب الضمان غير المغطى فإن علاقة المصرف بالعميل علاقة كفالة، وعقد الكفالة من عقود الإرفاق كما سبق في الرأي الثاني^(١) . فإذا اشترط الضامن شيئاً لنفسه خرج الضمان عن حقيقته فمنع لذلك . جاء في حاشية الصاوي : (أو فسدت) الحمالة نفسها شرعاً ؛ بأن اختل منها شرط أو حصل مانع فتبطل ؛ بمعنى أنه لا يترتب عليها حكمها من غرم أو غيره فلا يلزم اتحاد المعلق والمعلق عليه ، ومثل ذلك بقوله : (كيجعل) للضامن من رب الدين أو من المدين أو من أجنبي ، وعلة المنع أن الغريم إن أدى الدين لربه كان الجعل باطلاً ؛ فهو من أكل أموال الناس بالباطل وإن أداه الحميل لربه ثم رجع به على الغريم كان من السلف بزيادة ، فتفسد الحمالة ويرد الجعل لربه^(٢) .

(١) المرجع السابق .

(٢) حاشية الصاوي ج ٧ ص ٤٥٥ .

الترجيح:

بعد عرض آراء العلماء المعاصرون في حكم أخذ المصرف أجر نظير إصداره خطاب الضمان يتبين أن الراجح هو ما قال به أصحاب الرأي الثالث الذي فرق بين كون خطاب الضمان له غطاء مالي أم لا، فإذا كان له غطاء مالي جاز للمصرف أن يأخذ أجراً ؛ لأن علاقته بالعميل علاقة وكالة وهي تجوز بأجر وبدون أجر ، أما إذا كان غير مغطى فلا يجوز لما فيه من شبهة الربا وذلك لقوة أدلتهم ، كما أن في القول بذلك عدم فتح المجال لمن ليس لهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم في الدخول في المناقصات . - والله اعلم -

كما أن فيه حداً من التعامل الجشع والتوسع في الأعمال مما ليس في استطاعة الإنسان القيام به مما قد يضطره في النهاية إلى الخضوع لما تفرضه عليه المصارف من فوائد ربوية نظير قيامه بالسداد بمقتضى الضمان^(١).

(١) د/ محمد الزيني: المناقصات وتطبيقاتها المعاصرة ص ٨٩ .

الالتزامات المترتبة على عقد المناقصة

من المعلوم أن العقود ليست غاية في حد ذاتها إنما تعقد من أجل ما يترتب عليها من التزامات في ذمة طرفيها، ومما يترتب على إبرام عقد المناقصة سواء آلت المناقصة إلى عقد توريد أو عقد مقاوله عدة التزامات منها ما يقع على المناقص ومنها ما يقع على المناقص له :

أولاً : التزامات المناقص :

١ - تنفيذ العمل الذي تعهد به : يجب على المناقص القيام بالعمل الذي تعهد به ووفق الشروط والمواصفات المتفق عليها ما لم تكن هناك مخالفة شرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: (**وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا**) ^(١) وإذا لم يكن هناك ثمة شروط متفق عليها فالمرجع حينئذ إلى العرف عند أهل كل صناعة ^(٢).

٢ - تسليم العمل بعد إنجازه : يجب على المناقص إنجاز العمل خلال المدة الزمنية المحددة في العقد ما لم تكن هناك قوة قاهرة تمنع التسليم، وبعد إنجازه للعمل وفق الشروط والمواصفات والمدة المتفق

(١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الأحكام - باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ج ٣ ص ٦٢٦ ، حديث رقم (١٣٥٢) ، قال أبو عيسى حديث حسن صحيح .

(٢) الوسيط ج ٧ ص ٦٤-٦٥ ، عقد التوريد ص ٥٠-٥١ .

عليها، عليه أن يقوم بتسليمه إلى المناقص له وذلك إنما يكون بأن يخلي بين ما تعهد به وبين المناقص له على الوجه والمكان المتفق عليه، وفي حالة عدم قيام المناقص بتسليم العمل منجزاً ولم تمنع قوة قاهرة التسليم فإنه بذلك يكون مخالفاً بالتزاماته مما يترتب عليه تحمل المسؤولية والجزاءات الواردة في العقد^(١) .

٣- ضمان العمل بعد تسليمه : وهذا الضمان يعرف بضمان حسن أداء المعقود عليه بعد التسليم مدة معينة .

ثانياً: التزام المناقص له: يلتزم المناقص له بعدة التزامات هي :

١- تمكين المناقص من تنفيذ العمل الذي تعهد به : يجب على المناقص له أن يمكن المناقص من تنفيذ العمل ويتم ذلك بعدم الحيلولة بينه وبين البدء بالتنفيذ^(٢) عملاً بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}^(٣)

٢- دفع العوض : حث يلتزم المناقص له بدفع المقابل المالي للمناقص وفقاً لما تم الاتفاق عليه سواء من جهة المقدار والجنس والنوع وطريقة الدفع^(٤) .

(١) الوسيط ج ٧ ص ٩١ .

(٢) أصول القانون الإداري ص ٤٢٢ ، عقد التوريد ص ٥٤ .

(٣) سورة المائدة جزء من الآية ١ .

(٤) أصول القانون الإداري ص ٤٢٢ ، عقد التوريد ص ٥٤

٣- الحق في الحصول على تعويض: قد يقوم المناقص بعمل إضافات لم تطلب منه في العقد ، ولم يتم الاتفاق عليها ، فإذا تبين أن هذه الإضافات مفيدة ولازمة تعين على المناقص له أن يعرض المناقص مقابل ذلك^(١) .

(١) المرجع السابق ص ٤٣٣ .

حكم العجز عن تنفيذ عقد المناقصة:

لما كان تنفيذ عقد المناقصة يتم على مراحل زمنية متعددة فقد يقع في هذه المدة تغير جوهرى في الأسعار نتيجة لقوة قاهرة أي حادث طارئ مثل حرب أو زلزال أو طوفان مما يترتب عليه الإخلال بميزان المعاوضة المترتب على المناقصة، وهذا ينطبق على حكم الجائحة في الفقه الإسلامى^(١).

(١) الجائحة لغة: مشتقة من الجوح : الجيم والواو والحاء أصل واحد، وهو الاستئصال، يقال : جاح الشيء يجوحه : استأصله ، والجمع جوائح ، ومنه اشتقاق الجائحة : وهي المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتأحه كله، وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة. المعجم الوسيط ج١ ص ٣٠٣، مقاييس اللغة ج١ ص ٤٣٧.

وأما الجائحة اصطلاحاً: فقد عرفها ابن عرفة بقوله : ما أتلّف من معجوز عن دفعه عادة قدراً من ثمر أو نبات بعد بيعه. حاشية الدسوقي ج ٣ ص ١٨٢.

وفي المجموع: هي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها. تكملة المجموع ج ٣ ص ٩١. وفي المبدع : الجائحة. كل آفة سماوية لا صنع للإنسان فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أن يجز، فهو من ضمان البائع. المبدع شرح المقنع ج ٤ ص ١٧٠ .

ملخص الموضوع:

- ١- تهدف المناقصة للوصول إلى العرض الأقل سعراً على فرض تساوي المتقدمين جميعهم من حيث الشروط والمواصفات المذكورة في كراسة الشروط.
- ٢- من أهم المبادئ التي تقوم عليها المناقصة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المناقصين .
- ٣- تتضمن المناقصة الكثير من الإجراءات التي تحقق مبدأ السرية في المنافسة.
- ٤- تستمد أحكام المناقصة من المزايدة فهي أقرب المعاملات إليها فبينهما علاقة تضاد .
- ٥- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة كراسة الشروط بما لا يزيد على قيمته الفعلية
- ٦- لا مانع شرعاً من أخذ ضمانات من المناقصين للدخول في المناقصة.
- ٧- إذا عجز المناقص عن تنفيذ العقد لظروف طارئة بعد إرساء العطاء عليه، جاز له اللجوء للقضاء لتخفيف ذلك عليه إعتماًداً على الرأي القائل: بوضع الجوائح في الفقه الإسلامي.

أسئلة على هذا القسم :

السؤال الأول: اذكر تعريفاً للمصطلحات الآتية:

- ١- المناقصة .
- ٢- مبدأ المنافسة في المناقصات.
- ٣- خطاب الضمان المصرفي.

السؤال الثاني: بين:

- أ - العلاقة بين النجش والمناقصة .
- ب- حكم شراء كراسة الشروط .

السؤال الثالث: أكمل:

- أ- تجرى الدعوة إلى المناقصة عن طريق: وله فوائد كثيرة منها: ، ،
- ب- من التزامات المناقص له: المناقص من تنفيذ العمل الذي تعهد به ، ويتم ذلك بعدم بينه وبين البدء بالتنفيذ.
- ج- المناقصة يجريها

 فهرس موضوعات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٢	مقدمة
٤	الأهداف العامة للمقرر
٥	أساليب التعليم والتعلم
٦	القسم الأول: الإجارة المنتهية بالتملك
٧	مفهوم كل من الإجارة والتملك
١٧	أنواع عقد الإجارة باعتبار المعقود عليه
١٩	الفرق بين عقد الإجارة المنتهية بالتملك وبين بعض عقود المعاوضات
٢٢	مفهوم الإجارة المنتهية بالتملك، وما يطلق عليها من مصطلحات
٢٤	نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتملك
٢٦	مزايا عقد الإجارة المنتهية بالتملك
٣٠	صور عقد الإجارة المنتهية بالتملك

٣٥	حكم اجتماع البيع والإجارة
٤٤	حكم إلزام المستأجر بنفقات الصيانة والتأمين
٤٨	حكم بيع المؤجر العين المؤجرة للمستأجر
٥١	حكم الوفاء بالوعد
٦٢	التكييف الفقهي لصور الإيجار المنتهي بالتمليك
٩٦	أهم الضوابط التي تحكم الإجارة المنتهية بالتمليك
٩٩	القسم الثاني: البطاقات الائتمانية
١٠١	تعريف بطاقات الائتمان
١٠٤	نبذة تاريخية عن بطاقات الائتمان، والجهات المصدرة لها
١٠٥	أنواع البطاقات المصرفية
١٠٨	منافع بطاقة الائتمان العائدة على أطراف البطاقة
١١٠	أثر التعامل ببطاقات الائتمان على اقتصاد الفرد والمجتمع
١١٢	أقسام بطاقات الائتمان
١١٦	أطراف بطاقات الائتمان

١١٨	التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها
١٣٢	التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر
١٣٧	تكييف العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر
١٣٩	تكييف العلاقة بين المنظمة الراعية وأطراف البطاقة
١٤٢	الأحكام الفقهية المتعلقة ببطاقات الائتمان
١٤٢	أحكام العمولات التي يتقاضاها مصدر البطاقة
١٤٩	العمولات التي يقتطعها مصدر البطاقة من التاجر
١٥٥	عمولة السحب النقدي ببطاقة الائتمان
١٦١	شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان
١٧٠	البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان غير المغطاة
١٧٦	القسم الثالث: الشرط الجزائي
١٨٠	تعريف الشرط الجزائي
١٨١	صور الشرط الجزائي
١٨١	العوامل التي أدت للعمل بالشرط الجزائي

١٨٢	شروط تطبيق الشرط الجزائي
١٨٣	الأحوال التي لا ينفذ فيها الشرط الجزائي
١٨٦	التكييف الفقهي للشرط الجزائي
١٩٣	أنواع الشرط الجزائي
٢٠٥	حكم الشرط الجزائي في الديون
٢٢٠	القسم الرابع: عقود التوريد
٢٢٢	تعريف عقد التوريد
٢٢٧	أهمية عقد التوريد
٢٢٩	سبب ظهور عقد التوريد
٢٣١	أركان عقد التوريد وشروطه
٢٣٤	شروط عقد التوريد
٢٣٦	أقسام عقد التوريد
٢٤٠	صور عقد التوريد
٢٤٢	مميزات عقد التوريد وما ينفرد به عن غيره

٢٤٥	التكييف الفقهي لعقد التوريد
٢٦٦	حكم عقد التوريد إجمالاً
٢٦٩	ضوابط عقد التوريد
٢٧١	العناصر المؤثرة في صحة عقد التوريد
٢٧١	بعض المحاذير الواردة على عقد التوريد
٢٧٣	التزامات كل من المورد والمستورد
٢٧٥	عقد التوريد من الباطن، وأركانه، وصوره
٢٧٧	حكم التوريد من الباطن
٢٧٨	الفرق بين التوريد من الباطن والتنازل عن العقد
٢٨٠	انتهاء عقد التوريد
٢٨٣	القسم الخامس: عقود المناقصات
٢٨٤	تعريف عقد المناقصة
٢٨٧	إجراءات المناقصة
٢٨٩	الأسس التي تقوم عليها المناقصات

٢٩٢	أطراف المناقصة وأنواعها
٢٩٦	الأحكام الشرعية للمناقصات
٣٠٣	حكم بيع المزايدة
٣١١	بيوع منهى عنها تلتبس بالمناقصات
٣١١	بيع الرجل على بيع أخيه
٣١٥	السوم على السوم
٣١٧	النجش
٣٢٤	حكمبيع كراسة الشروط
٣٣٢	الضمان في المناقصات
٣٣٤	حكم المطالبة بالضمان
٣٣٨	الضمان النهائي
٣٤٠	الضمان بخطاب ضمان مصرفي
٣٤٢	أقسام خطاب الضمان المصرفي
٣٤٣	كيفية إصدار البنك لخطاب الضمان

٣٤٤	الحكم لشرعي لخطاب الضمان
٣٤٥	حكم أخذ المصرف عموله لإصداره خطاب الضمان
٣٥٠	الالتزامات المترتبة على عقد المناقصة
٣٥٠	التزامات المناقص
٣٥١	التزامات المناقص له
٣٥٣	حكم العجز عن تنفيذ المناقصة
٣٥٦	فهرس موضوعات الكتاب

😊 والحمد لله رب العالمين 😊